

민법 이론서 목차

PART 01 민법 총칙 ·· 4

제1장 서 론	4
제1절 민법의 법원	4
제2절 신의성실의 원칙과 권리남용금지의 원칙	5
제3절 민법의 효력	21
제4절 민법상의 권리(私權)	22
제2장 권리의 주체(自然人)	26
제1절 권리능력	26
제2절 행위능력	30
제3절 주소	44
제4절 부재와 실종	46
제3장 권리의 주체(法人)	55
제1절 법인의 의의와 종류 등	55
제2절 법인의 소멸과 등기	75
제4장 권리의 객체(물건)	78
제5장 법률행위	88
제1절 법률행위의 의의와 종류	88
제2절 법률행위의 성립요건과 효력요건	97
제3절 법률행위의 목적	99
제4절 의사표시	118
제5절 법률행위의 대리	141
제6절 무효와 취소	163
제7절 법률행위의 부관	178
제6장 기간과 소멸시효	187
제1절 기간	187
제2절 소멸시효	189

PART 02 물권법 ·· 209

제1장 물권변동	210
제1절 물권의 종류와 효력	210
제2절 부동산 물권변동	218
제3절 동산 물권변동	236
제4절 물권의 소멸	241
 제2장 점유권	 245
제1절 점유제도와 점유권	245
제2절 점유의 모습	247
제3절 점유권의 취득과 소멸	261
제4절 준점유	264
 제3장 소유권	 265
제1절 소유권 일반	265
제2절 상린관계	267
제3절 소유권의 취득	277
제4절 소유권에 기한 물권적청구권	292
제5절 공동소유	294
제6절 명의신탁	309
 제4장 용익물권	 316
제1절 지상권	316
제2절 지역권	340
제3절 전세권	346
 제5장 담보물권	 357
제1절 총설	357
제2절 유치권	360
제3절 질권	366
제4절 저당권	372
제5절 가등기담보	393
제6절 양도담보	404

P / A / R / T

01

민법 총칙



- 제1장 서 론
- 제2장 권리의 주체(自然人)
- 제3장 권리의 주체(法人)
- 제4장 권리의 객체(물건)
- 제5장 법률행위
- 제6장 기간과 소멸시효



1장 서론

제1절 민법의 법원

1. 법원(法源)의 의의와 순위

(1) 법원(法源)의 의의

법원이란 법이 존재하는 형식을 의미하며, 민법의 법원에는 성문민법과 불문민법이 있다. 성문법이란 문자로 표시되고 일정한 형식 및 절차에 따라 제정된 법이며, 불문법이란 성문법 이외의 것, 즉 관습법이나 판례법 또는 조리를 말한다.

(2) 법원의 순위

제1조 【법원】

민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.

- ① 민법 제1조는 “민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.” 라고 규정하고 있다.
- ② 이상의 규정에서 확인할 수 있는 것은 i) 우리나라는 법률을 1차적인 법원으로 규정하고 있는 성문법주의를 취하고 있으며, ii) 불문법(관습법)은 성문법이 없는 경우에 보충적으로 적용되는 관습법의 보충적 효력을 인정하고 있고 iii) 법원의 종류(법률·관습법·조리)와 그 순위를 정하고 있으며, iv) 판례의 법원성은 법적으로는 부정되고 있다는 것이다.
- ③ 아울러 민법 제1조에서의 법률은 실질적 의미의 법률을 말하므로, 명령이나 규칙 등을 포함하는 넓은 의미의 법률이다.

2. 민법의 법원의 종류

(1) 성문민법

1) 법률

① 민법전

본문 1118개조로 구성된 현행 민법을 의미하며, 1958년 2월 22일 제정·공포(법률 제471호)되고, 1960년 1월 1일 시행되었다. 전 5편으로 구성(민법총칙, 물권법, 채권법, 친족법, 상속법 : Pandekten system)되어 있다.

② 민사특별법

민사특별법이란 민법전에 규정하지 않은 특수한 사항에 대하여 규정하거나, 민법전의 제정 이후 사회사정의 변화에 대처하기 위하여 제정된 법률을 말하며, 주택임대차보호법, 상가건물임대차보호법, 가등기담보 등에 관한 법률 등이 있다.

③ 헌법재판소의 결정

헌법재판소의 결정은 법률과 동일한 효력을 가지므로 그 결정 내용이 실질적으로 민사에 관한 것인 때에는 민법의 법원이 된다. 헌법재판소의 결정으로서 민법의 법원이 될 수 있는 것은 i) 임대차의 존속기간은 20년을 넘지 못한다고 규정한 제651조 제1항에 대한 헌법에 위반된다는 헌법재판소의 결정(2011헌바234, 2013.12.26. 선고), ii) 민법 제764조의 적용에 있어서 사죄광고를 명하는 판결은 위헌이라는 결정(헌재 1991.4.1. 89헌가160), iii) 국유재산법 제5조 제2항에 대한 위헌결정(헌재 1991.5.13. 89헌가97) 등을 들 수 있다.

④ 대통령의 긴급명령

민사에 관한 대통령의 긴급명령, 경제명령 등은 민법의 법원이 된다.

2) 명령

국회의 의결을 거치지 아니하고 다른 국가기관에 의하여 제정된 법규, 즉 대통령령, 총리령, 각 부령을 말한다. 법률의 규정을 집행하기 위하여 세칙을 정하는 민사에 관한 집행명령도 민법의 법원이 된다.

3) 대법원규칙

민법의 법원이 되는 대법원규칙의 예를 들면 부동산등기규칙, 공탁규칙, 입목등기규칙 등이다.

4) 조약

조약이란 국가와 국가 간의 문서에 의한 합의로서 민법의 법원이 되는 조약의 예를 들면 세계저작권협약 등을 들 수 있다.

5) 자치법

조례나 규칙 중에서 민사에 관한 규정은 민법의 법원이 된다(통설).

(2) 불문민법

불문민법으로는 관습법과 판례법, 그리고 조리가 있다.

1) 관습법

① 의의

자연적으로 발생한 관행이나 관례가 사회 일반인들의 법적 확신을 얻음으로써 법규범으로 승격된 것을 말한다. 여기서 관행이란 어떤 사항에 대하여 상당한 기간 동일한 행위가 수차 반복된 상태를 말한다.

② 관습법의 성립요건(법적 확신설 : 통설)

㉠ 법적 내용에 관한 민사관행이 있어야 한다.

㉡ 관행이 법적 가치를 가진다는 법적 확신(법원의 판결)에 의하여 지지를 받아야 한다.

㉢ 관행이 공서양속(사회질서)에 반하지 않아야 한다.

③ 성립 시기

관습법은 법원의 판결에 의하여 그 존재가 시인되어야만 관습법으로 인정될 수 있다. 그러나 관습법의 성립 시기는 법원의 판결시가 아니라 거듭된 관행이 사회에서 법적 확신을 취득하였을 때로 소급한다(법적 확신설 : 통설).

④ 효력

㉠ 보충적 효력설(다수설·판례)

㉡ 성문법이 없는 부분에 관하여 관습법이 이를 보충하는 효력에 불과하다는 견해로서, 민법 제1조의 규정에 의하더라도 보충적 효력설이 타당하다고 한다.

㉢ 법치주의원리에 비추어 볼 때 관습법의 성문법에 대한 개폐력을 인정하는 것은 무리가 있다는 견해이다.

㉔ 변경적 효력설(소수설)

- ㉑ 성문법이 존재하더라도 관습법의 부단한 발생을 막을 수 없다고 본다.
- ㉒ 관습법상의 법정지상권, 동산의 양도담보, 명의신탁, 분묘기지권, 미분리 과실과 수목집단의 소유권이전에 관한 명인방법에서와 같이 성문법이 관습법에 의해 개폐되고 있으므로 정면으로 변경적 효력을 인정하는 것이 타당하다는 견해이다.
- ㉓ 상법 제1조의 규정, 즉 “상사(商事)에 관하여 본법에 규정이 없으면 상관 습법에 의하고, 상관습법이 없으면 민법에 의한다.”는 규정을 또 하나의 근거로 든다.

2) 판례법

① 의의

법원의 재판을 통하여 형성되는 법을 말한다. 판례는 성문법주의 국가에서도 중요한 기능을 담당한다. 즉, 법과 현실과의 틈을 메우는 작용을 한다.

② 법원성

- ㉑ 부정설(다수설) : 판례에 법원성을 인정하는 것은 법원에 입법권을 주는 결과가 되므로 삼권분립의 정신에 어긋난다.

㉒ 긍정설(소수설)

3) 조리(條理)

- ① 의의 : 경험칙·신의칙·사회통념·사회질서·정의 등으로 표현하기도 한다.

② 법원성

- ㉑ 긍정설(다수설) : 실정법과 법률행위의 해석의 기준이 되며, 실정법이나 관습 법도 없는 경우에는 최후의 보충적인 법원으로서 재판의 준거가 된다.

㉒ 부정설(소수설)

중요판례

대법원 2005.07.21. 2002다1178 전원합의체

[1] 관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말하고, 그러한 관습법은 법원(法源)으로서 법령에 저촉되지 아니하는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이고, 또 사회의 거듭된

관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위하여는 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다.

- [2] 사회의 거듭된 관행으로 생성된 사회생활규범이 관습법으로 승인되었다고 하더라도 사회 구성원들이 그러한 관행의 법적 구속력에 대하여 확신을 갖지 않게 되었다거나, 사회를 지배하는 기본적 이념이나 사회질서의 변화로 인하여 그러한 관습법을 적용하여야 할 시점에 있어서의 전체 법질서에 부합하지 않게 되었다면 그러한 관습법은 법적 규범으로서의 효력이 부정될 수밖에 없다.
- [3] 종원의 자격을 성년 남자만으로 제한하고 여성에게는 종원의 자격을 부여하지 않는 종래 관습에 대하여.....중략.....변화된 우리의 전체 법질서에 부합하지 아니하여 정당성과 합리성이 있다고 할 수 없으므로, 종중 구성원의 자격을 성년 남자만으로 제한하는 종래의 관습법은 이제 더 이상 법적 효력을 가질 수 없게 되었다.
- [4] 종중이란 공동선조의 분묘수호와 제사 및 종원 상호간의 친목 등을 목적으로 하여 구성되는 자연발생적인 종족집단이므로, 종중의 이러한 목적과 본질에 비추어 볼 때 공동선조와 성과 본을 같이 하는 후손은 성별의 구별 없이 성년이 되면 당연히 그 구성원이 된다고 보는 것이 조리에 합당하다.
- ☞ 전체 법질서에 부합하지 않아 정당성과 합리성이 결여된 관습에 대하여는 법적 규범인 관습법으로 인정될 수 없다. 따라서 종중 구성원의 자격을 성년 남자만으로 제한하는 종래의 관습법은 이제 더 이상 법적 효력을 가질 수 없게 되었다.

대법원 1983.06.14. 80다3231

- [1] 관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말하고, 사실인 관습은 사회의 관행에 의하여 발생한 사회생활규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것을 말하는 바, 관습법은 바로 법원으로서 법령과 같은 효력을 갖는 관습으로서 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이며, 이에 반하여 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위의 당사자의 의사를 보충함에 그치는 것이다.
- [2] 법령과 같은 효력을 갖는 관습법은 당사자의 주장·증명을 기다림이 없이 법원이 직권으로 이를 확정하여야 하고 사실인 관습은 그 존재를 당사자가 주장·증명하여야 하나, 관습은 그 존부자체도 명확하지 않을 뿐만 아니라 그 관습이 사회의 법적 확신이나 법적 인식에 의하여 법적 규범으로까지 승인되었는지의 여부를 가리기는 더욱 어려운 일이므로, 법원이 이를 알 수 없는 경우 결국은 당사자가 이를 주장·증명할 필요가 있다.

[3] 사실인 관습은 사적 자치가 인정되는 분야 즉 그 분야의 제정법이 주로 임의규정일 경우에는 법률행위의 해석기준으로서 또는 의사를 보충하는 기능으로서 이를 재판의 자료로 할 수 있을 것이나 이 이외의 즉 그 분야의 제정법이 주로 강행규정일 경우에는 그 강행 규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 스스로가 관습에 따르도록 위임한 경우 등 이외에는 법적 효력을 부여할 수 없다.

대법원 1976.07.13. 76다983

사실인 관습은 일반생활에 있어서의 일종의 경험칙에 속한다 할 것이고 경험칙은 일종의 법칙인 것이므로 법관은 어떠한 경험칙의 유무를 판단함에 있어서는 당사자의 주장이나 증명에 구애됨이 없이 스스로 직권에 의하여 판단할 수 있다.

☞ 사실인 관습은 그 존재를 당사자가 주장·증명하여야 함이 원칙이나, 당사자의 주장이나 증명 없이도 법원이 직권에 의하여 판단할 수 있다는 예외적인 판결이다.

제2절 신의성실의 원칙과 권리남용금지의 원칙

1. 신의성실의 원칙

(1) 의의

법률관계에 참여한 모든 자는 상대방의 정당한 이익을 고려할 의무를 진다는 것(考慮의命題)이며, 즉 상대방의 신뢰를 헛되이 하지 않도록 성실하게 행동하여야 한다는 원칙을 말한다. 이러한 신의성실의 원칙은 당사자의 행위규범이자 당사자 사이에서의 다툼에 대하여 법관의 재판규범(판단기준)이 될 수 있다.

(2) 근거

제2조 【신의성실】

- ① 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.
- ② 권리는 남용하지 못한다.

“권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.”(법 제2조 제1항). 이에 따라 권리의 행사가 신의칙에 반하면 권리의 남용이 되며, 의무의 이행이 신의칙에 반하면 채무불이행이 된다. 따라서 권리의 행사가 신의칙에 반하면 권리남용이 된다고 하여 권리남용의 금지를 신의칙의 효과로 보고 있으므로 신의칙과 권리남용금지의 원칙의 중복적용을 인정하고 있다(통설·판례).

(3) 적용

- ① 민법 전반에 적용되는 원칙이며, 특히 채권분야·계약관계에 가장 현저하게 적용된다. 따라서 신의칙이 적용되기 위해서는 당사자 사이에 법적인 결합관계가 있어야 한다. 그러나 후술하는 권리남용금지의 원칙은 법적인 결합관계가 없는 경우에도 적용될 수 있다.
- ② 신의성실의 원칙은 민법의 전 영역에 적용되며 사법의 전영역과 나아가 사회법(노동법 등) 및 공법(헌법·행정법·세법 등) 등에도 적용되고 있다.

- ③ 민법상으로는 불공정한 법률행위(제104조), 조건의 성취와 불성취의 의제(제150조), 상린관계(제215조 이하), 사정변경의 원칙(제286조·제628조), 이행보조자의 고의 또는 과실로 인한 채무자의 책임(제391조), 채권자지체(제400조·제538조), 계약체결상의 과실(제535조), 위험부담의 문제(제537조) 등에 그 적용이 있다.
- ④ 신의칙위반을 이유로 제한능력자의 취소권을 배척하지는 못한다. 우리 민법상 제한능력자 제도는 어떤 제도보다 우월하게 적용되기 때문이다. 아울러 신의칙을 인정하는 것이 강행법규의 입법취지를 몰각(위배)하게 하는 경우에도 신의칙은 적용되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

(4) 파생원칙

1) 실효의 원칙

권리자가 그의 권리를 장기간 행사하지 않아서 상대방이 이제는 그 권리를 행사하지 않는 것으로 믿을 만한 사유가 있는 후 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것은 이 원칙에 반하여 인정되지 않는다.

2) 사정변경의 원칙

판례는 사정변경의 원칙을 용인(容忍)하지 않고 있으나 예외적으로 계속적 채권관계, 즉 계속적인 보증계약에 있어서 보증계약 성립 당시의 사정에 현저한 변경이 생긴 경우에는 사정변경을 이유로 보증계약을 해지할 수 있다고 한다.

3) 금반언(禁反言)의 원칙

자신의 선행행위와 모순되는 행위는 허용되지 않는다는 원칙으로서 모순행위금지의 원칙이라고도 한다.

중요판례

대법원 1983.05.24. 82다카1919

신의칙은 비단 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제·지배하는 원리로 파악되며, 따라서 신의칙에 반하는 소권(訴權)의 행사 또한 허용될 수 없는 것이다.

☞ 민사소송법은 “당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다 (제1조 제2항).” 고 규정하고 있다. 따라서 신의칙은 널리 공법분야에도 적용된다.

대법원 1983.05.25. 91다41750

사용자로부터 해고된 근로자가 퇴직금 등을 수령하면서 아무런 이의의 유보나 조건을 제기하지 않았다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 해고처분을 유효한 것으로 인정했다고 할 것이고, 따라서 해임 및 의원면직된 후 9년이 지난 후에 해고의 효력을 다투는 訴를 제기하는 것은 신의칙이나 금반언의 원칙에 위배된다.

대법원 2003.4.11. 2002다63275

환자가 병원에 입원하여 치료를 받는 경우에 있어서, 병원은 진료뿐만 아니라 환자에 대한 숙식의 제공을 비롯하여 간호, 보호 등 입원에 따른 포괄적 채무를 지는 것인 만큼, 병원은 병실의 출입자를 통제·감독한다가 그것이 불가능하다면 최소한 입원환자에게 휴대품을 안전하게 보관할 수 있는 시정장치가 있는 사물함을 제공하는 등으로 입원환자의 휴대품 등의 도난을 방지함에 필요한 적절한 조치를 강구하여 줄 신의칙상의 보호의무가 있다고 할 것이고, 이를 소홀히 하여 입원환자와는 아무런 관련이 없는 자가 입원환자의 병실에 무단출입하여 입원환자의 휴대품 등을 절취하였다면 병원은 그로 인한 손해배상책임을 면하지 못한다.

대법원 1996.05.10. 95다12217

민법상의 신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자를 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 안 된다는 추상적인 규범을 말하는 것으로서, 신의성실에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위하여는 상대방에게 신의를 공여하였다거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.

대법원 1998.08.21. 97다37821

신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다.

대법원 2019.4.23. 2015다28968

[1] 부동산 거래에 있어 거래 상대방이 일정한 사정에 관한 고지를 받았더라면 그 거래를 하지 않았을 것임이 경험칙상 명백한 경우에는 신의성실의 원칙상 사전에 상대방에게 그와 같은 사정을 고지할 의무가 있으며, 그와 같은 고지의무의 대상이 되는 것은 직접적인 법령의 규정뿐 아니라 널리 계약상, 관습상 또는 조리상의 일반원칙에 의하여도 인정될 수 있고, 일단 고지의무의 대상이 되는 사실이라고 판단되는 경우 이미 알고 있는 자에 대하여는 고지할 의무가 별도로 인정될 여지는 없다.

[2] 우리 사회의 통념상으로는 공동묘지가 주거환경과 친한 시설이 아니어서 분양계약의 체결 여부 및 가격에 상당한 영향을 미치는 요인일 뿐만 아니라 대규모 공동묘지를 가까이에서 조망할 수 있는 곳에 아파트단지가 들어선다는 것은 통상 예상하기 어렵다는 점 등을 감안할 때 아파트 분양자는 아파트단지 인근에 공동묘지가 조성되어 있는 사실을 수분양자에게 고지할 신의칙상의 의무를 부담한다.

대법원 2002.09.04. 2000다54406

일반적으로 교환계약을 체결하려는 당사자는 서로 자기가 소유하는 교환 목적물은 고가로 평가하고 상대방이 소유하는 목적물은 염가로 평가하여 보다 유리한 조건으로 교환계약을 체결하기를 희망하는 이해상반의 지위에 있고 각자가 자신의 지식과 경험을 이용하여 최대한으로 자신의 이익을 도모할 것이 예상되기 때문에, 당사자 일방이 알고 있는 정보를 상대방에게 사실대로 고지하여야 할 신의칙상의 주의의무가 인정된다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 어느 일방이 교환 목적물의 시가나 그 가액 결정의 기초가 되는 사항에 관하여 상대방에게 설명 내지 고지를 할 주의의무를 부담한다고 할 수 없고, 일방 당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 아니하거나 혹은 허위로 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지하였다 하더라도 이는 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭을 한 것이라고 볼 수 없다.

대법원 1995.02.28. 94다51789

토지거래허가(土地來去許可)를 받지 아니하여 유동적 무효상태에 있는 계약이라고 하더라도 일단 거래허가신청을 하여 불허되었다면 특별한 사정이 없는 한, 불허된 때로부터 그 거래계약은 확정적으로 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 거래허가신청을 하지 아니하여 유동적 무효상태에 있던 계약이 확정적으로 무효로 됨에 있어서 귀책사유가 있는 자라고 하더라도 그 계약의 무효를 주장하는 것이 신의칙에 반한다고 할 수 없다(이 경우 상대방은 그로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 있다).

대법원 2003.04.22. 2003다2390,2406

특별한 사정이 없는 한, 법령에 위반되어 무효임을 알고서도 그 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 무효를 주장하더라도 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반하지 않는다.

대법원 1989.4.11. 87다가131

학생에 대한 학교의 편입학허가, 대학교졸업인정 등이 그 자격요건을 규정한 교육법에 위반되어 무효라면 이와 같은 당연무효의 행위를 학교법인이 취소하는 것은 그 편입학허가 등의 행위가 처음부터 무효이었음을 당사자에게 통지하여 확인시켜주는 것에 지나지 않으므로 여기에 신의칙을 적용할 수 없고 그러한 뜻의 취소권은 시효로 인하여 소멸하지도 않는다.

대법원 1998.05.22. 96다24101

취득시효완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다가 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다.

대법원 1981.07.07. 80다2064

채권자가 채권을 확보하기 위하여 제3자의 부동산을 채무자에게 명의신탁하도록 한 다음 해당 부동산에 대하여 강제집행을 하는 행위는 신의칙에 반한다.

대법원 2007.11.16. 2005다71659

법정대리인의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 미성년자가 사후에 법정대리인의 동의 없음을 사유로 들어 이를 취소하는 것은 신의칙에 반하지 않는다.

대법원 2005.10.28. 2005다45827

권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실패의 원칙에 따라 그 권리의 행사가 허용되지 않는다고 보아야 할 것이고, 또한 실패의 원칙이 적용되기 위하여 필요한 요건으로서의 실패기간(권리를 행사하지 아니한 기간)의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 있는 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리를 행사하지 아니한 기간의 장단과 함께 권리자 측과 상대방 측 쌍방의 사정 및 객관적으로 존재한 사정 등을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 할 것이다.

대법원 2006.6.15. 2004다59393

세무사의 세무대리업무처리에 대한 보수에 관하여 의뢰인과의 사이에 약정이 있는 경우, 그 대리업무를 종료한 세무사는 특별한 사정이 없는 한 약정된 보수액을 전부 청구할 수 있는 것이 원칙이지만, 대리업무수입의 경위, 보수금의 액수, 세무대리업무의 내용 및 그 업무 처리과정, 난이도, 노력의 정도, 의뢰인이 세무대리의 결과 얻게 된 구체적 이익과 세무사 보수규정, 기타 변론에 나타난 제반 사정을 고려하여 그 약정된 보수액이 부당하게 과다하여 신의성실의 원칙이나 형평의 원칙에 반하는 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 상당하다고 인정되는 범위 내의 보수액만을 청구할 수 있다고 할 것이다.

대법원 1992.3.31. 91다29804

변호사의 소송위임사무처리에 대한 보수의 액에 관하여 의뢰인과 사이에 약정이 있는 경우에 위임사무를 완료한 변호사는 특별한 사정이 없는 한 약정된 보수액을 전부 청구할 수 있는 것이 원칙이기는 하지만, 의뢰인과의 평소부터의 관계·사건 수입의 경위·착수금의 액·사건 처리의 경과와 난이도·노력의 정도·소송물가액·의뢰인이 승소로 인하여 얻게 된 구체적 이익과 소속 변호사회의 보수규정 등 기타 변론에 나타난 제반 사정에 비추어, 약정된 보수액이 부당하게 과다하여 신의성실의 원칙이나 형평의 원칙에 반한다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는, 예외적으로 위와 같은 제반 사정을 고려하여 상당하다고 인정되는 범위 내의 보수액만을 청구할 수 있다고 보아야 할 것이다.

대법원 2001.11.27. 2001므1353

인지청구권은 본인의 일신전속적인 신분관계상의 권리로서 포기할 수도 없으며 포기하였더라도 그 효력이 발생할 수 없는 것이고, 이와 같이 인지청구권의 포기가 허용되지 않는 이상 거기에 실효의 법리가 적용될 여지도 없다.

대법원 2002.01.08. 2001다60019

- [1] 권리자가 장기간에 걸쳐 그 권리를 행사하지 아니하여 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙에 위반되어 허용되지 아니한다고 하려면, 의무자인 상대방이 더 이상 권리자가 그 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있어야 한다.
 - [2] 토지소유자가 그 점유자에 대하여 부당이득반환청구권을 장기간 적극적으로 행사하지 아니하였다는 사정만으로는 부당이득반환청구권이 이른바 실효의 원칙에 따라 소멸하였다고 볼 수 없다.
- ☞ 일반적인 권리행사와 달리 소유권에 관한 권리의 실효인정에 대하여 판례는 신중한 태도를 보이고 있다.

대법원 2002.05.31. 2002다1673

계속적 보증에 있어서는 보증계약 후 당초 예기하지 못한 사정변경이 생겨 보증인에게 계속하여 보증책임을 지우는 것이 당사자의 의사해석 내지 신의칙에 비추어 상당하지 못하다고 인정되는 경우에, 상대방인 채권자에게 신의칙상 묵과할 수 없는 손해를 입게 하는 등의 특별한 사정이 없는 한 보증인의 일방적인 보증계약해지의 의사표시에 의하여 보증계약을 해지할 수 있다.

대법원 1990.02.27. 89다카1381

회사의 임원이나 직원의 지위에 있기 때문에 회사의 요구로 부득이 회사와 제3자 사이의 계속적 거래로 인한 회사의 채무에 대하여 보증인이 된 자가 그 후 회사로부터 퇴사하여 임원이나 직원의 지위를 떠난 때에는 보증계약 성립당시의 사정에 현저한 변경이 생긴 경우에 해당하므로 사정변경을 이유로 보증계약을 해지할 수 있다고 보아야 한다.

대법원 2004.01.27. 2003다45410

채권자와 채무자 사이에 계속적인 거래관계에서 발생하는 불확정한 채무를 보증하는 이른바 계속적 보증의 경우뿐만 아니라 특정채무를 보증하는 일반보증의 경우에 있어서도, 채권자의 권리행사가 신의칙에 비추어 용납할 수 없는 성질의 것인 때에는 보증인의 책임을 제한하는 것이 예외적으로 허용될 수 있을 것이나, 일단 유효하게 성립된 보증계약에 따른 책임을 신의칙과 같은 일반원칙에 의하여 제한하는 것은 자칫 잘못하면 사적 자치의 원칙이나 법적 안정성에 대한 중대한 위협이 될 수 있으므로 신중을 기하여 극히 예외적으로 인정하여야 한다.

☞ 사정변경의 원칙의 적용에 있어서, 판례는 계속적 채권관계, 특히 계속적 보증관계에서는 일관되게 사정변경의 원칙을 인정한다. 아울러 일반 확정채무에 대한 보증에 대하여는 그 적용을 부정하였으나, 일반 보증에 있어서도 신의칙에 반하는 특별한 사정이 있는 경우에는 보증인의 책임을 합리적인 범위로 제한할 수 있다고 하여, 판례의 태도가 완화되었다.

대법원 2007.03.29. 2004다31302

사정변경으로 인한 계약해제는, 계약성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 발생하였고 그러한 사정의 변경이 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서, 계약내용대로의 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 계약준수 원칙의 예외로서 인정되는 것이고, 여기에서 말하는 사정이라 함은 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정으로서, 일방당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 의미하는 것은 아니다.

☞ 종래의 판례는 사정변경에 의한 계약해제권을 인정하지 않았으나, 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 있고, 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 경우에는 해제권을 인정한다는 판결이다.

대법원 1996.11.12. 96다34061

임대차계약에 있어서 차임 부증액의 특약이 있더라도 그 약정 후 그 특약을 그대로 유지시키는 것이 신의칙에 반한다고 인정될 정도의 사정변경이 있다고 보여지는 경우에는 형평의 원칙상 임대인에게 차임증액청구를 인정하여야 한다.

◆ 금반언의 원칙의 적용을 긍정한 판례

대법원 1994.09.27. 94다20617

대리권한 없이 타인의 부동산을 매도한 자가 그 부동산을 상속한 후 소유자의 지위에서 자신의 대리행위가 무권대리행위임을 이유로 무효임을 주장하여 등기말소 등을 구하는 것은 금반언의 원칙이나 신의칙상 허용될 수 없다.

☞ 무권대리인이 본인의 지위를 상속받아 승계한 경우, 상속인의 지위에서 추인을 거절하여 무효를 주장하는 것은 금반언의 원칙이나 신의칙에 반한다.

대법원 2000.04.25. 99다34475

사용자로부터 해고된 근로자가 퇴직금 등을 수령하면서 아무런 이의의 유보나 조건을 제기하지 않았다면 해고의 효력을 인정하지 아니하고 이를 다투고 있었다고 볼 수 있는 객관적인 사정이 있다거나 그 외에 상당한 이유가 있는 상황 하에서 이를 수령하는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 해고의 효력을 인정하였다고 할 것이고, 따라서 그로부터 오랜 기간이 지난 후에 그 해고의 효력을 다투는 소를 제기하는 것은 신의칙이나 금반언의 원칙에 위배된다.

대법원 1997.06.27. 97다12211

근저당권자가 담보로 제공된 건물에 대한 담보가치를 조사할 당시 대항력을 갖춘 임차인이 그 임대차사실을 부인하고 임차보증금에 대한 권리주장을 앗겠다는 내용의 확인서를 작성해 준 경우, 그 후 건물에 대한 경매절차에서 이를 반복하여 대항력 있는 임대차의 존재를 주장함과 아울러 임차보증금의 배당요구를 하는 것은 금반언 및 신의칙에 위반된다.

◆ 금반언의 원칙의 적용을 부정한 판례

대법원 1993.12.24. 93다44319, 93다44326

강행법규인 국토이용관리법(現 국토의 계획 및 이용에 관한 법률) 규정을 위반하였을 경우에 있어서 위반한 자 스스로가 무효를 주장함이 신의성실의 원칙에 위배되는 권리의 행사라는 이유로서 이를 배척한다면 투기거래계약의 효력발생을 금지하려는 국토이용관리법의 입법 취지를 완전히 몰각시키는 결과가 되므로, 거래당사자 사이의 약정내용과 취득목적대로 관할관청에 토지거래허가신청을 하였을 경우에 그 신청이 국토이용관리법 소정의 허가기준에 적합하여 허가를 받을 수 있었으나 다른 급박한 사정으로 이러한 절차를 회피하였다고 볼만한 특단의 사정이 엿보이지 아니하는 한, 그러한 주장이 신의성실의 원칙에 반한다고는 할 수 없다.

☞ 대법원은 같은 취지로 다음과 같은 판결을 하였다. “강행법규에 위반하여 무효인 수익 보장약정이 투자신탁회사가 먼저 고객에게 제의를 함으로써 체결된 것이라고 하더라도, 이러한 경우에 강행법규를 위반한 투자신탁회사 스스로가 그 약정의 무효를 주장함이 신의칙에 위반되는 권리의 행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면, 이는 오히려 강행법규에 의하여 배제하려는 결과를 실현시키는 셈이 되어 입법취지를 완전히 몰각하게

되므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 주장이 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 할 수 없다(대법원 1999.03.23. 99다4405).”

대법원 2016.9.30. 2016다218713

채무자의 소멸시효에 기한 항변권의 행사도 우리 민법의 대원칙인 신의성실의 원칙과 권리남용금지의 원칙의 지배를 받는 것이어서, 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하였거나, 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었거나, 또는 일단 시효완성 후에 채무자가 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리가 그와 같이 신뢰하게 하였거나, 채권자 보호의 필요성이 크고 같은 조건의 다른 채권자가 채무의 변제를 수령하는 등의 사정이 있어 채무이행의 거절을 인정함이 현저히 부당하거나 불공평하게 되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것이 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로서 허용될 수 없다.

2. 권리남용금지의 원칙

(1) 의의 및 근거

외형상은 권리의 행사와 같이 보이지만 구체적·실질적으로 볼 때에는 권리의 사회성·공공성에 반하여 권리의 행사로서 인정될 수 없는 행위를 말한다. 민법은 “권리는 남용하지 못한다.”라고 규정(제2조 제2항)하고 있다.

(2) 적용

권리남용금지원칙은 신의칙과 함께 민법 전체에 적용되는 통칙적 규정이며, 공권(公權) 중에서도 소권(訴權) 등이 남용되는 경우에도 이 원칙이 적용되므로 널리 공법 분야에도 이 원칙은 적용된다.

(3) 요건

- ① 권리의 행사가 있을 것(권리의 불행사가 권리남용이 되는 경우가 있음)
- ② 권리의 행사가 사회성·공공성에 반할 것
- ③ 가해목적이 존재할 것(이 요건은 주관적 요건으로서 반드시 요하는 것은 아니라는 학설, 즉 객관적 표준설이 다수설)
- ④ 위법성이 있을 것

(4) 판례의 태도

대법원의 판례는 학설의 견해와는 달리 주관적 요건의 인정 여부에 대하여 명료하지는 않으나 대체로 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 그 요건으로 요구하는 것이 주류적 태도이다.

(5) 남용의 효과

- ① 청구권의 행사가 남용이 되면 법은 조력(助力)하지 않는다(주장배척).
- ②형성권의 행사가 남용이 되면 효과의 발생이 부정된다.
- ③친권의 행사가 남용이 되면 친권상실 또는 일시정지의 선고를 받는 경우가 있다(제924조).
- ④항변권의 행사가 남용이 되면 권리의 행사가 저지된다.

중요판례

대법원 2003.11.27. 2003다40422

- [1] 권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있으며, 어느 권리행사가 권리남용이 되는가의 여부는 개별적이고 구체적인 사안에 따라 판단되어야 한다.
- [2] 신축중인 건물 부지를 경락받은 자가 완공된 건물의 철거를 구하는 것은 권리남용에 해당하지 않는다.
- ☞ 권리남용의 요건으로서의 주관적 요건(가해의 의사나 목적)은 필요하지 않다는 것이 통설(객관적표준설)의 입장이며, 판례는 일관성이 없으나 과거부터 현재에 이르기까지 다수의 판결에서는 객관적 요건과 함께 주관적 요건도 함께 요구하고 있다.

대법원 2003.4.11. 2002다59481

상계권자의 지위가 법률상 보호를 받는 것은, 원래 상계제도가 서로 대립하는 채권·채무를 간이한 방법에 의하여 결제함으로써 양자의 채권채무관계를 원활하고 공정하게 처리함을 목적으로 하고 있으므로 상계권을 행사함에 이른 구체적·개별적 사정에 비추어, 그것이 위와 같은 상계 제도의 목적이나 기능을 일탈하고, 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 경우에는, 그 상계권의 행사는 신의칙에 반하거나 상계에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용되지 않는다고 함이 상당하고, 상계권 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 일반적인 권리 남용의 경우에 요구되는 주관적 요건을 필요로 하는 것은 아니다.

대법원 2006.03.10. 2002다1321

권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하며(민법 제2조), 법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하여서는 아니 되고, 권리행사가 정의를 관념에 비추어 용인할 수 없는 상태에 이른 경우에는 신의성실의 원칙에 의하여 그 권리행사를 부정할 수 있다.

대법원 1998.06.12. 96다52670

외국에 이민을 가 있어 주택에 입주하지 않으면 안 될 급박한 사정이 없는 딸이 고령과 지병으로 고통을 겪고 있는 상태에서 달리 마땅한 처처도 없는 아버지와 그를 부양하면서 동거하고 있는 남동생을 상대로 자기 소유 주택의 명도 및 퇴거를 청구하는 행위는 인륜에 반하는 행위로서 권리남용에 해당한다.

대법원 1997.01.24. 96다43928

친권자인 모(母)가 미성년자인 자(子)의 법정대리인으로서 자의 유일한 재산을 아무런 대가도 받지 않고 증여하였고 상대방이 그 사실을 알고 있었던 경우, 그 증여행위는 친권의 남용에 의한 것이므로 그 효과는 자에게 미치지 않는다.

☞ 권리남용금지의 원칙은 물권법외에 채권법이나 가족법에도 적용된다. 상기의 판례는 권리남용금지의 원칙이 가족법에 적용됨을 판시한 것이다. 그러나 가장 두드러지게 적용되는 분야(실효성이 가장 큰 분야)는 물권법이다.

제3절 민법의 효력

(1) 시(時)

“본법은 특별한 규정이 있는 경우 외에는 본법 시행일 전의 사항에 대하여도 적용한다.”고 규정(민법부칙 제2조)하여 법률불소급의 원칙의 예외를 인정하고 있다. 그러나 기득권 존중의 이상에 입각하여 “그러나 이미 구법에 의하여 생긴 효력에 영향을 미치지 아니한다.”라고 규정(부칙 제2조 단서)하여 실질적으로는 불소급의 원칙을 채택한 것과 같다.

(2) 인(人)

- ① 민법은 모든 한국국적을 가지는 자에게 적용한다. 따라서 국외에 있는 한국인에게도 당연히 적용된다(속인주의 ; 屬人主義).
- ② 민법은 대한민국 영토 내의 모든 외국인에게도 적용된다(속지주의 ; 屬地主義).

(3) 장소

민법은 우리나라 영토 전체에 그 효력이 미친다.

제4절 민법상의 권리(私權)

1. 권리의 분류

(1) 내용상의 분류

1) 인격권

권리의 주체와 분리할 수 없는 권리이다.

■ 생명권·신체권·자유권·명예권·정조권·성명권·초상권 등

2) 가족권(신분권)

친족권과 상속권이 이에 해당한다.

■ ① 친족권 : 친권·부양청구권·부부 사이의 동거청구권·면접교섭권·재산분할 청구권 등

② 상속권 : 재산상속권

3) 재산권

경제적 이익을 내용으로 하는 권리로서 양도성과 상속성을 가지는 권리이다.

■ ① 물권 : 점유권·소유권·지상권·지역권·전세권·유치권·질권·저당권 등

② 준물권 : 광업권·어업권 등 물건을 전속적으로 취득할 수 있는 권리

③ 채권 : 임차권·이자채권 등 일방이 타방에 대하여 일정한 행위를 요구하는 권리

④ 지식재산권(지적재산권·지식재산권) : 저작권·특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등

4) 사원권

단체의 구성원이 그 지위에 기하여 단체에 대하여 가지는 권리를 말한다.

■ ① 공익권 : 의결권·소수사원권·사무집행권·감독권 등

② 자익권 : 이익배당청구권·잔여재산분배청구권·사단설비비용권 등

(2) 작용에 의한 분류

1) 지배권

객체를 직접 배타적으로 지배할 수 있는 권리로서 절대권 또는 대세권(對世權)이라 한다.

■ 인격권·물권·지식재산권 등

2) 청구권

특정의 타인에 대하여 작위 또는 부작위를 요구할 수 있는 권리를 말하며 상대권 또는 대인권(對人權)이라 한다.

■ 채권·물권적 청구권·부양청구권·부부의 동거청구권·재산분할청구권·상속회복 청구권 등

3) 형성권

권리자의 일방적 의사표시만으로 권리의 발생·변경·소멸의 효과가 생기는 권리를 말한다.

- ① 권리자의 의사표시만으로 효력이 생기는 것 : 동의권·철회권·상계권·추인권·해지권·해제권·취소권·매매의 일방예약완결권 등
- ② 법원의 판결에 의하여 비로소 효력이 생기는 것 : 채권자취소권·친생부인권·재판상 이혼권 등
- ③ 청구권이라는 이름으로 불리우나 실질이 형성권인 권리 : 공유물분할청구권·지상물매수청구권·지료(차임, 전세금)증감청구권·지상권소멸청구권·전세권 소멸청구권·부속물매수청구권 등

4) 항변권

타인의 청구권의 행사를 저지하는 권리를 말한다.

- ① 연기적 항변권 : 동시이행의 항변권, 보증인의 최고·검색의 항변권
- ② 영구적 항변권 : 상속인의 한정승인의 항변권

4) 항변권

〈정리도해(권리의 기본적 분류)〉

구분	종류	내용
내용에 의한 분류	재산권	경제적 이익을 누리는 것을 내용으로 하는 권리로서 양도성과 상속성을 가지는 권리이다(물권·준물권·채권·지식재산권).
	인격권	권리의 주체와 분리할 수 없는 인격적 이익을 누리는 것을 내용으로 하는 권리이다(생명권·신체권·명예권·정조권·성명권·초상권 등).
	가족권	가족관계 내지 친족관계에 있어서의 일정한 지위에 따르는 이익을 누리는 것을 내용으로 하는 권리이다(친권·부양청구권·상속권 등).
	사원권	사단의 구성원이 그 지위에 기하여 사단에 대하여 가지는 권리를 말한다(이익배당청구권·의결권·업무집행권 등).
작용에 의한 분류	지배권	권리의 객체를 직접 배타적으로 지배할 수 있는 권리로서 절대권 또는 대세권이라고도 한다(인격권·물권·지식재산권·친권 등).
	청구권	특정인이 다른 특정인에 대하여 일정한 행위(급부)를 요구할 수 있는 권리이다(채권·물권적 청구권·부양청구권·재산분할청구권·계약갱신청구권 등).
	형성권	권리자의 일방적 의사표시만으로 권리의 발생·변경·소멸의 효과가 생기는 권리를 말하며, 상대방의 동의나 승낙을 요하지 않는다(별도로 설명).
	항변권	타인의 청구권의 행사를 저지하는 권리를 말한다(연기적 항변권으로서의 동시이행의 항변권과 보증인의 최고·검색의 항변권이 있고, 영구적 항변권으로서 상속인의 한정승인의 항변권이 있다).
기 타	절대권과 상대권	절대권(대세권)은 모든 사람에 대해 주장할 수 있는 권리(물권·지식재산권·친권·후견권 등)이며, 상대권(대인권)이란 특정인에 대해서만 주장할 수 있는 권리이다(채권 등의 청구권).
	일신전속권과 비전속권	일신전속적 권리란 양도성과 상속성이 없는 권리를 말하며(인격권·신분권 등), 비전속적 권리란 양도성·상속성이 있는 권리이다(물권·채권 등의 재산권).
	주된 권리와 종된 권리	원본채권이 주된 권리라면, 이자채권은 종된 권리에 해당한다.
	기대권	현재 발생된 상태의 권리가 아니라 기대상태에 있는 권리이다(조건부 권리·기한부 권리 등).

2. 권리의 순위와 경합

(1) 권리의 충돌

① 물권과 채권의 충돌

- ㉠ 성립순위와 관계없이 원칙적으로 물권이 채권에 우선한다.
- ㉡ 등기된 임차권은 물권과 동일한 효력(물권화)이 있으므로 후에 성립하는 물권에 우선한다(제621조).

② 물권 상호간의 충돌

- ㉠ 물권 상호간에는 먼저 성립한 물권이 후에 성립한 물권에 우선한다.
- ㉡ 제한물권은 소유권에 우선한다.

③ 채권 상호간의 충돌

- ㉠ 모든 채권 상호간에는 채권자평등의 원칙이 적용된다.
- ㉡ 등기된 임차권은 다른 채권에 우선한다.

(2) 권리의 경합

- ① 임차인이 임차목적물을 소실시켜 반환할 수 없게 된 경우에는 채무불이행으로 인한 손해배상청구권(제390조 이하)과 불법행위로 인한 손해배상청구권(제750조 이하)의 경합이 일어나게 된다.
- ② 하나의 권리를 행사하여 목적 달성이 된 경우에는 나머지 권리는 존재 목적을 잃고 당연히 소멸한다.
- ③ 각각의 권리는 독립하여 존재하므로 서로 관계없이 행사할 수 있으며 각각 시효 기타 원인으로 소멸할 수 있다.

(3) 법규의 경합

구 분	내 용
의의	① 하나의 사실관계에 대해 여러 개의 권리가 발생하지만 그 중 하나의 법규가 다른 법규를 배제하는 것을 말한다. ② 보통 일반법과 특별법과의 관계에서 나타난다.
사례	사용자배상책임(제756조)과 국가배상책임(국가배상법 제2조)



2장 권리의 주체(自然人)

제1절 권리능력

1. 권리주체와 권리능력

(1) 권리주체

권리주체란 권리의 귀속자를 말한다. 따라서 의무의 귀속자를 의무주체라고 할 수 있다.

(2) 권리능력

제3조 【권리능력의 존속기간】

사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.

〈주체별 권리능력의 취득〉

구분	내용
자연인	① 민법 제3조는 “사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.”라고 규정하여 권리능력의 존속기간을 명시하고 있다. ② 권리능력에 관한 규정은 강행규정이다.
법인	① 사단법인과 재단법인으로서 권리의 주체로서의 독립성을 인정한다. ② 권리능력의 존속기간은 설립등기에서 청산의 종결까지이다. ③ 권리능력 없는 사단이나 재단은 예외적으로 소송법상 당사자능력을 인정한다.
외국인	내외국인 평등주의에 입각하나 예외적으로 권리능력을 제한하는 경우가 있다.

2. 자연인의 권리능력

(1) 출생의 시기에 관한 학설의 대립

진통설(형법상 통설)과 전부노출설(민법상 통설)이 있다.

(2) 출생의 신고

출생이 있으면 1월 이내에 관계공무원에게 신고하여야 하지만 출생신고의 유무는 권리능력의 취득과는 무관(보고적 신고)하다. 출생신고는 일종의 보고적 신고이지 창설적 신고가 아니므로 신고가 없어도 출생과 동시에 당연히 권리능력을 취득한다.

(3) 태아의 권리능력

1) 입법주의

① 일반적 보호주의

- ㉠ 모든 법률관계에서 태아를 이미 출생한 것으로 보는 입법주의를 말한다.
- ㉡ 태아의 이익보호의 장점은 있으나 적용범위가 불명확하다는 단점이 있다.

② 개별적 보호주의

- ㉠ 중요한 법률관계에 대해서만 태아를 이미 출생한 것으로 보는 입법주의를 말한다.
- ㉡ 적용범위가 명확하나 태아보호에 불완전하다는 단점이 있다.

2) 우리 민법의 태도(개별적 보호주의)

① 불법행위로 인한 손해배상청구권(제762조)

- ㉠ 父의 생명침해로 인한 子 자신이 위자료를 청구하는 경우를 말하며, 父의 생명 침해로 인한 재산적 손해는 일단 父에게 손해배상청구권이 발생하고 그것이 상속인(태아)에게 상속된다는 것이 판례의 태도이다.
- ㉡ 태아 자신이 입은 불법행위로 인한 손해에 대하여 배상청구를 하는 경우이다.

② 상속(제1000조)

③ 유류분권(제1112조)

④ 대습상속(제1001조)

⑤ 유증(제1064조)

⑥ 인지(제858조) : 父의 태아에 대한 인지는 인정되나 태아의 父에 대한 인지청구권은 부정된다는 것이 다수설과 판례의 태도이다.

⑦ 사인증여(제562조)

- ㉠ 긍정설(다수설)

- ㉔ 부정설(소수설·판례) : 논거로서 첫째, 법률행위의 성질상 유증은 단독행위이고 사인증여는 계약이라는 것이다. 둘째, 현행법상 태아의 법정대리인제도가 인정되지 않는다.

3) 태아의 법률상의 지위

개별적 보호주의에 입각하여 태아의 지위를 “이미 출생한 것으로 본다.”의 의미를 어떻게 파악하여야 하는가에 대하여 정지조건설(판례)과 해제조건설(다수설)의 대립이 있다.

학설	정지조건설	해제조건설
학설의 대립	판례	다수설
태아중의 권리능력	① 태아인 동안에는 권리능력이 없다. ② 태아의 존재를 고려하지 않고 법률관계를 처리한다.	① 태아인 동안에도 출생한 것으로 보는 범위 내에서 사건이 발생한 시점부터 제한적인 권리능력이 인정된다. ② 태아도 출생한 사람과 동일하게 법률관계를 처리한다.
출생의 경우	사건 발생시까지 소급하여 출생했던 것으로 여겨 법률관계를 처리한다.	태아인 동안에 처리된 법률관계에는 변동이 없다.
사산의 경우	태아인 동안에 처리된 법률관계에는 변동이 없다.	사건발생시까지 소급하여 소멸하게 되며, 태아인 동안에 처리된 법률관계는 다시 정리를 요한다.
권리행사의 관계	출생 전에는 권리행사가 문제되지 않는다.	태아인 동안에도 권리행사를 위해 법정 대리인의 존재를 인정한다.
장·단점	① 태아에게 권리능력이 없으므로 법정대리인을 둘 수 없으며 따라서 상속재산의 보존·관리가 불가능하다. ② 태아의 사산의 경우이라도 타인에게 예측하지 않은 손해를 줄 염려가 없다. ③ 태아보다는 상대방 또는 제3자의 보호에 치중하고 있다.	정지조건설의 경우와 정반대의 결과가 된다.

중요판례

대법원 1968.03.05. 67다2869

교통사고의 충격으로 태아가 조산되고 그로 인하여 제대로 성장하지 못하고 사망하였다면 한편으로 산모에 대한 불법행위인 동시에 한편으로는 태아에 대한 불법행위라고 볼 수 있다.

☞ 태아의 개별적 보호주의에 따라 태아는 가해자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상청구권을 행사할 수 있다. 다만, 그 권리의 행사는 태아가 살아서 출생한다는 것을 전제로 하는 것이다. 비록 태아가 조산하였지만 살아서 출생한 후 사망한 것으로써 당연히 생명 침해로 인한 손해배상청구권을 행사할 수 있다는 판결이다.

대법원 1976.09.14. 76다1365

태아가 모체와 같이 사망하여 출생의 기회를 가지지 못한 이상, 불법행위로 인한 손해배상청구권을 논할 여지가 없다.

☞ 개별적 보호주의에 따라 '태아가 특정한 권리에 있어서 이미 태어난 것으로 본다'는 의미에 대하여 정지조건설(少, 判)과 해제조건설(多)의 대립이 있으며, 판례는 정지조건설을 취한다. 그러나 어떤 견해에 의하더라도 최소한 태아가 살아서 출생한다는 것을 전제로 한다.

대법원 1993.04.27. 93다4663

태아도 손해배상청구권에 관하여는 이미 출생한 것으로 보는 바, 父가 교통사고로 상해를 입을 당시 태아가 출생하지 않았다 하더라도 그 뒤에 출생한 이상 父의 부상으로 인하여 입게 될 정신적 고통에 대한 위자료를 청구할 수 있다.

3. 외국인의 권리능력

(1) 외국인의 권리능력이 부정되는 경우(절대적 제한)

- ① 한국선박·항공기의 소유권(선박법 제2조, 항공법 제6조)
- ② 도선사가 되는 권리(도선법 제6조)

(2) 상호주의에 의한 제한

- ① 토지를 취득하는 계약을 체결한 경우에는 계약체결일로부터 60일 내에 신고관청에 신고하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 제8조).
- ② 지식재산권(지적재산권)의 취득

4. 권리능력의 종기(終期)

(1) 자연인의 사망

자연인의 권리능력은 심폐정지설에 입각한 사망으로 소멸한다.

(2) 동시사망의 추정

제30조 【동시사망】

2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다.

- ① 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다(제30조). 추정규정이므로 반증을 들어 그 추정을 번복할 수 있다.
- ② 동시에 사망한 것으로 추정됨으로써 사망자 사이에는 상속의 문제가 발생되지 아니한다. 예컨대, A와 미혼의 자인 B가 항공기로 여행 중에 항공기가 추락하여 모두 사망하였는데 그 유족으로 A의妻 C와 母 D가 있을 때, C와 D간의 상속관계가 문제가 될 것이다. 즉, A와 B 중 누가 먼저 사망하였는가에 따라 결과가 달라지게 되는 것이다. 만약 A가 먼저 사망하였음이 증명되면 B·C가 A를 상속하게 되고 이어서 B의 상속분은 B의 사망으로 인해 C에게 단독 상속된다(제1000조). 그러나 만약 B가 A보다 먼저 사망하였음이 증명되면 직계비속(B)이 없으므로 A의 유산은 C·D에게 상속된다(제1000조·제1003조). 이처럼 A와 B의 사망의 선후에 따라 그 결과가 달라지지만 실제 동일한 사고에 의한 경우에 누구의 사망이 먼저 인가를 증명한다는 것은 불가능하므로 우리 민법은 이 경우 A와 B가 동시에 사망한 것으로 추정하고 있다. 따라서 이상의 사례에서의 결론은 C와 D가 공동상속하게 되는 것이다.

(3) 인정사망

- ① 사망한 것이 확실하다고 생각되지만 시체를 발견할 수 없는 경우에 그것을 조사한 관공서의 사망보고에 의하여 가족관계등록부에 사망으로 기재하는 제도이다(가족관계등록에 관한 법률 제87조).
- ② 실종선고는 간주주의를 취하나, 인정사망은 추정주의를 취한다.

(4) 실종선고

사망이 확실하지 않으나 그 개연성이 매우 높은 경우에 실종선고에 의하여 일정한 시기에 사망한 것으로 간주하는 제도이다(제27조). 실종자의 종래의 주소나 거소를 중심으로 한 사법적 법률관계만을 종료하게 하는 제도로서 실종자의 권리능력의 상실과는 무관하다.

제2절 행위능력

1. 각종 능력의 비교

종류	의의	흠결의 효과
권리능력	권리나 의무의 주체가 될 수 있는 추상적·획일적 능력이다.	법률행위 불성립 (또는 무효)
의사능력	① 사물을 판단하고 행위의 의미나 결과를 예측할 수 있는 구체적·개별적 능력으로서 단순한 심리적 능력이 아니라 구체적 법률행위와 관련하여 판단되는 규범적 능력이다. ② 의사무능력자의 법률행위는 절대적 무효로서 선의의 제3자에게도 무효로서 대항할 수 있으며 무효행위의 전환(제138조)도 인정되지 아니한다. ③ 민법에 명문규정이 없다. ④ 의사능력자는 권리능력자이나 권리능력자가 반드시 의사능력자인 것은 아니다.	법률행위 무효 (유아·정신병자·술에 만취된 자 등)
행위능력	① 단독으로 유효한 법률행위를 행할 수 있는 추상적·획일적 능력을 말한다. ② 행위능력에 관한 총칙의 규정은 가족법상의 신분행위에는 원칙적으로 적용되지 않는다.	법률행위 취소사유 (미성년자·피한정후견인·피성년후견인)
불법행위 능력 (책임능력)	① 행위의 책임을 변식할 수 있는 구체적·개별적 능력을 말한다. ② 의사능력을 불법행위의 측면에서 본 것이 책임능력이라 할 수 있다. ③ 책임능력을 의사능력보다 조금 높게 인정하는 견해도 있다.	불법행위책임없음 (감독자의 책임으로 귀속 : 제753조 이하)

2. 제한능력자 제도

(1) 제한능력자 제도의 성격 및 적용범위

1) 성격

- ① 제한능력자가 단독으로 행한 법률행위는 원칙적으로 취소할 수 있다. 따라서 제한

능력자제도는 상대방과 거래의 안전보다는 제한능력자 자신을 보호하는 데 그 일차적인 목적이 있다.

② 제한능력자제도에 관한 규정은 강행규정이며 어떠한 제도보다 우선하여 적용된다.

2) 적용범위

① 신분행위 : 가족법상의 신분행위에는 특별규정이 있는 경우를 제외하고는 원칙적으로 적용되지 아니한다.

② 불법행위 : 제한능력자가 불법행위를 행한 경우에는 책임능력의 유무에 따라 판단하여야 할 것이다.

③ 사실적 계약관계 : 원칙적으로 적용되지 아니한다.

(2) 제한능력자의 법률행위의 효력

① 제한능력자의 법률행위는 제한능력자측에서 취소할 수 있다(제5조 제2항). 그리고 제한능력에 대한 증명책임은 법률행위의 효력을 부인하는 자에게 있다.

② 취소의 효과는 절대적 취소로써 선의의 제3자에게 대항할 수 있다.

③ 취소의 효과로 권리의무에 관하여 아직 이행하지 않은 부분은 이행할 필요가 없게 되지만 이미 이행한 부분은 부당이득으로 서로 반환하여야 한다(제741조). 이 경우에 제한능력자측은 현존이익만을 반환하면 된다(제141조 단서).

3. 제한능력자의 유형

미성년자

(1) 미성년자의 의의

제4조 【성년기】

사람은 19세로 성년에 이르게 된다.

1) 미성년자

① 만 19세 미만자로서 혼인하지 않는 자를 미성년자라고 한다.

② 연령은 출생일을 산입하여 역(曆)에 따라 계산한다(제158조, 초일산입).

2) 혼인에 의한 성년의제(성년간주)

- ① 미성년자가 법정대리인의 동의를 얻어 혼인한 경우 성년자와 같은 능력을 갖는다.
여기서의 혼인은 법률혼을 말하는 것이지, 사실혼을 의미하지 않는다.
- ② 성년의제는 민사상의 법률관계에 한하여 적용되며, 공법상의 법률관계에는 적용되지 않는다. 따라서 「공직선거법」, 「근로기준법」, 「청소년보호법」 등에는 성년의제규정이 적용되지 않는다.
- ③ 혼인의 해소되거나 혼인이 취소된 경우에도 성년의제의 효과는 소멸하지 않는다.

(2) 미성년자의 행위능력

1) 원칙

제5조 【미성년자의 능력】

- ① 미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다.
- ② 전항의 규정에 위반한 행위는 취소할 수 있다.

미성년자가 법률행위를 하려면 원칙으로 법정대리인의 동의를 얻어야 한다(제5조 제1항 본문). 동의를 얻지 않은 법률행위는 미성년자 본인이나 법정대리인이 이를 취소할 수 있다(동조 제2항).

2) 예외

제6조 【처분을 허락한 재산】

법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 임의로 처분할 수 있다.

제7조 【동 의와 허락의 취소】

법정대리인은 미성년자가 아직 법률행위를 하기 전에는 전2조의 동 의와 허락을 취소할 수 있다.

제8조 【영업의 허락】

- ① 미성년자가 법정대리인으로부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관하여는 성년자와 동일한 행위능력이 있다.
- ② 법정대리인은 전항의 허락을 취소 또는 제한할 수 있다. 그러나 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

다음의 경우에는 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 단독으로 법률행위를 할 수 있지만 의사능력은 가지고 있어야 한다.

① 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위(제5조 제1항 단서)

㉠ 부담없는 증여를 받거나 채무면제를 받는 행위, 서면에 의하지 않은 증여계약의 해제(제555조)

㉡ 부담부 증여, 상속의 승인, 경제적으로 유리한 매매계약을 체결하는 행위, 변제를 받는 행위 등은 법정대리인의 동의를 요한다.

② 처분(포괄적인 재산처분의 허락이 아니라 범위를 정하여)이 허락된 재산의 처분 행위(제6조)

■ 부모로부터 받은 등록금을 친구의 병원비로 지급하였다.

처분행위로 취득한 재산이 처분이 허락된 재산보다 상당한 고액인 경우, 이 취득 재산을 다시 처분하기 위해서는 법정대리인의 동의가 필요하다고 해석한다.

중요판례

대법원 2007.11.16. 2005다71659

[1] 만 19세(2013년 민법개정 전, 성년의 연령기준은 만20세)가 넘은 미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 사안에서, 스스로 얻고 있던 소득에 대하여는 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 보아 위 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다.

[2] 미성년자가 법률행위를 함에 있어서 요구되는 법정대리인의 동의는 언제나 명시적이어야 하는 것은 아니고 묵시적으로도 가능한 것이며, 미성년자의 행위가 위와 같이 법정대리인의 묵시적 동의가 인정되거나 처분허락이 있는 재산의 처분 등에 해당하는 경우라면, 미성년자로서는 더 이상 행위무능력(제한능력)을 이유로 그 법률행위를 취소할 수 없다.

대법원 1970.02.24. 69다1568

미성년자가 문제된 토지매매행위를 부인하고 있는 경우에는 미성년자가 그 법정대리인의 동의를 얻었다는 점에 관한 증명책임은 미성년자의 상대방에게 있다.

대법원 1981.08.25. 80다3149

미성년자는 원칙적으로 법정대리인에 의하여서만 소송행위를 할 수 있으나, 미성년자 자신의 노무제공에 따른 임금의 청구는 근로기준법 규정에 의하여 미성년자가 독자적으로 할 수 있다.

③ 허락받은 영업에 관한 행위(제8조 제1항)

- ㉠ 여기서 ‘영업’이란 상업에 한하지 않고 널리 영리를 목적으로 하는 독립적·계속적 사업을 의미하며 법정대리인이营业을 허락함에 있어서는 반드시 영업의 종류를 특정하여야 한다. 따라서 모든 영업을 허락하거나, 영업 중의 일부만을 허락할 수는 없다.
- ㉡ 미성년자의 허락받은 영업에 관한 행위(점포임대차, 점원고용, 자금차입 등)에 관하여는 법정대리인의 대리권은 소멸한다. 허락받은 영업에 관한 일체의 행위는 미성년자가 단독으로 할 수 있기 때문이다.
- ④ 대리행위(제117조) : 대리인은 행위능력자임을 요하지 않으므로 미성년자인 대리인의 대리행위로 인한 모든 법률효과는 직접 본인에게 귀속되고 대리행위로 인한 불이익이 미성년자에게 귀속되지 않으므로 허용된다.
- ⑤ 혼인을 한 미성년자의 행위(제826조의2)
- ⑥ 유언행위(제1061조) : 만 17세에 달한 미성년자는 단독으로 유효하게 유언을 할 수 있다.
- ⑦ 법정대리인의 허락을 얻어 회사의 무한책임사원이 된 미성년자가 그 사원자격에 기하여 하는 행위(상법 제7조)
- ⑧ 근로계약의 체결과 임금의 청구(근로기준법 제67조·제68조), 임금의 청구에 대하여는 법정대리인의 대리권이 제한된다.

3) 동의와 허락의 취소(철회) 또는 제한

- ① 미성년자가 법률행위를 하기 전에는 법정대리인은 동의나 일정범위의 재산처분에 대한 허락을 취소(철회)할 수 있다(제7조). 여기서의 취소는 철회의 의미로 해석한다. 따라서 소급효가 없다. 철회의 상대방은 미성년자나 그 상대방이 된다.
- ② 법정대리인은 미성년자에게 한 영업의 허락을 취소(철회) 또는 제한할 수 있으나 그것을 가지고 선의의 제3자에게는 대항할 수 없다고 해석한다(제8조 제2항). 미성년자와 거래한 상대방을 보호하기 위한 규정이다.
- ③ 동의를 받은 미성년자가 단독으로 법률행위를 행하기 위해서는 적어도 의사능력을 필요로 한다.

4) 미성년자의 법정대리인(法定代理人)

- ① 미성년자의 법정대리인이 되는 자는 제1차로 친권자이고 제2차로 후견인이다.

- ② 친권은 부모가 혼인 중인 경우에는 공동으로 행사한다. 그러나 부모의 의견이 일치하지 아니하는 때에는 당사자의 청구에 의하여 가정법원(법원, 이하 같음)이 이를 정한다(제909조 제2항).
- ③ 친권자가 없거나 대리권을 행사할 수 없을 때에는 후견인이 법정대리인이 된다.

(3) 미성년자의 법정대리인의 권한

1) 동의권

- ① 미성년자는 법정대리인의 동의를 얻어 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있으므로 법정대리인은 ‘동의권’을 갖는다.
- ② 후견인은 법률이 정한 일정한 중요한 행위에 관하여 동의를 하고자 할 때에는 후견감독인의 동의를 얻어야 한다(제950조).

2) 대리권

법정대리인은 미성년자의 재산상의 법률행위를 대리할 수 있다(제920조, 제949조).

3) 취소권

- ① 법정대리인은 미성년자가 동의를 받지 않고서 행한 법률행위를 취소할 수 있다(제5조 제2항, 제140조 이하). 이는 법정대리인 자신이 취소권자가 된다는 의미이다.
- ② 취소에는 소급효가 있으며, 제한능력을 이유로 한 취소의 소급적 효과는 선의의 제3자에 대해서도 주장할 수 있다.

제140조 【법률행위의 취소권자】

취소할 수 있는 법률행위는 제한능력자, 착오로 인하거나 사기·강박에 의하여 의사표시를 한 자, 그의 대리인 또는 승계인만이 취소할 수 있다.

제141조 【취소의 효과】

취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다. 다만, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환(償還)할 책임이 있다.

4) 추인권

법정대리인은 미성년자가 동의를 받지 않고서 행한 법률행위를 추인할 수 있다.

피한정후견인

(1) 피한정후견인의 의의

제12조 【한정후견개시의 심판】

- ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 성년후견인, 성년후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 한정후견개시의 심판을 한다.
- ② 한정후견개시의 경우에 제9조 제2항을 준용한다.

(2) 피한정후견인의 행위와 동의

- ① 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다(제13조 제1항).
- ② 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 한정후견인, 한정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 제1항에 따른 한정후견인의 동의를 받아야만 할 수 있는 행위의 범위를 변경할 수 있다(제13조 제2항).
- ③ 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위에 대하여 한정후견인이 피한정후견인의 이익이 침해될 염려가 있음에도 그 동의를 하지 아니하는 때에는 가정법원은 피한정후견인의 청구에 의하여 한정후견인의 동의를 갈음하는 허가를 할 수 있다(제13조 제3항).
- ④ 한정후견인의 동의가 필요한 법률행위를 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 하였을 때에는 그 법률행위를 취소할 수 있다. 다만, 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위에 대하여는 그러하지 아니하다(제13조 제4항).

(3) 한정후견의 종료

한정후견개시의 원인이 소멸된 경우에는 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 한정후견인, 한정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 한정후견종료의 심판(재판)을 한다(제14조).

피성년후견인

(1) 피성년후견인의 의의

제9조 【성년후견개시의 심판】

- ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견개시의 심판을 한다.
- ② 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.

제14조의 3 【심판사이의 관계】

- ① 가정법원이 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대하여 성년후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 한정후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다.
- ② 가정법원이 피성년후견인 또는 피특정후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다.

(2) 피성년후견인의 행위와 취소

- ① 피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다(제10조 제1항).
- ② 제1항에도 불구하고 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다(제10조 제2항).
- ③ 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 성년후견인, 성년후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 제2항의 범위를 변경할 수 있다(제10조 제3항).
- ④ 제1항에도 불구하고 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위는 성년후견인이 취소할 수 없다(제10조 제4항).

(3) 성년후견의 종료

성년후견개시의 원인이 소멸된 경우에는 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 성년후견인, 성년후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견 종료의 심판을 한다(제11조).

피특정후견인

(1) 피특정후견인의 의의

- ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 일시적 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원이 필요한 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 특정후견의 심판을 한다(제14조의 2 제1항).
- ② 특정후견은 본인의 의사에 반하여 할 수 없다(제14조의 2 제2항).
- ③ 특정후견의 심판을 하는 경우에는 특정후견의 기간 또는 사무의 범위를 정하여야 한다(제14조의 2 제3항).

(2) 피특정후견인의 행위능력

- ① 특정후견의 심판을 하는 경우에 가정법원은 특정후견의 기간 또는 사무의 범위를 정하여야 한다.
- ② 특정후견의 심판이 있다고 하여 피특정후견인의 행위능력이 제한되는 것은 아니다.

4. 제한능력자와 거래한 상대방보호

(1) 상대방보호의 필요성과 보호제도

1) 상대방보호의 필요성

제한능력자가 법정대리인의 동의 없이 한 법률행위는 제한능력자나 그 법정대리인이 취소할 수 있는 것이므로 제한능력자와 법률행위를 한 상대방은 언제 당해 법률행위가 취소될지 모르는 불안한 지위에 놓이게 된다. 그리하여 「민법」은 제한능력자 상대방의 이러한 불확정한 상태를 신속히 확정함으로써 상대방을 보호하기 위해 상대방 보호 제도를 두고 있다.

2) 상대방 보호제도

일반적 보호방법으로서 취소권의 단기소멸제도와 법정추인제도를 두고, 이와 함께 특별한 보호방법으로서 상대방의 최고권·철회권·거절권 및 취소권의 배제를 규정하고 있다. 취소권의 단기소멸제도(제146조)와 법정추인제도(제145조)는 후술하기로 한다.

(2) 확답을 촉구할 권리(최고권)

제15조 【제한능력자의 상대방의 확답을 촉구할 권리】

- ① 제한능력자의 상대방은 제한능력자가 능력자가 된 후에 그에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 확답을 촉구할 수 있다. 능력자로 된 사람이 그 기간 내에 확답을 발송하지 아니하면 그 행위를 추인한 것으로 본다.
- ② 제한능력자가 아직 능력자가 되지 못한 경우에는 그의 법정대리인에게 제1항의 촉구를 할 수 있고, 법정대리인이 그 정하여진 기간 내에 확답을 발송하지 아니한 경우에는 그 행위를 추인한 것으로 본다.
- ③ 특별한 절차가 필요한 행위는 그 정하여진 기간 내에 그 절차를 밟은 확답을 발송하지 아니하면 취소한 것으로 본다.

구분	내용
의의	① 형성권의 일종이다. ② 제한능력자 측에 취소 또는 추인 여부를 촉구하고 기간 내에 확답이 없을 때에는 취소 또는 추인의 효과가 발생한다.
요건	상대방은 제한능력자 측에 대하여 1월 이상의 유예기간을 정하여 추인 여부의 확답을 최고(촉구)할 수 있다.
상대방	법정대리인 또는 제한능력자이었던 본인이 그 상대방이 된다.
효과	기간 내에 확답을 발신하지 않은 때 ① 보통의 경우(법정대리인이 단독으로 추인할 수 있는 경우) : 추인으로 간주한다. ② 특별한 절차를 요하는 경우 : 취소로 간주한다.

- ① 최고(촉구)의 상대방은 법정대리인이며, 제한능력자는 직접 최고의 상대방이 될 수 없다. 그러나 제한능력자가 능력자로 된 후라면 직접 최고의 상대방이 될 수 있다.
- ② 상대방의 최고에 대하여 제한능력자 측에서 추인을 하면 상대방은 철회 또는 거절할 수 없다.

(3) 제한능력자의 상대방의 철회권과 거절권

제16조 【제한능력자의 상대방의 철회권과 거절권】

- ① 제한능력자가 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 상대방이 그 의사표시를 철회할 수 있다.
다만, 상대방이 계약 당시에 제한능력자임을 알았을 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있다.
- ③ 제1항의 철회나 제2항의 거절의 의사표시는 제한능력자에게도 할 수 있다.

- ① 선의의 상대방은 제한능력자와 체결한 계약에 대하여 제한능력자 측의 추인이 있기 전까지는 그 의사표시를 철회할 수 있다(제16조 제1항).
- ② 제한능력자의 단독행위에 대해 제한능력자 측에서 추인하기 전까지는 상대방은 거절할 수 있다(제16조 제2항). 철회권과 달리 거절권은 상대방의 선의·악의를 불문한다.
- ③ 철회나 거절의 의사표시는 법정대리인뿐만 아니라 제한능력자에 대하여도 할 수 있다.

(4) 취소권의 배제

제17조 【제한능력자의 속임수】

- ① 제한능력자가 속임수로써 자기를 능력자로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소할 수 없다.
- ② 미성년자나 피한정후견인이 속임수로써 법정대리인의 동의를 있는 것으로 믿게 한 경우에도 제1항과 같다.

- ① 제한능력자가 능력자인 것처럼 보이기 위하여 상대방을 속인 경우 제한능력자의 취소권을 박탈하여 상대방을 보호하고 거래안전을 도모한다.
- ② 미성년자나 피한정후견인이 속임수로써 법정대리인의 동의를 있는 것으로 믿게 한 경우에도 그 행위를 취소할 수 없다.
- ③ 속임수(사술)의 정도에 대하여 판례는 적극적 속임수(동의서 위조 등)만이 이에 해당한다고 한다.

중요판례

대법원 1971.12.14. 71다2045

미성년자가 단순히 자기가 능력자라 사언(詐言)함은 민법 제17조의 이른바 속임수(사술)을 쓴 것이라고 할 수 없다.

대법원 1971.06.22. 71다940

미성년자가 속임수(사술)로써 상대방으로 하여금 성년자로 믿게 한 의사표시는 이를 취소할 수 없다.

1. 의의

제18조 【주소】

- ① 생활의 근거되는 곳을 주소로 한다.
- ② 주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있다.

사람의 생활관계는 일정한 장소를 중심으로 형성되며 그 장소를 중심으로 일정한 법률 효과가 발생한다. 민법은 주소를 “생활의 근거가 되는 곳”(제18조 제1항)이라고 규정하고 있다.

2. 입법주의

(1) 형식주의와 실질주의

1) 형식주의

형식적인 표준에 따라 획일적으로 주소를 결정한다(등록기준지·주민등록지).

2) 실질주의

생활의 실질관계를 중시하여 구체적으로 결정한다.

(2) 의사주의와 객관주의

1) 의사주의

생활의 근거라는 객관적 사실 외에 정주(定住)의 의사까지 필요하다는 입장이다.

2) 객관주의

정주(定住)의 사실만으로 주소를 결정한다(통설).

(3) 단수주의와 복수주의

1) 단수주의

주소를 한 곳밖에 인정하지 않는 주의이다.

2) 복수주의

주소는 동시에 두 곳 이상 둘 수 있다는 주의를 말한다(제18조 제2항).

(4) 우리 민법의 태도

우리 민법이 인정하는 입법주의는 실질주의(생활의 실질관계를 중시하여 구체적으로 결정)와 복수주의(주소는 동시에 두 곳 이상 둘 수 있음)이며, 민법에 명문규정은 없으나 객관주의(정주(定住)의 사실만으로 주소를 결정)를 취하는 것이 통설이다.

3. 주소의 법률상의 효과

- ① 부재와 실종의 표준(제22조·제27조)
- ② 법인의 주소(제36조)
- ③ 상속의 개시지(제998조)
- ④ 채무의 이행장소(제467조)
- ⑤ 부부동거의 장소(제826조)

4. 주소와 비슷한 개념

제19조 【거소】

주소를 알 수 없으면 거소를 주소로 본다.

제20조 【거소】

국내에 주소 없는 자에 대하여는 국내에 있는 거소를 주소로 본다.

제21조 【가주소】

어느 행위에 있어서 가주소를 정한 때에는 그 행위에 관하여는 이를 주소로 본다.

- ① 거소 : 주소를 알 수 없을 때와 국내에 주소가 없는 자에 대해서는 거소를 주소로 본다(제19조·제20조).
- ② 현재지 : 장소와의 밀접도가 거소보다 못한 곳(▶ 여행자가 일시 체재하는 장소)을 말한다.
- ③ 가주소(임시주소) : 어떤 거래에 관하여 당사자가 일정한 장소를 정하여 주소로 정한 때 그 장소를 말한다(제21조).

제4절 부재와 실종

1. 제도의 취지

부재자란 종래의 주소나 거소를 떠나서 당분간 돌아올 가능성이 없는 자를 말하는 것으로 그의 잔류재산이 관리되지 못하고 방치된 상태에 있게 됨으로써 부재자 자신과 잔존배우자, 상속인 등 이해관계인에게 불이익이 발생할 수 있는 것이다. 따라서 민법은 부재자 본인과 이해관계인의 이익을 보호하고 법률생활의 안정을 도모하기 위하여 2단계의 제도를 두고 있다.

- 제1단계 : 재산관리제도(제22조~제26조)
부재자가 일단은 생존하고 있는 것으로 취급하여 그의 재산을 관리하면서 돌아오기를 기다리는 제도
- 제2단계 : 실종선고제도(제27조~제29조)
생사불명의 상태가 장기간 지속될 경우에 사망한 것으로 간주하여 상속을 개시하는 등, 사망으로서 법률효과를 발생시키는 제도

2. 부재자의 재산관리

(1) 부재자의 의의

- ① 부재자란 종래의 주소나 거소를 떠나서 당분간 돌아올 가능성이 없는 자를 말하는 것으로 반드시 생사불명일 것을 요하지 아니한다. 예컨대, 장기간 계속하여 외국에 가 있어 그의 잔류재산을 관리할 필요가 있는 자는 부재자이다.
- ② 부재자는 성질상 자연인에 한하여 적용되며 법인에게는 적용의 여지가 없다.

(2) 부재자 자신이 재산관리인을 정한 경우

제22조 【부재자의 재산의 관리】

- ① 종래의 주소나 거소를 떠난 자가 재산관리인을 정하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 재산관리에 관하여 필요한 처분을 명하여야 한다. 본인의 부재중 재산관리인의 권한이 소멸한 때에도 같다.

- ② 본인이 그 후에 재산관리인을 정한 때에는 법원은 본인, 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 전항의 명령을 취소하여야 한다.

제23조 【관리인의 개입】

부재자가 재산관리인을 정한 경우에 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 법원은 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리인을 개입할 수 있다.

제24조 【관리인의 직무】

- ① 법원이 선임한 재산관리인은 관리할 재산목록을 작성하여야 한다.
- ② 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산을 보존하기 위하여 필요한 처분을 명할 수 있다.
- ③ 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 이해관계인이나 검사의 청구가 있는 때에는 법원은 부재자가 정한 재산관리인에게 전2항의 처분을 명할 수 있다.
- ④ 전3항의 경우에 그 비용은 부재자의 재산으로써 지급한다.

제25조 【관리인의 권한】

법원이 선임한 재산관리인이 제118조에 규정한 권한을 넘는 행위를 함에는 법원의 허가를 얻어야 한다. 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 부재자가 정한 재산관리인이 권한을 넘는 행위를 할 때에도 같다.

제26조 【관리인의 담보제공, 보수】

- ① 법원은 그 선임한 재산관리인으로 하여금 재산의 관리 및 반환에 관하여 상당한 담보를 제공하게 할 수 있다.
- ② 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다.
- ③ 전2항의 규정은 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 부재자가 정한 재산관리인에 준용한다.

지위	부재자의 수임인이며 임의대리인이다.
권한	① 부재자와 재산관리인의 계약에 의한다. ② 재산관리인의 권한이 분명치 않을 때에는 제118조를 적용한다.
법원의 개입	• 원칙 : 법원은 개입하지 않는다. • 개입 ① 본인의 부재 중에 관리인의 권한이 소멸한 때 ② 부재자의 생사가 불명하게 된 경우 (가정법원은 재산관리인·이해관계인·검사의 청구에 의해 관리인을 개입하거나 감독을 행함)

(3) 부재자 자신이 재산관리인을 정하지 않은 경우

1) 법원의 처분

- ① 법원은 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리에 관하여 필요한 처분을 명한다.
- ② 필요한 처분이란 재산관리인의 선임 등이다.
- ③ 이해관계인이란 법률상의 이해관계인을 말하는 것으로 상속인, 배우자, 채권자, 보증인 등을 말하며 사실상의 이해관계를 가진 자, 즉 사실혼의 배우자나 친구 등은 이에 해당하지 아니한다.
- ④ 선임된 재산관리인은 언제든지 사임할 수 있고, 법원도 언제든지 개임할 수 있다.

2) 재산관리인의 권리와 의무

지위	일종의 법정대리인이다.
권리	보수청구권을 가진다(제26조 제2항).
권한	① 관리행위(보존·이용·개량행위)는 가능하다(제118조). ② 처분행위(매각·담보설정행위)는 법원의 허가를 요하며 또한 부재자를 위한 경우에 가능하다(판례).
의무	선량한 관리자의 주의의무로 재산을 관리하여야 한다(제681조).

중요판례

대법원 1997.03.22. 76다1437

부재자재산처분에 있어서는 민법 제25조에 따른 권한초과행위에 대한 허가를 받아야 하며 그 허가를 받지 아니하고 한 부재자의 재산매각은 무효이다.

대법원 2000.12.26. 99다19278

부재자 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위(기왕의 매매)에 대한 추인으로도 할 수 있다.

대법원 1981.07.28. 80다2668

부재자 재산관리인으로서 권한초과행위의 허가를 받고 그 선임결정이 취소되기 전에 위 권한에 의하여 이루어진 행위는 부재자에 대한 실종선고기간이 만료된 뒤에 이루어졌다고 하더라도 유효하다.

☞ 부재자 재산관리인의 선임결정이 취소되었다 하더라도 그 취소는 소급효가 없으며, 따라서 이미 한 처분행위는 그대로 유효하다.

대법원 1971.03.23. 71다189

법원이 선임한 부재자의 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인된 후라 하더라도 그 선임 결정이 취소되지 않는 한 그 관리인으로서의 권한이 소멸되는 것은 아니다.

대법원 1976.12.21. 75마551

부재자 재산관리인이 법원의 매각처분허가를 얻었다 하더라도 부재자와 아무런 관계가 없는 타인의 채무 담보를 위하여 근저당권을 설정하는 행위는 부재자를 위한 처분행위라고 볼 수 없다.

☞ 법원의 매각처분허가를 얻었다 하더라도, 그것은 부재자의 이익을 위하여 처분되어야 하는 것을 전제로 한다.

대법원 1973.07.24. 72다2136

부재자로부터 재산처분권까지 위임받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 받아야 하는 것은 아니다.

☞ 부재자 자신이 재산관리인을 둔 경우, 이는 부재자의 수임인이며 임의대리인이므로 부재자와 재산관리인 사이의 계약에 의하여 정하여진다.

3. 실종선고

(1) 의의

부재자의 생사불명의 상태가 장기간 계속된 경우에 일정한 조건하에 법원이 실종 선고를 하고 일정한 기간(실종기간)의 경과에 의해서 사망으로 간주하는 제도이다.

(2) 요건

제27조 【실종의 선고】

- ① 부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 실종선고를 하여야 한다.
- ② 전지에 임한 자, 침몰한 선박 중에 있던 자, 추락한 항공기 중에 있던 자 기타 사망의 원인이 될 위난을 당한 자의 생사가 전쟁종지 후 또는 선박의 침몰, 항공기의 추락 기타 위난이 종료한 후 1년간 분명하지 아니한 때에도 제1항과 같다.

- 1) 부재자의 생사가 불명할 것
- 2) 일정한 실종기간이 경과할 것

보통실종 (제27조 제1항)	최후의 소식이 있는 때로부터 기산한다(통설).		5년
특별실종 (제27조 제2항)	전쟁실종	전쟁이 종지한 때(항복·휴전선언)	1년
	선박실종	선박이 침몰한 때	1년
	항공기실종	항공기가 추락한 때	1년
	위난실종	위난이 종료한 때(지진·화재·홍수 등)	1년

- 3) 이해관계인(배우자, 상속인, 채권자, 법정대리인, 재산관리인 등) 또는 검사의 청구가 있을 것(제27조 제1항·제2항)
사실상의 이해관계인(사실혼 배우자, 친구 등)은 해당되지 않는다.

4) 공시최고를 행할 것

- ① 6월 이상의 기간을 정하여 공시최고를 행한다.
- ② 공시최고기간의 경과 후 실종선고를 한다.

* 이상의 요건이 갖추어진 경우에는 법원은 반드시 실종선고를 하여야 한다. 즉, 선고는 필연적이다.

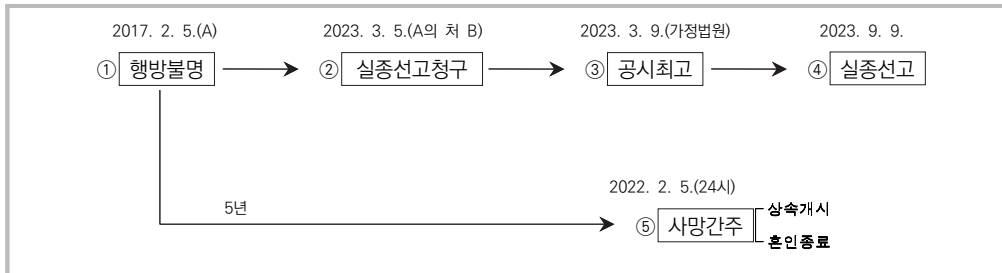
(3) 효과

제28조 【실종선고의 효과】

실종선고를 받은 자는 전조의 기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다.

- ① 실종기간 만료시에 사망한 것으로 간주한다(제28조). 따라서 상속이 개시되고 잔존 배우자와의 사이에 혼인관계가 종료한다. 우리 민법은 간주주의(의제주의)를 취하므로 실종선고가 취소되지 않는 한 생존 등의 반증이 제기되더라도 선고의 효력을 부정할 수 없다.
- ② 실종자의 종래의 주소를 중심으로 하는 사법적 법률관계(상속·혼인의 종료 등)만을 종료하게 한다. 따라서 공법관계(선거권·피선거권·납세의무·범죄능력 등)에는 선고의 효과가 미치지 아니한다.

- ③ 생환 후의 법률관계나 신주소지에서의 법률관계에는 선고의 효과가 미치지 아니한다. 실종선고제도는 실종자의 권리능력 자체를 박탈하는 제도가 아님을 주의하여야 한다.



(4) 실종선고의 취소

1) 의의

제29조 【실종선고의 취소】

- ① 실종자의 생존한 사실 또는 전조의 규정과 상이한 때에 사망한 사실의 증거가 있으면 법원은 본인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 실종선고를 취소하여야 한다. 그러나 실종선고후 그 취소전에 선의로 한 행위의 효력에 영향을 미치지 아니한다.
- ② 실종선고의 취소가 있을 때에 실종의 선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다.

실종선고를 한 후 그 요건이 충족되지 않거나 잘못된 경우에는 일정한 요건 및 절차에 따라 선고를 취소할 수 있는 제도를 말한다. 즉, 실종선고에 의하여 사망으로 의제되는 효과를 반복하기 위한 가정법원의 심판절차를 말한다.

2) 취소의 요건(실질적 요건)

- ① 실종자가 생존하고 있는 것으로 판명된 경우(제29조 제1항)
- ② 선고에 의한 사망시기와 다른 시기에 사망한 확증이 있는 경우(제29조 제1항)
- ③ 실종기간 기산점 후 어느 시기에 생존한 사실이 있는 경우

3) 절차(형식적 요건)

- ① 본인·이해관계인·검사의 실종선고취소청구가 있어야 한다(제29조 제1항).

- ② 실종선고절차와 달리 공시최고는 요하지 아니한다.
- ③ 법원의 선고는 필연적이다.

4) 효과

① 원칙

- ㉠ 실종선고로 인하여 생긴 법률관계는 소급적으로 무효가 된다.
- ㉡ 실종자의 생존을 이유로 취소된 경우에는 종전의 재산관계 및 신분관계는 복귀한다.

② 예외

- ㉠ 소급효의 제한 : 민법은 실종선고를 신뢰하여 이해관계를 가지게 된 자를 보호하기 위하여 다음과 같은 예외를 인정하고 있다.
- ㉡ 실종선고로 직접 재산을 취득한 자의 반환의무
 - ㉠ 선의자는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환의무가 있다.
 - ㉡ 악의자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하여야 하고, 손해가 있으면 그 것을 배상하여야 한다.
 - ㉢ ‘직접 재산을 취득한 자’란 실종선고를 직접의 원인으로 재산을 취득한 자로서 상속인·수유자·생명보험금 수익자 등을 의미하며 이들로부터 다시 재산을 취득한 전득자는 해당되지 않는다.
 - ㉣ 반환의무는 성질상 부당이득의 반환이며, 반환범위는 부당이득에 있어서의 수익자의 반환범위와 동일하다(제748조).
 - ㉤ 반환청구권은 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ㉢ 효과 : 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. 여기서 선의란 실종선고가 사실과 다르다는 사실을 알지 못함을 의미한다.
 - ㉠ 재산관계(계약의 경우)
 - 당사자의 일방 또는 쌍방이 악의인 경우에는 본인에게 반환하여야 한다는 것이 다수설이다(쌍방선의설).
 - 실종선고를 원인으로 하여 직접 재산을 취득한 자는 별개로 하고 이후의 취득자가 선의이면 유효, 악의이면 무효로 한다는 견해, 즉 개별적으로 결정하자는 학설이 있다(소수설).

- 취득자가 선의취득이나 취득시효의 요건을 갖춘 경우에는 어느 견해에 의하든 그 권리를 인정한다.
- 단독행위의 경우에는 행위자의 선의로써 족하다는 것이 통설이다. 예컨대 상속인이 상속한 채권에 대해 면제의 의사표시를 한 경우에는, 상속인이 선의인 한 채무자가 악의이더라도 유효한 채무면제가 된다.

㉞ 신분관계

- 양 당사자가 모두 선의인 경우에는 후혼(後婚)은 전혼(前婚)에 의하여 깨어지지 아니한다(통설·판례).
- 당사자 일방이 악의인 경우에는 견해의 대립이 있다.
 - 제1설 : 후혼은 유효이나 취소혼이 되고 전혼은 부활한다.
 - 제2설 : 후혼은 무효이며 전혼은 부활한다.

중요판례

대법원 1980.09.08. 80스27

민법 제27조 소정의 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 법률상뿐만 아니라 경제적 또는 신분적 이해관계인이어야 하므로 부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다.

대법원 1970.03.10. 69다2103

실종선고에 의한 사망의 효과를 번복하려면 반증으로서는 안 되고, 그 선고의 취소가 있어야 한다.

대법원 1986.10.10. 86스20

- [1] 민법 제27조의 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 부재자의 법률상 사망으로 인하여 직접적으로 신분상 또는 경제상의 권리를 취득하거나 의무를 면하게 되는 사람만을 뜻한다.
- [2] 부재자의 자매로서 제2순위 상속인에 불과한 자는 부재자에 대한 실종선고의 여부에 따라 상속지분에 차이가 생긴다고 하더라도 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다.

대법원 1994.09.27. 94다21542

실종선고를 받은 자는 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 간주되는 것이므로, 실종선고로 인하여 실종기간 만료시를 기준으로 하여 상속이 개시된 이상, 이후 실종선고가 취소되어야

할 사유가 생겼다고 하더라도 실제로 실종선고가 취소되지 않는 한, 임의로 실종기간이 만료하여 사망한 때로 간주되는 시점과 달리 사망시점을 정하여 이미 개시된 상속을 부정하고 이와 다른 상속관계를 인정할 수는 없다.

☞ 우리민법은 실종선고에 관하여 간주주의를 취하는 결과, 실종선고가 사실과 다르다는 것 만으로는 선고의 효과가 반복되지 아니한다. 따라서 별도의 법원의 취소절차가 있어야 선고의 결과를 부정할 수 있다.

대법원 1992.7.14. 92다2455

실종선고의 효력이 발생하기 전에는 실종기간이 만료된 실종자라 하여도 소송상 당사자 능력을 상실하는 것은 아니므로 실종선고 확정 전에는 실종기간이 만료된 실종자를 상대로 하여 제기된 소(訴)도 적법하고, 실종자를 당사자로 하여 선고된 판결도 유효하다. 따라서 실종자를 당사자로 한 판결이 확정된 후에 실종선고가 확정되어 그 사망간주의 시점이 소 제기 전으로 소급하는 경우에도 위 판결 자체가 소급하여 당사자능력이 없는 사망한 사람을 상대로 한 판결로서 무효가 된다고는 볼 수 없다.

대법원 1995.12.22. 95다12736

동일인에 대하여 2차례의 실종선고가 있는 경우, 상속관계의 판단 기준시점은 제1의 선고에 의하여 판단하여야 한다.



3장 권리의 주체(法人)

제1절 법인의 의의와 종류 등

1. 법인의 의의

법인이란 자연인이 아니면서 법률에 의하여 권리능력이 부여된 사단 또는 재단을 말한다. 사단이란 일정한 목적하에 결합된 사람의 단체를 말하며, 재단이란 일정한 목적 하에 각출된 재산의 집합체를 말한다.

2. 법인의 종류

제31조 【법인성립의 준칙】

법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다.

제32조 【비영리법인의 설립과 허가】

학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관 청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.

〈넓은 의미의 법인의 분류〉

공법인	① 법인의 설립이나 관리에 국가의 공권력이 관여하는 법인(국가, 지방자치단체, 공공조합 등)을 말한다. ② 공공사무를 집행하는 것을 존재목적으로 하는 법인이다.
사법인	공법인 이외의 법인(사단법인, 재단법인, 각종의 회사 등)이다.
영리법인	① 영리를 목적으로 하는 법인을 말한다. ② 영리법인은 언제나 사단법인(상사회사, 민사회사)이다. ③ 영리사단법인은 상법상의 회사설립에 관한 규정에 따라 법인격을 취득한다. ④ 영리법인의 설립은 준칙주의에 따른다.

비영리법인	① 학술·종교·자선·기예·사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 법인을 말한다(제32조). ② 민법상 법인은 모두 비영리법인이다. 단, 목적 달성을 위한 한도 내에서는 영리행위가 가능하다. ③ 비영리법인의 설립은 허가주의에 따른다.
-------	---

(1) 사단법인과 재단법인의 비교

구분		사단법인	재단법인
설 립 행 위	의의	2인 이상의 설립자의 정관작성 (제40조)	설립자의 재산출연과 정관작성(제43조)
	구성원	2인 이상의 사원	일정한 목적에 바쳐진 재산
	법적 성질	합동행위	① 설립자가 1인인 경우 : 상대방 없는 단독행위 ② 설립자가 2인 이상의 경우 : 단독행위 경합설(다수설)
	의사 결정	① 사원총회에 의해 결정 ② 자율적 법인	① 설립자의 의도가 반영된 정관에서 정한 목적에 따라 결정 ② 타율적 법인
	기관	이사·감사·사원총회	이사·감사
	설립 모습	생전행위	생전행위 또는 사후행위
	정관의 필요적 기재 사항	① 목 적 ② 명 칭 ③ 사무소의 소재지 ④ 자산에 관한 규정 ⑤ 이사의 임면에 관한 규정 ⑥ 사원자격의 득실에 관한 규정 ⑦ 존립시기나 해산사유를 정하는 경우 그 시기 또는 사유	① 목 적 ② 명 칭 ③ 사무소의 소재지 ④ 자산에 관한 규정 ⑤ 이사의 임면에 관한 규정

구분		사단법인	재단법인
정관 변경	요건	① 사원총회의 결의 : 원칙적으로 총사원의 3분의 2 이상의 동의(제42조 제1항) ② 정관의 모든 사항에 관하여 변경 가능(다수설) ③ 정관변경을 금지한 규정의 변경도 가능하나 이 경우에는 전사원의 동의가 필요(다수설) ④ 주무관청의 허가(제42조 제2항)를 받아야 효력발생	원칙적으로 변경이 불가하나 다음의 경우에 가능하다. ① 설립자가 정관에서 그 변경방법을 정하고 있는 경우에는 그 방법에 따른 변경 가능(제45조 제1항) ② 목적달성·재산의 보전을 위하여 명칭·사무소의 소재지 변경 가능(제45조 제2항) ③ 목적달성이 불가능한 경우 설립의 취지를 참작하여 주무관청의 허가를 얻어 설립자나 이사가 정관을 변경할 수 있다(제46조). ④ 주무관청의 허가를 받아야 효력발생(제45조 제3항·제46조)
해산 사유	공통	① 존립시기의 만료 기타 정관에서 정한 해산사유의 발생(제40조 제7호) ② 법인의 목적달성 또는 달성불능 ③ 파산 ④ 설립허가의 취소	
	사단법인 특유	① 사원이 없게 된 때 ② 총회의 해산결의(임의해산 : 총사원의 4분의 3 이상의 동의)	

중요판례

대법원 1982.10.26. 81누363

법인에 대한 설립허가의 취소는 민법 제38조에 해당하는 경우에 한하여 가능하다. 또한 제38조에서 말하는 비영리법인이 공익을 해치는 행위를 한 때라 함은 법인의 기관이 공익을 침해하는 행위를 하거나 사원총회가 그러한 결의를 한 경우를 의미한다.

대법원 1968.05.28. 67누55

비영리법인 설립 후에 그 목적달성이 불능하게 되었다는 것으로는 민법 제77조의 해산사유에 해당되지만, 그 사유만으로 설립허가를 취소할 사유에 해당되지는 않는다.

☞ 법인의 설립허가의 취소사유는 다음과 같다. ① 허가조건의 위배, ② 목적이외의 사업(영리추구), ③ 공익저해행위 등이다. 따라서 목적달성의 불능은 법인의 해산사유가 되고 설립허가의 취소사유에는 해당하지 않는다.

(2) 사단과 조합의 비교

1) 의의

사람의 단체는 단체성의 강약에 따라 여러 형태로 나누어지나 민법은 사단과 조합을 구별하고 있다.

2) 사단

사단은 단체성이 강하여 그 구성원은 개성을 상실하고 단체가 표면에 나타난다. 즉, 단체는 기관에 의하여 행동하고 그 법률효과도 직접 단체에게 발생하며, 구성원은 총회를 통하여 단체의 운영에 참여한다. 단체의 자산이나 부채도 모두 단체 자체에 속한다. 구성원은 단체의 자산으로부터 배당을 받을 뿐이고 단체의 채무에 대하여는 이를 이행할 책임을 지지 않는다(유한책임). 따라서 사단은 소송당사자능력이 인정된다(민사소송법 제48조).

3) 조합

조합은 단체이지만 그 단체로서의 일체성은 희박하며 구성원인 조합원의 개성이 강하게 나타난다. 조합의 활동은 단체의 조합구성원 전원으로부터 대리권을 수여받은 자에 의하여 이루어지고 그 법률효과도 조합원 전원에게 귀속된다. 조합의 재산은 전원의 합유이며 채무는 조합원 전원이 공동으로 부담한다(무한책임). 민법은 조합을 계약관계로 보아 채권법에 규정(제703조 이하)하고 있다. 아울러 노동조합, 각종의 협동조합 등은 조합이라는 명칭으로 불리우나 그 실체는 사단에 해당하므로 사단과 조합의 구별은 명칭만으로 정하여지는 것은 아니다.

4) 사단과 조합의 차이점

사항	사단	조합
설립	주무관청의 허가과 설립등기 (법인격 있음)	구성원의 계약(법인격 없음)
내부규제	정관	규약(계약관계)
구성원의 수	다수(2인 이상)	소수
조직	계속적 조직체	독립된 조직체가 아님
가입·탈퇴	비교적 자유로움	자유롭지 못함
단체성	단체성이 강함	구성원의 개성이 강함

사항	사단	조합
존속기간	장기간	단기간
대외적 거래주체	단체 자체	단체 구성원
업무집행	대표(이사)	업무집행사원 (구성원 전원으로부터 위임받은 자)
재산소유 형태	단독소유	합 유
책임	유한책임(사단 자체가 부담)	무한책임(조합원 전원의 공동부담)
소송당사자능력	있음	없음

(3) 권리능력 없는 사단과 재단

구분	권리능력 없는 사단	권리능력 없는 재단
의의	사단으로서의 실체를 가지나 주무관청의 허가나 설립등기를 하지 않아 법인격이 없는 단체를 말한다. ■ 종중, 문중, 교회, 동·리, 부락 등	재단으로서의 실체를 가지나 주무관청의 허가나 설립등기를 하지 않아 법인격이 없는 단체를 말한다. ■ 재단지당의 목적재산, 상속인 없는 상속재산, 유치원 등
성립 요건	① 단체로서의 조직을 가지고 있어야 한다. ② 규칙이나 정관이 확정되어 있어야 한다 (대표의 방법, 사단의 명칭 등).	권리능력 없는 재단은 설립자의 단독행위에 의하여 이루어진다.
내부 관계	① 민법의 비영리사단법인의 규정을 유추 적용한다(다수설, 판례). ② 재산소유형태는 총유이며 부채도 총유적으로 귀속한다(유한책임 : 다수설).	① 재단법인에 관한 규정을 유추적용한다 (다수설). ② 재산소유형태는 재단의 단독소유로 본다.
외부 관계	① 대표자가 있을 때 당사자능력을 인정한다 (민사소송법 제52조). 따라서 제3자는 단체재산에 강제집행을 행할 수 있다. ② 부동산등기능력을 인정한다(부동산등기법 제26조). ③ 단체에 불법행위능력을 인정하므로 기관 개인과 사단 자체가 손해배상책임을 진다.	당사자능력(민사소송법 제52조)과 부동산 등기능력(부동산등기법 제26조)을 인정하며 명예권·명칭권 등의 인격권도 향유한다.

대법원 2014.02.13. 2012다112299

총유물의 보존에 있어서는 공유물의 보존에 관한 민법 제265조의 규정이 적용될 수 없고, 민법 제276조 제1항의 규정에 따른 사원총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야 하므로, 법인 아닌 사단인 교회가 총유재산에 대한 보존행위로서 소송을 하는 경우에도 교인 총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야 한다.

대법원 2003.07.22. 2002다64780

비법인사단의 경우에는 대표자의 대표권 제한에 관하여 등기할 방법이 없어 민법 제60조의 규정을 준용할 수 없고, 비법인사단의 대표자가 정관에서 사원총회의 결의를 거쳐야 하도록 규정한 대외적 거래행위에 관하여 이를 거치지 아니한 경우라도, 이와 같은 사원총회 결의 사항은 비법인사단의 내부적 의사결정에 불과하다 할 것이므로, 그 거래 상대방이 그와 같은 대표권 제한 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아니라면 그 거래행위는 유효하고, 거래의 상대방이 대표권 제한 사실을 알았거나 알 수 있었음은 이를 주장하는 비법인사단 측이 주장·증명하여야 한다.

대법원 2011.04.28. 2008다15438

비법인사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법 규정 가운데 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 하는데, 민법 제62조에 비추어 보면 비법인사단의 대표자는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있을 뿐 비법인사단의 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없으므로 비법인사단 대표자가 행한 타인에 대한 업무의 포괄적 위임과 그에 따른 포괄적 수임인의 대행행위는 민법 제62조를 위반한 것이어서 비법인사단에 대하여 그 효력이 미치지 않는다.

대법원 1992.10.09. 92다23087

법인 아닌 사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법규정 가운데서 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하므로, 사단법인에 있어서는 사원이 없게 된다고 하더라도 이는 해산사유가 될 뿐 막바로 권리능력이 소멸하는 것이 아니므로, 법인 아닌 사단에 있어서는도 구성원이 없게 되었다 하여 막바로 그 사단이 소멸하여 소송상의 당사자능력을 상실하였다고 할 수는 없고, 청산사무가 완료되어야 비로소 그 당사자능력이 소멸한다.

대법원 2006.04.20. 2004다37775 전원합의체

[1] 우리 민법이 사단법인에 있어서 구성원의 탈퇴나 해산은 인정하지만 사단법인의 구성원들이 2개의 법인으로 나뉘어 각각 독립한 법인으로 존속하면서 종전 사단법인에게 귀속

되었던 재산을 소유하는 방식의 사단법인의 분열은 인정하지 아니한다. 그 법리는 법인 아닌 사단에 대하여도 동일하게 적용되며, 법인 아닌 사단의 구성원들의 집단적 탈퇴로써 사단이 2개로 분열되고 분열되기 전 사단의 재산이 분열된 각 사단들의 구성원들에게 각각 총유적으로 귀속되는 형태의 법인 아닌 사단의 분열은 허용되지 않는다.

- [2] 일부 교인들이 교회를 탈퇴하여 그 교회 교인으로서의 지위를 상실하게 되면 탈퇴가 개별적인 것이든 집단적인 것이든, 종전 교회의 총유 재산의 관리처분에 관한 의결에 참가할 수 있는 지위나 그 재산에 대한 사용·수익권을 상실하고, 종전 교회의 재산은 그 교회에 소속된 잔존 교인들의 총유로 귀속됨이 원칙이다.
- [3] 소속 교단에서의 탈퇴 내지 소속 교단의 변경은 사단법인 정관변경에 준하여 의결권을 가진 교인 2/3 이상의 찬성에 의한 결의를 필요로 하고, 그 결의요건을 갖추어 소속 교단을 탈퇴하거나 다른 교단으로 변경한 경우에 종전 교회의 실체는 이와 같이 교단을 탈퇴한 교회로서 존속하고 종전 교회 재산은 위 탈퇴한 교회 소속 교인들의 총유로 귀속된다.

대법원 2009.02.12. 2006다23312

비법인사단인 교회의 대표자는 총유물인 교회 재산의 처분에 관하여 교인총회의 결의를 거치지 아니하고는 이를 대표하여 행할 권한이 없다. 그리고 교회의 대표자가 권한 없이 행한 교회 재산의 처분행위에 대하여는 민법 제126조의 표현대리에 관한 규정이 준용되지 아니한다.

대법원 1995.11.14. 95다16103

종중은 그 성립을 위하여 특별한 조직행위를 필요로 하는 것이 아니다. 다만, 그 목적인 공동 선조의 분묘수호, 제사봉행, 종원 상호간의 친목을 규율하기 위하여 규약을 정하는 경우가 있고 또 대외적인 행위를 할 때에는 대표자를 정할 필요가 있기는 하나, 반드시 특정한 명칭의 사용 및 서면화된 종중규약이 있어야 하거나 종중의 대표자가 계속하여 선임되어 있는 등의 조직을 갖추어야 하는 것은 아니다.

대법원 1991.04.23. 91다4478

공동주택의 입주자대표회의는 단체로서의 조직을 갖추고 의사결정기관과 대표자가 있을 뿐만 아니라, 또 현실적으로는 자치관리기구를 지휘, 감독하는 등 공동주택의 관리업무를 수행하고 있으므로 특별한 다른 사정이 없는 한 법인 아닌 사단으로서 당사자능력이 있다.

대법원 2007.04.19. 2004다60072 전원합의체

비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르지 아니하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물의 관리·처분행위라고 볼 수는 없다. 따라서 비법인사단인 재건축조합의 조합장이 채무보증계약을 체결하면서 조합규약에서 정한 조합 임원회의 결의를 거치지 않았거나 조합원총회 결의를 거치지 않았다 하더라도 그것만으로 바로 그 보증계약이 무효라고 할 수는 없다.

대법원 1996.8.20. 96다18656

종중 소유의 재산은 종중원의 총유에 속하는 것이므로 그 관리 및 처분에 관하여 먼저 종중 규약에 정하는 바가 있으면 이에 따라야 하고, 그 점에 관한 종중규약이 없으면 종중총회의 결의에 의하여야 하므로, 비록 종중 대표자에 의한 종중 재산의 처분이라고 하더라도 그러한 절차를 거치지 아니한 채 한 행위는 무효이다.

대법원 2009.01.30. 2006다60908

사단법인의 하부조직의 하나라 하더라도 스스로 단체로서의 실체를 갖추고 독자적인 활동을 하고 있다면 사단법인과는 별개의 독립된 비법인사단으로 볼 수 있다.

대법원 1996.05.16. 95누4810 전원합의체

민법 제45조와 제46조에서 말하는 재단법인의 정관변경 “허가”는 법률상의 표현이 허가로 되어 있기는 하나, 그 성질에 있어 법률행위의 효력을 보충해 주는 것이지 일반적 금지를 해제하는 것이 아니므로, 그 법적 성격은 인가이다.

대법원 1996.09.10. 95누18437

비영리 재단법인의 설립에 관하여 허가주의를 채용하고 있는 제도 아래서 그에 관한 주무관청의 허가는 그 본질상 주무관청의 자유재량에 속하는 행위로서 그 허가여부는 다룰 수 없으므로 그에 대한 불허가처분은 행정소송의 대상이 되지 않는다.

만약, 법인설립에 관하여 인가주의를 채택한다면, 법률이 정한 요건을 갖추어 인가를 신청하면 주무관청은 반드시 법인설립을 인정하여야 한다. 즉, 허가주의와 달리 주무관청의 자유재량의 여지가 없다.

대법원 2007.6.18. 2005마1193

사회복지법인이 기본재산을 매도하기 위하여는 보건복지부장관의 허가를 받아야 하고, 이는 경매절차에 의한 매각의 경우에도 마찬가지인 바, 사회복지법인의 기본재산에 대하여 실시된 부동산경매절차에서 최고가매수신고인이 그 부동산 취득에 관하여 보건복지부장관의 허가를 얻지 못하였다면 경매법원은 그에 대한 매각을 불허하여야 한다.

대법원 2000.11.24. 99다12437

사단법인의 정관은 이를 작성한 사람뿐만 아니라 그 후에 가입한 사람이나 사단법인의 기관 등도 구속하는 점에 비추어보면 그 법적 성질은 계약이 아니라 자치법규로 보는 것이 타당하므로, 이는 어디까지나 객관적인 기준에 따라 그 규범적인 의미 내용을 확정하는 법규해석의 방법으로 해석되어야 하는 것이지, 작성자의 주관이나 해석 당시의 사원의 다수결에 의한 방법으로 자의적으로 해석될 수는 없다. 따라서 어느 시점의 사단법인의 사람들이 정관의 규범적인 의미 내용과 다른 해석을 사원총회의 결의라는 방법으로 표명하였다 하더라도 그 결의에 의한 해석은 그 사단법인의 구성원인 사람들이나 법원을 구속하는 효력이 없다.

대법원 2018.7.20. 자2017마1565

민법상 재단법인의 기본재산에 관한 저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 정관의 기재 사항을 변경하여야 하는 경우에 해당하지 않으므로, 그에 관하여는 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.

3. 재단법인의 출연재산의 귀속시기

(1) 민법의 규정

제47조 【증여, 유증에 관한 규정의 준용】

- ① 생전처분으로 재단법인을 설립하는 때에는 증여에 관한 규정을 준용한다.
- ② 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 유증에 관한 규정을 준용한다.

- ① 출연재산의 종류는 불문하며 출연재산의 귀속시기에 대한 민법의 규정은 생전행위(증여의 규정을 준용)인 경우에는 법인의 설립등기시에 귀속(제48조 제1항)하며,
- ② 유언(유증의 규정을 준용)인 경우에는 유언자의 사망시에 귀속(제48조 제2항)한다고 규정하고 있다.

(2) 출연재산(소유권) 귀속시기에 대한 학설의 대립과 판례

제48조 【출연재산의 귀속시기】

- ① 생전처분으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 법인이 성립된 때로부터 법인의 재산이 된다.
- ② 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 유언의 효력이 발생한 때로부터 법인에 귀속한 것으로 본다.

제186조 【부동산물권변동의 효력】

부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.

제187조 【등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득】

상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.

- ① 다수설 : 제187조의 법률의 규정에 의한 물권변동으로 보아 등기나 인도를 요하지 않고 당연히 설립등기시 또는 유언의 효력발생시에 법인에 귀속한다.
- ② 소수설 : 재산권의 인도청구권만이 법인설립시 또는 유언효력발생시에 법인에 귀속하고 현실적으로 재산권이 법인에 귀속되는 것은 일정한 형식(등기 또는 인도)을 갖춘 때이다.
- ③ 판례

판례의 태도 : 출연자와 법인 사이에서는 다수설의 입장을 따르나 법인이 제3자에게 대항하기 위해서는 일정한 형식(등기 또는 인도)을 갖추어야 한다는 입장(절충설)을 취한다(대법원 1993. 9.14. 93다8054).

중요판례

대법원 1993.09.14. 93다8054

- [1] 민법 제48조는 재단법인 성립에 있어서 재산출연자와 법인과의 관계에 있어서의 출연 재산의 귀속에 관한 규정이고, 이 규정은 그 기능에 있어서 출연재산의 귀속에 관하여 출연자와 법인과의 관계를 상대적으로 결정함에 있어서의 기준이 되는 것에 불과하여, 출연재산은 출연자와 법인과의 관계에 있어서 그 출연행위에 터잡아 법인이 성립되면 그로써 출연재산은 민법의 위 조항에 의하여 법인설립시에 법인에게 귀속되어 법인의 재산이 되는 것이고, 출연재산이 부동산인 경우에 있어서도 위 양 당사자 간의 관계에

있어서는 위 요건(법인의 성립) 외에 등기를 필요로 하는 것이 아니나, 제3자에 대한 관계에 있어서는 출연행위가 법률행위이므로 출연재산의 법인에의 귀속에는 부동산의 권리에 관해서는 법인성립외에 등기를 필요로 한다.

- [2] 유언으로 재단법인을 설립하는 경우에는 제3자에 대한 관계에서는 출연재산이 부동산인 경우는 그 법인에의 귀속에는 법인의 설립 외에 등기를 필요로 하는 것이므로, 재단법인이 그와 같은 등기를 마치지 아니하였다면 유언자의 상속인의 한 사람으로부터 부동산의 지분을 취득하여 이전등기를 마친 선의의 제3자에 대하여 대항할 수 없다.

대법원 1999.07.09. 98다9045

재단법인의 출연자가 착오를 원인으로 출연을 한 경우에는 출연자는 재단법인의 성립 여부나 출연된 재산의 기본재산인 여부와 관계없이 그 의사표시를 취소할 수 있다.

대법원 2011.2.10. 2006다65774

재단법인의 기본재산은 재단법인의 실체를 이루는 것이므로, 재단법인 설립을 위한 기본 재산의 출연행위에 관하여 그 재산출연자가 소유명의만을 재단법인에 귀속시키고 실질적 소유권은 출연자에게 유보하는 등의 부관을 붙여서 출연하는 것은 재단법인 설립의 취지에 어긋나는 것이어서 관할 관청은 이러한 부관이 붙은 출연재산을 기본재산으로 하는 재단 법인의 설립을 허가할 수 없다.

4. 법인의 능력

법인도 자연인과 마찬가지로 권리의 주체로서 권리능력·행위능력 및 불법행위능력을 가지고 있다. 다만, 민법은 권리능력(제34조)과 불법행위능력(제35조)에 관한 규정만을 두고 있으며, 이 규정은 강행규정으로서 모든 법인에 관하여 원칙적으로 적용한다.

(1) 법인의 권리능력

제34조 【법인의 권리능력】

법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다.

법인의 권리능력은 법률의 규정과 정관으로 정한 목적에 의하여 제한된다(제34조). 그 외에도 자연인과 다른 성질상의 제한이 있다.

(2) 법인의 행위능력

목적범위 내에서 활동하며 법인의 행위능력의 범위는 권리능력의 범위와 같다. 따라서 그 권리능력의 범위 내에서 모든 행위를 할 수 있으며 민법은 법인의 행위능력에 대해서는 명문규정을 두고 있지 않다.

- ① 이사, 임시이사, 특별대리인, 청산인, 직무대행자 등의 행위는 곧 법인의 행위로 본다.
- ② 대표행위의 방식에 관해서는 대리의 규정을 준용한다(제59조 제2항). 따라서 현명주의(顯名主義), 무권대리, 표현대리에 관한 규정을 준용한다.
- ③ 법인의 대표기관의 대표권을 제한하는 경우에는 이를 등기하여야 하고 대표권 제한을 등기하지 않은 경우에는 선의·악의를 불문하고 제3자에게 대항할 수 없다는 것이 판례이다.

제41조 【이사의 대표권에 대한 제한】

이사의 대표권에 대한 제한은 이를 정관에 기재하지 아니하면 그 효력이 없다.

제60조 【이사의 대표권에 대한 제한의 대항요건】

이사의 대표권에 대한 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다.

중요판례

대법원 2001.09.21. 2000그98

법인의 권리능력은 법인의 설립근거가 된 법률과 정관상의 목적에 의하여 제한되나 그 목적 범위 내의 행위라 함은 법률이나 정관에 명시된 목적 그 자체에 국한되는 것이 아니라 그 목적을 수행하는데 있어 직접, 간접으로 필요한 행위는 모두 포함된다.

(3) 법인의 불법행위능력

제35조 【법인의 불법행위능력】

- ① 법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.
- ② 법인의 목적범위외의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다.

우리 민법은 제35조 제1항에서 법인은 대표기관이 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다고 규정함으로써 법인의 불법행위능력을 인정하고 있다.

☑ 성립요건

(1) 대표기관의 행위

- ① 이사, 임시이사, 특별대리인, 청산인, 직무대행자의 행위이어야 한다.
- ② 사원총회, 감사, 이사의 임의대리인, 지배인은 대표기관이 아니므로 법인의 불법행위는 성립될 수 없다. 단, 사용자배상책임은 성립할 수 있다.

(2) 대표기관의 직무에 관한 행위

- ① 외형상 직무행위로 볼 수 있는 행위와 직무행위와 사회통념상 관련성을 가지는 행위도 포함한다는 견해(외형설)가 다수설과 판례의 태도이다. 이는 거래안전을 위한 것이다.
- ② 대표기관이 개인적인 목적으로 권한을 남용하여 부정한 대표행위를 행한 경우에도 법인의 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다는 것이 판례이다.

(3) 민법 제750조의 불법행위의 요건 구비

☑ 불법행위의 효과

- ① 법인은 민법 제756조의 사용자책임과 달리 대표자의 선임·감독상의 과실 없음을 가지고 항변하지 못한다. 즉, 선임·감독에 주의를 다하였음을 이유로 면책되지 않는다(무과실책임).
- ② 피해자는 그가 받은 손해의 충분한 전보(填補)를 받을 때까지 법인이나 대표기관에 대하여 동시에 또는 선택적으로 손해배상청구를 할 수 있다(부진정연대채무).
- ③ 법인이 배상한 경우에는 기관 개인에 대하여 선량한 관리자의 주의의무(제61조)의 위반을 이유로 구상권을 행사할 수 있다(제65조).
- ④ 법인의 불법행위가 성립하지 않는 경우에는 기관 개인만이 제750조에 의한 불법행위의 책임을 진다. 다만 민법은 피해자보호를 위하여 그 사항의 의결에 찬성한 사원과 이사 그리고 그것을 집행한 이사, 기타 대표기관은 언제나 연대하여 손해배상책임을 진다(제35조 제2항).

중요판례

대법원 1992.02.14. 91다24564

법인의 정관에 대표권제한에 관한 규정이 있으나, 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 제3자가 선의나 악의나에 관계없이 대항할 수 없다.

대법원 1997.08.29. 97다18059

주식회사의 대표이사가 그 대표권의 범위 내에서 한 행위는 설사 대표이사가 회사의 목적과 관계없이 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 그 권한을 남용한 것이라 할지라도 일단 회사의 행위로서 유효하고, 다만 그 행위의 상대방이 대표이사의 진의를 알았거나 알

수 있었을 때에는 회사에 대하여 무효가 된다.

☞ 대표기관이 대표권을 남용한 경우에 관하여 현재의 판례의 입장은 제107조 제1항 단서의 유추적용설에 입각하여, 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 때에는 법인에 대하여 무효가 된다고 한다.

대법원 2004.02.27. 2003다15280

행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리(私利)를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다.

대법원 1978.03.14. 78다132

학교법인의 이사장이 이사회 결의와 주무관청의 허가를 받지 아니하고 금원을 차용하여 개인적인 용도로 소비하였다 하더라도, 그 차금행위가 외형상 직무행위의 범위 내에 속할 때에는 학교법인은 위 이사장의 행위로 인한 손해를 배상하여야 한다.

대법원 1987.04.28. 86다카2534

학교법인의 설립자로서 이사 겸 학교장인 자가 자기 개인의 사업자금으로 사용할 목적으로 학교법인의 명의로 금원을 차용하면서, 그 차용을 위하여 학교법인의 이사회 결의까지 있었다면 그 차용금의 사용목적이 무엇이었던 간에 위 학교장의 차금행위는 학교법인의 사무 집행행위에 해당한다.

대법원 2004.03.26. 2003다34045

법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 (악의) 또는 중대한 과실로 인하여(중과실) 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다.

대법원 2005.12.23. 2003다30159

민법 제35조에서 말하는 ‘이사 기타 대표자’는 법인의 대표기관을 의미하는 것이고 대표권 없는 이사는 법인의 기관이기는 하지만 대표기관은 아니기 때문에 그 행위로 인하여 법인의 불법행위는 성립하지 않는다.

대법원 2011.04.28. 2008다15438

‘법인의 대표자’에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다.

대법원 1987.12.08. 86다카1170

법인에 대한 손해배상책임의 원인이 대표기관의 고의적인 불법행위라고 하더라도, 피해자에게도 손해발생에 과실이 있다면 법원은 과실상계의 법리에 따라 이를 참작하여야 한다.

5. 법인의 기관

법인이 사회적 활동을 하기 위해서는 법인의 내부 사무를 처리하고 외부에 대하여 행동하는 기관을 필요로 한다. 이러한 기관에는 이사, 감사, 사원총회가 있다.

제57조 【이사】

법인은 이사를 두어야 한다.

제58조 【이사의 사무집행】

- ① 이사는 법인의 사무를 집행한다.
- ② 이사가 수인인 경우에는 정관에 다른 규정이 없으면 법인의 사무집행은 이사의 과반수로써 결정한다.

제59조 【이사의 대표권】

- ① 이사는 법인의 사무에 관하여 각자 법인을 대표한다. 그러나 정관에 규정한 취지에 위반할 수 없고 특히 사단법인은 총회의 의결에 의하여야 한다.
- ② 법인의 대표에 관하여는 대리에 관한 규정을 준용한다.

제61조 【이사의 주의의무】

이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다.

제62조 【이사의 대리인 선임】

이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있다.

제65조 【이사의 임무해태】

이사가 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 법인에 대하여 연대하여 손해배상의 책임이 있다.

(1) 이사와 감사

기관	성격	임무
이사	① 사단·재단법인에 공통한 기관이다. ② 필수기관이다(제57조).	① 대외적으로 법인을 대표하고 대내적으로 법인의 업무를 집행한다(제58조, 제59조). ② 선량한 관리자의 주의의무로써 사무집행을 하여야 한다. ③ 이사의 성명·주소는 등기사항이며 등기하지 않으면 이사의 선임·해임·퇴임을 가지고 제3자에게 대항할 수 없다(대항요건).

		④ 각자 법인을 대표하며 대표의 방식은 대리의 규정을 준용한다(제59조 제2항). ⑤ 정관에 다른 규정이 없으면 법인의 사무 집행은 이사의 과반수로써 결정한다(제58조 제2항).
감사	① 사단·재단법인에 공통한 기관이다. ② 임의기관이다(제6조).	① 법인의 재산 및 사무상태를 감독한다(제67조). ② 선관주의의무를 지며 각자 단독으로 업무를 집행한다.
사원총회	사단법인에만 존재한다.	① 사단법인의 최고 의사결정기관이다(제68조). ② 통상총회와 임시총회가 있다.

(2) 임시이사와 특별대리인

제63조 【임시이사의 선임】

이사가 없거나 결원이 있는 경우에 이로 인하여 손해가 생길 염려 있는 때에는 법원은 이해관계인이나 감사의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다.

제64조 【특별대리인의 선임】

법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 관하여는 이사는 대표권이 없다. 이 경우에는 전조의 규정에 의하여 특별대리인을 선임하여야 한다.

〈임시이사와 특별대리인〉

구분	선임하여야 할 경우	선임기관
임시이사	이사가 없거나 결원이 된 때에 이해관계인이나 감사의 청구로 선임한다(제63조).	법원
특별대리인	법인과 이사의 이익이 상반될 때에 다른 이사가 없는 경우에 이해관계인 또는 감사의 청구로 선임한다(제64조).	법원

(3) 사원총회

☑ 사원총회의 세부적 내용

(1) 총회의 종류

① 통상총회

- ㉠ 적어도 1년에 1회 이상 일정한 시기에 소집되는 사원총회이다(제69조).
- ㉡ 소집시기는 정관에 정함이 없으면 총회의 결의로 정하고, 총회의 결의가 없는 경우에는 이사가 정한다.

② 임시총회

- ㉠ 이사가 필요하다고 인정한 때, 감사가 보고하기 위하여 필요한 때(제67조), 총사원의 1/5 이상이 회의의 목적사항을 제시하여 청구한 때(소수사원권 ; 제70조 제2항·제3항) 소집된다.
- ㉡ 소수사원의 총회소집의 청구가 있는 후 2주간 내에 이사가 총회소집절차를 밟지 않은 때에는 청구한 사원은 법원의 허가를 얻어 스스로 소집할 수 있다(제70조 제3항).

(2) 총회의 소집

소집은 1주간 전에 그 회의의 목적사항을 기재한 통지를 발신하고 그 밖에 정관에 정한 방법에 의하여야 한다(제71조).

(3) 총회의 권한

- ① 총회는 이사 기타의 임원에게 위임한 사항을 제외하고는 사단법인의 모든 사무를 결의할 수 있다(제68조).
- ② 정관의 변경(제42조) 및 임의해산(제77조 제2항)은 총회의 전권사항이며, 정관에 의하여서도 이 권한을 박탈하지 못한다.
- ③ 소수사원권(제70조 제2항), 결의권(제73조)과 같은 사원의 고유의 권리는 그 사원의 동의 없이는 총회의 결의로도 제한 또는 박탈하지 못한다.

(4) 총회의 결의방법

- ① 총회가 적법하게 소집되고 정족수의 사원이 출석하여야 한다.
- ② 총회의 결의사항은 총회를 소집할 때 미리 통지된 사항에 한하며(제72조), 총회가 권한 이외의 사항을 결의하거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 사항을 결의한 때에는 무효이다.
- ③ 각 사원은 원칙적으로 평등한 결의권을 가지며(제73조 제1항), 이러한 결의권 평등의 원칙은 사원의 고유권을 박탈하지 않는 범위 내에서 정관으로 변경할 수 있다. 법인과 어느 사원과의 관계(■ 법인과 사원과의 매매계약)에 대하여 의결하는 때에는 그 사원은 결의권이 없다.
- ④ 정관에 다른 규정이 없으면 결의에 필요한 정족수는 사원과반수의 출석과 출석사원의 결의권의 과반수이다(제75조 제1항). 서면이나 대리인을 통해 결의권을 행사한 사원도 출석한 것으로 본다(제75조 제2항).

(5) 사원권(사원의 지위)

- ① 사원의 권리로서는 공익권과 자익권이 있다.
- ② 사원의 의무로서는 회비납부의무, 출자의무(영리법인의 경우) 등이 있다.
- ③ 영리법인에서는 자익권이 강하게 나타나고, 비영리법인에서는 공익권이 강하게 나타난다.
- ④ 공익권이 강한 비영리법인의 경우에는 사원권을 양도·상속할 수 없으나(일신전속권; 제56조) 자익권이 강한 영리법인의 경우에는 그러하지 아니하다.

대법원 2006.06.15. 2004다10909

법인의 이사를 사임하는 행위는 상대방 있는 단독행위라 할 것이어서 그 의사표시가 상대방에게 도달함과 동시에 그 효력이 발생하고 그 의사표시가 효력을 발생한 후에는 마음대로 이를 철회할 수 없음이 원칙이나, 사임의사가 즉각적이라고 볼 수 없는 특별한 사정이 있을 경우에는 별도의 사임서 제출이나 대표자의 수리행위 등이 있어야 사임의 효력이 발생하고, 그 이전에 사임의사를 철회할 수 있다.

대법원 2006.10.27. 2006다23695

중증의 대표자가 사임하는 경우에는 대표자의 사임으로 그 권한을 대행하게 될 자에게 도달한 때에 사임의 효력이 발생하고 이와 같이 사임의 효력이 발생한 뒤에는 이를 철회할 수 없다.

대법원 1970.09.17. 70다1256

대표자의 임기만료 후에 개임하지 않았을 경우 그 유임 내지 중임을 금한 계약이 없는 한 임기만료와 동시에 묵시적으로 다시 대표자를 선출한 것으로 본다.

대법원 2005.03.25. 2004다65336

민법상 법인의 기관인 이사의 임기가 만료되면 일단 법인과 이사와의 위임관계는 종료되는 것이나, 기관이 없는 법인은 당장 정상적 활동을 중단치 않을 수 없어 이는 민법 제691조의 급박한 사정이 있는 때에 해당하므로, 임기만료된 구이사는 후임 이사 선임시까지 이사의 직무를 수행할 수 있다.

대법원 1983.09.27. 83다카938

아직 임기가 만료되지 않은 다른 이사들로서 정상적인 법인의 활동을 할 수 있는 경우에는, 구태여 구이사로 하여금 이사로서의 직무를 계속 행사케 할 필요가 없으므로, 임기만료된 이사는 당연히 퇴임하는 것으로 본다.

대법원 2000.01.28. 98다26187

법인에 관한 등기사항의 변경이 있을 때 그 변경등기는 효력발생요건이 아니고 제3자에 대한 대항요건이다.

대법원 1997.09.26. 95다6205

사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다고 규정한 민법 제56조의 규정은 강행규정이 아니므로, 비법인사단에서도 사원의 지위는 규약이나 관행에 의하여 양도 또는 상속될 수 있다.

대법원 2009.4.9. 2008다1521

민법 제74조는 사단법인과 어느 사원과의 관계사항을 의결하는 경우 그 사원은 의결권이 없다고 규정하고 있으므로, 민법 제74조의 유추해석상 민법상 법인의 이사회에서 법인과 어느 이사와의 관계사항을 의결하는 경우에는 그 이사는 의결권이 없다. 이 때 의결권이 없다는 의미는 이해관계 있는 이사는 이사회에서 의결권을 행사할 수는 없으나 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에는 포함되고, 다만 결의 성립에 필요한 출석이사에는 산입되지 아니한다고 풀이함이 상당하다.

제2절 법인의 소멸과 등기

1. 법인의 소멸

(1) 법인의 청산

제81조 【청산법인】

해산한 법인은 청산의 목적범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다.

제82조 【청산인】

법인이 해산한 때에는 파산의 경우를 제하고는 이사가 청산인이 된다. 그러나 정관 또는 총회의 결의로 달리 정한 바가 있으면 그에 의한다.

제83조 【법원에 의한 청산인의 선임】

전조의 규정에 의하여 청산인이 될 자가 없거나 청산인의 결원으로 인하여 손해가 생길 염려 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 선임할 수 있다.

제84조 【법원에 의한 청산인의 해임】

중요한 사유가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 해임할 수 있다.

제88조 【채권신고의 공고】

- ① 청산인은 취임한 날로부터 2월내에 3회이상의 공고로 채권자에 대하여 일정한 기간 내에 그 채권을 신고할 것을 최고하여야 한다. 그 기간은 2월 이상이어야 한다.
- ② 전항의 공고에는 채권자가 기간 내에 신고하지 아니하면 청산으로부터 제외될 것을 표시하여야 한다.
- ③ 제1항의 공고는 법원의 등기사항의 공고와 동일한 방법으로 하여야 한다.

제89조 【채권신고의 최고】

청산인은 알고 있는 채권자에게 대하여는 각각 그 채권신고를 최고하여야 한다. 알고 있는 채권자는 청산으로부터 제외하지 못한다.

제90조 【채권신고기간내의 변제금지】

청산인은 제88조 제1항의 채권신고기간 내에는 채권자에 대하여 변제하지 못한다. 그러나 법인은 채권자에 대한 지연손해배상의 의무를 면하지 못한다.

제91조 【채권변제의 특례】

- ① 청산중의 법인은 변제기에 이르지 아니한 채권에 대하여도 변제할 수 있다.
- ② 전항의 경우에는 조건있는 채권, 존속기간의 불확정한 채권 기타 가액의 불확정한 채권에 관하여는 법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다.

제92조 【청산으로부터 제외된 채권】

청산으로부터 제외된 채권자는 법인의 채무를 완제한 후 귀속권리자에게 인도하지 아니한 재산에 대하여서만 변제를 청구할 수 있다.

청산절차에 관한 민법의 규정은 제3자의 이해관계에 중대한 영향을 미치므로 강행 규정이다. 청산인이 될 수 있는 자는 정관 또는 총회의 결의로 정한 바가 없으면 이사가 청산인이 된다.

(2) 청산인의 청산사무

1) 법인해산등기와 신고(제85조·제86조)

2) 현존사무의 종결(제87조 제1항)

3) 채권의 추심(제87조 제1항)

4) 채무의 변제(제87조 제1항)

청산기간 내에는 변제기에 이르지 않은 채권에 대하여도 변제할 수 있으며(제91조), 청산인이 알고 있는 채권자는 신고가 없더라도 변제하여야 한다.

5) 잔여재산의 인도(제80조) : 잔여재산의 귀속순서

- ① 정관에서 정한 자가 있을 때에는 그 자에게
- ② 지정한 자가 없는 경우에는 유사목적법인에게 귀속시키며(사단법인의 경우에는 총회의 결의절차를 요한다)
- ③ 최종적으로는 국고에 귀속시킨다.

중요판례

대법원 1992.04.28. 91누9848

법인의 청산절차에 관한 규정은 제3자의 이해관계에 중대한 영향을 미치기 때문에 강행규정이다. 청산법인이 청산의 목적범위 외의 행위를 한 때에는 무효이다.

대법원 1997.04.22. 97다3408

법인에 대한 청산종결등기가 경료된 때에도 청산사무가 종료되었다 할 수 없는 경우에는 청산법인으로 존속한다.

2. 법인의 등기

(1) 등기의 성질

법인등기 중에서 설립등기는 성립요건(제33조)으로서의 등기이나 기타의 등기는 모두 제3자에게 대항하기 위한 대항요건(제54조 제1항)으로서의 등기이다.

(2) 설립등기

법인의 설립등기사항은 다음과 같다(제49조 제2항).

- ① 목적
- ② 명칭
- ③ 사무소
- ④ 설립허가의 연월일
- ⑤ 존립시기와 해산사유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유
- ⑥ 자산의 총액
- ⑦ 출자의 방법을 정한 때에는 그 방법
- ⑧ 이사의 성명, 주소
- ⑨ 이사의 대표권을 제한한 때에는 그 제한

3. 법인의 감독

법인의 업무감독은 주무관청이 하고(제37조), 법인의 해산·청산의 감독은 법원이 행한다(제95조).

〈주무관청과 법원의 법인에 관한 권한사항〉

주무관청	법원
① 비영리법인의 설립허가(제32조)	① 임시이사의 선임(제63조)
② 법인의 사무에 대한 검사·감독(제37조)	② 특별대리인의 선임(제64조)
③ 법인의 설립허가의 취소(제38조)	③ 청산인의 선임·해임(제83·84조)
④ 정관변경의 허가(제42·45·46조)	④ 해산·청산의 검사·감독(제95조)
⑤ 청산인의 해산신고(제86조)	⑤ 법인의 파산선고(파산법 제115조 이하)
⑥ 청산인의 청산종결의 신고(제94조)	



4장 권리의 객체(물건)

1. 물건의 의의

물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리가능(배타적 지배)한 자연력을 말한다(제98조).

2. 물건의 요건

(1) 관리 가능한 유체물 또는 자연력

- ① 해, 달, 공기, 해양 등의 유체물은 관리가 가능하지 못하므로 법률상 물건이라고 볼 수 없다. 다만, 해양은 일정한 구획을 정하여 둔 경우에는 어업권의 객체가 될 수 있다.
- ② 사람의 신체 또는 신체의 일부분은 인격존중의 원리에 비추어 볼 때 물건으로 볼 수 없다. 그리고 신체에 부착된 의수·의족·가발·의치 등은 신체에 고착되어 있는 한 물건으로 볼 수 없으며, 모발이나 혈액·치아 등이 신체로부터 분리되면 물건으로 된다.
- ③ 학설과 판례는 대체적으로 시체나 유골을 물건으로 본다.

(2) 독립된 존재일 것

- ① 권리의 객체인 물건은 배타적으로 지배할 수 있는 것이어야 하기 때문에 독립성이 요구된다. 그리고 독립성 유무에 대한 판단은 사회관념에 의하여 결정된다.
- ② 용익물권의 객체는 토지나 건물의 일부 위에 설정이 가능하다.
- ③ 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 독립하여 소유권의 객체가 된다.
- ④ 소유권보존등기를 한 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 된다.

3. 물건의 분류(부동산과 동산)

제99조 【부동산, 동산】

- ① 토지 및 그 정착물은 부동산이다.
- ② 부동산이외의 물건은 동산이다.

(1) 토지

- ① 토지란 일정한 지면과 사람의 지배와 이용이 가능한 범위 내에서 그 상하에 미치는 입체적 존재를 말한다(제212조 참조).
- ② 토지는 자연적으로는 연속하고 있으나 인위적으로는 지표에 선을 긋고 경계로 삼고 구획되며 토지대장 또는 임야대장에 등록된다. 그리고 등록된 각 구역은 독립성이 있으며 그 개수는 '필(筆)'로서 계산된다. 1필의 토지일부는 분필절차를 밟기 전에는 양도나 제한물권을 설정하지 못하는 것이 원칙이나 예외적으로 용익물권은 1필의 토지일부 위에도 설정할 수 있다.
- ③ 하천은 국유 또는 공유에 속하며(하천법 제3조), 사인은 관리청의 허가를 얻어 하천구역을 점유할 수는 있어도 소유할 수는 없다.
- ④ 도로는 사적 소유권이 인정되나 그 행사가 크게 제한된다(도로법 제4조).
- ⑤ 광물을 취득할 권리는 광업법상 국가가 광업권자에게 이를 부여할 권능을 가지기 때문에, 토지소유자의 소유권은 이에 미치지 않는다.

(2) 토지의 정착물

- ① 토지의 정착물이란 토지에 고정적으로 부착되어 용이하게 이동할 수 없는 물건으로서, 거래관념상 계속적으로 토지에 부착하여 이용되는 것으로 인정되는 것을 말한다. 예컨대, 건물, 수목, 돌담, 교량, 도로의 포장 등을 들고 있다. 이에 대하여 판잣집, 가식 중의 수목, 토지나 건물에 충분히 정착되어 있지 않은 기계 등은 정착물이 아니라 동산이다.
- ② 건물은 토지로부터 완전히 독립한 별개의 부동산이다.
- ③ 1동의 건물의 일부분이 구조상과 이용상의 독립성이 인정될 때에는 구분소유권의 목적이 될 수 있음을 규정하고 있다(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제1조).
- ④ 용익물권 중 전세권은 1동의 건물의 일부 위에 설정될 수 있다.
- ⑤ 수목은 토지의 정착물로서 독립하여 물권의 객체가 되지 못한다. 그러나 임목법에 의하여 등기된 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다(임목에 관한 법률 제3조). 그리고 관습법상의 명인방법을 갖춘 수목의 집단이나 미분리의 과실은 독립하여 소유권의 객체가 된다.
- ⑥ 토지에 경작재배하고 있는 농작물은 토지의 일부이다. 다만, 정당한 권원에 의하여

타인의 토지에서 경작·재배한 농작물은 토지에 부합하지 않고 토지와는 독립된 물건으로 다루어진다(제256조 단서). 그런데 판례는 아무런 권원 없이 타인의 토지에 경작·재배한 경우에 명인방법을 갖출 필요 없이 성숙한 농작물의 소유권은 언제나 그 경작자에 있다고 한다(대법원 1978.3.14. 77다2396).

(3) 동산

- ① 부동산 이외의 물건은 모두 동산이다(제99조 제2항).
- ② 정착물이 아닌 토지의 부착물·건·전기 기타 관리할 수 있는 자연력은 동산이나, 선박·자동차·항공기·건설기계 등은 법률상 부동산처럼 취급된다.
- ③ 상품권, 승차권 같은 무기명채권은 현행민법에서는 권리인 채권으로 다룬다.

(4) 특수한 동산(금전)

- ① 금전은 특수한 동산의 일종이다. 금전은 소유와 점유가 일치하여 점유가 곧 소유의 권원이 되므로 타인의 점유에 속한 금전은 언제나 채권적 반환청구권만이 인정되며, 물권적 반환청구권이 인정되지 아니한다.
- ② 금전에는 간접점유가 인정되지 않는다. 따라서 사용대차나 임대차의 목적이 될 수 없으며, 오로지 소비대차의 목적만이 될 수 있을 뿐이다.

사항	부동산	동산
의의	토지와 그 정착물(제99조 제1항)	부동산 이외의 물건(제99조 제2항)
공시방법	등기(제186조)	점유(인도)(제188조)
상관관계	적용(제215조 이하)	적용배제
취득시효	① 등기부취득시효 : 10년(제245조 제2항) ② 점유취득시효 : 20년(제245조 제1항)	① 선의취득시효 : 5년(제246조 제2항) ② 일반취득시효 : 10년(제246조 제1항)
공신력	없음(등기)	있음(점유)
선의취득	적용배제	적용(제249조)
선점	무주의 부동산은 국유(제252조 제2항)	무주의 동산은 선점자의 소유(제252조 제1항)
제한물권	① 지상권·지역권·전세권·저당권의 설정 ② 유치권의 성립	① 질권의 설정 ② 유치권의 성립
환매기간	5년	3년

사항	부동산	동산
부합의 효력	부동산에의 부합 부동산소유자가 부합한 동산의 소유권을 취득(제256조)	동산 간의 부합 ① 부합한 동산 사이에 주종을 구별할 수 있는 때 : 주된 동산의 소유자가 합성물의 소유권을 취득 ② 주종을 구별할 수 없는 때 : 각 동산의 소유자는 부합 당시의 가격의 비율로 합성물을 공유(제257조)
가공의 효력	가공은 인정되지 않음	타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 속함(제259조 제1항)
강제집행의 절차	강제경매·강제관리에 의함(민소법 제599조)	압류에 의함(민소법 제525조)
재판관할의 특칙	부동산에 관한 訴는 부동산소재지의 법원에 제기할 수 있음(민소법 제18조)	규정 없음

중요판례

대법원 1996.06.14. 94다53006

독립된 부동산으로서의 건물이라고 함은 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지면 법률상 건물이라고 할 수 있다.

대법원 1970.09.22. 70다1494

임야에 있는 자연석을 조각하여 제작한 석불이라도 그 임야의 일부분이라 할 수 없고, 임야와 독립된 소유권의 대상이 된다.

대법원 1990.07.27. 90다카6160

구분소유권이 인정되기 위해서는 객관적, 물리적인 측면에서 구분건물이 구조상, 이용상의 독립성을 갖추어야 하고, 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 의사표시 즉 구분행위가 있어야 하는 것으로서, 소유자가 기존 건물에 증축을 한 경우에도 증축 부분이 구조상, 이용상의 독립성을 갖추었다는 사유만으로 당연히 구분소유권이 성립된다고 할 수 없다.

4. 물건의 분류(주물과 종물)

제100조 【주물, 종물】

- ① 물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위하여 자기소유인 다른 물건을 이에 부속하게 한 때에는 그 부속물은 종물이다.
- ② 종물은 주물의 처분에 따른다.

(1) 주물·종물의 의의

물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공(供)하기 위하여 자기 소유인 다른 물건을 이에 부속시킨 경우에 그 물건을 주물이라 하고, 주물에 부속된 다른 물건을 종물이라 한다(제100조 제1항).

(2) 종물의 요건

1) 주물의 상용에 공(供)하는 것일 것

- ① 사회 관념상 주된 물건의 경제적 효용을 보조하기 위하여 계속적으로 이바지되어야 하는 관계가 있어야 한다(대법원 1991.5.14. 91다2779). 예컨대, 배와 노, 자물통과 열쇠, 새와 새장, 주택과 광은 주물·종물의 관계에 있다.
- ② 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건은 종물이 아니다. 식기·침구·난로·텔레비전·책상 등은 건물의 종물의 아니다.

2) 독립한 물건일 것

- ① 종물은 주물의 구성부분이 아니고, 독립한 물건이어야 한다.
- ② 주물과 종물 모두 부동산이든 동산이든 불문한다.

3) 장소적으로 밀접한 위치에 있을 것

주물에 부속시킨 것으로 인정할 만한 정도의 밀접한 장소적 관계가 있어야 한다.

4) 주물·종물 모두 동일한 소유자에게 속할 것

다만, 제3자의 권리를 침해하지 않는 경우에는 타인의 소유에 속하는 물건 사이에도 주물·종물의 관계를 인정한다는 것이 통설이다.

(3) 종물의 효과

1) 종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항).

- ① 주물 위에 저당권이 설정된 경우에는 그 저당권의 효력은 저당권설정 전후를 불문하고 종물에도 그 효력이 미친다(제358조 참조).
- ② 제100조 제2항의 규정은 임의규정이다. 따라서 당사자의 특약으로 달리 약정할 수 있다.

2) 종물이론의 준용

종물이론은 권리 상호간과 물건과 권리 간에도 준용될 수 있다.

중요판례

대법원 1988.02.23. 87다카600

상용에 공한다 함은 사회관념상 계속하여 주물의 효용을 완성시키는 작용을 한다고 인정되는 종류의 물건이고 또 특정의 주물에 부속된다고 인정할 만한 장소적 관계에 있어야 한다.

대법원 1993.02.12. 92도3234

횃집으로 사용할 점포건물에 거의 붙여서 횃감용 생선을 보관하기 위하여, 즉 위 점포건물의 상용에 공하기 위하여 신축한 수족관건물은 횃집건물의 종물이다.

대법원 1994.06.10. 94다11606

어느 건물이 주된 건물의 종물이기 위해서는 주물의 상용에 이바지되어야 하는 관계가 있어야 하는 바, 여기에서 주물의 상용에 이바지한다 함은 주물 그 자체의 경제적 효용을 다하게 하는 것을 말하는 것이며, 주물이 소유자나 이용자의 상용에 공여되고 있더라도 주물 그 자체의 효용과는 직접 관계없는 물건은 종물이 아니다.

대법원 1996.04.26. 95다52864

저당권의 효력이 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다는 민법 제358조 본문을 유추하여 보면, 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다. 따라서 건물에 대한 저당권이 실행되어 경락인이 그 건물의 소유권을 취득하였다면, 경락 후 건물을 철거한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 경락인은 건물 소유를 위한 지상권도登記 없이 당연히 취득하게 되고, 경락인이 건물을 제3자에게 양도한 때에는, 특별한 사정이 없는 한 건물과 함께 종된 권리인 지상권도 양도한 것으로 본다.

대법원 2016.4.28. 2012다19659

- [1] 집합물에 대한 양도담보권자가 점유개정의 방법으로 양도담보권설정계약 당시 존재하는 집합물의 점유를 취득한 후 양도담보권설정자가 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입한 경우, 양도담보권의 효력은 나중에 반입한 물건에도 미친다. 다만 반입한 물건이 제3자 소유인 경우에는 그러하지 아니하다.
- [2] 양도담보권의 목적인 주된 동산에 다른 동산이 부합되어 부합된 동산에 관한 권리자가 권리를 상실하는 손해를 입은 경우, 민법 제261조에 따라 보상을 청구할 수 있는 상대방은 양도담보권자가 아니라 양도담보설정자이다.

대법원 1995.06.29. 94다6345

- [1] 주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크를 토지로부터 분리하는데 과다한 비용이 들고 이를 분리하여 발굴할 경우 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것이 분명하다는 이유로, 그 유류저장탱크는 토지에 부합된 것으로 본다. 따라서 부합물이며, 종물이 아니다.
- [2] 주유소의 주유기는 계속해서 주유소 건물 자체의 경제적 효용을 다하게 하는 작용을 하고 있으므로 주유소건물의 상용에 공하기 위하여 부속시킨 종물이다.

대법원 2000.10.28. 2000마5527

토지 지하에 설치된 유류저장탱크와 건물에 설치된 주유기는 토지에 부합되거나 건물의 상용에 공하기 위하여 부속시킨 종물로서 토지 및 건물에 대한 경매의 목적물이 된다.

대법원 1993.08.13. 92다43142

백화점 건물의 지하 2층 기계실에 설치되어 있는 전화교환설비가 건물의 원소유자가 설치한 부속시설이며, 위 건물인 10층 백화점의 효용과 기능을 다하기에 필요 불가결한 시설들로서, 상용에 제공된 종물이다.

대법원 1993.12.10. 93다42399

정화조는 건물의 대지가 아닌 다른 필지의 지하에 설치되어 있다 하더라도 독립한 물건인 종물이라기보다는 건물의 구성부분이다.

대법원 1990.12.26. 88다카20224

일반적으로 일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보설정계약체결도 가능하며 이 경우 그 목적 동산이 담보설정자의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정되어 있으면 그 전부를 하나의 재산권으로 보아 이에 유효한 담보권의 설정이 된 것으로 볼 수 있다. 따라서 성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양만장 내의 뱀장어 등 어류 전부에 대한 양도담보계약은 그 담보목적물이 특정되었으므로 유효하게 성립한다.

5. 물건의 분류(원물과 과실)

제101조 【천연과실, 법정과실】

- ① 물건의 용법에 의하여 수취하는 산출물은 천연과실이다.
- ② 물건의 사용대가로 받는 금전 기타의 물건은 법정과실로 한다.

제102조 【과실의 취득】

- ① 천연과실은 그 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 속한다.
- ② 법정과실은 수취할 권리의 존속기간일수의 비율로 취득한다.

(1) 의의

과실이란 물건에서 생기는 경제적 수익을 말하며, 과실을 생기게 하는 물건을 원물이라고 한다. 이러한 과실에는 천연과실(天然果實)과 법정과실(法定果實)이 있다.

(2) 천연과실

1) 의의

- ① 천연과실이란 물건의 용법에 따라 산출되는 산출물을 말한다(제101조 제1항).
- ② 과수에 맺힌 열매, 가축의 새끼, 광산의 광물, 석재, 토사 등이 이에 해당한다.
- ③ 천연과실은 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 귀속한다(제102조 제1항).

2) 천연과실의 수취권자

- ① 원물의 소유자(제211조)
- ② 선의의 점유자(제201조)
- ③ 지상권자(제279조)
- ④ 전세권자(제303조)
- ⑤ 유치권자(제323조)
- ⑥ 질권자(제343조)
- ⑦ 압류한 후의 저당권자(제359조)
- ⑧ 목적물인도 전의 매도인(제587조)

⑨ 사용차주(제609조)

⑩ 임차인(제618조)

* 유치권자와 질권자는 원칙적으로는 수취권자가 될 수 없으나, 예외적으로 담보물에서 파생되는 과실로서 변제에 충당할 수 있다. 그리고 저당권의 효력도 목적물의 과실에는 원칙적으로 미치지 아니하나, 압류 후에는 그 효력이 미친다.

(3) 법정과실

1) 의의

- ① 법정과실이란 물건의 사용대가로 받는 금전 기타의 물건을 말한다(제101조 제2항). 임대차에 있어서의 사용료, 즉 차임(집세)이나 지료 등이다.
- ② 원물과 과실은 모두 물건이어야 하므로 노동의 대가(임금)·권리사용의 대가(주식의 배당금·특허권의 사용료) 등은 법정과실이 아니다.

2) 법정과실의 귀속

- ① 법정과실은 이를 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다(제102조 제2항).
- ② 제102조 제2항은 임의규정이며 당사자의 특약이 있으면 그에 의한다.

중요판례

대법원 2001.12.28. 2000다27749

국립공원의 입장료는 토지의 사용대가라는 민법상 과실이 아니라 수익자 부담의 원칙에 따라 국립공원의 유지·관리비용의 일부를 국립공원 입장객에게 부담시키고자 하는 것이어서 토지의 소유권이나 그에 기한 과실수취권과는 아무런 관련이 없다.

6. 물건의 분류(학문상의 분류)

기준	분류	내용	구별의 실익
사법상 거래의 대상이 될 수 있는가에 따른 분류	유통물	일반적인 물건	
	불유통물	• 공용물 : 관공서의 청사·국공립학교의 건물과 같이 국가·공공단체가 소유하고 공공목적으로 사용되는 물건 • 공공용물 : 도로·하천·항만·공원과 같이 공중의 일반적 사용에 제공되는 물건	

기준	분류	내용	구별의 실익
		• 금제물 : 국보·지정문화재·마약·위조지폐 등과 같이 거래 또는 소유가 금지·제한되는 물건	
물건의 성질 또는 가격을 현저하게 손상시키지 않고 분할할 수 있는가의 여부에 따른 분류	가분물	금전·곡물·토지 등	• 공유물의 분할(제269조) • 다수당사자의 채권관계(제408조 이하) 등에서 구별의 실익이 있다.
	불가분물	건물·소·말 등	
물건의 용도에 따른 반복 사용·수익의 여부에 따른 분류	소비물	금전·곡물·술 등과 같이 1회의 사용으로 그 존재를 잃거나 그 주체가 변하는 물건	• 소비대차(제598조) • 사용대차(제609조) 등에서 구별의 실익이 있다.
	비소비물	건물·책 등과 같이 반복 사용·수익이 가능한 물건	
일반거래상 물건의 개성의 중요성 여부에 따른 분류	대체물	금전·곡물·술 등과 같이 동종·동질·동량의 물건으로 바꾸어도 당사자에게 영향을 주지 않는 물건	• 소비대차(제598조) • 소비임치(제702조) 등에서 구별의 실익이 있다.
	불대체물	건물·그림·골동품 등과 같이 개성이 중요시되어 다른 것으로 바꿀 수 없는 물건	
당사자의 의사에 따른 분류	특정물	당사자가 동종의 다른 것으로 바꿀 것을 허용하지 않는 물건	• 채권의 목적물의 보관의무(제374조) • 채무변제의 장소(제467조) • 매도인의 담보책임(제507조) 등에서 구별의 실익이 있다.
	불특정물	당사자가 동종의 다른 것으로 바꿀 것을 허용한 물건	
물건의 형태에 따른 분류	단일물	책 1권, 접시 1개 등	
	합성물	자동차, 선박, 보석반지 등	
	집합물	도서관의 장서, 공장시설 등	



5장 법률행위

제1절 법률행위의 의의와 종류

1. 법률사실·법률요건·법률효과

법률행위(법률요건)란 한 개 또는 수 개의 의사표시(법률사실)를 필수불가결의 요소로 하는 법률요건을 말한다. 예컨대, 매매라는 법률행위(법률요건)는 서로 대립하는 두 개의 의사표시(법률사실), 즉 청약과 승낙이 합치되어 이루어지며 이에 따라 매도인의 재산권이전의무와 매수인의 대금지급의무(법률효과)가 발생하게 된다. 그리고 법률요건은 보통 다수의 법률사실로 구성되어지나 한 개의 법률사실로써 법률요건을 이루는 경우도 있다(단독행위인 법률행위).

2. 권리변동의 원인(용태와 사건)

법률행위는 표의자가 의욕한 바에 따라 그 효과가 발생하나 준법률행위는 법률에 정해진 바에 따라 그 효과가 발생한다.

(1) 용태

사람의 의식이나 정신작용에 의하는 것을 말한다.

1) 외부적 용태 : 행위·작위·부작위를 포함한다.

① 적법행위

㉠ 의의 : 법률이 가치 있는 것으로 평가하여 허용하는 행위를 말한다.

㉡ 의사표시(법률행위) : 청약·승낙·취소·추인·해제·해지·동의·철회 등

㉢ 준법률행위

㉠ 의의 : 준법률행위란 법률행위를 제외한 인간의 행위 또는 행위의 결과를 의미하며 법률의 규정에 의하여 일정한 법률효과가 발생한다.

㉞ 표현행위(의식의 표현)

- ㉞ 의사의 통지 : 각종의 최고(제15조·제88조·제131조·제381조·제387조·제552조 등)·각종의 거절(제16조·제132조·제487조·제552조 등)과 같이 자기의 의사를 타인에게 통지하는 것을 말한다.
- ㉞ 관념의 통지(사실의 통지) : 사원총회소집의 통지(제71조)·채무승인(제68조·제450조)·채권양도통지 및 승낙(제450조)·공탁통지(제488조)·승낙연착통지(제528조)와 같이 과거 또는 현재의 사실을 상대방에게 알리는 것을 말한다.
- ㉞ 감정의 표시 : 용서(제556조·제81조)와 같이 일정한 감정을 표시하는 것을 말한다.

㉟ 비표현행위(사실행위)

- ㉞ 순수사실행위 : 주소의 설정(제18조)·매장물발견(제254조)·가공(제259조) 등과 같이 행위자의 내심적 의식과 관계 없이 외부적·사실적 결과의 야기에 의하여 법이 이에 일정한 법률효과를 부여한 것이다.
 - ㉞ 혼합사실행위 : 무주물의 선점(제252조)·물건의 인도(제187조)·사무관리(제734조)·부부의 동거 등과 같이 외부적 결과의 야기 이외에 일정한 의식내용을 필요로 하는 것을 말한다.
- ② 위법행위 : 법률이 가치 없는 것으로 평가하여 허용하지 않는 행위를 말한다. 이에 는 채무불이행(제390조)과 불법행위(제750조 이하)가 있다.

2) 내부적 용태

- ① 의의 : 내심적 의식상태로 원래는 법적 의미를 가지지 않으나 예외적인 일정한 경우에 한하여 법적 효과를 부여한다.
- ② 관념적 용태 : 선의·악의(제29조·제107조·제108조·제109조·제110조)·정당한 대리인이라는 신뢰(제126조)와 같이 어떤 사람이 일정한 의사를 가지느냐 여부의 내심적 과정이다.
- ③ 의사적 용태 : 소유의 의사(제197조), 제3자의 변제에 있어서 채무자의 허용 또는 불허용의 의사(제469조), 사무관리에 있어서 본인의 의사(제734조), 반대의 의사와 같이 일정한 사실에 관한 관념 또는 인식이 있는가 여부의 내심적 과정이다.

(2) 사건

사람의 정신작용에 기하지 않는 것을 말하며, 법률이 일정한 효과를 인정하고 있는 것이다. 사람의 출생, 사망, 실종, 시간의 경과, 물건의 자연적 발생 또는 소멸, 물건의 파괴, 부합·혼화, 과실의 분리, 부당이득 등이 있다.

〈법률사실의 체계〉

용 태	외 부 적 용 태	적법 행위	의 사 표 시			청약, 승낙, 추인, 동의 등
			준 법 률 행 위	표현 행위	의사의 통지	각종의 최고나 거절
					관념의 통지	사원총회소집의 통지, 대리권수여의 통지, 채무의 승인, 공탁의 통지, 채권양도의 통지, 승낙연착의 통지 등
					감정의 표시	망은행위에 대한 용서, 이혼사유에 대한 용서 등
				비표현 행위	순수사실행위	매장물발견, 가공, 주소의 설정 등
					혼합사실행위	선점, 물건의 인도, 부부의 동거, 사무관리 등
		위법 행위	불법행위			불법행위
			채무불이행			이행지체, 이행불능, 불완전이행 등
	내부적 용태	관념적 용태			선의악의, 정당한 대리인이라는 신뢰 등	
		의사적 용태			점유의 의사, 소유의 의사, 정주의 의사, 본인을 위한 의사 등	
사 건						물건의 자연적 발생과 소멸, 시간의 경과, 사람의 출생·사망·실종, 천연과실의 분리, 물건의 부합, 물건의 파괴·혼동 등

3. 권리변동의 모습

법률효과는 권리의 발생·변경·소멸이라는 모습으로 나타나는데 이를 권리주체의 입장에서 보면 권리의 취득·변경·상실이 된다. 이 때의 권리의 취득과 상실은 권리의 상대적인 발생과 소멸을 의미하는 것이다.

다시 설명하면, 권리의 발생이란 어떤 자가 권리를 취득한다는 것을 의미하며, 권리의 변경이란 권리가 그의 동일성을 잃지 않고서 그의 주체·내용·작용에 관하여 변경을 받는 것이다.

아울러 권리의 소멸이란, 그 사람이 권리를 상실한다는 것을 말한다.

	모습			의의	예
권리 변동	권리의 취득 (발생)	절대적 발생 (원시취득)		타인의 권리에 의하지 않고 새로이 권리가 발생하는 것	선점(제252조)·습득(제253조)·시효취득(제245조)·선의 취득(제249조) 등
		상대적 발생 (승계 취득)	이전적 승계	포괄 승계 타인의 권리를 포괄적으로 승계하는 것	상속(제997조)·포괄유증(제1078조)·회사의 합병 등
			특정 승계	타인의 개별적인 권리를 승계하는 것	매매(제563조)·증여(제554조) 등
		설정적 승계		소유자의 권리는 그대로 존속 하면서 타인이 새로운 권리를 설정받는 것	지상권설정(제279조)·지역권 설정(제291조)·전세권설정(제303조)·저당권설정(제356조)·임차권설정(제618조)
	권리의 변경	주체의 변경		다른 면에서 본다면 권리의 승계·상대적 소멸에 해당	
		작용의 변경			• 저당권의 순위가 변경되는 것 • 부동산임차권의 대항력 취득
		성질적 변경			특정물인도채권이 손해배상채권으로 변하는 경우(제390조·394조)
		수량적 변경			소유권에 지상권 등의 제한물권이 설정되거나 소멸하는 것

	모습		의의	예
권리 변동	권리의 소멸	절대적 소멸	권리 자체가 소멸하는 것	목적물 멸실로 인한 권리의 소멸·소멸시효(제162조)·변제에 의한 권리소멸 등
		상대적 소멸	권리 자체는 소멸하지 않고 권리의 주체만이 변경되는 것	매매나 증여로 인한 매도인 또는 증여자의 권리상실 등

4. 법률행위의 종류

(1) 단독행위·계약·합동행위

1) 의의

법률행위의 불가결의 구성요소인 의사표시가 어떻게 결합하는가에 따른 분류로서, 가장 기본적인 구별이다.

2) 단독행위

- ① 의의 : 단독행위란 행위자 한 사람이 한 개의 의사표시로 성립하는 법률행위이며, 일방행위라고도 한다. 단독행위는 상대방에게 미치는 영향이 크므로 민법 기타 법률에 특별규정이 있는 경우 이외에는 허용하지 아니한다. 단독행위는 상대방의 유무에 따라 다시 나누어진다.
- ② 상대방 있는 단독행위 : 의사표시가 상대방에게 도달하여야 법률효과가 발생하는 행위로 동의·추인·채무면제·상계·취소·철회·해제·해지 등이다.
- ③ 상대방 없는 단독행위 : 의사표시를 수령한 상대방이 특정되어 있지 않고 그 의사표시가 있으면 곧 법률효과가 발생하는 행위로, 유증·재단법인의 설립행위·권리의 포기 등이다. 단, 권리의 포기 중에서 기한이익의 포기·시효이익의 포기·제한물권의 포기는 상대방 있는 단독행위에 해당한다.

3) 계약

넓은 의미의 계약이란 두 개의 서로 대립되는 의사표시의 합치에 의하여 성립하는 법률행위이다. 계약은 반드시 복수인의 의사표시를 필요로 하므로 단독행위와 다르다. 따라서 이를 쌍방행위라고도 한다. 또한 계약은 이해관계가 대립되는 각 당사자의 의사표시가 합치되어 성립하는 것이므로 합동행위와 다르다. 좁은 의미의 계약은

채권의 발생을 목적으로 하는 채권계약만을 의미한다. 그러나 넓은 의미의 계약에는 채권계약 외에도 물권계약과 가족법상 계약을 포함할 수 있다. 민법은 제3편 제2장에서 15개의 전형적인 채권계약을 규정하고 있다.

4) 합동행위

합동행위란 서로 대립하지 않는 복수당사자의 내용과 방향을 같이하는 복수의 의사 표시가 합치함으로써 성립하는 법률행위이다. 사단법인의 설립행위를 그 예로 들 수 있다.

(2) 채권행위·물권행위·준물권행위

1) 의의

재산법상의 법률행위에 의하여 발생하는 효과의 종류에 따른 분류이다.

2) 채권행위

채권행위란 단순히 채권·채무를 발생시키는 법률행위를 말한다. 매매·증여·임대차 등이 이에 속한다. 채권행위가 행하여지는 경우에, 이를 채무자의 입장에서 본다면 그는 언제나 일정한 채무를 부담하게 된다. 여기서 채무행위는 이를 의무부담행위라 한다. 채권행위는 채권·채무에 관하여 '이행'이라는 문제를 남기게 되나, 물권행위나 준물권행위에서는 이행의 문제는 생기지 않는 점에서 크게 다르다. 여기서 물권행위나 준물권행위를 처분행위라 한다.

3) 물권행위

물권행위란 물권의 발생·변경·소멸, 즉 물권의 변동을 생기게 하는 법률행위를 말한다. 소유권의 이전·지상권설정행위·저당권설정행위 등이 이에 속한다. 따라서 물권행위는 채권행위와 같은 이행이라는 문제를 남기지 않는 점에 그 특색이 있다.

4) 준물권행위

준물권행위란 물권 이외의 권리의 발생·변경·소멸을 직접 생기게 하는 법률행위이다. 다시 말해서 물권 이외의 권리를 중국적으로 변동시키고 더 이상은 이행의 문제를 남기지 않는 법률행위를 말한다. 예컨대, 채권양도(제449조 제1항)·채무면제(제506조)·지식재산권의 양도 등이 이에 속한다.

〈법률행위의 종류〉

표준	세분	내용	예
의사 표시	단독행위	상대방 있는 단독행위	동의, 철회, 상계, 추인, 해제, 해지, 취소, 채무면제 등
		상대방 없는 단독행위	권리의 포기, 재단법인의 설립행위, 유언 등
	계약	전형계약(15종)	매매, 교환, 임대차, 사용대차, 증여, 소비대차, 위임, 도급, 여행계약, 화해, 조합, 현상광고, 고용, 임치, 종신통기금
	합동행위		사단법인의 설립행위
법률 효과	채권행위	채권을 발생시키며 이행의 문제를 남김(원인, 약속 : 15종의 계약) ; 의무 부담행위	
	물권행위	물권변동이 일어나며 더 이상의 이행의 문제는 없음(결과, 이행 : 소유권 이전, 전세권설정 등) ; 처분행위	
	준물권행위	물권 이외의 권리의 종국적 변동을 일으키고 이행의 문제는 없음(채권 양도, 채무면제 등) ; 처분행위	

(3) 요식행위·불요식행위

1) 의의

의사표시의 형식에 의한 분류이다. 즉, 법률행위가 성립하기 위하여 서면의 작성 등 일정한 방식을 요하는가에 의한 구별이다.

2) 불요식행위

불요식행위는 법정의 방식을 요하지 아니하는 법률행위이다. 매매·임대차·소비대차·위임 등이 그 예이다. 계약자유가 기본적 가치로서 인정되는 법제에서는 불요식행위를 원칙으로 하고 있다.

3) 요식행위

요식행위란 의사표시가 일정한 방식에 따라 하였을 때에 비로소 법률행위가 성립 내지 효력이 발생하는 법률행위를 말한다. 예컨대, 당사자로 하여금 신중하게 행위를 하게 하기 위하여(혼인·이혼 등의 신분행위), 또는 법률관계를 명확하게 하기 위하여(법인의 설립행위·유언 등), 특히 외형을 신뢰하여 민활하게 거래하게 할 필요가 있는 행위(어음·수표 등의 유가증권에 관한 행위 등)에는 일정한 방식이 요구된다.

(4) 생전행위·사후행위(사인행위)

사후행위란 행위는 생전에 성립되지만, 행위자의 사망으로 그 효력이 발생하는 법률 행위이며 사인행위라고도 한다. 예컨대, 유언(제1073조)·사인증여(제562조)가 이에 속한다. 생전행위는 문자 그대로 생전에 하는 법률행위를 말한다.

(5) 재산행위·가족법상의 행위(신분행위)

매매계약·임대차계약·증여계약과 같이 재산상의 법률효과를 발생케 하는 법률행위를 재산행위라고 하며, 혼인·입양·인지·파양 등과 같이 신분상의 법률효과를 발생케 하는 법률행위를 신분행위라고 한다.

(6) 출연행위·비출연행위

1) 의의

재산행위 중 자기의 재산을 감소시켜 타인의 재산을 증가시키는 행위(■ 매매·임대차)를 출연행위라고 하며, 타인의 재산을 증가시키지 않고 자기의 재산만을 감소시키거나 (■ 소유권의 포기), 직접 재산의 증감을 가져오지 않는 행위(■ 대리권의 수여)를 비출연행위라고 한다. 출연행위는 다시 다음과 같이 분류된다.

2) 유상행위·무상행위

유상행위란 재산의 출연을 목적으로 하는 법률행위 중에서 매매·교환·임대차·고용 등과 같이 대가를 수반하는 것을 말하며, 무상행위는 증여·사용대차와 같이 대가적 출연을 받지 않는 행위를 말한다. 유상행위와 무상행위는 선량한 관리자의 주의의무(제374조)를 지느냐, 자기재산과 동일한 주의의무(제695조)를 지느냐에 차이가 있다.

3) 유인행위·무인행위

유인행위란 원인된 법률행위의 효력에 따라 영향을 받는 법률행위를 말하며, 무인행위란 그러하지 아니한 법률행위를 말한다. 다시 말해서 유인행위란 그 원인이 불성립 하거나 무효가 되면 출연행위 자체도 무효가 되는 것을 말하며, 무인행위란 출연행위의 효력이 그 원인의 불성립이나 무효에 의해 영향을 받지 않는 법률행위를 말한다. 어음행위 및 수표행위가 무인행위에 해당한다.

(7) 독립행위·보조행위

독립행위는 직접 법률관계의 변동을 일어나게 하는 법률행위이고, 보조행위는 단순히 다른 법률행위의 효과를 형식적으로 보충하거나 확정하는 법률행위이다. 대부분의 법률행위는 독립행위이나 동의·추인·대리권의 수여행위 등은 보조행위이다.

(8) 주된 행위와 종된 행위

법률행위가 유효하게 성립하기 위하여 다른 법률행위의 존재를 전제하여 이에 부종하여 성립되는 법률행위를 종된 행위라 하고, 그 전제가 되는 행위를 주된 행위라 한다. 부부재산계약은 혼인의 종된 계약이고, 질권 또는 저당권설정계약은 소비대차계약의 종된 행위이다. 종된 행위는 주된 행위와 법률적 운명을 같이 하는 것이 원칙이다.

제2절 법률행위의 성립요건과 효력요건

1. 의의

법률행위가 그 법률효과를 발생하려면 먼저 법률행위로서 성립하고, 다음에 법률행위의 효력이 발생되어야 한다. 이와 같이 법률행위가 성립하기 위한 요건을 법률행위의 성립요건이라 하고, 성립한 법률행위가 효력이 발생되기 위한 요건을 효력요건 또는 유효요건이라 한다.

2. 법률행위의 성립요건

(1) 일반적 성립요건

법률행위에 일반적으로 요구되는 성립요건으로서, 예컨대 매매라는 법률행위를 행하기 위해서는 행위의 ‘당사자(매도인과 매수인)’가 존재하여야 하고, 당사자가 의도하는 ‘목적(재산권의 이전과 대금지급)’과 ‘의사표시(청약과 승낙)’가 있어야 한다. 따라서 ‘당사자·목적·의사표시’ 이 세 가지를 일반적 성립요건이라 한다.

(2) 특별성립요건

개개의 법률행위에 관하여 그의 성립에 필요한 요건으로 규정하고 있는 것으로, 예를 들면 혼인에 있어서의 신고(제812조), 유언에 있어서의 증서의 작성(제1060조), 요물 계약에서의 물건의 인도 등이 있다.

3. 법률행위의 효력요건

일단 성립한 법률행위가 법률상 효력을 발생하는 데 필요한 요건을 말한다.

(1) 일반적 효력요건

모든 법률행위에 요구되는 효력요건이다.

- ① 당사자가 권리능력·의사능력·행위능력을 가지고 있을 것

- ② 법률행위의 목적이 가능·적법·사회적 타당성·확정할 수 있을 것
- ③ 의사표시에 있어서 의사와 표시가 일치하고 의사표시에 하자가 없을 것

(2) 특별효력요건

일정한 법률행위에 있어서 요구되는 특유한 효력요건이다.

- ① 대리행위에 있어서의 정당한 대리권의 존재(제114조 내지 제136조)
- ② 조건부 법률행위에 있어서의 조건의 성취(제147조 이하)
- ③ 기한부 법률행위에 있어서의 기한의 도래
- ④ 유언에 있어서의 유언자의 사망(제1073조)
- ⑤ 토지거래허가구역에서의 관할관청의 허가

〈성립요건과 효력요건의 비교〉

구분	성립요건	효력요건
일반요건	당사자	권리능력·의사능력·행위능력을 가질 것
	목적	가능·적법·사회적 타당성·확정할 수 있을 것
	의사표시	의사와 표시가 일치하고 의사표시에 하자가 없을 것
특별요건	• 법인설립시 정관작성 • 혼인의 경우 신고 • 유언의 경우 증서 • 요물계약에서의 물건 의 인도	• 대리에 있어서는 정당한 대리권의 존재 • 조건부 법률행위에 있어서는 조건의 성취 • 기한부 법률행위에 있어서는 기한의 도래 • 유언에 있어서는 유언자의 사망 • 토지거래허가구역에서의 관할관청의 허가

제3절 법률행위의 목적

1. 의의

법률행위의 목적이란 행위자가 그의 법률행위에 의하여 발생시키려고 하는 법률효과를 말하며 법률행위의 내용이라고도 한다. 예컨대, 매매계약이라는 법률행위의 목적은 매도인의 대금지급청구권과 매수인의 재산권이전청구권이라 할 수 있다. 법률행위의 목적은 가능·적법·사회적 타당성·확정할 수 있는 것이어야 한다.

2. 목적의 적법

(1) 의의

강행법규란 당사자가 의사에 의하여 그 규정의 적용을 배제할 수 없는 규정을 말하며, 임의법규란 당사자가 의사에 의하여 그 규정의 적용을 배제할 수 있는 규정을 말한다. 따라서 강행법규에 반하는 내용의 법률행위는 그 효력이 발생되지 아니한다.

(2) 강행규정(강행법규)

민법은 그 규정 자체에서 강행규정이라고 밝히고 있는 경우(제608조)도 있으나 대부분은 강행법규임을 명시하지 않고 있으므로 그 구별의 기준이 애매하다. 따라서 규정의 성질과 종류, 입법목적 등을 고려하여 개별적으로 판단할 것을 요한다.

(3) 단속규정(단속법규)

일정한 행정상의 목적을 달성하기 위하여 사실행위를 금지·제한하거나 거래행위를 금지·제한하고 이에 위반한 경우 형벌이나 행정상의 불이익을 가하게 하는 규정을 말한다. 단순한 단속법규에 위반한 경우에는 그 사법상의 효력은 유효이나 별칙의 적용 대상이 된다.

(4) 임의규정(임의법규)

선량한 풍속 기타 사회질서와 관계 없는 규정으로서 당사자의 특약으로 그 규정의 적용을 배제하거나 변경하더라도 무효가 아닌(유효) 규정을 말한다.

(5) 탈법행위

강행법규에 직접 위반하지는 않으나 강행규정이 금지하고 있는 것을 다른 적법행위의 형식을 빌어서 실질적으로 실현하는 행위를 의미하며, 그 효과는 무효이다.

3. 목적의 가능

(1) 의의

법률행위의 목적은 그 실현이 가능한 것이어야 한다. 따라서 법률행위의 성립 당시에 목적이 불능(원시적 불능)한 것이면 그 법률행위는 무효이다.

(2) 가능·불능의 표준

법률행위의 목적이 가능한가 또는 불능한가의 표준은 사회통념에 따라 결정된다. 즉, 물리적으로 불능인 경우(하늘의 별을 따다는 계약, 죽은 사람을 살린다는 계약 등)는 물론 물리적으로는 가능하더라도 사회통념상 불능한 경우(한강에 빠뜨린 바늘을 찾는다는 계약 등)에도 불능이다. 아울러 불능은 확정적이어야 하며 일시적으로 불능한 것이라도 가능으로 될 개연성이 높은 것은 불능이 아니다.

(3) 불능의 분류

1) 원시적 불능과 후발적 불능

- ① 의의 : 법률행위의 성립 당시에 이미 법률행위의 목적이 실현불가능인 것이 원시적 불능이며, 법률행위의 성립 당시에는 가능하였으나, 그 이행 전에 불능하게 된 것이 후발적 불능이다. 예컨대, 이미 불타 버린 건물의 매매계약을 체결한 것은 원시적 불능이고, 매매계약체결 후에 건물이 불타 버린 경우라면 후발적 불능이다.
- ② 원시적 불능의 효과 : 원시적 불능의 법률행위는 무효이다. 다만 목적물의 인도 의무자가 그 불능을 알았거나(악의) 알 수 있었다면(과실) 상대방이 그 계약이 유효하다고 믿음으로써 받은 손실(신뢰이익)을 배상하여야 한다(제535조, 계약체결상의 과실).

제535조 【계약체결상의 과실】

- ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다.
- ② 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

- ③ 후발적 불능의 효과 : 후발적 불능은 법률행위 자체를 무효로는 하지 않는다. 단, 채무자의 귀책사유(고의 또는 과실)로 인한 후발적 불능인 경우에는 채무불이행의 하나인 이행불능(제390조)이 되고, 채무자의 귀책사유 없는 후발적 불능인 경우에는 위험부담의 문제(제537조)가 된다. 아울러, 이행불능의 경우에는 채무자는 손해배상책임을 지게 되며, 위험부담의 문제가 될 때에는 채무자는 원칙적으로 자기 채무의 이행의무를 면하게 되나 상대방에 대하여 반대급부의 이행을 청구할 수 없게 된다(제537조·제538조 채무자 위험부담주의).

2) 전부불능과 일부불능

- ① 의의 : 매매목적물인 건물이 전부 소실된 경우와 같이 법률행위의 목적전부가 불능인 것을 전부불능, 일부만이 소실된 경우와 같이 일부만이 불능인 것을 일부불능이라 한다.
- ② 전부불능의 효과 : 원시적 불능인가 또는 후발적 불능인가에 따라 법률효과가 발생한다.
- ③ 일부불능의 효과 : 일부불능의 경우에는 원칙적으로 전부무효가 되나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였으리라 인정될 때에는 나머지 부분은 유효인 것으로 본다(제137조).

4. 목적의 사회적 타당성

법률행위의 목적이 적법하고 가능하더라도 그것이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 것을 내용으로 할 때에는 무효이다.

제103조 【반사회질서의 법률행위】

선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다.

(1) 사회질서위반의 실질적 유형

사회질서에 위반하는 법률행위를 구체적으로 열거하는 것은 불가능하기에 민법은 제 103조에 추상적·일반적 규정을 두고 있다. 판례에 의하여 나타난 사회질서위반의 구체적 내용은 다음과 같다.

유형	구체적인 예
정의의 관념에 반하는 행위	① 매도인의 배임행위에 적극 가담한 이중매매 ② 법정에서 허위진술을 대가로 금전의 교부약정 ③ 경매나 입찰에서의 담합행위 ④ 불법행위를 하거나 하지 않을 것을 내용으로 하는 계약 ⑤ 밀수자금의 소비대차, 공무원의 청탁과 수뢰약정
인륜에 반하는 행위	① 첩계약은 처의 동의유무를 불문하고 무효 단, 첩관계의 단절을 목적으로 위자로 지급계약이나 첩관계에서 태어난 자(子)의 양육비 지급계약은 유효 ② 자식의 부모에 대한 불법행위를 이유로 한 손해배상청구 ③ 모자(母子) 불동거계약
개인의 자유를 극도로 제한하는 행위	① 개인의 정신 또는 신체의 자유를 극도로 제한하는 행위 • 평생 혼인하지 않겠다는 계약 • 혼인하면 퇴직하겠다는 각서를 써 준 경우 • 어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 약정 ② 개인의 경제활동의 자유를 지나치게 제한하는 행위
생존의 기초가 되는 재산의 처분행위	① 사찰이 그 존립에 없어서는 안 될 임야를 증여하는 행위 ② 장래에 취득하게 될 모든 재산을 양도하는 계약
도박 등의 사행행위	① 도박계약이나 도박자금을 대여하는 계약 ② 도박채무의 변제로 토지의 양도계약

대법원 1995.07.14. 94다40147

도박채무의 변제를 위하여 채무자로부터 부동산의 처분을 위임받은 채권자가 그 부동산을 제3자에게 매도한 경우, 도박채무 부담행위 및 그 변제약정이 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되어 무효라 하더라도, 위와 같은 사정을 알지 못하는 제3자가 도박채무자의 대리인인 도박채권자를 통하여 위 부동산을 매수한 행위까지 무효가 된다고 할 수는 없다.

대법원 2004.05.28. 2003다70041

강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위로 볼 수 없다.

대법원 1993.5.25. 93다296

양도소득세의 회피 및 투기의 목적으로 자신 앞으로 소유권이전등기를 하지 아니하고 미등기인 채로 매매계약을 체결(명의신탁)하였다고 하여, 그것만으로 그 매매계약이 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 된다고 할 수 없다.

대법원 1967.10.06. 67다1134

혼인관계가 존속중인 사실을 알면서 남의 첩이 되어 부첩행위를 계속한 경우에는 본처의 사전승인이 있었다 하더라도 장래의 부첩관계의 사전승인이라는 것은 선량한 풍속에 위배되는 행위이므로 본처에 대하여 불법행위가 성립한다.

대법원 1980.06.24. 80다458

피고가 원고와의 부첩관계를 해소하기로 하는 마당에 그 동안 원고가 피고를 위하여 바친 노력과 비용 등의 희생을 배상 내지 위자하고 또 원고의 장래 생활대책을 마련해 준다는 뜻에서 금원을 지급하기로 약정한 것이라면 부첩관계를 해소하는 마당에 위와 같은 의미의 금전지급약정은 공서양속에 반하지 않는다고 보는 것이 타당하다.

대법원 2001.11.09. 2001다44987

매매계약체결 당시에 정당한 대가를 지급하고 목적물을 매수하는 계약을 체결하였다면, 비록 그 후 목적물이 범죄행위로 취득된 것을 알게 되었다고 하더라도, 그 목적물에 대한 소유권이전등기를 구하는 것은 민법 제103조의 공서양속에 반하는 행위라고 볼 수 없다.

☞ 법률행위가 반사회질서에 해당하는지의 여부를 어느 시기를 기준으로 하여 판단하여야 하는지에 관하여, 학설은 법률행위시설과 효력발생시설이 대립하나, 판례는 법률행위 시설에 따른다.

대법원 1994.03.11. 93다40522

- [1] 민법 제103조에 의하여 무효로 되는 반사회질서행위는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라 그 내용 자체는 반사회 질서적인 것이 아니라고 하여도 법률적으로 이를 강제하거나 법률행위에 반사회질서적인 조건 또는 금전적 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함한다.
- [2] 어떠한 사실을 알고 있는 사람과의 사이에 소송에서 사실대로 증언하여 줄 것을 조건으로 어떠한 급부를 할 것을 약정한 경우, 증인은 법률에 의하여 증언거부권이 인정되지 않는 한 진실을 진술할 의무가 있는 것이고, 이러한 당연한 의무의 이행을 조건으로 상당한 정도의 급부를 받기로 하는 약정은 증인에게 부당하게 이익을 부여하는 것이라고 할 것이고, 그러한 급부의 내용이 통상적으로 용인될 수 있는 수준(예컨대 증인에게 일당 및 여비가 지급되기는 하지만 증인이 증언을 위하여 법원에 출석함으로써 입게 되는 손해에는 미치지 못하는 경우 그러한 손해를 전보하여 주는 경우 정도)을 넘어서, 어느 당사자가 그 증언이 필요함을 기화로 증언하여 주는 대가로 용인될 수 있는 정도를 초과하는 급부를 제공받기로 한 약정은 반사회질서적인 금전적 대가가 결부된 경우로 그러한 약정은 민법 제103조 소정의 반사회질서행위에 해당하여 무효로 된다.

대법원 2015.7.23. 2015다200111 전원합의체

- [1] 형사사건에 관하여 체결된 성공보수약정이 가져오는 여러 가지 사회적 폐단과 부작용 등을 고려하면, 구속영장청구 기각, 보석 석방, 집행유예나 무죄 판결 등과 같이 의뢰인에게 유리한 결과를 얻어내기 위한 변호사의 변론활동이나 직무수행 그 자체는 정당하다 하더라도, 형사사건에서의 성공보수약정은 수사·재판의 결과를 금전적인 대가와 결부 시킴으로써, 기본적 인권의 옹호와 사회정의의 실현을 사명으로 하는 변호사 직무의 공공성을 저해하고, 의뢰인과 일반 국민의 사법제도에 대한 신뢰를 현저히 떨어뜨릴 위험이 있으므로, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있다. 다만 선량한 풍속 기타 사회질서는 부단히 변천하는 가치관념으로서 어느 법률행위가 이에 위반되어 민법 제103조에 의하여 무효인지는 법률행위가 이루어진 때를 기준으로 판단하여야 하고, 또한 그 법률행위가 유효로 인정될 경우의 부작용, 거래자유의 보장 및 규제의 필요성, 사회적 비난의 정도, 당사자 사이의 이익균형 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 사회 통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다.

- [2] 그런데 그동안 대법원은 수입한 사건의 종류나 특성에 관한 구별 없이 성공보수약정이 원칙적으로 유효하다는 입장을 취해 왔고, 대한변호사협회도 1983년에 제정한 '변호사 보수기준에 관한 규칙'에서 형사사건의 수입료를 착수금과 성공보수금으로 나누어 규정 하였으며, 위 규칙이 폐지된 후에 권고양식으로 만들어 제공한 형사사건의 수입약정서 에도 성과보수에 관한 규정을 마련하여 놓고 있었다. 이에 따라 변호사나 의뢰인은 형사 사건에서의 성공보수약정이 안고 있는 문제점 내지 그 문제점이 약정의 효력에 미칠 수 있는 영향을 제대로 인식하지 못한 것이 현실이고, 그 결과 당사자 사이에 당연히 지급 되어야 할 정상적인 보수까지도 성공보수의 방식으로 약정하는 경우가 많았던 것으로 보인다.
- [3] 이러한 사정들을 종합하여 보면, 종래 이루어진 보수약정의 경우에는 보수약정이 성공 보수라는 명목으로 되어 있다는 이유만으로 민법 제103조에 의하여 무효라고 단정하기는 어렵다. 그러나 대법원이 이 판결을 통하여 형사사건에 관한 성공보수약정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있음을 명확히 밝혔음에도 불구하고 향후 에도 성공보수약정이 체결된다면 이는 민법 제103조에 의하여 무효로 보아야 한다.

대법원 1969.08.19. 69므18

어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 각서를 써 주었다 하더라도 그와 같은 의사표시는 신분행위의 의사결정을 구속하는 것으로서 공서양속에 위배하여 무효이다.

대법원 2007.06.14. 2007다3285

양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실제로 거래한 가액을 매매대금으로 기재하지 아니하고 그보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재하였다 하여, 그것만으로 그 매매 계약이 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 볼 수 없다.

대법원 2001.2.9. 99다38613

다수의 문화재를 보유하고 있는 전통사찰의 주지직을 거액의 금품을 대가로 양도·양수하 기로 하는 약정이 있음을 알고도 이를 묵인 혹은 방조한 상태에서 한 종교법인의 주지임명 행위라고 하여, 그 임명행위 자체가 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다고는 할 수 없다.

☞ 甲이 전통사찰의 전 주지인 乙에게 주지직 사임 대가로 3억 원을 지급하기로 하고 乙을 주지직에서 사임하게 한 다음 해당 종교법인으로부터 위 사찰의 주지로 임명받은 사안에서, 대법원은 甲과 乙 사이의 위와 같은 약정은 전통사찰의 주지직을 거액의 금품을 대가로 양도·양수하기로 하는 계약으로서 그 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 행위로서

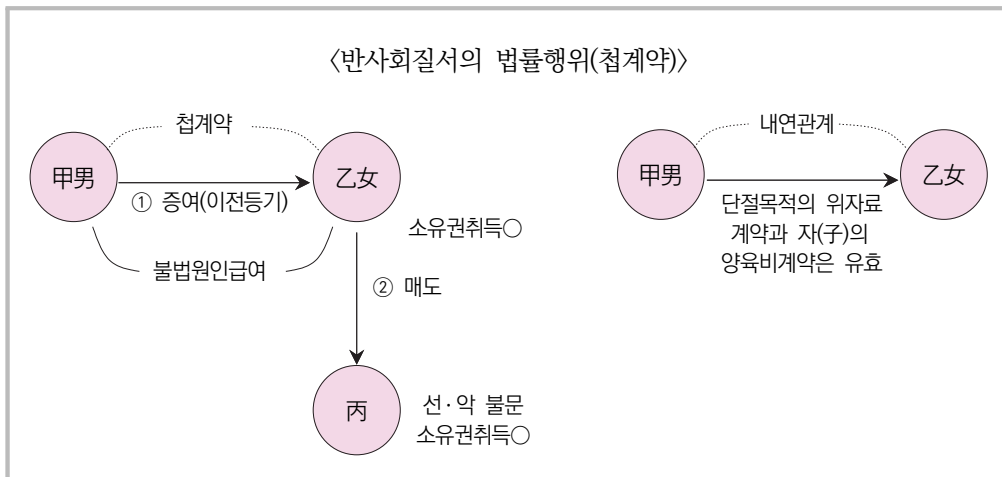
무효라고 보아야 할 것이나, 해당 종교법인이 위와 같은 약정이 있음을 알고 이를 묵인하거나 혹은 방조한 상태에서 甲을 주지로 임명하였다고 하더라도 그 임명행위 자체가 선량한 풍속 기타 사회질서에 반한다고 할 수는 없다고 판시하였다.

대법원 1982.06.22. 82다카90

해외에 파견된 근로자가 귀국일로부터 일정기간 소속회사에 근무하여야 한다는 사규나 약정은 민법 제103조 또는 제104조에 위반된다고 할 수 없다.

대법원 1995.08.11. 94다54108

- [1] 민법 제746조에서 불법의 원인으로 인하여 급여함으로써 그 반환을 청구하지 못하는 이익은 종국적인 것을 말한다.
- [2] 도박자금으로 금원을 대여함으로써 인하여 발생한 채권을 담보하기 위한 근저당권설정등기가 경료되었을 뿐인 경우와 같이 수령자가 그 이익을 향수하려면 경매신청을 하는 등 별도의 조치를 취하여야 하는 경우에는, 그 불법원인급여로 인한 이익이 종국적인 것이 아니므로 등기설정자는 무효인 근저당권설정등기의 말소를 구할 수 있다.



(2) 부동산의 이중매매

1) 이중매매의 유효성

- ① 이중매매는 계약자유의 원칙에 따라 원칙적으로 유효하다. 제2매수인이 소유권을 취득하는 경우 제1매매행위는 이행불능이 되어 제1매수인은 매도인에게 채무불이행의 책임을 물을 수 있다.

- ② 제1매수인에 대한 매도인의 불법행위가 성립될 수 있으며, 제1매수인은 매도인에 대하여 대상청구권을 행사할 수도 있다.

2) 이중매매가 무효인 경우

- ① 제2매매행위가 제103조 위반으로 무효라 하더라도 매도인 자신은 불법원인급여가 되어 제2매수인에게 반환청구를 할 수 없고 소유권에 기한 반환청구도 할 수 없다.
- ② 판례는 제1매수인은 매도인을 대위하여 제2매수인에게 등기의 말소를 청구할 수 있다고 한다(채권자대위권).
- ③ 제1매수인의 채권자취소권은 부정된다는 것이 통설과 판례의 태도이다(채권자취소권의 피보전채권은 금전채권에 한함).

중요판례

대법원 1994.03.11. 93다55289

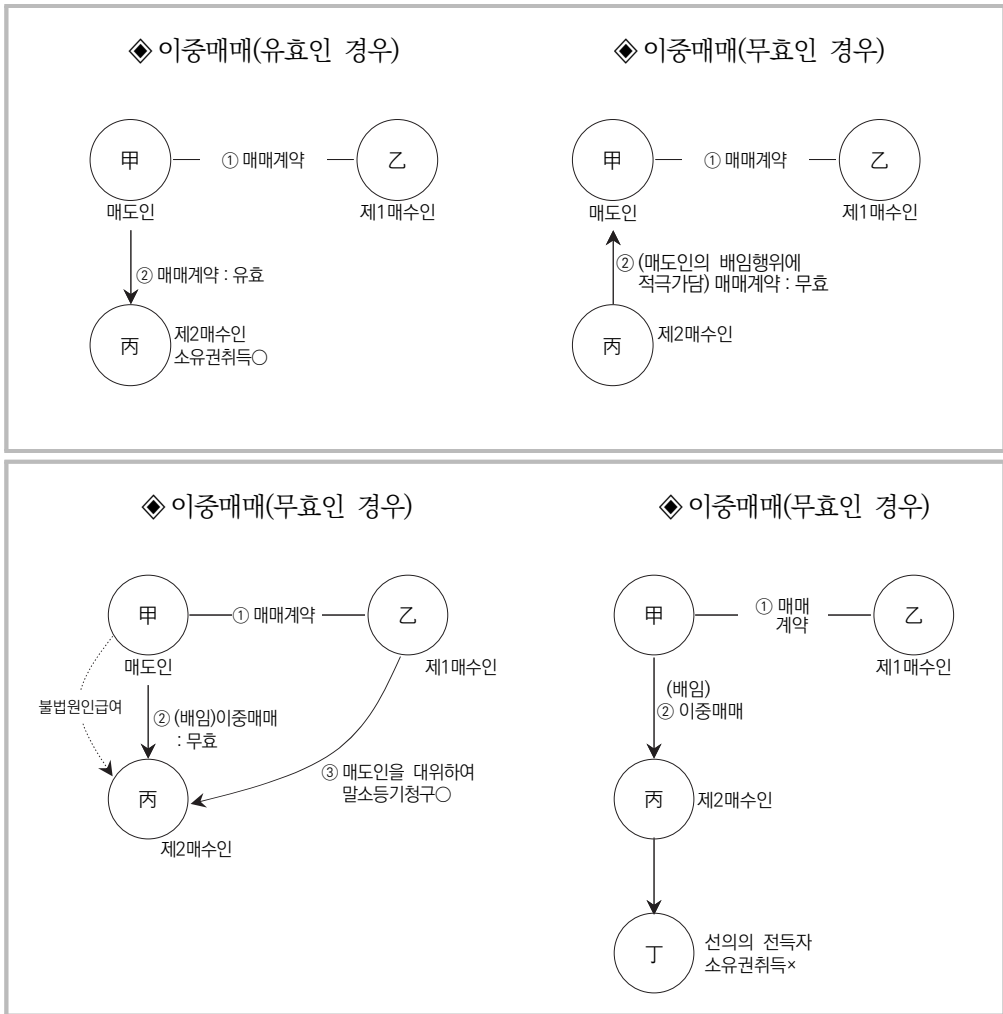
부동산의 이중매매가 반사회적 법률행위로서 무효가 되기 위하여는 매도인의 배임행위와 매수인이 매도인의 배임행위에 적극 가담한 행위로 이루어진 매매로서, 그 적극 가담하는 행위는 매수인이 다른 사람에게 매매목적물이 매도된 것을 안다는 것만으로는 부족하고, 적어도 그 매도사실을 알고도 매도를 요청하여 매매계약에 이르는 정도가 되어야 한다.

대법원 1983.04.26. 83다카57

매도인의 매수인에 대한 배임행위에 가담하여 증여를 받아 이를 원인으로 소유권이전등기를 경료한 수증자에 대하여 매수인은 매도인을 대위하여 위 등기의 말소를 청구할 수는 있으나 직접 청구할 수는 없다는 것은 형식주의 아래서의 등기청구권의 성질에 비추어 당연하다.

대법원 1996.10.25. 96다29151

부동산의 이중매매가 반사회적 법률행위에 해당하는 경우에 이중매매계약은 절대적으로 무효이므로, 당해 부동산을 제2매수인으로부터 다시 취득한 제3자는 설사 제2매수인이 당해 부동산의 소유권을 유효하게 취득한 것으로 믿었더라도 이중매매계약이 유효하다고 주장할 수 없다.



(3) 불공정한 법률행위

제104조 【불공정한 법률행위】

당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.

1) 의의

불공정한 법률행위는 상대방의 자유로운 의사결정이 곤란한 상태를 이용하여 상대방으로부터 자기의 급부에 비하여 현저하게 균형을 잃은 반대급부를 하게 하여 부당한 재산적 이익을 얻는 행위를 말한다.

2) 제103조와의 관계

다수설과 판례는 제104조는 제103조의 하나의 예시적 규정에 해당한다고 한다.

3) 요건

① 주관적 요건

- ㉠ 가해자가 피해자의 궁박·경솔 또는 무경험을 이용하였어야 한다. 궁박이란 경제적인 궁박상태 뿐만 아니라 물리적·정신적 궁박도 포함된다. 그리고 당사자의 궁박·경솔·무경험 중 어느 하나라도 갖추어지면 된다. 아울러 무경험이란 특정영역에서의 경험부족을 말하는 것이 아니라, 거래 일반의 경험부족을 뜻하는 것이라는 것이 판례이다.
- ㉡ 폭리자가 피해자에게 위와 같은 사정이 있음을 알고서 그것을 이용하려는 의사, 즉 악의를 가지고 있어야 한다는 것이 판례의 태도이다.
- ㉢ 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 객관적 요건과 주관적 요건은 그 법률행위의 무효를 주장하는 자가 이를 증명하여야 한다. 즉 급부와 반대급부가 현저히 불공정하다고 하여 궁박·경솔·무경험이 추정되는 것은 아니기 때문이다 (통설·판례).

② 객관적 요건

불균형을 판정하는 시기에 대하여 통설과 판례는 법률행위 당시를 기준으로 하여야 한다고 해석한다.

4) 효과

① 급부가 이행되지 않은 경우

폭리행위는 무효이다. 따라서 아직 이행하기 전이면 이행할 필요가 없다.

② 급부가 이미 이행된 경우

불법원인은 폭리행위자 측에만 있으므로 폭리행위의 상대방은 급부한 것의 반환을 청구할 수 있으나(제746조 단서), 폭리행위자는 반환청구권을 행사할 수 없다.

5) 폭리행위의 적용범위

① 유상·쌍무계약

폭리행위는 급부와 반대급부가 대가적 관계를 이루는 유상·쌍무계약에서 원칙적으로 문제가 된다.

② 무상행위

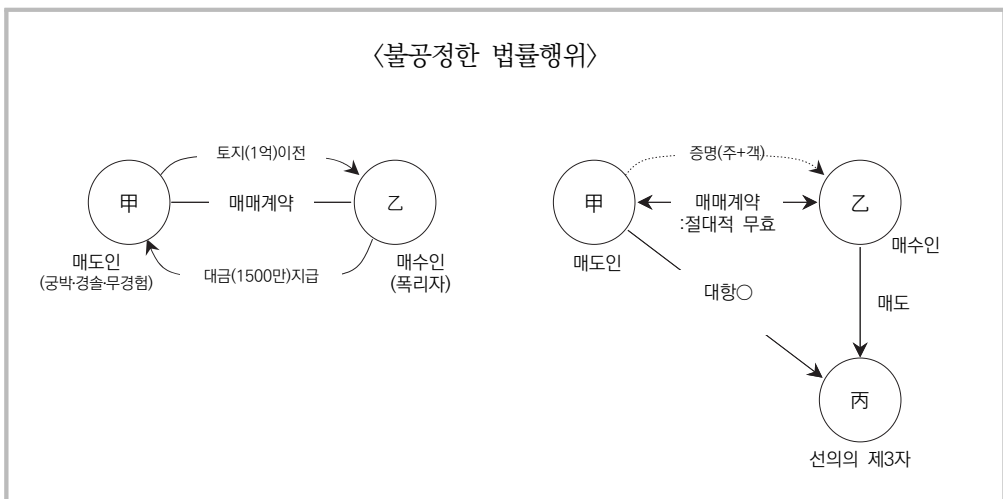
판례는 증여계약(또는 기부행위)과 같이 아무런 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니라고 한다(대판 2000.2.11, 99다다56833).

③ 단독행위

이에 관해서 불공정한 법률행위임을 인정한 판례가 있다. “남편의 징역을 면하기 위하여 부정수표를 회수하려면 물품외상대금채권에 대한 포기서를 써야 된다는 채무자의 요구에 따라, 처가 보관 중이던 남편의 인감을 이용하여 남편을 대리하여 포기서를 작성하여 준 채권포기행위는 불공정한 법률행위로 보는 것이 상당하다.”고 하였다(대판 1975.5.13., 75다92).

④ 경매

경매 등 법률행위에 의하지 않은 재산권의 이전에는 적용되지 않는다.



중요판례

대법원 1994.03.11. 93다55289

부동산의 이중매매가 반사회적 법률행위로서 무효가 되기 위하여는 매도인의 배임행위와 매수인이 매도인의 배임행위에 적극 가담한 행위로 이루어진 매매로서, 그 적극 가담하는 행위는 매수인이 다른 사람에게 매매목적물이 매도된 것을 안다는 것만으로는 부족하고, 적어도 그 매도사실을 알고도 매도를 요청하여 매매계약에 이르는 정도가 되어야 한다.

대법원 1992.02.25. 91다40351

땅 소유자가 문맹에다 농사일 외의 다른 사회경험이 없고 부동산시세가 어두운 고령인 점을 이용, 현시가 1억 원 이상 짜리의 땅을 감정가격의 30%에도 미치지 못하는 1천5백만 원에 토지매매계약을 체결했다면 그 계약은 무효이다.

대법원 1993.10.12. 93다19924

불공정한 법률행위가 성립하기 위하여는 법률행위의 당사자 일방이 궁박, 경술 또는 무경험의 상태에 있고, 상대방이 이러한 사정을 알고서 이를 이용하려는 의사가 있어야 하며, 나아가 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 있어야 하는 바, 위 당사자 일방의 궁박, 경술, 무경험은 모두 구비하여야 하는 요건이 아니고 그 중 어느 하나만 갖추어져도 충분하다.

☞ 불공정한 법률행위를 주장하는 자는 스스로 궁박, 경술, 무경험으로 인하였음을 증명하여야 하고, 그 법률행위가 현저하게 공정을 잃었다 하여 곧 그것이 경솔하게 이루어졌다고 추정하거나 궁박한 사정이 인정되는 것이 아니다(대법원 1969.07.08. 69다594). 따라서 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 주관적 요건인 궁박, 경술, 또는 무경험과 객관적 요건인 현저한 불공정은 모두 무효를 주장하는 자가 증명하여야 한다.

대법원 2011.04.28. 2010다106702

매매계약과 같은 쌍무계약이 급부와 반대급부와의 불균형으로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 ‘불공정한 법률행위’에 해당하여 무효라고 한다면, 그 계약으로 인하여 불이익을 입는 당사자로 하여금 위와 같은 불공정성을 소송 등 사법적 구제수단을 통하여 주장하지 못하도록 하는 부제소합의 역시 다른 특별한 사정이 없는 한 무효이다.

대법원 2011.04.28. 선고 2010다106702

매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 ‘불공정한 법률행위’에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다.

대법원 2013.09.26. 2010다42075

불공정 법률행위에 해당하는지는 법률행위가 이루어진 시점을 기준으로 약속된 급부와 반대급부 사이의 객관적 가치를 비교 평가하여 판단하여야 할 문제이고, 당초의 약정대로 계약이 이행되지 아니할 경우에 발생할 수 있는 문제는 달리 특별한 사정이 없는 한 채무의 불이행에 따른 효과로서 다루어지는 것이 원칙이다.

대법원 1996.06.14. 94다46374

불공정한 법률행위에 있어서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고, 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있는 바, 일반인이 수사 기관에서 법관의 영장에 의하지 않고 30시간 이상 불법구금된 상태에서 구속을 면하고자 하는 상황에 처해 있었다면 특별한 사정이 없는 한 정신적 또는 심리적 원인에 기인한 급박한 곤궁의 상태에 있었다고 본다.

대법원 2002.10.22. 2002다38927

‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, ‘무경험’이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에 있어서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 폭리자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정한 법률행위는 성립하지 않는다.

대법원 1994.06.24. 94다10900

불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다.

대법원 2003.06.27. 2002다68034

법인 아닌 어촌계가 취득한 어업권은 어촌계의 총유이고, 그 어업권의 소멸로 인한 보상금도 어촌계의 총유에 속하므로 총유물인 손실보상금의 처분은 원칙적으로 계원총회의 결의에 의하여 결정되어야 할 것이지만, 어업권의 소멸로 인한 손실보상금은 어업권의 소멸로 손실을 입은 어촌계원들에게 공평하고 적정하게 분배되어야 할 것이므로, 어업권의 소멸로 인한 손실보상금의 분배에 관한 어촌계 총회의 결의 내용이 각 계원의 어업권 행사 내용, 어업 의존도, 계원이 보유하고 있는 어업 장비나 멸실된 어업 시설 등의 제반 사정을 참작한 손실의 정도에 비추어 볼 때 현저하게 불공정한 경우에는 그 결의는 무효이다.

대법원 1993.07.16. 92다41528

불공정한 법률행위에 해당하기 위하여는 급부와 반대급부와 사이에 현저히 균형을 잃을 것이 요구되므로 증여와 같이 상대방에 의한 대가적 의미의 재산관계의 출연이 없이 당사자 일방의 급부만 있는 경우에는 급부와 반대급부 사이의 불균형의 문제는 발생하지 않는다.

대법원 1993.03.23. 92다52238

민법 제104조가 규정하는 현저히 공정을 잃은 법률행위라 함은 자기의 급부에 비하여 현저하게 균형을 잃은 반대급부를 하게 하여 부당한 재산적 이익을 얻는 행위를 의미하는 것이므로 기부행위와 같은 아무런 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니다.

대법원 2002.10.22. 2002다38927

대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 그 법률행위가 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경솔과 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하고, 궁박은 본인의 입장에서 판단하여야 한다.

(4) 동기의 불법

1) 의의

도박을 위해 금전을 대차한다든가 또는 범행 장소로 사용하기 위해 건물을 임차하는 경우와 같이 법률행위 자체는 사회질서에 위배되지 않으나 당사자가 그 의사표시를 하게 된 동기에 반사회성이 있는 경우를 말한다. 이 때 이와 같은 소비대차, 매매, 임대차계약의 효력 상의 문제가 나타난다.

2) 효력에 관한 학설과 판례

- ① 표시설(다수설) : 동기는 표시된 때에 한하여 법률행위의 내용을 이루므로 동기가 공서양속에 반하더라도 표시된 경우에 한하여 그 법률행위는 무효로 된다고 하는 견해이다.
- ② 판례의 태도 : “민법 제103조에 의하여 무효로 되는 반사회질서행위는 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함한다(대법원 1984.12.11. 84다1402).”라고 하여 다수설과 같은 입장이다.

5. 목적의 확정

- ① 법률행위의 내용은 확정되어 있거나 확정할 수 있는 것이어야 한다. 따라서 늦어도 이행기까지는 확정되어야 한다.
- ② 확정할 수 없는 경우에는 그 법률행위는 무효이다.

③ 내용의 확정성은 법률행위의 해석의 문제와 직결된다.

중요판례

대법원 1997.01.24. 96다 26176

매매계약에 있어서 그 목적물과 대금을 반드시 계약체결 당시에 구체적으로 특정될 필요는 없고 이를 사후에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있으면 족하다. 그 목적물의 표시가 너무 추상적이어서 매매계약 이후에 이를 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있다고 볼 수 없다면 매매계약이 성립되었다고 볼 수 없다.

6. 법률행위의 해석

(1) 법률행위해석의 의의

법률행위의 해석이란 법률행위의 내용을 명확히 하는 것을 말한다. 그런데 법률행위는 의사표시를 불가결의 구성요소로 하기 때문에 법률행위의 해석이란 의사표시의 해석이라고도 한다.

(2) 법률행위해석의 표준

제106조 【사실인 관습】

법령중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다.

이는 명확하지 못한 법률행위에서의 해석의 순서라 할 수 있다. 즉 ① 당사자가 기도한 목적, ② 사실인 관습, ③ 임의법규, ④ 신의성실의 원칙(조리)에 따라 합리적으로 해석한다는 것이다.

(3) 법률행위의 해석방법

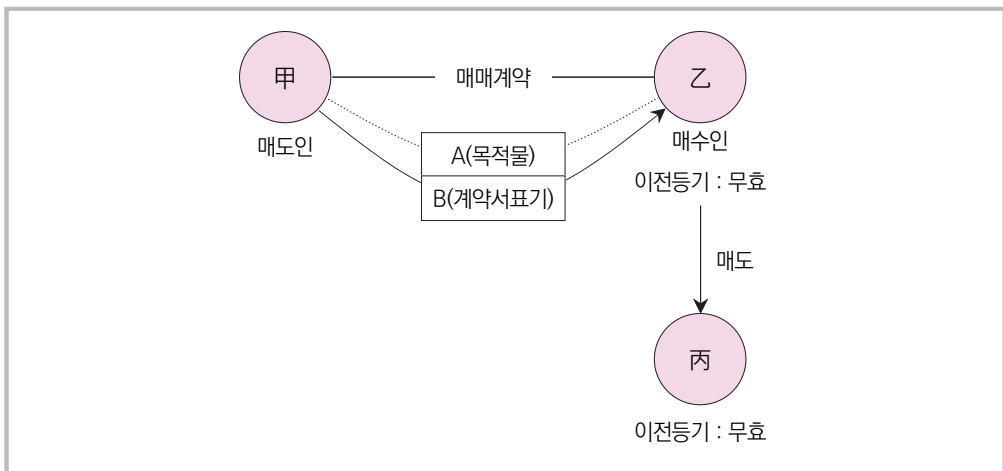
1) 자연적 해석

표현의 문자적 의미에 구속되지 않고 표의자의 실제의 의사를 중시하여 해석하는 표의자 중심의 해석방법이다. 일명 ‘오표시무해의 원칙(誤表示無害의 原則)’이라고 한다.

중요판례

대법원 1996.08.20. 96다19581

부동산의 매매계약에 있어 쌍방 당사자가 모두 특정의 A토지를 계약의 목적물로 삼았으나 그 목적물의 지번 등에 관하여 착오를 일으켜 계약을 체결함에 있어서는 계약서상 그 목적물을 A토지와는 별개인 B토지로 표시하였다 하여도, A토지에 관하여 이를 매매의 목적물로 한다는 쌍방 당사자의 의사합치가 있는 이상 그 매매계약은 A토지에 관하여 성립한 것으로 보아야 하고 B토지에 관하여 매매계약이 체결된 것으로 보아서는 안 될 것이며, 만일 B토지에 관하여 그 매매계약을 원인으로 하여 매수인 명의로 소유권이전등기가 경료되었다면 이는 원인 없이 경료된 것으로서 무효이다.



- ① 상기의 판례에서는 양 당사자의 의사는 합치되므로 제109조의 착오문제는 발생하지 않는다.
- ② A, B 토지 모두 물권변동(소유권이전)은 발생하지 않으므로 소유권은 甲에게 있다.
- ③ 乙은 甲에 대하여 A토지에 대한 소유권이전등기청구권을 행사할 수 있으며, 甲은 乙에 대하여 B토지에 대한 원인무효를 이유로 한 말소등기청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 丙은 무효인 등기를 기초로 소유권을 취득한 자이므로 비록 선의이더라도 소유권을 취득하지 못한다.

2) 규범적 해석

상대방의 시각에서 표시행위에 따라 법률행위의 내용을 확정하는 것으로 상대방 중심의 해석방법이다. 규범적 해석에 따른 판례는 다음과 같다.

3) 보충적 해석

법률행위 특히 주로 계약에서 당사자가 정하지 않은 사항에 관하여 분쟁이 생기는 수가 흔히 있다. 이러한 분쟁은 보통 임의규정을 보충적으로 적용하여 해결되지만, 경우에 따라서는 임의규정이 없는 수가 있다. 그러한 경우에는 당사자가 법률행위의 흠결을 알았다면 정하였을 내용인 당사자의 가정적 의사(假定的 意思)를 통해 보충하는 해석방법이다. 이 보충은 법원이 한다.

4) 계약당사자의 확정

중요판례

대법원 2005.02.24. 2005다56186

법률행위의 해석은 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 사용된 문언에만 구애받는 것은 아니지만, 어디까지나 당사자의 내심의 의사가 어떠한지에 관계없이 그 문언의 내용에 의하여 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 합리적으로 해석하여야 하는 것이고, 당사자가 표시한 문언에 의하여 그 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 그 문언의 형식과 내용 그 법률행위가 이루어진 동기 및 경위, 당사자가 그 법률행위에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고려하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 한다.

대법원 1969.07.08. 69다563

채권자 A가 채무자 B로부터 36만 원을 수령하면서 실제로는 더 받을 금전이 있는데도 36만 원이라도 우선 받기 위해 영수증에 “충 완결”이라고 써 준 사안에서, 그것으로 모든 결제가 끝난 것으로 해석하는 것이 영수증 작성자의 의사에 부합한다.

대법원 1979.05.22. 79다508

음식점 경영을 위하여 임대차계약을 체결하면서 종업원이나 고객의 부주의로 인한 경우는 물론 그 밖의 모든 경우의 화재에 대하여도 임차인이 그 손해를 부담하기로 특약을 맺은 사안에서, “모든 경우의 화재”에는 불가항력의 경우도 포함하는 뜻으로 해석함이 상당하다.

대법원 1996.10.25. 96다16049

어떠한 의무를 부담하는 것과 관련하여 “협조를 최대한 한다”라고 기재한 경우, 당사자가 그 문구를 기재한 객관적인 의미는 그러한 의무를 법적으로 부담할 수는 없지만 사정이 허락하는 한 그 이행을 사실상 하겠다는 취지로 해석함이 상당하다.

대법원 2008.03.13, 2007다76603

실제 매매계약을 체결한 행위자가 자신의 이름은 특정하여 기재하되 불특정인을 추가하는 방식으로 매매계약서상의 매수인을 표시한 경우(즉, 실제 계약체결자의 이름에 '외 ○인'을 부가하는 형태), '외 ○인'에 해당하는 매수인 명의를 특정하여 고지한 바가 없다면, 그러한 계약의 매수인 지위는 실제 계약을 체결한 행위자에게만 인정된다.

대법원 2001.05.29, 2000다3897

계약을 체결하는 행위자가 타인의 이름으로 계약을 한 경우에 행위자 또는 명의인 가운데 누구를 계약의 당사자로 볼 것인가에 관하여는, 우선 행위자와 상대방의 의사가 일치한 경우에는 그 일치한 의사대로 확정해야 하고, 의사가 일치하지 않는 경우에는 상대방이 합리적인 사람이라면 행위자와 명의자 중 누구를 계약 당사자로 이해할 것인가에 의하여 당사자를 결정하여야 한다.

☞ 말하자면 甲의 사업자등록명의를 빌려 乙이 甲의 이름으로 丙과 계약을 체결한 경우, 丙이 甲을 당사자로 알고 있었고, 乙 또한 경제적 효과는 자신에게 귀속시킬지라도 법률상의 효과는 甲에게 귀속시키려는 의사를 가지고 있었다면, 이 계약의 당사자는 甲과 丙이다.

대법원 2009.03.19, 2008다45828

예금의 실질적 출연자와 예금명의자가 다른 경우에는 예금명의자를 예금의 당사자로 본다.

☞ 예컨대 甲이 배우자인 乙을 대리하여 丙은행과 乙의 실명확인절차를 거쳐서 乙명의의 예금계약을 체결한 경우, 丙은행이 예금의 실질적 출연자가 甲이라는 사실을 알고 있었다 하더라도 원칙적으로 예금계약의 당사자는 乙이다.

1. 의의

일정한 법률효과를 바라는 의사의 표시로서 법률행위의 불가결한 요소가 되는 법률 사실을 말한다.

2. 의사와 표시의 불일치

(1) 의사와 표시와의 불일치

의사표시는 의사와 표시가 일치할 때에 비로소 의사표시대로 효과가 발생한다. 그런데 때로는 표의자의 내심의 진정한 의사와 표시가 불일치하는 경우가 있다. 다시 말하면, 표의자의 내심의 의사(내심의 효과의사)가 표시행위로부터 추단되는 의사(표시상의 효과의사)와 일치하지 않는 경우가 있다. 이와 같이 표의자의 내심의 의사와 표시와의 불일치, 즉 내심의 효과의사와 표시상의 효과의사와의 불일치를 ‘의사와 표시와의 불일치’ 또는 ‘의사의 흠결’이라고 한다.

(2) 비진의 의사표시(심리유보, 단독허위표시)

제107조 【진의 아닌 의사표시】

- ① 의사표시는 표의자가 진의아님을 알고한 것이라도 그 효력이 있다. 그러나 상대방이 표의자의 진의아님을 알았거나 이를 알 수 있었을 경우에는 무효로 한다.
- ② 전항의 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

1) 의의

표의자가 내심의 의사와 표시가 일치하지 않는다는 것을 알면서 하는 의사표시를 말한다. 진의아닌 의사표시, 심리유보라고도 한다.

2) 요건

- ① 사법상의 의사표시가 존재하여야 한다. 따라서 공법상의 의사표시에는 제107조의 적용이 없다.

- ② 진의와 표시가 불일치하여야 한다.
- ③ 진의와 표시의 불일치를 표의자가 인식하고 있어야 한다.

3) 효과

① 원칙

표시주의이론에 따라 의사표시는 표시된 대로 효력이 발생한다(제107조 제1항 본문). 즉 상대방이 선의이며 무과실인 경우에는 유효하다.

② 상대방에 대한 효력

- ㉠ 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나(악의) 알 수 있었을 경우(과실)에는 그 의사표시는 무효로 한다(제107조 제1항 단서).
- ㉡ 상대방의 악의 또는 과실유무에 대한 주장·증명책임은 무효를 주장하는 자에게 있다(통설·판례).

③ 제3자에 대한 효력

- ㉠ “선의의 제3자에게는 대항하지 못한다.”(제107조 제2항). 이는 거래의 안전 보호를 위한 취지이다.
- ㉡ ‘제3자’란 당사자와 포괄승계인 이외의 자 중에서 진의 아닌 의사표시에 의하여 새로운 법률관계를 맺은 자를 의미한다.

중요판례

대법원 1992.02.18. 92다21036

근로자들이 일괄적으로 사직원을 제출할 때 근로계약관계를 종료시키고자 하는 내심의 의사가 없었고, 사용자 또한 이러한 사정을 알고서 사직원을 수리하였다면 위 근로자들의 사직의사표시는 무효이다.

대법원 1980.10.14. 79다2168

물의를 일으킨 사립대학교 조교수가 사직원이 수리되지 않을 것이라고 믿고 사태수습을 위하여 형식상 이사장 앞으로 사직원을 제출하였던 바, 의외로 이사회에서 “본인의 의사이니 하는 수 없다.”고 하여 사직원이 수리된 경우, 위 조교수의 사직원이 설사 진의에 이르지 아니한 비진의의사표시라 하더라도 학교법인이나 그 이사회에서 그러한 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아니라면 그 의사표시에 따라 효력을 발생한다.

대법원 1980.07.08. 80다639

학교법인이 사립학교법상의 제한규정 때문에 그 학교의 교직원들의 명의를 빌려 A로부터 금원을 차용한 경우에, A 역시 그러한 사정을 알고 있었다고 하더라도, 위 교직원들의 의사는

위 금전의 대차에 관하여 그들이 주채무자로서 채무를 부담하겠다는 뜻이라고 해석함이 상당하므로 이를 진의 아닌 의사표시라고 볼 수 없다.

대법원 1996.09.01. 96다18182

비진의의사표시에 해당하여 그 표시행위에 나타난 대로의 법률효과가 발생하지 않기 위해서는 적어도 그 표시행위에 대응하는 내심의 효과의사가 없어야 하는데, 법률상 또는 사실상 장애로 자기명의로 대출받을 수 없는 자를 위하여 대출금채무자로서의 명의를 빌려준 자에게 그와 같은 채무부담의 의사가 없는 것이라고 볼 수 없다.

대법원 2015.08.27. 2015다211630

진의 아닌 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음속에서 바라지는 아니하였다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것이 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 이를 내심의 효과의사가 결여된 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다.

대법원 1993.07.16. 92다41528

비진의의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로, 비록 재산을 강제로 뺏긴다는 것이 표의자의 본심으로 잠재되어 있었다 하여도 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 비진의의사표시라고 할 수 없다.

☞ 따라서 의사의 흠결이 아니므로 비진의의사표시에 해당하지 않으며, 증여는 무상행위이므로 제104조의 불공정한 법률행위에도 적용되지 않는다. 민법 제110조의 강박에 의한 의사표시로서 그 법률행위를 취소할 수 있다.

(3) 통정허위표시

제108조 【통정한 허위의 의사표시】

- ① 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효로 한다.
- ② 전항의 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

1) 의의

허위표시란 상대방과 통정함으로써 하는 진의 아닌 허위의 의사표시를 말하며, ‘통정 허위표시’ 또는 ‘가장행위’, ‘통모’라고도 한다.

2) 요건

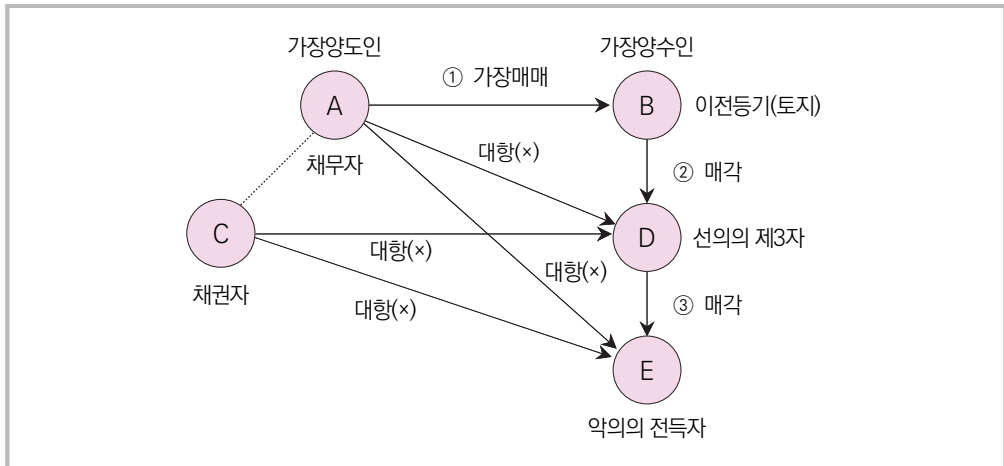
- ① 의사표시가 존재하여야 한다.
- ② 표시와 진의가 불일치하여야 한다.
- ③ 표의자가 불일치를 인식하고 있어야 한다.
- ④ 상대방과의 사이에 통정이 있어야 한다.

3) 효과

- ① 당사자 사이에는 언제나 무효이다(제108조 제1항).
- ② 불법원인급여(제746조)의 적용은 없다. 왜냐하면 허위표시 자체가 사회적 타당성에 반하는 것은 아니기 때문이다.
- ③ 가장양도인의 채권자는 채권자취소권의 요건을 구비한 때에는 채권자취소권(제406조)을 행사할 수 있다.

4) 제3자에 대한 효력

- ① 허위표시의 무효를 가지고 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제108조 제2항). 선의에 대한 과실유무는 불문한다.
- ② 선의의 제3자에게 대항하지 못한 결과, 가장양도인에게 손해가 있을 때에는 가장양도인은 가장양수인에 대하여 불법행위를 이유로 한 손해배상청구권 또는 부당이익반환청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 선의의 제3자로부터 악의의 전득자에게 양도되었을 때에도 대항하지 못한다.
- ④ 선의의 제3자가 당사자에게 무효를 주장하는 것은 무방하다.
- ⑤ 증명책임은 제3자가 악의라는 사실(무효)을 주장하는 자에게 있다.
- ⑥ 허위표시는 당사자 간에는 철회할 수 있으나 선의의 제3자에게는 대항할 수 없다.
- ⑦ 제3자라 함은 통정허위표시를 기초로 하여 새로운 법률상의 이해관계를 맺은 자를 말한다.



☑ 통정허위표시에 있어서의 제3자에 해당하는 자

- ㉠ 가장매매의 매수인으로부터 가등기를 취득한 자, 저당권을 설정 받은 자, 목적물의 임대차 계약을 체결한 자
- ㉡ 가장저당권설정행위에 기한 저당권의 실행으로 경락 받은 자
- ㉢ 가장매매에 기한 대금채권의 양수인
- ㉣ 가장소비대차에 기한 채권의 양수인
- ㉤ 허위표시에 의한 채권을 가압류한 자
- ㉥ 가장매매의 매수인에 대한 압류채권자
- ㉦ 가장전세권설정에 기한 전세권저당권자
- ㉧ 파산자와는 독립한 지위에서 파산채권자 전체의 공동의 이익을 위하여 직무를 행하게 된 파산관재인

☑ 통정허위표시에 있어서의 제3자에 해당하지 않는 자

- ㉠ 가장매매에 기한 손해배상청구권의 양수인
- ㉡ 채권의 가장양도에 있어서의 채무자
- ㉢ 주식이 가장양도된 경우의 그 회사
- ㉣ 가장매매의 매수인으로부터 그 지위를 상속받은 자
- ㉤ 저당권을 가장포기한 경우의 후순위저당권자
- ㉥ 제3자를 위한 계약에서의 제3자(수익자)
- ㉦ 채권의 가장 양수인으로부터 '추심'을 위하여 채권을 양수한 자

☑ 허위표시와 구별하여야 할 행위

㉠ 은닉행위

증여를 하면서 증여세를 탈세하기 위하여 매매로 가장하여 소유권이전등기를 하는 것과 같이 허위표시(가장행위) 뒤에 감추어진 행위를 은닉행위라 한다. 은닉행위라는 것만으로 당연히 무효라고 할 수 없다. 즉, 감추어진 행위가 그에 요구되는 요건을 갖추고 있느냐 아니냐에 따라서 그 효력이 정하여진다. 판례는 증여를 하면서 매매계약서를 작성한 경우에 당사자의 진정한 의사가 증여라 하면 매매계약서는 증여계약서로 볼 수 있다고 한다(대판 1991.9.10. 91다6160). 그러나 명의신탁의 등기원인을 매매로 가장한 경우에는 매매도 무효이며, 명의신탁 약정의 은닉행위 또한 무효이다.

㉡ 신탁행위

신탁행위는 어떤 경제적인 목적을 달성하기 위하여 당사자의 일방이 상대방에게 그 목적 달성에 필요한 정도를 넘는 권리를 이전하면서, 경제상의 목적을 넘어서 권리를 행사하지 않는다는 의무를 부여하는 법률행위를 민법학상의 신탁행위라 한다. 법률적 형식과 경제적 목적이 일치하지 않으므로 허위표시와 비슷하지만 권리를 이전하려는 진의가 있기 때문에 허위표시가 아니다. 예컨대, 양도담보, 추심을 위한 채권양도 등이 이에 해당한다.

중요판례

대법원 2004.05.28. 2003다70041

강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 민법 제 103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로 볼 수 없다.

대법원 1987.02.24. 86다215

매수인이 매수 당시 불과 400만 원의 전셋집에 살면서 세금도 못 낼 만큼 가세가 어려웠던 터에 그가 출처불명의 현금 2,400만 원을 가지고 있다가 친구로부터 빌린 2,000만 원(역시 출처불명)을 합쳐 매매대금 중 4,400만 원을 지급하였다는 것이 납득되지 않는 점 및 매도 인도 그가 받았다는 대금의 보관 상태나 사용처를 대지 못하는 점 등에 비추어 이는 가장 매매라고 본다.

대법원 1998.02.27. 97다50985

채무자의 법률행위가 통정허위표시인 경우에도 채권자취소권의 대상이 되고, 한편 채권자 취소권의 대상으로 된 채무자의 법률행위라도 통정허위표시의 요건을 갖춘 경우에는 무효이다.

대법원 1983.01.18. 82다594

통정허위표시의 무효를 가지고 대항할 수 없는 제3자란 허위표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서, 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 토대로 새로운 법률원인으로써 이해관계를 갖게 된 자를 말한다.

대법원 1996.04.26. 94다12074

상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효이고 누구든지 그 무효를 주장할 수 있는 것이 원칙이나, 허위표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 토대로 실질적으로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 선의의 제3자에 대하여는 허위표시의 당사자 뿐만 아니라 그 누구도 허위표시의 무효를 대항하지 못하고, 따라서 선의의 제3자에 대한 관계에 있어서는 허위표시도 표시된 대로 효력이 있다.

대법원 2006.03.10. 2002다1321

[1] 민법 제108조 제1항에서 상대방과 통정한 허위의 의사표시를 무효로 규정하고, 제2항에서 그 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다고 규정하고 있는데, 여기에서 제3자는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정할 것이므로, 제3자가 악의라는 사실에 관한 주장·증명책임은 그 허위표시의 무효를 주장하는 자에게 있다.

[2] 민법 제108조 제2항에 규정된 통정허위표시에 있어서의 제3자는 그 선의 여부가 문제이지 이에 관한 과실 유무는 따지지 않는다.

☞ 보호되는 제3자는 선의이기만 하면 되고, 무과실까지는 요하지 않는다.

대법원 1978.04.25. 78다226

특별한 사정 없이 동거하는 부부간에 토지를 매도하고 소유권이전등기까지 경료함은 이례에 속하는 일로서 가장매매라고 추정된다.

대법원 2000.07.06. 99다51258

허위표시를 선의의 제3자에게 대항하지 못하게 한 취지는 이를 기초로 하여 별개의 법률원인에 의하여 고유한 법률상의 이익을 갖는 법률관계에 들어간 자를 보호하기 위한 것이므로 제3자의 범위는 권리관계에 기초하여 형식적으로만 파악할 것이 아니라 허위표시행위를 기초로 하여 새로운 법률상 이해관계를 맺었는지 여부에 따라 실질적으로 파악하여야 한다.

(3) 착오로 인한 의사표시

제109조 【착오로 인한 의사표시】

- ① 의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.
- ② 전항의 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

1) 의의

표시와 내심의 효과의사가 일치하지 않는 경우로서 그 불일치를 표의자 자신이 알지 못하는 것을 말한다.

2) 착오의 유형

① 표시상의 착오

표시행위 자체를 잘못하여 의사와 표시가 불일치한 경우를 말한다(매매계약서에 69만 원이라고 기재하려 했으나 오키하여 96만 원으로 기재한 경우).

② 내용상의 착오

표시행위 자체에는 착오가 없으나 표시행위가 가지는 법적 의미(내용)에 관하여 착오가 있는 것을 말한다(평과 ㎡를 같은 단위로 생각하고 100평이라고 기재할 것을 100㎡로 기재한 경우).

③ 표시기간의 착오

표시기관이라는 매개자가 잘못 표시한 경우로 매개자에 의하여 전달된 내용이 표시행위가 되므로 본인의 착오와 동일하게 다룬다.

④ 전달기관의 착오

착오의 문제로 다루지 않으며 의사표시의 불도달의 문제로 다룬다(제111조).

⑤ 동기의 착오

의사표시를 하게 된 동기(연유)에 착오가 있는 경우를 말하며, 동기의 착오가 취소의 대상이 되는 착오인가에 대하여 다수설과 판례는 원칙적으로 제109조를 적용하지 않지만 표의자 본인의 보호와 거래안전의 조화를 위하여, 동기의 착오는 ㉠ 동기가 표시된 경우 ㉡ 표시되지 않아도 상대방으로부터 제공되었거나 유발된 경우에 한하여 제109조를 적용하여 취소할 수 있다고 한다.

3) 효과

① 원칙

법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다(제109조 제1항). 중요부분에 관한 것(착오사실과 착오가 의사표시에 결정적 영향을 미쳤다는 사실)이라는 점에 대하여는 표의자가 증명책임을 부담한다.

② 예외

- ㉠ 표의자에게 중대한 과실이 있는 경우에는 취소하지 못한다(제109조 제1항 단서).
- ㉡ 중대한 과실이란 표의자의 직업·행위의 종류·목적 등에 따라서 보통 기울여야 할 주의를 현저하게 결여한 것을 말한다.
- ㉢ 표의자에게 중대한 과실이 있다 하더라도 상대방이 표의자의 착오를 악용하는 경우에는 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있는 것으로 본다.
- ㉣ 중대한 과실이 있다는 점에 대한 증명책임을 표의자의 상대방이 부담한다.

③ 임의규정성

착오에 관한 제109조 제1항의 규정은 임의규정으로서 그 적용을 배제하는 약정은 유효이다.

(4) 제3자에 대한 관계

착오로 인한 의사표시는 그 취소로써 선의의 제3자에게 대항하지 못한다(제109조 제1항).

(5) 표의자의 손해배상

표의자가 과실(경과실)로 착오에 빠져 의사표시를 하였으나 그 과실 있는 표의자가 착오를 이유로 취소한 경우, 취소로 인한 상대방의 손해를 표의자가 부담하는가에 대하여 민법에는 규정이 없다. 이에 대하여 착오를 이유로 취소하는 경우에는 제535조의 '계약체결상의 과실책임'을 유추적용하여 표의자의 상대방에 대한 신뢰이익의 배상책임을 인정한다는 것이 다수설이나, 판례는 부정한다(1997.8.22. 97다13023).

(6) 적용범위

- ① 제109조는 원칙적으로 모든 재산상의 의사표시에 적용된다.

- ② 신분법상의 행위에는 적용되지 않는다.
- ③ 주식의 인수(상법 제320조 제1항) 등과 같은 단체법적 행위에는 그 적용이 없다.
- ④ 화해계약(제731조 이하)은 그 계약의 특수성으로 인하여 착오가 있더라도 취소는 허용되지 않는다(제733조). 그러나 화해당사자의 자격에 착오가 있거나 화해의 목적인 분쟁 이외의 사항에 착오가 있는 경우에는 제109조의 적용이 있다(제733조 단서).
- ⑤ 공법상의 행위·소송행위에 대하여는 제109조가 적용되지 않는다.

✓ 착오와 다른 제도와와의 경합

㉠ 착오와 사기

착오가 타인의 기망행위에 기하여 발생한 때에는 착오와 사기가 경합된다. 이 경우 그 요건을 증명하여 선택적으로 사기 또는 착오를 주장할 수 있다(다수설·판례)

㉡ 착오와 하자담보책임

㉠ 매매계약의 당사자가 매매목적물에 하자가 있는 것을 모르고 매매계약을 체결한 경우에는 착오에 의한 취소와 제570조 이하의 담보책임이 문제되는데, 양자의 관계에 대해서 견해의 대립이 있다.

㉡ 다수설은 제570조 이하의 규정은 착오에 대한 특별규정이므로 매도인의 담보책임이 성립하는 범위에서 제109조는 적용되지 않는다는 입장이다.

㉢ 판례는 양자를 선택적으로 행사할 수 있다고 한다(대판 1973.10.23. 73다268).

중요판례

대법원 1997.04.11. 96다31109

매수인이 토지에 대한 전용허가를 받기 위하여는 사업계획의 승인을 받는 등의 복잡한 절차를 거쳐야 한다는 사실을 모르고 곧바로 벽돌공장을 지을 수 있는 것으로 잘못 알고 있었다고 하여도, 그러한 착오는 동기의 착오에 지나지 않으므로 당사자 사이에 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼았을 때 한하여 의사표시의 내용의 착오가 되어 취소할 수 있다.

☞ 동기의 착오는 원칙적으로 중요부분의 착오에 해당하지 않으나, 동기가 표시되어 상대방이 알고 있는 경우에는 의사표시의 내용이 되므로 착오를 이유로 취소할 수 있다는 것이 다수설과 판례의 태도이다.

대법원 1995.11.21. 95다5516

동기의 착오를 이유로 법률행위를 취소할 수 있게 되는 요건으로서의 중요부분의 착오는, 표의자가 그 동기를 당해 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하고 의사표시의

해석상 법률행위의 내용으로 되어 있다고 인정되면 충분하고, 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의까지 이루어질 필요는 없다.

대법원 1978.07.11. 78다719

귀속해제된 토지인데도 귀속재산인줄로 잘못 알고 국가에 증여를 한 경우 이러한 착오는 일종의 동기의 착오라 할 것이나 그 동기를 제공한 것이 관계 공무원이었고 그러한 동기의 제공이 없었더라면 위 토지를 선뜻 국가에게 증여하지는 않았을 것이라면 그 동기는 증여 행위의 중요부분을 이룬다고 할 것이므로 뒤늦게 그 착오를 알아차리고 증여계약을 취소했다면 그 취소는 적법하다.

☞ 상대방에 의해 유발된 동기의 착오는 동기가 표시되지 않은 경우에도 중요부분의 착오로 취소할 수 있다는 것이 판례의 태도이다.

대법원 1992.10.23. 92다29337

부동산 매매에 있어서 시가에 관한 착오는 부동산을 매매하려는 의사를 결정함에 있어 동기의 착오에 불과할 뿐 법률행위의 중요부분에 관한 착오라고 할 수 없다.

대법원 1997.09.30. 97다26210

착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못하는 바, 여기서 '중대한 과실'이란 함은 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 결여하는 것을 의미한다.

대법원 2020.3.26. 2019다288232

[1] 의사표시는 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 법률행위 중요부분의 착오란 표의자가 그러한 착오가 없었더라면 그 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 하고 보통 일반인도 표의자의 처지에 있었더라면 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 한다. 가령 토지의 현황과 경계에 착오가 있어 계약을 체결하기 전에 이를 알았다면 계약의 목적을 달성할 수 없음이 명백하여 계약을 체결하지 않았을 것으로 평가할 수 있을 경우에 계약의 중요부분에 관한 착오가 인정된다.

[2] 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 그 의사표시를 취소할 수 있으나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다. 여기서 '중대한 과실'이란 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 게을리한 것을 의미한다. 토지매매에서 특별한 사정이 없는 한 매수인에게 측량을 하거나 지적도와 대조하는 등의 방법으로 매매목적물이 지적도상의 그것과 정확히 일치하는지 여부를 미리 확인하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다.

대법원 1989.07.25. 88다카9364

- [1] 민법 제219조 제1항 소정의 주위토지통행권은 주위토지소유자에게 가장 손해가 적은 범위내에서 허용되는 것이지만 적어도 통행권자가 그 소유토지 및 지상주택에서 일상 생활을 영위하기 위하여 출입을 하고 물건을 운반하기에 필요한 범위는 허용되어야 하며, 어느 정도를 필요한 범위로 볼 것인가는 통행권자의 소유토지와 주위토지의 각 지리적 상황 및 이용관계 등 제반사정을 참작하여 정하여야 한다.
- [2] 주위토지통행권자가 인접대지위의 담장이 그 대지의 경계선과 일치하는 것으로 잘못 알고 이 담장을 기준으로 통로 폭을 정하여 주위토지소유자의 담장설치에 합의하였다면 이러한 합의는 토지의 현황·경계에 관한 착오에 기인한 것으로서 그 착오는 법률행위의 중요부분에 관한 착오라고 볼 수 있다.

대법원 1981.11.10. 80다2475

법률에 관한 착오(양도소득세가 부과될 것인데도 부과되지 아니하는 것으로 오인)라도 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 관한 것인 때에는 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있고, 또 매도인에 대한 양도소득세의 부과를 회피할 목적으로 매수인이 주택건설을 목적으로 하는 주식회사를 설립하여 여기에 출자하는 형식을 취하면 양도소득세가 부과되지 않을 것이라고 말하면서 그러한 형식에 의한 매매를 제의하여 매도인이 이를 믿고 매매계약을 체결한 것이라 하더라도 그것이 곧 사회질서에 반하는 것이라고 단정할 수 없으므로 이러한 경우에 역시 의사표시의 착오의 이론을 적용할 수 있다.

대법원 1995.12.22. 95다37087

甲이 채무자란이 백지로 된 근저당권설정계약서를 제시받고 그 채무자가 乙인 것으로 알고 근저당설정자로 서명날인을 하였는데 그 후 채무자가 丙으로 되어 근저당권설정등기가 경료된 경우, 甲은 그 소유의 부동산에 관하여 근저당권설정계약상의 채무자를 丙이 아닌 乙로 오인한 나머지 근저당설정의 의사표시를 한 것이고, 이와 같은 채무자의 동일성에 관한 착오는 법률행위내용의 중요부분에 관한 착오에 해당한다.

대법원 1984.04.23. 84다카890

법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는가의 여부는 각 행위에 관하여 주관적·객관적 표준에 좇아 구체적 사정에 따라 가려져야 할 것이고 추상적·일률적으로 이를 정할 수 없다.

대법원 2006.12.07. 2006다41457

착오로 인하여 표의자가 무슨 경제적인 불이익을 입은 것이 아니라면 이를 법률행위 내용의 중요 부분의 착오라고 할 수 없다.

대법원 2000.05.12. 2000다12259

매매대상 토지 중 20~30평 가량만 도로에 편입될 것이라는 중개인의 말을 믿고 주택신축을 위하여 토지를 매수하였고 그와 같은 사정이 계약체결과정에서 현출되어 매도인도 이를 알고 있었는데 실제로는 전체면적의 약 30%에 해당하는 197평이 도로에 편입된 경우, 동기의 착오를 이유로 매매계약의 취소를 인정할 수 있으며, 매매대상 토지 중 도로편입 부분에 대한 매수인의 착오가 중대한 과실에 기인한 것이라고 볼 수 없다.

대법원 1993.06.29. 92다38881

- [1] 민법 제109조 제1항 단서에서 규정하고 있는 “중대한 과실”이라 함은 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저하게 결여한 것을 말한다.
- [2] 공장을 경영하는 자가 공장이 협소하여 새로운 공장을 설립할 목적으로 토지를 매수함에 있어 토지상에 공장을 건축할 수 있는지 여부를 관할관청에 알아보지 아니한 과실은 “중대한 과실”에 해당한다.

☞ 착오가 표의자의 중대한 과실에 기인한 경우에는 취소하지 못한다.

대법원 1991.08.27. 91다11308

매도인이 매수인의 중도금 지급채무 불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인으로서는 상대방이 한 계약해제의 효과로서 발생하는 손해배상책임을 지거나 매매 계약에 따른 계약금의 반환을 받을 수 없는 불이익을 면하기 위하여 착오를 이유로 한 취소권을 행사할 수 있다.

☞ 매도인의 해제권행사와 매수인의 착오로 인한 취소권행사에 관한 판례이다.

3. 의사표시의 하자

제110조 【사기, 강박에 의한 의사표시】

- ① 사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다.
- ② 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 행한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ③ 전2항의 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

(1) 사기에 의한 의사표시

1) 의의

타인의 기망행위에 의하여 착오에 빠지고 그 결과로써 한 의사표시를 말한다.

2) 성립요건

- ① 2단의 고의가 있어야 한다(다수설).
 - ㉠ 타인을 기망하여 착오에 빠지게 하려는 고의
 - ㉡ 착오에 빠져 의사표시를 하게 하려는 고의
- ② 위법한 기망행위가 있어야 한다.
 - ㉠ 적극적 기망
허위사실을 날조 또는 유포하는 것을 의미한다.
 - ㉡ 소극적 기망
진실을 은폐하거나 또는 침묵을 지키는 것(소극적 기망이 사기가 되기 위해서는 사기자에게 일정한 고지의무가 있었어야 한다)을 말한다.
 - ㉢ 기망의 정도
기망행위는 사회통념상 위법성이 있다고 할 정도의 행위를 의미한다.
- ③ 인과관계가 있어야 한다.

(2) 강박에 의한 의사표시

1) 의의

타인의 강박행위에 의해 공포심에 빠지고, 그 해악을 피하기 위하여 행한 진의 아닌 의사표시를 말한다.

2) 성립요건

- ① 2단의 고의가 있어야 한다.
- ② 위법한 강박행위가 있어야 한다.
 - ㉠ 강박에 의하여 의사결정의 자유가 배제될 정도에 이른 경우 그 의사표시는 무효이다.
 - ㉡ 불법행위를 한 자를 고발·고소하여 형사상 소추를 하겠다고 하는 경우에 대하여 다수설과 판례는 단순히 소추를 하겠다고 할 뿐이고 그것이 부정한 이익을 목적으로 하지 않을 때는 강박이 되지 않으나, 어떤 부정한 이익의 취득을 목적으로 하거나 목적이 정당하더라도 행위나 수단 등이 부당한 때에는 위법성이 있다고 한다.
- ③ 인과관계가 있어야 한다.

(3) 하자 있는 의사표시의 효과

1) 상대방의 사기·강박의 경우

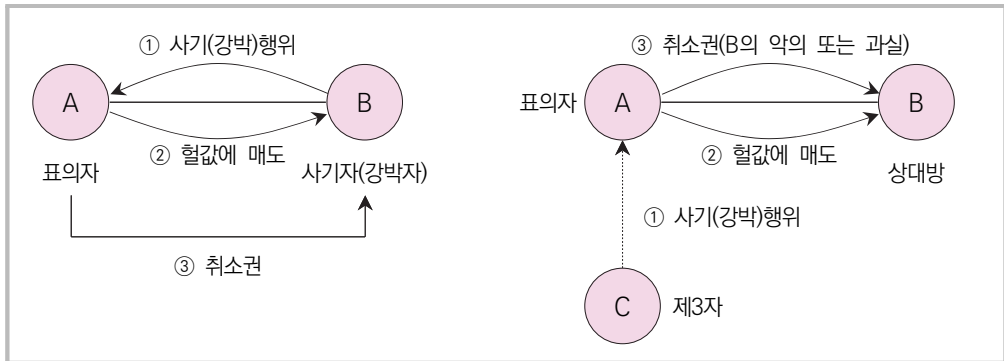
표의자는 언제든지 법률행위를 취소할 수 있다(제110조 제1항).

2) 제3자의 사기·강박의 경우

- ① 상대방 없는 의사표시
표의자는 언제든지 그 법률행위를 취소할 수 있다(다수설).
- ② 상대방 있는 의사표시
 - ㉠ 상대방이 제3자의 사기나 강박을 알았거나(악의), 알 수 있었을 경우(과실)에 한하여 취소할 수 있다(제110조 제2항).
 - ㉡ 상대방의 악의·과실에 대한 증명책임은 표의자가 부담한다.

3) 제3자와의 관계

선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제110조 제3항).



중요판례

대법원 2014.01.23. 2012다84417

상품의 선전·광고에 다소의 과장이나 허위가 수반되는 것은 그것이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다고 하겠으나, 거래에 있어서 중요한 사항에 관하여 구체적 사실을 신의성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지한 경우에는 기망행위에 해당한다.

대법원 1993.08.13. 92다52665

대형백화점의 변칙세일은 물품구매동기에 있어서 중요한 요소인 가격조건에 관하여 기망이 이루어진 것으로서 그 사술의 정도가 사회적으로 용인될 수 있는 상술의 정도를 넘은 것이어서 위법성이 있다.

대법원 1993.08.13. 92다52665

상품의 선전, 광고에 있어 다소의 과장이나 허위가 수반되는 것은 그것이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다고 하겠으나, 거래에 있어서 중요한 사항에 관하여 구체적 사실을 신의성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지한 경우에는 기망행위에 해당한다.

대법원 2002.09.04. 2000다54406

일반적으로 교환계약을 체결하려는 당사자는 서로 자기가 소유하는 교환 목적물은 고가로 평가하고 상대방이 소유하는 목적물은 염가로 평가하여 보다 유리한 조건으로 교환계약을 체결하기를 희망하는 이해상반의 지위에 있고 각자가 자신의 지식과 경험을 이용하여 최대한으로 자신의 이익을 도모할 것이 예상되기 때문에, 당사자 일방이 알고 있는 정보를 상대방에게 사실대로 고지하여야 할 신의칙상의 주의의무가 인정된다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 어느 일방이 교환 목적물의 시가나 그 가액 결정의 기초가 되는 사항에 관하여 상대방에게 설명 내지 고지를 할 주의의무를 부담한다고 할 수 없고, 일방 당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 아니하거나 혹은 허위로 시가보다

높은 가액을 시가라고 고지하였다 하더라도 이는 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭(기망)을 한 것이라고 볼 수 없다.

대법원 2001.05.29. 99다55601

상가를 분양하면서 그 곳에 첨단 오락타운을 조성하고 전문경영인에 의한 위탁경영을 통하여 일정 수익을 보장한다는 취지의 광고를 하였다고 하여 이로써 상대방을 기망하여 분양계약을 체결하게 하였다거나 상대방이 계약의 중요부분에 관하여 착오를 일으켜 분양계약을 체결하게 된 것이라 볼 수 없다.

대법원 1997.12.26. 96다44860

사기를 이유로 한 법률행위의 취소로써 대항할 수 없는 민법 제110조 제3항 소정의 제3자라 함은 사기에 의한 의사표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 사기에 의한 의사표시를 기초로 하여 새로운 법률원인으로써 이해관계를 맺은 자를 의미한다.

대법원 1985.04.09. 85도167

기망행위로 인하여 법률행위의 중요부분에 관하여 착오를 일으킨 경우뿐만 아니라, 법률행위의 내용으로 표시되지 아니한 의사결정의 동기에 관하여 착오를 일으킨 경우에도, 표의자는 그 법률행위를 사기에 의한 의사표시로써 취소할 수 있다.

대법원 1993.04.27. 92다56087

법률행위가 사기에 의한 것으로서 취소되는 경우에 그 법률행위가 동시에 불법행위를 구성하는 때에는, 취소의 효과로 생기는 부당이득반환청구권과 불법행위로 인한 손해배상청구권은 경합하여 병존하는 것이므로, 채권자는 어느 것이라도 선택하여 행사할 수 있지만 중첩적으로 행사할 수 없다.

대법원 1979.01.16. 78다1968

각서에 서명날인할 것을 강력히 요구한 것만으로는 이를 강박행위라고 할 수 없다.

대법원 1997.03.25. 96다47951

일반적으로 부정행위에 대한 고소·고발은 그것이 부정한 이익을 목적으로 하는 것이 아닌 때에는 정당한 권리행사가 되어 위법하다고 할 수 없는 바, 간통으로 고소하지 않기로 하는 등의 대가로 금 1억7천만 원의 합의금을 받게 된 경우, 상간자의 배우자가 부정한 이익을 목적으로 위법한 강박행위를 한 것으로 볼 수 없다.

대법원 2003.05.13. 2002다73708

강박에 의한 법률행위가 하자 있는 의사표시로써 취소되는 것에 그치지 않고, 나아가 무효로

되기 위하여는 강박의 정도가 단순한 불법적 해악의 고지로 상대방으로 하여금 공포를 느끼도록 하는 정도가 아니고, 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도이어야 한다.

☞ 강박에 의한 법률행위가 무효로 되기 위해서는 강박의 정도가 극심하여 의사표시자의 의사결정의 자유가 완전히 박탈된 상태에서 이루어져야 한다.

대법원 2000.03.23. 99다64049

강박에 의한 의사표시라고 하려면 상대방이 불법으로 어떤 해악을 고지함으로 말미암아 공포를 느끼고 의사표시를 한 것이어야 하는 바, 여기서 어떤 해악을 고지하는 강박행위가 위법하다고 하기 위하여는, 강박행위 당시의 거래관념과 제반 사정에 비추어 해악의 고지으로써 추구하는 이익이 정당하지 아니하거나 강박의 수단으로 상대방에게 고지하는 해악의 내용이 법질서에 위배된 경우 또는 어떤 해악의 고지가 거래관념상 그 해악의 고지으로써 추구하는 이익의 달성을 위한 수단으로 부적당한 경우 등에 해당하여야 한다.

대법원 2006.10.12. 2004다48515

아파트 분양자는 아파트 단지 인근에 쓰레기 매립장이 건설예정인 사실을 분양계약자에게 고지할 신의칙상 의무를 부담한다.

☞ 고지의무 위반은 부작위에 의한 기망행위에 해당하므로 원고들로서는 기망을 이유로 분양계약을 취소하고 분양대금의 반환을 구할 수도 있고 분양계약의 취소를 원하지 않을 경우 그로 인한 손해배상만을 청구할 수도 있다.

대법원 1998.03.10. 97다55829

제3자의 사기행위로 인하여 피해자가 주택건설사와 사이에 주택에 관한 분양계약을 체결하였다고 하더라도 제3자의 사기행위 자체가 불법행위를 구성하는 이상, 제3자로서는 그 불법행위로 인하여 피해자가 입은 손해를 배상할 책임을 부담하는 것이므로, 피해자가 제3자를 상대로 손해배상청구를 하기 위하여 반드시 그 분양계약을 취소할 필요는 없다.

대법원 1999.02.23. 98다60828,60835

상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있으나, 상대방의 대리인 등 상대방과 동일시할 수 있는 자의 사기나 강박은 제3자의 사기·강박에 해당하지 아니한다.

대법원 1998.01.23. 96다41496

의사표시의 상대방이 아닌 자로서 기망행위를 하였으나 민법 제110조 제2항에서 정한 제3자에 해당되지 아니한다고 볼 수 있는 자란 그 의사표시에 관한 상대방의 대리인 등 상대방과

동일시할 수 있는 자만을 의미하고, 단순히 상대방이 사용자책임을 져야 할 관계에 있는 피용자에 지나지 않는 자는 이 규정에서 말하는 제3자에 해당한다.

☞ 제3자가 사기나 강박을 한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있으며(제110조 제2항), 이때의 제3자에 범위에 대하여 대리인은 해당하지 않으나, 피용자는 제3자에 해당한다.

대법원 1970.11.24. 70다2155

사기의 의사표시로 인한 매수인으로부터 부동산의 권리를 취득한 제3자는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정할 것이므로 사기로 인하여 의사표시를 한 부동산의 양도인이 제3자에 대하여 사기에 의한 의사표시의 취소를 주장하려면 제3자의 악의를 증명하여야 한다.

대법원 2005.05.27. 2004다43824

사기에 의한 의사표시란 타인의 기망행위로 말미암아 착오에 빠지게 된 결과 어떠한 의사표시를 하게 되는 경우이므로 거기에는 의사와 표시의 불일치가 있을 수 없고, 단지 의사의 형성과정 즉 의사표시의 동기에 착오가 있는 것에 불과하며, 이 점에서 고유한 의미의 착오에 의한 의사표시와 구분되는데, 신원보증서류에 서명날인한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증의 서면에 서명날인한 경우, 결국 위와 같은 행위는 강학상 기명날인의 착오(또는 서명의 착오), 즉 어떤 사람이 자신의 의사와 다른 법률효과를 발생시키는 내용의 서면에, 그것을 읽지 않거나 올바르게 이해하지 못한 채 기명날인을 하는 이른바 표시상의 착오에 해당하므로, 비록 위와 같은 착오가 제3자의 기망행위에 의하여 일어난 것이라 하더라도 그에 관하여는 사기에 의한 의사표시에 관한 법리, 특히 상대방이 그러한 제3자의 기망행위 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아닌 한 의사표시자가 취소권을 행사할 수 없다는 민법 제110조 제2항의 규정을 적용할 것이 아니라, 착오에 의한 의사표시에 관한 법리만을 적용하여 취소권 행사의 가부를 가려야 한다.

4. 의사표시의 효력발생

제111조 【의사표시의 효력발생시기】

- ① 상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에 도달한 때로부터 그 효력이 생긴다.
- ② 표의자가 그 통지를 발한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

(1) 효력발생시기에 관한 입법주의

1) 전달과정

표백(表白) → 발신 → 도달 → 요지(了知)의 단계

2) 표백주의

- ① 의사표시가 성립한 때에 효력이 발생한다.
- ② 표의자보호에 치중한 제도이다.

3) 발신주의

- ① 의사표시가 발신된 때에 효력이 발생한다.
- ② 표의자보호에 치중한 제도이다.
- ③ 주로 상법분야에 적용되는 경우가 많다.

✓ 민법상 발신주의 적용의 예

- 격지자 사이에서의 계약의 승낙의 통지(제531조)
- 제한능력자의 상대방의 최고에 대한 법정대리인의 확답(제15조)
- 무권대리인의 상대방의 최고에 대한 본인의 확답(제131조)
- 채권자의 채무인수자에 대한 승인의 통지(제455조 제2항)
- 사원총회소집의 통지(제71조)
- 승낙연착의 통지 및 지연의 통지(제528조 제2항)

4) 도달주의

- ① 의사표시가 상대방에게 도달된 때에 효력이 발생한다.
- ② 표의자와 상대방의 이익을 조화한 입법주의이다.
- ③ 우리 민법의 입법주의이다. 즉, “상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에게 도달한 때에 효력이 생긴다.”(제111조 : 임의규정)라고 규정함으로써 도달주의 원칙을 취하고 있다.

5) 요지주의

- ① 상대방이 의사표시의 내용을 이해한 때에 효력이 발생한다.
- ② 상대방보호에 치중한 제도이다.

(2) 도달주의의 원칙

- ① 도달의 개념은 사회통념상 요지할 수 있는 상태에 달한 때를 말한다.

[대화자] → 거리적·장소적 개념이 아니라 시간적 개념이다.
[격지자]

- ② 의사표시의 연착 또는 불착은 표의자의 불이익으로 돌아간다.
- ③ 의사표시의 철회는 도달 전에 한하여 행할 수 있으며 늦어도 본래의 의사표시와 동시에 도달되어야 한다.
- ④ 발신 후 도달 전의 사정의 변화(표의자의 사망, 행위능력상실)는 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항).

(3) 의사표시의 공시송달(제113조)

제113조 【의사표시의 공시송달】

표의자가 과실없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우에는 의사표시는 민사소송법공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다.

- ① 상대방 또는 상대방의 주소를 모르는 데 대하여 표의자의 과실이 없었어야 한다 (무과실).
- ② 법원사무관 등이 공시송달할 서류를 보관하고, 그 사유를 법원게시판에 게시하며

법원게시판에 게시한 날로부터 2주일이 경과한 때에는 도달로 간주한다(민사소송법 제196조).

(4) 의사표시의 수령능력

제112조 【의사표시의 수령능력】

의사표시의 상대방이 이를 받은 때에 무능력자인 경우에는 그 의사표시으로써 대항하지 못한다. 그러나 법정대리인이 그 도달을 안후에는 그러하지 아니하다.

- ① 민법상 모든 제한능력자는 의사표시의 수령능력이 없다(제112조). 따라서 의사표시를 제한능력자가 수령한 때에는 상대방은 도달을 주장하지 못한다.
- ② 제한능력자가 도달을 주장하는 것은 무방하며, 법정대리인이 의사표시의 도달을 인식한 때에는 표의자는 도달을 주장할 수 있다.

중요판례

대법원 1997.11.25. 97다31281

의사표시는 상대방에게 도달됨으로써 효력을 발생하는 것이고, 여기서 도달이라 함은 사회관념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 있다고 인정되는 상태를 의미하므로, 상대방이 이를 현실적으로 수령하였다거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지는 필요로 하지 않는다.

대법원 1992.03.27. 91누3819

우편물이 등기취급의 방법으로 발송된 경우 반송되는 등 특별한 사정이 없는 한 그 무렵 수취인에게 배달되었다고 본다.

대법원 2009.12.10. 2007두20140

내용증명우편이나 등기우편과는 달리, 보통우편의 방법으로 발송되었다는 사실만으로는 그 우편물이 상당한 기간 내에 도달하였다고 추정할 수 없고, 송달의 효력을 주장하는 측에서 증거에 의하여 이를 증명하여야 한다.

☞ 보통우편으로 발송된 때에는 비록 반송된 사실이 없다 하더라도 우편제도상 당연히 도달된 것으로 추정되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

대법원 2006.03.24. 2005다66411

우편물이 수취인 가구의 우편함에 투입되었다고 하더라도 분실 등을 이유로 그 우편물이 수취인의 수중에 들어가지 않을 가능성이 적지 않게 존재하는 현실에 비추어, 우편함의 구조를 비롯하여 수취인이 우편물을 수취하였음을 추인할 만한 특별한 사정에 대하여 심리를 다하지 아니한 채 아파트 경비원이 집배원로부터 우편물을 수령한 후 이를 우편함에 넣어 둔 사실만으로 수취인이 그 우편물을 수취하였다고 볼 수 없다.

1. 서론

(1) 의의

타인(대리인)이 본인을 위한 것을 표시하여 법률행위를 하거나 의사표시를 수령하여 그 법률효과가 직접 본인에게 귀속되는 제도를 말한다. 대리제도는 법률행위에 있어서 행위자와 그 효과의 귀속주체가 분리되는 예외적인 제도이다.

(2) 사회적 작용

1) 사적자치의 보충(법정대리제도)

제한능력자가 권리·의무를 취득하려면 법정대리인의 대리나 동의가 있어야 한다. 이 경우 대리는 제한능력자에 대한 능력의 보충이며, 그것은 사적자치의 보충이라는 기능을 하고 있는 것이다. 사적자치의 보충의 작용은 법정대리에서 강하게 나타난다.

2) 사적자치의 확장(임의대리제도)

오늘날과 같이 거래관계가 고도화·복잡화하여 거래규모가 현저하게 확대되고 있는 경우에는 법률관계를 혼자 힘만으로 처리한다는 것은 거의 불가능하다. 여기서 타인을 대리인으로 하고, 그 대리인을 통해서 법률관계를 처리하게 한다면, 개인의 활동범위는 그의 활동능력 이상으로 확대된다. 이러한 의미에서 대리제도는 사적자치의 범위의 확대 내지 연장이라고 할 수 있다. 사적자치의 확장의 작용은 임의대리에서 강하게 나타난다.

(3) 대리가 인정되는 범위

- ① 의사표시를 요소로 하는 법률행위에 인정된다(114조).
- ② 가족법상의 신분행위(혼인, 인지, 입양, 파양, 유언), 불법행위, 사실행위, 준법률 행위(의사의 통지와 관념의 통지는 대리를 유추적용 가능)는 대리가 부정된다.

(4) 대리의 종류

1) 임의대리와 법정대리

- ① 임의대리란 본인의 수권행위에 의한 대리이며, 법정대리란 법률의 규정에 의하여 대리권이 부여된 대리를 말한다.
- ② 양자의 구별실익은 복임권의 유무와 대리권의 소멸 등에 있다.

2) 능동대리와 수동대리

대리인이 상대방에 대하여 의사표시를 하는 대리가 능동대리(적극대리)이며, 제3자가 하는 의사표시를 수령하는 대리를 수동대리(소극대리)라 한다.

3) 유권대리와 무권대리

정당한 대리권을 가진 대리를 유권대리, 그러하지 않은 경우를 무권대리라 한다.

2. 대리권

(1) 대리권의 성질

대리권이란 법률상 일정한 법률효과를 발생하게 하는 지위 또는 자격이라는 자격설이 다수설이다. 따라서 대리권은 권리가 아니라 권한이다.

(2) 대리권의 발생원인

1) 법정대리권의 발생원인

- ① 일정한 지위에 있는 자가 당연히 대리인이 되는 경우 : 친권자, 미성년후견인 등
- ② 본인 이외의 일정한 지정권자의 지정으로 대리인이 되는 경우 : 지정후견인 등
- ③ 법원의 선임으로 대리인이 되는 경우 : 부재자의 재산관리인, 상속재산관리인 등

2) 임의대리권의 발생원인

본인의 수권행위에 의하여 발생하며, 수권행위의 법적 성질은 다음과 같다.

- ① 상대방의 수령을 요하는 본인의 단독행위로 해석한다(다수설).
- ② 불요식행위(통상의 경우 위임장을 교부)이다.
- ③ 기본행위(위임, 고용, 도급, 조합)와는 구별하여야 한다.

(3) 대리권의 범위

1) 법정대리

법률의 규정에 의한다(제25조·제916조·제941조·제1040조 등). 또한 법정대리권의 범위에 관한 법률의 규정은 강행규정이다.

2) 임의대리

제118조 【대리권의 범위】

권한을 정하지 아니한 대리인은 다음 각 호의 행위만을 할 수 있다.

- ① 보존행위
- ② 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 그 이용 또는 개량하는 행위

본인의 수권행위의 해석에 의하여 결정되나 명확하지 않을 때에는 제118조를 적용한다.

〈권한이 분명하지 않은 대리인의 대리권(제118조)〉

보존행위	무제한 가능	재산의 현상을 유지하는 행위로서 건물의 수선, 기한 도래의 채무변제, 소멸시효의 중단, 미등기부동산의 보존등기, 부패성 있는 물건의 처분행위 등
이용행위	권리나 물건의 성질을 변하지 않는 범위 내에서 가능	수익을 도모하는 행위로서 부동산의 임대차 설정행위, 금전의 이자부대여 등
개량행위		경제적 가치를 증대하는 행위로서 사용대차를 임대차로, 무이자소비대차를 이자부소비대차로 하는 행위 등
처분행위	불가능	매각행위, 담보설정행위(저당권 또는 전세권설정 등)

다만, 개량행위에 해당하는 것 중에서 본인의 예금을 인출하여 주식을 매입하는 행위 또는 본인의 농지를 대지로 지목을 변경하는 행위 등은 권리나 물건의 성질을 변하게 하는 행위로서 인정되지 않는다.

중요판례

대법원 1994.02.08. 93다39379

임의대리에 있어서 대리권의 범위는 수권행위(대리권수여행위)에 의하여 정하여지는 것이므로 어느 행위가 대리권의 범위 내의 행위인지의 여부는 개별적인 수권행위의 내용이나 그 해석에

의하여 판단할 것이나, 일반적으로 말하면 수권행위의 통상의 내용으로서의 임의대리권은 그 권한에 부수하여 필요한 한도에서 상대방의 의사표시를 수령하는, 이른바 수령대리권을 포함하는 것으로 보아야 한다. 따라서 부동산의 소유자로부터 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 매매계약에서 약정한 바에 따라 중도금이나 잔금을 수령할 권한도 있다.

대법원 1992.04.14. 91다43107

부동산의 소유자로부터 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 다른 사정이 없는 한 그 매매계약에서 약정한 바에 따라 중도금이나 잔금을 수령할 수도 있다고 보아야 하고, 매매계약의 체결과 이행에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 다른 사정이 없는 한 상대방에 대하여 약정된 매매대금지급기일을 연기하여 줄 권한도 가진다.

대법원 2008.06.12. 2008다11276

어떠한 계약의 체결에 관한 대리권을 수여받은 대리인이 수권된 법률행위를 하게 되면 그것으로 대리권의 원인된 법률관계는 원칙적으로 목적을 달성하여 종료하는 것이고, 법률행위에 의하여 수여된 대리권은 그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸하는 것이므로(민법 제128조), 그 계약을 대리하여 체결하였던 대리인은 체결된 계약의 해제권 등 일체의 처분권과 상대방의 의사를 수령할 권한까지는 없다.

대법원 2001.01.19. 2000다20694

진의 아닌 의사표시가 대리인에 의하여 이루어지고 그 대리인의 진의가 본인의 이익이나 의사에 반하여 자기 또는 제3자의 이익을 위한 배임적인 것임을 그 상대방이 알았거나 알 수 있었을 경우에는 민법 제107조 제1항 단서의 유추해석상 그 대리인의 행위에 대하여 본인은 아무런 책임을 지지 않는다.

(4) 대리권의 제한

1) 자기계약·쌍방대리의 금지

제124조 【자기계약, 쌍방대리】

대리인은 본인의 허락이 없으면 본인을 위하여 자기와 법률행위를 하거나 동일한 법률행위에 관하여 당사자 쌍방을 대리하지 못한다. 그러나 채무의 이행은 할 수 있다.

- ① 대리인이 본인을 대리하면서 본인과 직접 법률행위를 하는 것을 자기계약이라고 하며, 본인의 대리인이 상대방도 대리하는 것을 쌍방대리라고 한다. 민법은 자기 계약과 쌍방대리를 원칙적으로 금하나(제124조), 예외적으로 본인의 승낙 또는 채무의 이행의 경우에는 허용된다. 그러나 다툼이 있는 채무의 이행, 기한 미도래의 채무이행, 경개(更改), 대물변제는 허용하지 아니한다.
- ② 자기계약·쌍방대리의 금지규정에 위반한 대리행위는 무효가 되는 것이 아니라 무권대리행위(제126조의 표현대리)가 된다. 따라서 본인의 추인이 있을 경우에는 유권대리가 될 수 있다.
- ③ 자기계약·쌍방대리의 금지규정은 임의대리와 법정대리 모두에 적용된다.

2) 대리인이 수인인 때

제119조 【각자대리】

대리인이 수인인 때에는 각자가 본인을 대리한다. 그러나 법률 또는 수권행위에 다른 정한 바가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

- ① 각자대리가 원칙이나 공동대리의 예외를 인정한다.
- ② 자기계약·쌍방대리의 금지규정과 공동대리의 제한에 위반한 경우에는 대리권의 범위를 초과한 대리행위(제126조의 표현대리)로 본다.

(5) 대리권의 소멸

제127조 【대리권의 소멸사유】

대리권은 다음 각 호의 사유로 소멸한다.

- ① 본인의 사망
- ② 대리인의 사망, 성년후견의 개시 또는 파산

1) 공통 소멸사유(제127조)

- ① 본인의 사망(예외적으로 특약이 있는 경우 등은 소멸사유가 아니다)
- ② 대리인의 사망
- ③ 대리인의 성년후견개시(대리인의 한정후견개시는 소멸사유가 아니다)
- ④ 대리인의 파산

2) 임의대리의 특유한 소멸사유(제128조)

제128조 【임의대리의 종료】

법률행위에 의하여 수여된 대리권은 전조의 경우 외에 그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸한다. 법률관계의 종료 전에 본인이 수권행위를 철회한 경우에도 같다.

- ① 수권행위의 철회
- ② 원인된 법률관계의 종료 : 다만, 원인된 법률관계가 종료하더라도 대리권만을 존속시킬 수 있는 예외는 인정된다.

3) 법정대리의 특유한 소멸사유

- ① 법원의 개입(제23조·제1023조)
- ② 대리권의 상실선고(제924조·제925조·제940조·제1106조) 등

3. 대리행위

제114조 【대리행위의 효력】

- ① 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접본인에게 대하여 효력이 생긴다.
- ② 전항의 규정은 대리인에게 대한 제3자의 의사표시에 준용한다.

제115조 【본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 행위】

대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때에는 그 의사표시는 자기를 위한 것으로 본다. 그러나 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었을 때에는 전조 제1항의 규정을 준용한다.

(1) 대리의사의 표시(현명주의)

- ① 본인을 위한 것임을 표시하여야 하며(제114조), 현명의 방식(명시적 또는 묵시적, 서면 또는 구두)에는 제한이 없다. 상행위의 대리과 일상가사대리에서는 대리인의 현명을 요하지 아니한다.
- ② 현명하지 않은 대리행위는 대리인 자신을 위한 행위로 간주한다. 다만 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었을 때에는 본인에게 그 효력이 발생한다(제115조).

(2) 대리행위의 하자

제116조 【대리행위의 하자】

- ① 의사표시의 효력이 의사에 흠결, 사기, 강박 또는 어느 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준하여 결정한다.
- ② 특정한 법률행위를 위임한 경우에 대리인이 본인의 지시에 좇아 그 행위를 한 때에는 본인은 자기가 안 사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 관하여 대리인의 부지를 주장하지 못한다.

- ① 의사표시의 효력이 의사에 흠결, 사기, 강박 또는 어떤 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 결정한다(제116조 제1항).
- ② 특정한 법률행위를 위임한 경우에 대리인이 본인의 지시에 좇아 그 행위를 한 때에는 본인은 자기가 안 사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 관하여 대리인의 부지(不知)를 주장하지 못한다(제116조 제2항).

☑ 의사의 흠결·하자와 대리행위

㉠ 대리에 있어서의 비진의표시

대리인이 진의 아닌 의사표시를 하더라도 그 의사표시는 표시된 대로 효력이 발생한다(제107조 제1항 본문). 그러나 상대방이 진의 아님을 알 수 있었을 경우에는 비진의표시는 무효이다(제107조 제1항 단서). 이 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제107조 제2항), 본인은 여기의 제3자에 해당하지 아니한다.

㉡ 대리에 있어서의 통정허위표시

- ㉠ 대리인이 상대방과 통정하여 허위의 의사표시를 한 경우에 그 의사표시는 무효이다(제108조 제1항). 이 때 본인이 통정의 사실을 알지 못하였다 하더라도 본인은 선의의 제3자로서 보호받지 못한다.
- ㉡ 대리인과 상대방이 통정하여 본인을 기망할 목적으로 허위표시를 한 경우에는 본인을 보호할 필요가 있다. 따라서 이 경우에는 본인은 통정허위표시의 무효를 주장할 수 있으나, 상대방은 신의칙상 본인에 대하여 법률행위의 무효를 주장할 수 없다.

㉢ 대리에 있어서의 착오

대리인에게 대리행위에 관한 착오가 있으면 그 착오가 표의자(대리인)의 중대한 과실로 인한 것이 아닌 한 이를 취소할 수 있다(제108조). 착오의 유무, 중대한 과실의 유무는 모두 대리인을 표준으로 결정한다. 따라서 본인에게 착오가 있다 하더라도 대리인에게 착오가 없으면 취소할 수 없다.

㉔ 대리에 있어서의 사기·강박

㉔ 대리인이 상대방의 사기·강박에 의하여 의사표시를 한 경우에는 본인은 제110조 제1항에 의하여 대리인의 의사표시를 취소할 수 있다. 사기·강박을 받았는지의 유무는 대리인을 기준으로 하여 판단하여야 하므로, 본인이 사기·강박을 받았다 하더라도 대리인이 사기·강박을 받지 않은 한 본인은 대리행위를 취소할 수 없다.

㉔ 상대방이 대리인의 사기·강박에 의하여 의사표시를 한 경우에는 상대방은 그 의사표시를 취소할 수 있다.

㉕ 불공정한 법률행위에서의 공박·경솔·무경험

대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 그 법률행위가 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경솔과 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하고, 공박은 본인의 입장에서 판단하여야 한다(대법원 2002.10.22. 2002다38927).

(3) 대리인의 능력

제117조 【대리인의 행위능력】

대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다.

대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다(제117조). 따라서 본인은 대리인의 제한능력을 이유로 상대방에게 그 대리행위를 취소하지 못한다. 그러나 제한능력자는 본인과 기초적 내부관계를 발생시키는 행위(위임계약)를 취소할 수 있다.

4. 복대리

1) 의의

복대리인이란 대리인이 자기의 이름과 책임으로 선임한 본인의 대리인을 말한다(제123조).

2) 법률적 성질

① 복대리인은 본인의 대리인이며, 복대리인은 언제나 임의대리인이다.

② 복대리인은 대리인이 자기의 이름과 책임으로 선임한 자이며, 복대리인 선임행위는 대리행위가 아니다.

3) 복임권

제122조 【법정대리인의 복임권과 그 책임】

법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다. 그러나 부득이한 사유로 인한 때에는 전조 제1항에 정한 책임만이 있다.

- ① 법정대리인은 언제든지 복임권이 있다(무과실책임). 다만, 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우에는 그 책임이 경감된다(과실책임).

제120조 【임의대리인의 복임권】

대리권이 법률행위에 의하여 부여된 경우에는 대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유 있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다.

제121조 【임의대리인의 복대리인 선임의 책임】

- ① 전조의 규정에 의하여 대리인이 복대리인을 선임한 때에는 본인에게 대하여 그 선임 감독에 관한 책임이 있다.
- ② 대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 그 부적임 또는 불성실함을 알고 본인에게 대한 통지나 그 해임을 태만한 때가 아니면 책임이 없다.

- ② 임의대리인은 원칙적으로 복임권이 없으나 예외적으로 본인의 승낙 또는 부득이한 사유가 있는 때에 한하여 복임권을 갖는다(과실책임). 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 책임이 경감된다. 즉, 본인이 지명한 자가 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에게 그 통지를 하지 않았거나 해임을 태만(게을리)히 한 때가 아니면 책임지지 아니한다(제121조 제2항).

4) 복대리인의 지위

제123조 【복대리인의 권한】

- ① 복대리인은 그 권한내에서 본인을 대리한다.
- ② 복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.

- ① 복대리권은 대리권의 범위를 초과할 수 없다(제123조).
- ② 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다.
- ③ 복대리인 선임 후에도 대리인의 대리권은 존속한다.

- ④ 본인에 대하여는 복대리인도 대리인과 동일한 지위를 가진다.
- ⑤ 복대리인의 복임권에 대하여는 임의대리와 같은 조건하에서 인정된다는 것이 통설이다.

5) 복대리권의 소멸사유

- ① 대리권 일반의 소멸원인에 의하여 소멸한다.
- ② 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다.
- ③ 대리인과 복대리인 사이의 선임행위의 철회에 의하여서도 소멸한다.

중요판례

대법원 1999.09.03. 97다56099

임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있지 아니하면 복대리인을 선임할 수 없는 것인 바, 아파트 분양업무는 그 성질상 분양위임을 받은 수임인의 능력에 따라 그 분양 사업의 성공 여부가 결정되는 사무로서, 본인의 명시적인 승낙 없이는 복대리인의 선임이 허용되지 않는다.

대법원 1998.05.29. 97다55317

대리인이 대리권소멸 후 직접 상대방과 사이에 대리행위를 하는 경우는 물론 대리인이 대리권소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에 대리행위를 하도록 한 경우에도, 상대방이 대리권소멸 사실을 알지 못하여 복대리인에게 적법한 대리권이 있는 것으로 믿었고 그와 같이 믿은 데 과실이 없다면 제129조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다.

5. 무권대리

(1) 의의

무권대리라 함은 대리권 없이 대리행위를 행한 것, 즉 대리행위의 외관을 갖추고 있으나 대리권을 가지지 않고 행위를 한 것을 말한다.

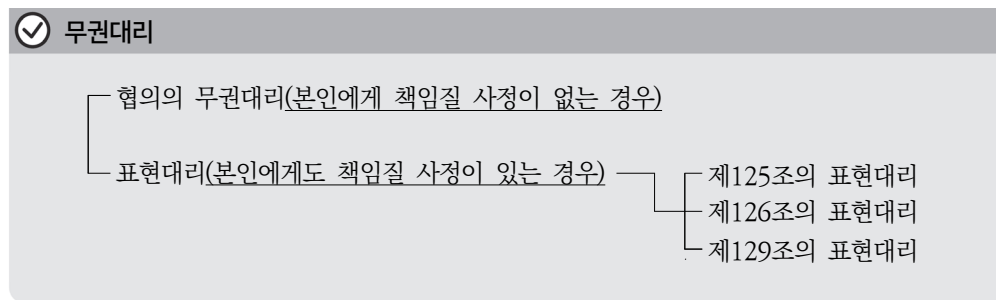
(2) 제도의 취지

- ① 무권대리는 대리권이 없이 행해진 행위이므로 법적 효과를 본인에게 귀속시킬 수 없을 뿐만 아니라, 대리인에 대해서도 대리 의사로써 행한 행위이기 때문에 법적 효과를 귀속시킬 수 없다.

- ② 민법은 무권대리인과 거래한 상대방의 보호를 위하여 특별규정을 두고 있다. 무권 대리행위를 본인과 관계에 있어서 완전히 무효로 하지 않고 추인에 의하여 대리의 효과를 발생시킬 수 있는 여지를 둠과 동시에 무권대리인에게 무거운 책임을 지운다. 본인과 무권대리인 간에 일정한 긴밀한 관계가 있는 경우에는 본래 무권 대리이어야 할 행위로 하여금 정당한 대리행위로서의 효과를 발생시킨다.

(3) 무권대리의 체계

무권대리의 체계에 대하여 학설의 대립이 있으나 다음의 분류(기능적 이원설)가 다수 설의 태도이다.



(4) 협의의 무권대리

대리인이 대리권 없이 대리행위를 행한 경우에 표현대리로 볼 수 있는 특별한 사정이 없는 경우, 즉 광의의 무권대리 중 표현대리를 제외한 무권대리를 말한다. 협의의 무권대리의 특징은 본인의 추인이 없는 한 본인에게 효과가 나타나지 않는다는 데 있다. 즉, 상대방은 본인에 대하여 책임을 추궁하지 못하는 데에 있어서 표현대리와 그 차이가 있다.

제130조 【무권대리】

대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약은 본인이 이를 추인하지 아니하면 본인에 대하여 효력이 없다.

제131조 【상대방의 최고권】

대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 계약을 한 경우에 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에게 그 추인여부의 확답을 최고할 수 있다. 본인이 그 기간 내에 확답을 발하지 아니한 때에는 추인을 거절한 것으로 본다.

제132조 【추인, 거절의 상대방】

추인 또는 거절의 의사표시는 상대방에 대하여 하지 아니하면 그 상대방에 대항하지 못한다. 그러나 상대방이 그 사실을 안 때에는 그러하지 아니하다.

제133조 【추인의 효력】

추인은 다른 의사표시가 없는 때에는 계약시에 소급하여 그 효력이 생긴다. 그러나 제3자의 권리를 해하지 못한다.

제134조 【상대방의 철회권】

대리권 없는 자가 한 계약은 본인의 추인이 있을 때까지 상대방은 본인이나 그 대리인에 대하여 이를 철회할 수 있다. 그러나 계약당시에 상대방이 대리권 없음을 안 때에는 그러하지 아니하다.

1) 계약의 무권대리

- ① 무권대리행위는 당연히는 본인에 대하여 효과가 발생할 수 없고, 본인이 원한다면 추인함으로써 정당한 대리권을 수반하여 행한 경우와 동일한 효과를 발생하게 할 수 있다.
- ② 추인은 단독행위이며 형성권으로서, 무권대리인이나 상대방의 동의를 요하지 않는다. 아울러 본인은 당연히 추인거절권을 가진다.
- ③ 추인의 의사표시는 상대방이나 무권대리인뿐만 아니라 무권대리행위로 인한 권리의 승계인에 대하여도 할 수 있으나, 무권대리인에 대해 추인한 경우에는 상대방이 추인이 있었던 사실을 알지 못한 때에는 그에 대해 추인의 효과를 주장하지 못한다(제132조).
- ④ 본인이 무권대리인이 한 계약의 내용을 변경하여 추인하거나 일부 추인한 경우에는 상대방의 동의가 있어야 추인의 효력이 발생한다.
- ⑤ 본인의 추인으로 말미암아 무권대리행위는 계약한 때 소급하여 적법한 대리행위가 있는 것으로 되고, 유효한 계약으로서 본인에 대하여 효력이 생긴다(제132조).
- ⑥ 추인의 소급효는 제3자의 권리를 해하지 못한다(제133조 단서). 예컨대, 무권대리인이 본인의 특정부동산을 매매한 경우 본인이 제3자에게 그 부동산을 매도하고 등기를 행한 경우라면, 이후 본인이 추인하더라도 제3자는 보호된다.
- ⑦ 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에 대하여 추인여부의 확답을 구하는 최고를

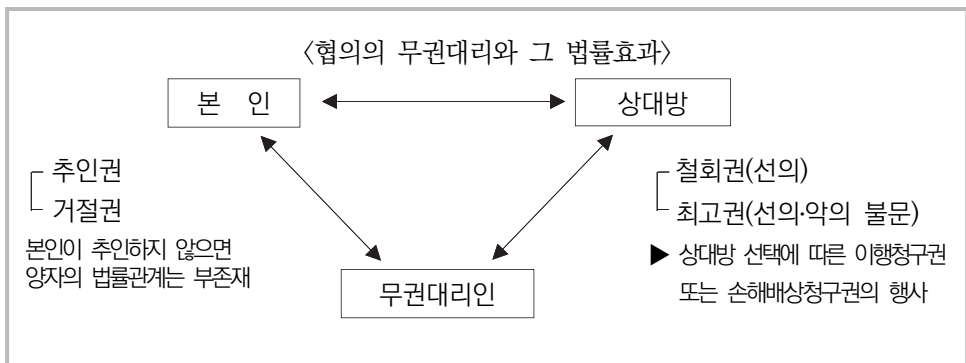
할 수 있다. 만약 그 기간 내에 본인이 확답을 발하지 않는 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다. 악의의 상대방에게도 최고권을 인정한다.

- ⑧ 상대방은 계약 당시에 무권대리인임을 알지 못한 경우에(선의) 한하여 본인이 아직 추인하지 않고 있는 동안 본인이나 무권대리인에게 그 계약을 철회할 수 있다. 철회권이 행사되면 처음부터 그 무권대리행위는 무효로 확정되고 그 후 본인은 추인하지 못한다.
- ⑨ 무권대리인은 상대방의 선택에 따라서 이행 또는 손해배상(이행이익)의 책임을 져야 한다.
- ⑩ 무권대리인이 책임을 지기 위한 요건은 다음과 같다.

제135조 【무권대리인의 상대방에 대한 책임】

- ① 다른 자의 대리인으로서 계약을 맺은 자가 그 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 받지 못한 경우에는 그는 상대방의 선택에 따라 계약을 이행할 책임 또는 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 대리인으로서 계약을 맺은 자에게 대리권이 없다는 사실을 상대방이 알았거나 알 수 있었을 때 또는 대리인으로서 계약을 맺은 사람이 제한능력자일 때에는 제1항을 적용하지 아니한다.

- ㉠ 본인의 추인이 없을 것
- ㉡ 상대방의 철회가 없을 것
- ㉢ 상대방이 선의·무과실일 것
- ㉣ 대리권을 증명할 수 없을 것
- ㉤ 무권대리인이 행위능력자일 것



2) 단독행위의 무권대리

제136조 【단독행위와 무권대리】

단독행위에는 그 행위당시에 상대방이 대리인이라 칭하는 자의 대리권 없는 행위에 동의하거나 그 대리권을 다투지 아니한 때에 한하여 전6조의 규정을 준용한다. 대리권 없는 자에 대하여 그 동의를 얻어 단독행위를 한 때에도 같다.

- ① 상대방이 없는 단독행위의 무권대리는 언제나 확정적·절대적으로 무효이며, 본인의 추인에 의하여 유효하게 될 여지는 없고 무권대리인의 책임도 발생하지 않는다.
- ② 상대방이 있는 단독행위의 무권대리는 예외적으로 계약에 있어서의 무권대리와 동일하게 불확정무효이다.

중요판례

대법원 1982.01.26. 81다카549

무권대리행위의 추인은 무권대리인에 의하여 행하여진 불확정한 행위의 효과를 자기에게 직접 발생하게 할 것을 목적으로 하는 의사표시이고 상대방의 동의나 승낙을 요하지 않는 단독행위이므로 어떤 방식이 요구되지 아니하고 명시적이거나 묵시적이거나를 묻지 아니하나, 추인은 의사표시의 전부에 대하여 행하여져야 하고 그 일부에 대하여 추인을 하거나 그 내용을 변경하여 추인을 하였을 경우에는 상대방의 동의를 얻지 못하는 한 무효이다.

대법원 2001.11.09. 2001다44291

- [1] 무권대리행위의 추인에 특별한 방식이 요구되는 것이 아니므로 명시적인 방법만 아니라 묵시적인 방법으로도 할 수 있고, 그 추인은 무권대리인, 무권대리행위의 직접의 상대방 및 그 무권대리행위로 인한 권리 또는 법률관계의 승계인에 대하여도 할 수 있다.
- [2] 민법 제132조는 본인이 무권대리인에게 무권대리행위를 추인한 경우에 상대방이 이를 알지 못하는 동안에는 본인은 상대방에게 추인의 효과를 주장하지 못한다는 취지이므로 상대방은 그때까지 민법 제134조에 의한 철회를 할 수 있고, 또 무권대리인에의 추인이 있었음을 주장할 수도 있다.

대법원 2001.03.23. 2001다4880

무권대리행위의 추인은 무권대리행위가 있음을 알고 그 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로서 그 의사표시의 방법에 관하여 일정한 방식이 요구되는 것은 아니나, 그 무권대리행위를 안 직후에 그것이 자기에게 효력이 없다고 이의를 제기하지 않았거나 상당기간 방치하였다고 하여 그 무권대리행위를 추인하였다고 볼 수는 없다.

대법원 1994.09.27. 94다20617

무권대리인 乙이 甲으로부터 부동산을 상속받아 그 소유자가 되어 소유권 이전등기이행의무를 이행하는 것이 가능하게 된 시점에서 자신이 소유자라고 하여 자신으로부터 부동산을 매수한 丙에게 원래 자신의 매매행위가 무권대리행위여서 무효였다는 이유로 丙 앞으로 경료된 소유권이전등기가 무효의 등기라고 주장하여 그 등기의 말소를 청구하거나 부동산의 점유로 인한 부당이득금의 반환을 구하는 것은 금반언의 원칙이나 신의성실의 원칙에 반하여 허용될 수 없다. 아울러 丙으로부터 전득한 丁에 대한 관계에서도 마찬가지이다.

대법원 1963.04.11. 63다64

본인이 매매계약을 체결한 무권대리인으로부터 매매대금의 전부 또는 일부를 받았다면 특단의 사유가 없는 한 무권대리인의 매매계약을 추인하였다고 본다.

대법원 1973.01.30. 72다2309,2310

무권대리인이 차용한 금전의 변제기일에 채권자가 본인에게 그 변제를 독촉하자 그 기한의 유예를 요청하였다면 무권대리인의 행위를 추인하였다고 본다.

(5) 표현대리

대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 마치 그것이 있는 것과 같은 외관이 있고, 또한 그러한 외관의 발생에 관하여 본인이 어느 정도의 원인을 주고 있는 경우에, 그 무권대리행위에 대하여 본인이 책임을 지게 함으로써 그러한 외관을 신뢰한 선의·무과실의 제3자(상대방)를 보호하고, 거래의 안전을 보호하고자 하는 것이 표현대리 제도이다.

1) 제125조의 표현대리(대리권수여의 표시에 의한 표현대리)

제125조 【대리권수여의 표시에 의한 표현대리】

제3자에 대하여 타인에게 대리권을 수여함을 표시한 자는 그 대리권의 범위 내에서 행한 그 타인과 그 제3자간의 법률행위에 대하여 책임이 있다. 그러나 제3자가 대리권 없음을 알았거나 알 수 있었을 때에는 그러하지 아니하다.

① 의의

대리권수여의 뜻을 본인이 상대방에게 표시하였으나 사실은 대리권을 주고 있지 않은 경우를 말한다. 본조(제125조)의 표현대리는 임의대리에만 적용된다.

② 요건

- ㉠ 본인이 제3자(무권대리인의 상대방이 될 자)에 대하여 어떤 자에게 대리권을 수여하였음을 통지하였을 것
- ㉡ 수여한 것으로 표시된 대리권의 범위 내에서 대리행위를 하였을 것
- ㉢ 대리권수여의 통지를 받은 제3자(무권대리인의 상대방이 될 자)와의 사이에서 대리행위를 하였을 것
- ㉣ 타인에게 명의를 대여하는 것도 대리권수여의 표시가 될 수 있다는 것이 통설과 판례의 태도이다.
- ㉤ 제3자(무권대리인의 상대방)는 대리권의 부존재에 대하여 선의·무과실일 것. 이 때 상대방의 악의 또는 과실에 대한 증명책임은 본인에게 있다.

③ 효과

- ㉠ 본인은 무권대리인의 행위에 대하여 상대방에 대하여 책임이 있다(제125조 본문).
- ㉡ 본인의 추인으로 인해 유효한 대리행위로서의 효력이 발생하므로 본인이 원한다면 상대방이 먼저 철회권을 행사하기 전에 추인하면 된다.
- ㉢ 제135조(무권대리인의 책임)는 표현대리에는 적용되지 않는다는 것이 통설이다.
- ㉣ 본인은 표현대리로 인한 손해가 발생한 경우에는 표현대리인에 대하여 채무불이행 또는 불법행위를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다.

중요판례

대법원 1998.06.12. 97다53762

민법 제125조가 규정하는 대리권수여의 표시에 의한 표현대리는 본인과 대리행위를 한 자 사이의 기본적인 법률관계의 성질이나 그 효력의 유무와는 직접적인 관계가 없이 어떤 자가 본인을 대리하여 제3자와 법률행위를 함에 있어 본인이 그 자에게 대리권을 수여하였다는 표시를 제3자에게 한 경우에는 성립될 수가 있고, 또 본인에 의한 대리권수여의 표시는 반드시 대리권 또는 대리인이라는 말을 사용하여야 하는 것이 아니라 사회통념상 대리권을 추단할 수 있는 직함이나 명칭 등의 사용을 승낙 또는 묵인한 경우에도 대리권수여의 표시가 있는 것으로 볼 수 있다.

☞ 호텔 등의 시설이용 우대회원 모집계약을 체결하면서 자신의 판매점, 총대리점 또는 연락사무소 등의 명칭을 사용하여 회원모집 안내를 하거나 입회계약을 체결하는 것을 승낙 또는 묵인하였다면 민법 제125조의 표현대리가 성립한다.

대법원 2001.08.21. 2001다31264

민법 제125조가 규정하는 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리는 본인과 대리행위를 한 자 사이의 기본적인 법률관계의 성질이나 그 효력의 유무와는 관계가 없이 어떤 자가 본인을 대리하여 제3자와 법률행위를 함에 있어 본인이 그 자에게 대리권을 수여하였다는 표시를 제3자에게 한 경우에 성립하는 것이고, 이 때 서류를 교부하는 방법으로 민법 제125조 소정의 대리권 수여의 표시가 있었다고 하기 위하여는 본인을 대리한다고 하는 자가 제출하거나 소지하고 있는 서류의 내용과 그러한 서류가 작성되어 교부된 경위나 형태 및 대리행위라고 주장하는 행위의 종류와 성질 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

대법원 1983.12.13. 83다카1489 전원합의체

유권대리에 있어서는 본인이 대리인에게 수여한 대리권의 효력에 의하여 법률효과가 발생하는 반면 표현대리에 있어서는 대리권이 없음에도 불구하고 법률이 특히 거래상대방 보호와 거래안전유지를 위하여 본래 무효인 무권대리행위의 효과를 본인에게 미치게 한 것으로서, 표현대리가 성립된다고 하여 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니므로, 양자의 구성요건 해당사실 즉 주요사실은 다르다고 볼 수 밖에 없으니 유권대리에 관한 주장 속에 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수 없다.

☞ 대리권이 있다는 것과 표현대리가 성립한다는 것은 그 요건사실이 다르므로 유권대리의 주장이 있으면 표현대리의 주장이 당연히 포함되는 것은 아니다(대법원 1990.03.27. 88다카181).

대법원 1996.07.12. 95다49554

표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다.

2) 제126조의 표현대리(권한을 넘은 표현대리)

제126조 【권한을 넘은 표현대리】

대리인이 그 권한 외의 법률행위를 한 경우에 제3자가 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 때에는 본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다.

① 의의

일정한 범위의 대리권을 가진 대리인이 그 권한을 넘는 대리행위를 한 경우를 말한다. 일명 월권대리라고도 한다.

② 요건

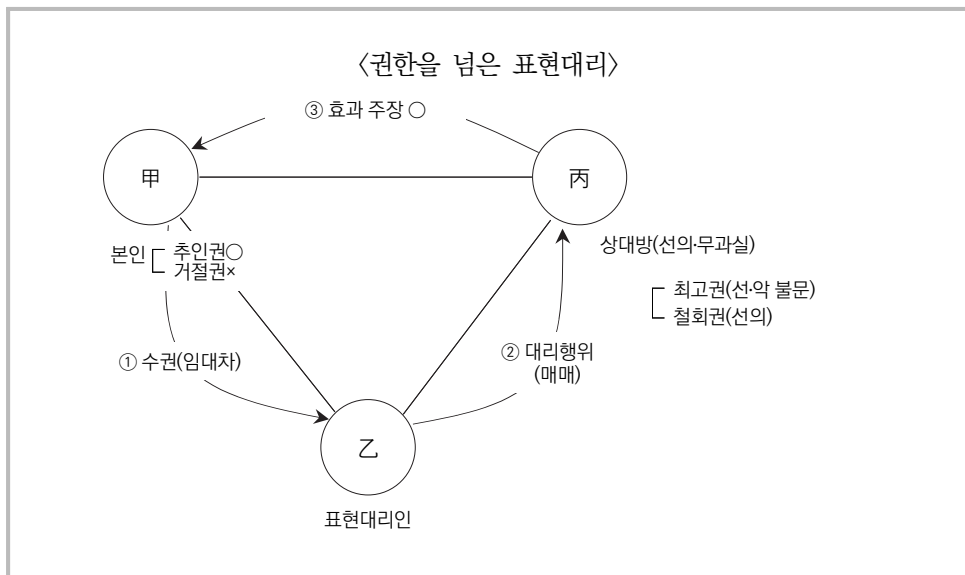
- ㉠ 대리인이 권한 밖의 대리행위를 하였을 것
- ㉡ 대리인의 기본적인 대리권과 월권된 행위가 반드시 동종, 유사일 것을 요하지 않는다는 것이 통설·판례의 태도이다.
- ㉢ 상대방은 선의 그리고 무과실일 것. 즉, 상대방이 대리권한이 있다고 믿고, 그러한 믿음에 정당한 이유가 있을 것을 요한다. 정당한 이유의 판단시점은 대리행위시를 기준으로 한다는 것이 다수설·판례의 태도이다.
- ㉣ 정당한 이유의 증명책임에 대하여서도 학설의 대립이 있으나 상대방이 증명하여야 한다는 것이 판례의 태도이다.

③ 효과

본인은 대리인의 권한 밖의 행위에 대하여 책임이 있다. 아울러 제125조의 표현대리에서의 효과는 그대로 본조에도 적용된다.

④ 본조의 적용범위

- ㉠ 본조는 임의대리 외에도 법정대리에도 적용된다.
- ㉡ 일상가사대리권(日常家事代理權)도 법정대리권의 일종으로 그것을 기본대리권으로 하여 본조가 적용된다.
- ㉢ 사실혼 관계에 있는 부부간에도 일상가사에 관한 대리권이 인정되므로, 이를 기본대리권으로 하는 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.



대법원 1981.06.23. 80다609

처가 남편의 승낙 없이 그의 부동산에 대해 담보목적의 가등기를 설정하는 것은 일상가사 대리권의 범위를 벗어난 것이지만, 일상가사대리권에도 제126조의 적용이 있으므로, 제3자(상대방)가 처에게 그 권한이 있다고 믿는 것에 정당한 이유가 있다면 남편은 그에 관해 책임을 져야 한다.

대법원 2016.6.9. 2014다58139

남편이 처에게 타인의 채무를 보증함에 필요한 대리권을 수여한다는 것은 사회통념상 이례에 속하므로, 처가 특별한 수권 없이 남편을 대리하여 위와 같은 행위를 하였을 경우에 그것이 민법 제126조 표현대리가 되려면 처에게 일상가사대리권이 있었다는 것만이 아니라 상대방이 처에게 남편이 그 행위에 관한 대리권한을 주었다고 믿었음을 정당화할 만한 객관적인 사정이 있어야 한다.

대법원 2001.03.09. 2000다67884

권한을 넘은 표현대리에 있어 대리인에게 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는지 여부는 행위 당시를 기준으로 판단하여야 하고, 그 이후의 사정은 고려하지 않는다.

대법원 2002.06.28. 2001다49814

민법 제126조의 표현대리는 대리인이 본인을 위한다는 의사를 명시 혹은 묵시적으로 표시 하거나 대리의사를 가지고 권한 외의 행위를 하는 경우에 성립하고, 사술을 써서 위와 같은 대리행위의 표시를 하지 아니하고 단지 본인의 성명을 모용하여 자기가 마치 본인인 것처럼 기망하여 본인 명의로 직접 법률행위를 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 표현대리는 성립될 수 없다.

대법원 1978.10.10. 78다75

인감증명서는 인장사용에 부수해서 그 확인방법으로 사용되며 인장사용과 분리해서 그것만 으로서는 어떤 증명방법으로 사용되는 것이 아니므로 인감증명서만의 교부는 일반적으로 어떤 대리권을 부여하기 위한 행위라고 볼 수 없다.

☞ 부동산매도에 관하여 인장 및 등기서류를 교부한 때에는 일반적으로 대리권을 수여한 것으로 해석되나, 인감증명서만의 교부는 일반적으로 어떤 대리권을 부여하기 위한 행위 라고 볼 수 없다.

대법원 1978.03.28. 78다282,283

기본대리권이 등기신청행위(공법행위)라 할지라도 표현대리인이 그 권한을 초과하여 대물변제(또는 매매)라는 사법행위를 한 경우에는 표현대리의 법리가 적용된다.

대법원 1963.11.21. 63다418

제126조의 표현대리는 문제된 법률행위와 수여받은 대리권 사이에 아무런 관계가 없는 경우에도 적용이 있다.

☞ 제126조의 표현대리에서 기본행위와 월권된 행위는 동종, 유사할 것을 요하지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

대법원 1994.05.27. 93다21521

권한을 넘은 표현대리에 관한 민법 제126조의 규정에서 제3자라 함은 당해 표현대리행위의 직접 상대방이 된 자만을 지칭하는 것이고, 이는 약속어음의 배서행위의 직접 상대방은 그 배서에 의하여 어음을 양도받은 피배서인만을 가리키고 그 피배서인으로부터 다시 어음을 취득한 자는 민법 제126조 소정의 제3자에는 해당하지 아니한다.

☞ 표현대리의 규정에서의 제3자란 대리행위의 직접 상대방을 의미하는 것이며, 그로부터 전득한 자는 제3자에 해당하지 않는다.

3) 제129조의 표현대리(대리권소멸 후의 표현대리)

제129조 【대리권소멸후의 표현대리】

대리권의 소멸은 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 그러나 제3자가 과실로 인하여 그 사실을 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다.

① 의의

이전에는 대리권을 가지고 있었으나 대리행위를 할 때에는 대리권이 소멸하고 있는 경우를 말한다.

② 요건

㉠ 대리행위를 할 때에는 대리권이 존재하지 않을 것

㉡ 상대방은 선의 그리고 무과실일 것. 본인이 상대방의 악의 또는 과실을 증명하여야 한다.

③ 효과

본인은 상대방에 대하여 대리권의 소멸을 가지고 대항하지 못한다.

④ 본조의 적용범위

본조는 임의대리와 법정대리 양자에 적용된다.

중요판례

대법원 1998.05.29. 97다55317

대리인이 대리권소멸 후 직접 상대방과 사이에 대리행위를 하는 경우는 물론 대리인이 대리권소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에 대리행위를 하도록 한 경우에도, 상대방이 대리권소멸 사실을 알지 못하여 복대리인에게 적법한 대리권이 있는 것으로 믿었고 그와 같이 믿은 데 과실이 없다면 제129조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다.

대법원 2008.01.31. 2007다74713

- [1] 민법 제129조에 의한 표현대리가 인정되는 경우, 그 표현대리의 권한을 넘는 대리행위가 있을 때 민법 제126조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다.
 - [2] 과거에 가졌던 대리권이 소멸되어 민법 제129조에 의하여 표현대리로 인정되는 경우에 그 표현대리의 권한을 넘는 대리행위가 있을 때에는 제126조에 의한 표현대리가 성립할 수 있고, 또한, 표현대리의 효과를 주장하려면 상대방이 대리권이 있다고 믿고 그와 같이 믿는 데 정당한 이유가 있을 것을 요건으로 하는 것인데, 여기의 정당한 이유의 존부는 대리행위가 행하여 질 때에 존재하는 제반 사정을 객관적으로 관찰하여 판단하여야 한다.
- ☞ 대리권 소멸후의 표현대리가 인정되는 경우, 그 표현대리의 권한을 넘는 대리행위가 있을 때에는 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.

대법원 2016.5.12. 2013다49381

계약체결의 요건을 규정하고 있는 강행법규에 위반한 계약은 무효이므로 그 경우에 계약 상대방이 선의·무과실이더라도 민법 제107조의 비진의표시의 법리 또는 표현대리 법리가 적용될 여지는 없다.

〈3개 표현대리의 공통점〉

구분	표현대리(제125조·제126조·제129조)
요건상의 공통점	㉠ 상대방은 선의·무과실이어야 한다. ㉡ 상대방의 악의 또는 과실의 증명책임은 본인에게 있다(제126조의 표현대리는 상대방이 선의·무과실을 증명하여야 한다는 것이 판례). ㉢ 제3자란 대리행위의 상대방만을 의미한다. ㉣ 제125조의 표현대리는 임의대리에만 적용된다. 제126조·제129조의 표현대리는 임의대리, 법정대리의 양자 모두에 적용된다.
효과상의 공통점	㉠ 상대방은 최고권·철회권을 행사할 수 있다. ㉡ 본인은 추인권을 행사할 수 있다. ㉢ 본인은 표현대리인에 대하여 손해배상을 청구할 수 있고, 기타 부당이득이 성립한다.

제6절 무효와 취소

1. 서론

(1) 무효와 취소의 의의

법률행위의 무효란 당사자가 의도한 법률행위의 효력이 법률상 처음부터 생기지 않는 것을 말한다. 무효는 취소와 함께 법률행위의 효력요건을 결여하고 있기 때문에 법률행위에 법적 효과가 주어지지 않는 경우지만, 양자는 성질을 달리한다. 즉, 법률행위의 취소는 일단 유효하게 성립한 법률행위를 후에 취소의 의사표시에 의하여 무효로 하는 것이다. 따라서 무효는 원칙적으로 처음부터 누구에 대해서도 또 누구에 의해서도 무효를 주장할 수 있으며, 그 효과가 확정적이다. 그러나 취소는 취소권자만이 주장할 수 있고, 취소하기까지는 일단 유효로 다루어지나 취소권을 행사하면 소급하여 그 법률행위는 무효가 된다.

(2) 무효와 취소의 구별

분류	무효	취소
특정인의 주장	특정인의 주장을 필요로 하지 않고 당연무효이다.	특정인(취소권자)의 주장이 있어야 비로소 효력이 없게 된다.
성립시의 효력	처음부터 효력이 없다.	취소를 하기 전에는 일단은 효력이 있는 것으로 다루어진다.
추인의 차이	새로운 법률행위로 본다. (비소급적 추인)	취소권의 포기과 같다.
시간의 경과와 보정(補正)	시간의 경과에 의하여 효력에 변동이 생기지 않고 언제나 무효이다.	① 일정한 시간이 경과하면 취소권이 소멸한다. ② 취소권을 행사하면 무효, 방치하면 유효가 된다.

(3) 무효인 법률행위와 취소할 수 있는 법률행위

무효인 법률행위	취소할 수 있는 법률행위
① 의사무능력자의 법률행위 ② 원시적 불능인 법률행위 ③ 강행법규(효력규정)에 위반한 법률행위(제105조) ④ 반사회질서의 법률행위(제103조) ⑤ 불공정한 법률행위(제104조)	① 제한능력자의 행위(제5조·제10조 등) ② 착오에 의한 의사표시(제109조) ③ 사기·강박에 의한 의사표시(제110조)
⑥ 비진의 의사표시(상대방의 악의, 과실)(제107조) ⑦ 통정허위표시(제108조)	
①~⑤ : 절대적 무효(추인 不可) ⑥·⑦ : 상대적 무효(추인 가능)	① : 절대적 취소(추인 가능) ②·③ : 상대적 취소(추인 가능)

2. 법률행위의 무효

(1) 무효의 의의

- ① 무효인 법률행위가 물건행위이면 물건변동이 일어나지 않으며, 채권행위인 경우에는 채권은 발생하지 않는다.
- ② 무효인 법률행위는 아직 이행 전이면 이행할 필요가 없으며, 이행 후이면 상대방에 대하여 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다. 다만, 불법을 원인으로 한 무효는 불법원인급여로 인해 반환청구를 행하지 못한다.
- ③ 양 당사자가 서로 부당이득반환의무를 부담하는 경우에는 양자의 의무는 동시 이행의 관계에 선다.
- ④ 법률행위의 무효는 누구나 주장할 수 있다. 다만, 해석상 특정인만이 주장할 수 있는 경우가 있다(비진의 의사표시로 인한 무효).
- ⑤ 법률행위의 무효는 언제까지나 주장할 수 있으나 실제로는 무효에 의한 부당이득 반환청구권이 소멸시효에 걸리기 때문에 그 행사가 제한되는 경우가 있다.

(2) 무효의 종류

1) 상대적 무효와 절대적 무효

① 상대적 무효

- ㉠ 특정인에 대하여서는 주장할 수 없는 무효이다.
- ㉡ 허위표시·비진의표시의 예외의 경우가 이에 해당한다.

② 절대적 무효

- ㉠ 누구에게나 그 효과를 주장할 수 있는 무효이다.
- ㉡ 상대적 무효 이외의 전부가 이에 해당한다.

2) 당연무효와 재판상 무효

- ① 당연무효 : 법률행위를 무효로 하기 위하여 특별한 행위나 절차를 요하지 않는 무효를 말한다.
- ② 재판상 무효
 - ㉠ 재판에 의한 무효선고를 요하는 무효이다.
 - ㉡ 회사설립의 무효, 회사합병의 무효 등이 그 예이다.

3) 전부무효와 일부무효

제137조 【법률행위의 일부무효】

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다.

- ① 전부무효 : 법률행위의 내용의 전부에 관하여 무효원인이 있는 경우이다.
- ② 일부무효
 - ㉠ 원칙 : 일부무효의 법리에 따라 법률행위 전부를 무효로 한다(제137조).
 - ㉡ 예외 : 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였으리라 인정될 때에는 나머지 부분은 유효하다(제137조 단서).

중요판례

대법원 1993.12.14. 93다45930

매매계약이 그 목적물 중 개발제한구역에 관한 부분에 관하여서만 무효라고 하더라도, 민법 제137조에 따라서 원칙적으로 위 매매계약의 전부가 무효가 되며, 다만 그 무효부분이 없더라도 위 매매계약을 체결하였을 것이라고 인정될 때에 한하여 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다.

4) 유동적 무효

① 의의

현재는 무효이나 추후에 허가 또는 주인이 있게 되면 소급하여 유효한 것으로 될 수 있는 것을 유동적 무효라고 한다.

② 확정적 무효사유

㉠ 불허가 처분을 받은 경우

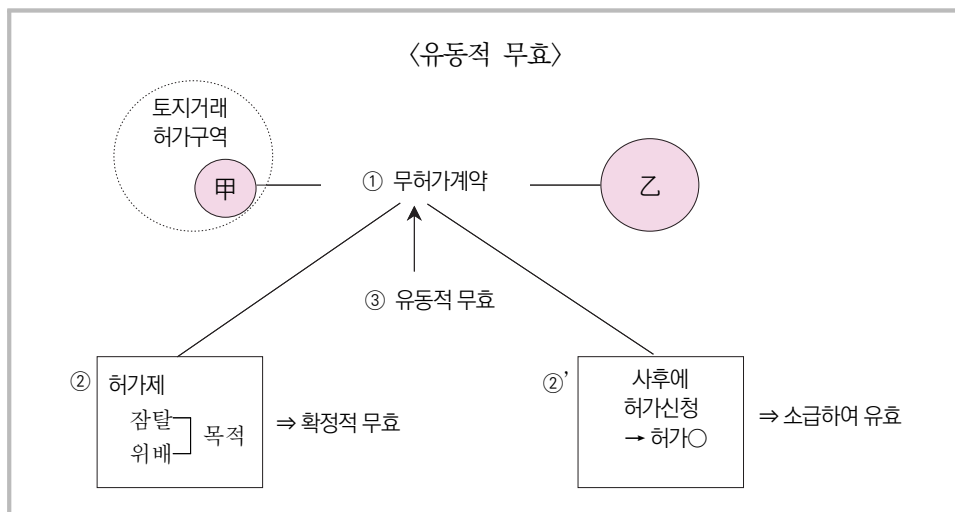
㉡ 허가신청에 대한 이행거절의 의사를 명백히 한 경우

㉢ 처음부터 허가를 배제하거나 잠탈(潛脫)하는 내용의 계약을 체결한 경우 등

③ 확정적 유효사유

㉠ 허가구역지정이 해제된 경우

㉡ 허가구역지정의 기간 만료 후 재지정이 없는 경우 등



대법원 1991.12.24. 90다12243

국토의 계획 및 이용에 관한 법률(2016.1.19 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률’로 토지거래 허가제 이관됨, 이하 같다)의 허가구역 내의 토지에 대하여 관할 도지사의 허가를 받기 전에 체결한 매매계약은 허가받을 것을 전제로 한 계약일 경우에는 허가를 받을 때까지는 법률상의 미완성의 법률행위로서 소유권 등 권리의 이전에 관한 계약의 효력이 전혀 발생하지 않음은 위의 확정적 무효의 경우와 다를 바 없지만, 일단 허가를 받으면 그 계약은 소급하여 유효한 계약이 되고, 이와 달리 불허가가 된 때에는 무효로 확정되므로 허가를 받기까지는 유동적 무효의 상태에 있다고 보며, 허가받을 것을 전제로 한 거래계약은 허가받기 전의 상태에서 거래계약의 채권적 효력도 전혀 발생하지 않으므로 권리의 이전 또는 설정에 관한 어떠한 내용의 이행청구도 할 수 없다.

대법원 1991.12.24. 90다12243

위 계약이 효력 있는 것으로 완성될 수 있도록 서로 협력할 의무가 있음이 당연하므로, 계약의 쌍방당사자는 공동으로 관할 관청의 허가를 신청할 의무가 있고, 이러한 의무에 위반하여 허가신청절차에 협력하지 않는 당사자에 대하여 상대방은 협력의무의 이행을 소송으로써 구할 수 있다.

대법원 1993.07.27. 91다33766

유동적 무효상태의 매매계약을 체결하고 매수인이 이에 기하여 임의로 지급한 계약금은 그 계약이 유동적 무효상태로 있는 한 이를 부당이득으로 반환을 구할 수 없고 유동적 무효 상태는 확정적으로 무효가 되었을 때 비로소 부당이득으로 그 반환을 구할 수 있다.

대법원 1993.06.22. 91다21435

유동적 무효 상태 하에서 당사자 일방이 허가신청협력의무의 이행거절의사를 명백히 표시한 경우에는, 계약의 유동적 무효상태가 더 이상 지속한다고 볼 수는 없고 그 계약관계는 확정적으로 무효라고 보아야 한다.

대법원 1997.11.14. 97다36118

거래허가를 받지 아니한 거래계약은 처음부터 위 허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 계약이 아닌 한 허가를 받기까지는 유동적 무효의 상태에 있고 거래 당사자는 거래허가를 받기 위하여 서로 협력할 의무가 있으나, 그 토지거래가 계약 당사자의 표시와 불일치한 의사(비진의표시, 허위표시 또는 착오) 또는 사기, 강박과 같은 하자 있는 의사에 의하여 이루어진 경우에는, 이들 사유에 의하여 그 거래의 무효 또는 취소를 주장할 수 있는 당사자는 그러한

거래허가를 신청하기 전 단계에서 이러한 사유를 주장하여 거래허가신청 협력에 대한 거절 의사를 일방적으로 명백히 함으로써 그 계약을 확정적으로 무효화시키고 자신의 거래허가 절차에 협력할 의무를 면할 수 있다.

대법원 1997.06.27. 97다9369

매매당사자 일방이 계약 당시 상대방에게 계약금을 교부한 경우 당사자 사이에 다른 약정이 없는 한 당사자 일방이 계약이행에 착수할 때까지 계약금 교부자는 이를 포기하고 계약을 해제할 수 있고, 그 상대방은 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제할 수 있음이 계약 일반의 법리인 이상, 특별한 사정이 없는 한 국토이용관리법상의 토지거래허가를 받지 않아 유동적 무효상태인 매매계약에 있어서도 당사자 사이의 매매계약은 매도인이 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제함으로써 적법하게 해제된다.

대법원 1999.06.17. 98다40459 전원합의체

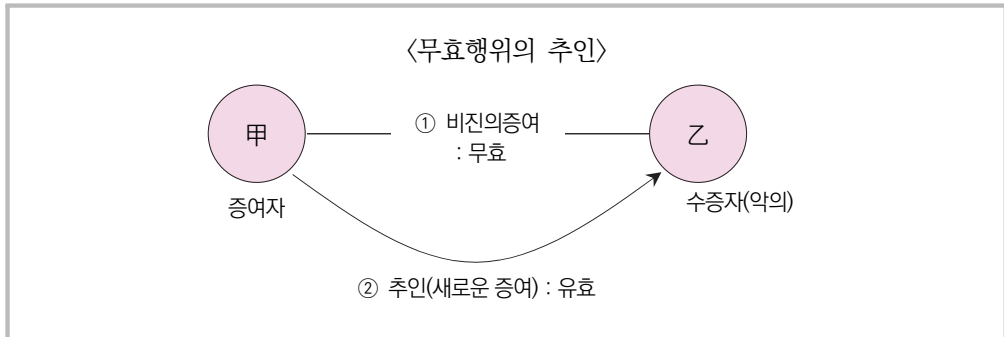
허가구역 지정기간 중에 허가구역 안의 토지에 대하여 토지거래허가를 받지 아니하고 토지 거래계약을 체결한 후 허가구역 지정해제 등이 된 때에는 그 토지거래계약이 허가구역 지정이 해제되기 전에 확정적으로 무효로 된 경우를 제외하고는, 더 이상 관할 행정청으로부터 토지거래허가를 받을 필요가 없이 확정적으로 유효로 되어 거래당사자는 그 계약에 기하여 바로 토지의 소유권 등 권리의 이전 또는 설정에 관한 이행청구를 할 수 있고, 상대방도 반대급부의 청구를 할 수 있다고 보아야 할 것이지, 여전히 그 계약이 유동적 무효상태에 있다고 볼 것은 아니다.

(3) 무효행위의 추인

제139조 【무효행위의 추인】

무효인 법률행위는 추인하여도 그 효력이 생기지 아니한다. 그러나 당사자가 그 무효임을 알고 추인한 때에는 새로운 법률행위로 본다.

- ① 당사자가 법률행위의 무효임을 알고서 추인한 경우에는 그 때부터 새로운 법률 행위를 한 것으로 본다. 따라서 무효행위의 추인은 소급효가 없는 것이 원칙이나 (제139조), 예외적으로 당사자 사이에서만 소급효를 인정하는 것은 무방하다(통설).
- ② 절대적 무효에 해당하는 법률행위는 추인하여도 유효로 될 여지가 없다.
- ③ 추인은 명시적 또는 묵시적으로도 할 수 있다.



중요판례

대법원 1983.09.27. 83므22

무효인 행위의 추인이라 함은 법률행위로서의 효과가 확정적으로 발생하지 아니하는 무효 행위를 뒤에 이를 유효하게 하는 의사표시를 말하는 것으로 원래 무효인 행위는 그 효과가 발생하지 않는 것으로 확정되어 있는 것이므로 그 뒤의 어떤 사유에 의하여도 이를 유효하게 할 수는 없는 것이나, 법은 편의상 당사자의 의사를 추측하여 추인에 의하여 이것을 새로운 행위를 한 것으로 보아 유효하게 하고 있는 것으로, 따라서 이 경우의 추인은 무효행위를 사후에 유효로 하는 것이 아니라 새로운 의사표시에 의하여 새로운 행위가 있는 것으로 하여 그 때부터 유효하게 되는 것이므로, 추인은 '법률행위'이며, 또 무효행위의 추인에는 원칙적으로 소급효가 인정되지 않는다.

대법원 2009.10.29. 2009다47685

집합채권의 양도가 양도금지특약에 위반해서 무효인 경우 채무자는 일부 개별 채권을 특정하여 추인하는 것이 가능하다.

대법원 1992.05.12. 91다26546

무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인할 경우 새로운 법률행위를 한 것으로 간주할 뿐이고 소급효가 없는 것이므로 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용키로 한 약정은 그 때부터 유효하고 이로써 위 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.

(4) 무효행위의 전환

제138조 【무효행위의 전환】

무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서 효력을 가진다.

1) 의의

무효행위의 전환이란 법률행위의 당사자가 본래 의욕한 대로 법률효과가 발생하지 못하는 무효인 행위이지만 그 행위가 다른 법률행위로서의 요건을 갖추고, 당사자가 그러한 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕 하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서의 효력발생을 인정하는 것을 말한다(제138조).

2) 요건

- ① 일단 성립한 법률행위가 무효이어야 한다.
- ② 당사자가 그 법률행위의 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라는 것이 인정되어야 한다.

3) 전환의 모습

- ① 불요식행위로서 무효인 것을 다른 불요식행위로의 전환이 인정된다.
- ② 요식행위로서 무효인 것을 다른 불요식행위로의 전환이 인정된다.
- ③ 요식행위로서 무효인 것을 다른 요식행위로서의 전환이 인정된다.
- ④ 불요식행위로서 무효인 것을 다른 요식행위로의 전환은 인정되지 않는다.

3. 법률행위의 취소

(1) 본래 의미의 취소

- ① 법률행위의 취소라 함은 원칙적으로 제한능력 또는 의사표시가 착오·사기·강박으로 행하여졌다는 것을 이유로 일단 유효하게 성립한 법률행위의 효력을 후에 행위시에 소급하여 소멸케 하는 특정인(취소권자)의 의사표시를 말한다.
- ② 취소는 철회와 구별된다. 철회는 법률행위의 효과가 발생하기 전에 그 효과의 발생을 방지하는 행위이며 소급효가 없다.

- ③ 취소는 해제와도 구별된다. 해제는 일단 유효하게 성립한 계약의 효력을 소멸케 하는 행위이다.

(2) 취소권자

제140조 【법률행위의 취소권자】

취소할 수 있는 법률행위는 제한능력자, 착오로 인하거나 사기·강박에 의하여 의사표시를 한 자, 그의 대리인 또는 승계인만이 취소할 수 있다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{제한능력자} \\ \text{착오} \\ \text{사기·강박} \end{array} \right] \text{에 의한 의사표시자·대리인·승계인}$$

1) 대리인

- ① 법정대리인
- ② 임의대리인. 다만, 임의대리인이 취소권을 행사하려면 본인으로부터 취소에 대한 별도의 수권이 있어야 한다.

2) 승계인

- ① 포괄승계인
- ② 특정승계인. 그러나 취소권만의 승계는 인정되지 아니한다.

(3) 취소의 방법

제142조 【취소의 상대방】

취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 확정된 경우에는 그 취소는 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다.

- ① 취소권은 형성권으로서 권리자의 일방적 의사표시(상대방 있는 단독행위)로써 행한다.

- ② 취소권의 행사는 특별한 방식을 요하지 않으며 명시적으로 하든 묵시적으로 하든 무방하다.
- ③ 취소의 상대방은 본래의 법률행위의 상대방이 된다.

중요판례

대법원 1993.09.14. 93다13162

법률행위의 취소는 상대방에 대한 의사표시으로써 하여야 하나, 그 취소의 의사표시는 특별히 재판상 행하여짐이 요구되는 이외에는 특정한 방식이 요구되는 것이 아니고, 취소의 의사가 상대방에 의하여 인식될 수 있다면 어떠한 방법에 의하더라도 무방하다 할 것이고, 법률행위의 취소를 당연한 전제로 한 소송상의 이행청구나 이를 전제로 한 이행거절 가운데는 취소의 의사표시가 포함되어 있다고 본다.

대법원 2002.09.10. 2002다21509

하나의 법률행위의 일부분에만 취소사유가 있다고 하더라도 그 법률행위가 가분적이거나 그 목적물의 일부가 특정될 수 있다면, 그 나머지 부분이라도 이를 유지하려는 당사자의 가정적 의사가 인정되는 경우 그 일부만의 취소도 가능하다고 할 것이고, 그 일부의 취소는 법률행위의 일부에 관하여 효력이 생긴다.

(4) 취소의 효과

제141조 【취소의 효과】

취소한 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다. 그러나 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.

- ① 취소권을 행사하면 소급적으로 그 법률행위는 무효가 된다(제141조).
- ② 제한능력자의 취소를 제외하고는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.
- ③ 취소권을 행사함으로써 아직 이행하기 전이면 이행을 요하지 아니하며, 이미 이행한 후이면 상대방에 대하여 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 이미 이행이 된 경우에 부당이득반환의 모습은 원물이 남아 있으면 소유권에 기한 반환청구를 하고, 원물이 없거나 반환불능인 경우에는 가액에 따른 부당이득반환청구를 행한다.
- ⑤ 제한능력자가 부당이득반환의무를 부담하는 경우에는 항상 현존이익만을 반환하면 되는 특칙이 있다(제141조 단서).

(5) 취소할 수 있는 행위의 추인

제143조 【추인의 방법, 효과】

- ① 취소할 수 있는 법률행위는 제140조에 규정한 자가 추인할 수 있고 추인 후에는 취소하지 못한다.
- ② 전조의 규정은 전항의 경우에 준용한다.

제144조 【추인의 요건】

- ① 추인은 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야만 효력이 있다.
- ② 제1항은 법정대리인 또는 후견인이 추인하는 경우에는 적용하지 아니한다.

1) 의의

- ① 취소할 수 있는 법률행위를 취소하지 않겠다는 의사표시를 말한다.
- ② 상대방 있는 단독행위이다.
- ③ 형성권에 해당한다.
- ④ 취소권의 포기에 해당한다.

2) 요건

- ① 추인권자가 행사하여야 한다.
- ② 취소의 원인이 종료한 후에 행사하여야 한다. 다만, 법정대리인은 이러한 제한을 받지 않는다.
- ③ 미성년자나 피한정후견인은 법정대리인의 동의를 얻으면 능력자가 되기 전이라도 추인할 수 있으며, 피성년후견인은 동의를 얻더라도 추인하지 못한다.
- ④ 취소할 수 있는 법률행위임을 알고서 행사하여야 한다.

3) 효과

일단 추인한 후에는 다시는 취소할 수 없으며, 그 법률행위는 유효한 것으로 확정된다.

중요판례

대법원 1982.06.08. 81다107

강박에 의하여 채무인수의 의사표시를 하고 그 상태를 벗어나지 못한 상태에서 한 근저당권 설정계약서작성 및 교부행위는 취소의 원인이 종료되기 전에 한 추인에 불과하여 추인으로서의 효력이 없다.

대법원 1997.12.12. 95다38240

취소한 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 간주되므로 법률행위가 일단 취소된 이상 그 후에는 추인에 의하여 이미 취소되어 무효인 것으로 간주된 의사표시를 다시 확정적으로 유효하게 할 수는 없고, 다만 무효행위의 추인의 요건과 효력으로서 추인할 수는 있다. 아울러 무효행위의 추인은 그 무효 원인이 소멸한 후에 하여야 그 효력이 있고, 무효 원인이 소멸한 후란 것은 당초의 의사표시의 성립 과정에 존재하였던 취소의 원인이 종료된 후, 즉 강박 상태에서 벗어난 후라고 보아야 한다.

(6) 법정추인

제145조 【법정추인】

취소할 수 있는 법률행위에 관하여 전조의 규정에 의하여 추인할 수 있는 후에 다음 각호의 사유가 있으면 추인한 것으로 본다. 그러나 이의를 보류한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 전부나 일부의 이행
2. 이행의 청구
3. 경계
4. 담보의 제공
5. 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도
6. 강제집행

1) 의의

- ① 추인이라고 인정할 수 있는 일정한 사실이 있을 때 법률상 당연히 추인이 있었던 것으로 간주되는 것을 말한다(제145조).
- ② 취소권의 단기소멸제도와 함께 취소권자의 상대방보호와 법률관계의 안정을 도모하기 위한 제도에 해당한다.
- ③ 취소권자가 이의를 보류하지 않았어야 한다(제145조 단서).

2) 법정추인사유

- ① 전부나 일부의 이행
 - ㉠ 취소권자가 이행한 경우를 말한다.
 - ㉡ 취소권자가 상대방의 이행을 수령한 경우도 포함한다.

- ② 이행의 청구 : 취소권자가 상대방에게 청구한 경우에 한한다.
- ③ 경개(更改)

취소권자가 채권자 또는 채무자로서 구채권·채무를 소멸시키고 신채권·채무를 성립시키는 계약을 체결한 경우를 말한다.
- ④ 담보의 제공
 - ㉠ 취소권자가 채무자로서 담보를 제공하거나 채권자로서 담보의 제공을 받는 경우가 이에 해당한다.
 - ㉡ 담보의 제공은 인적·물적 담보를 불문한다.
- ⑤ 권리의 양도
 - ㉠ 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부를 양도하는 것을 말한다.
 - ㉡ 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리 위에 제한물권을 설정하는 것을 포함한다.
- ⑥ 강제집행

취소권자가 채권자로 집행하는 경우와 취소권자가 채무자로서 집행을 받는 경우도 포함한다.

3) 효 과

법정추인 역시 추인으로 간주되므로 다시는 취소권을 행사하지 못한다.

법정추인사유	내용
전부나 일부의 이행	취소권자가 이행한 경우 또는 취소권자가 상대방의 이행을 수령한 경우에는 추인으로 본다.
이행의 청구	취소권자가 상대방에게 청구한 경우에 한한다.
경 개	취소권자가 채권자 또는 채무자로서 경개계약을 체결한 경우를 말한다.
강제집행	취소권자가 채권자로 집행하는 경우 또는 취소권자가 채무자로서 집행을 받는 경우를 포함한다.
담보의 제공	취소권자가 채무자로서 담보를 제공하거나 채권자로서 담보의 제공을 받는 경우가 이에 해당한다.
취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도	취소권자가 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부를 양도하는 것을 말한다.

(7) 취소권의 단기소멸

제146조 【취소권의 소멸】

취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.

- ① 추인할 수 있는 날로부터 3년 내, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 취소권을 행사하지 아니하면 취소권은 소멸한다(제146조).
- ② 취소권자의 상대방보호제도에 해당한다.
- ③ 두 기간 중 어느 것이든 먼저 경과하면 취소권은 소멸한다(통설).
- ④ 제146조가 규정하고 있는 기간은 제척기간으로 보는 것이 통설·판례의 태도이다.

중요판례

대법원 1996. 09. 20. 96다25371

민법 제146조는 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에 행사하여야 한다고 규정하고 있는바, 이때의 3년이라는 기간은 일반 소멸시효기간이 아니라 제척기간으로서 제척기간이 도과하였는지 여부는 당사자의 주장에 관계없이 법원이 당연히 조사하여 고려하여야 할 사항이다.

대법원 1998.11.27. 98다7421

민법 제146조 전단은 “취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에 행사하여야 한다.”고 규정하는 한편, 민법 제144조 제1항에서는 “추인은 취소의 원인이 종료한 후에 하지 아니하면 효력이 없다.”고 규정하고 있는 바, 위 각 규정의 취지와 추인은 취소권의 포기를 내용으로 하는 의사표시인 점에 비추어 보면, 민법 제146조 전단에서 취소권의 제척기간의 기산점으로 삼고 있는 「추인할 수 있는 날」이란 취소의 원인이 종료되어 취소권행사에 관한 장애가 없어져서 취소권자가 취소의 대상인 법률행위를 추인할 수도 있고 취소할 수도 있는 상태가 된 때를 가리킨다고 보아야 한다.

☑ 소급효 있는 행위와 소급효 없는 행위

소급효 있는 행위	소급효 없는 행위
① 실종선고의 취소(제29조) ② 제한능력자의 법률행위의 취소(제5조 제2항·제10조·제13조) ③ 착오·사기·강박에 의한 의사표시의 취소(제109조·제110조) ④ 무권대리행위의 추인(제133조) ⑤ 소멸시효의 완성(제167조) ⑥ 선택채권에 있어서의 선택(제386조) ⑦ 상속재산의 분할(제1015조) ⑧ 상계(제493조) ⑨ 계약의 해제(제548조) ⑩ 이혼의 취소(제838조) ⑪ 인지(제860조)	① 미성년자의 영업허락의 취소(제8조) ② 성년후견종료의 심판(제11조) ③ 한정후견종료의 심판(제14조) ④ 부재자재산관리명령의 취소(제22조) ⑤ 법인설립허가의 취소(제38조) ⑥ 무효행위의 추인(제139조) ⑦ 기한부 법률행위의 효력(제152조) ⑧ 혼인의 취소(제824조) ⑨ 계약의 해지(제550조) ⑩ 입양의 취소(제897조) ⑪ 조건의 성취(제147조) ⑫ 공유물의 분할(제269조)

1. 서론

(1) 의의

부관이란 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸에 관하여 이를 제한하기 위하여 주된 의사표시에 부가하는 종된 의사표시를 말한다. 이러한 부관에는 조건과 기한, 그리고 부담이 있으며 사적자치의 원칙상 법률행위에 부관을 붙이는 것을 인정하고 있다.

2. 조건

(1) 조건의 의의

법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부(成否)에 의존하게 하는 법률행위의 부관을 말한다.

(2) 가장조건(假裝條件)

1) 의의

외관상·형식상으로는 조건이지만 실질적으로는 조건으로 인정하지 못하는 것을 말한다.

2) 종류

① 법정조건 : 법률의 규정에 의해 부가된 조건을 말하며 조건으로서의 의미가 없다.

┃ ㉠ 법인설립에 있어서의 주무관청의 허가

㉡ 유언에 있어서의 유언자의 사망

② 불법조건 : 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 조건으로서 조건만이 무효가 아니라 법률행위 전부를 무효로 한다.

┃ 물건을 훔쳐 오면, 대가를 지급하겠다.

③ 기성조건 : 법률행위 당시에 이미 성립하고 있는 조건으로서 기성조건이 정지 조건이면 조건 없는 법률행위(유효)가 되고, 기성조건이 해제조건이면 무효이다 (제151조 제2항).

- ④ 불능조건 : 객관적으로 실현이 불가능한 사실을 내용으로 하는 조건으로서 불능조건이 정지조건이면 무효이고, 불능조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위(유효)가 된다(제151조 제3항).

불능조건 + 정지조건 : 무효
 불능조건 + 해제조건 : 유효(= 조건없는 법률행위)
 기성조건 + 정지조건 : 유효(= 조건없는 법률행위)
 기성조건 + 해제조건 : 무효

(3) 조건의 종류

1) 정지조건과 해제조건

- ① 법률행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존하게 하는 조건을 정지조건이라 한다.

┃ 시험에 합격하면, 학비를 주겠다.

- ② 법률행위의 효력의 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존하게 하는 조건을 해제조건이라 한다.

┃ 시험에 합격할 때까지, 생활비를 보조하겠다.

2) 적극조건과 소극조건

- ① 조건이 되는 사실이 현상의 변경에 있는 경우에 이를 적극조건이라 한다.

┃ 매매대금을 지급하면, 소유권을 이전해 주겠다.

- ② 조건이 되는 사실이 현상의 불변경에 있는 경우를 소극조건이라 한다.

┃ 매매대금을 지급하지 않으면, 계약을 해제하겠다.

3) 수의조건과 비수의조건

① 수의조건

- ㉠ 순수수의조건 : 일방의 의사에만 의존하는 조건으로서 무효이다.

┃ 내마음이 내키면, 변제하겠다.

- ㉡ 단순수의조건 : 일방의 의사에 다른 사실상태의 성립을 요하는 조건으로서 유효이다.

┃ 내가 제주에 가면, 선물을 사 주겠다.

② 비수의조건

㉠ 우성조건 : 자연의 사실 또는 제3자의 의사나 행위에 의존하는 조건을 말한다.

┃ 내일 비가 오면, 우산을 주겠다.

㉡ 혼성조건 : 일방의 의사에다 제3자의 의사까지를 요하는 조건을 말한다.

┃ 네가 甲女와 혼인하면, 반지를 주겠다.

(4) 조건을 붙일 수 없는 법률행위(조건과 친하지 않은 법률행위)

① 가족법상 신분행위(혼인·이혼·입양·파양·상속의 승인과 포기 등)

② 어음행위, 수표행위(기한과는 친함). 단 어음보증에는 조건을 허용한다.

③ 조건을 붙이는 것이 강행법규 또는 사회질서에 반하는 경우에는 허용되지 않는다.
따라서 불법조건은 조건만이 무효가 아니라 그 법률행위 전부를 무효로 한다.

④ 단독행위(해제·해지·취소·상계 등)는 조건을 붙일 수 없으나 채무면제나 유증은 상대방만을 유리하게 하는 것으로 허용되며 상대방의 동의가 있는 경우에는 조건을 붙이는 것이 허용된다(통설).

(5) 조건성취와 불성취의 의제

1) 성취의 의제

조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취된 것으로 주장할 수 있다(제150조 제1항).

2) 불성취의 의제

조건의 성취로 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취되지 않은 것으로 주장할 수 있다(제150조 제2항).

중요판례

대법원 1993.05.25. 93다296

매매계약에서 매도인에게 부과될 공과금을 매수인이 책임진다는 취지의 특약을 하였다 하더라도 이는 공과금이 부과되는 경우 그 부담을 누가 할 것인가에 관한 약정으로서 그 자체가 불법조건이라고 할 수 없고 이것만 가지고 사회질서에 반한다고 볼 수도 없다.

대법원 1966.06.21. 66다530

부첩관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 그 조건만이 무효인 것이 아니라 증여계약 자체가 무효이다.

☞ 불법조건은 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 조건으로서, 조건만이 무효가 아니라 법률행위 전부를 무효로 한다.

대법원 1998.12.22. 98다42356

[1] 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 이러한 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.

[2] 조건성취의 방해는 고의에 의한 경우만이 아니라 과실에 의한 경우에도 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에 해당한다.

대법원 1993.09.28. 93다20832

어떠한 법률행위가 조건의 성취시 법률행위의 효력이 발생하는 소위 정지조건부 법률행위에 해당한다는 사실은 그 법률행위로 인한 법률효과의 발생을 저지하는 사유로서 그 법률효과의 발생을 다투려는 자에게 증명책임이 있다.

대법원 1993.04.12. 81다카692

정지조건부 법률행위에 있어서 조건이 성취되었다는 사실은 이에 의하여 권리를 취득하고자 하는 측에서 그 증명책임이 있다 할 것이므로, 정지조건부 채권양도에 있어서 정지조건이 성취되었다는 사실은 채권양도의 효력을 주장하는 자에게 그 증명책임이 있다.

대법원 2007.06.01. 2006도8400

동산의 매매계약을 체결하면서, 매도인이 대금을 모두 지급받기 전에 목적물을 매수인에게 인도하기는 하지만 대금이 모두 지급될 때까지는 목적물의 소유권은 매도인에게 유보되며 대금이 모두 지급된 때에 그 소유권이 매수인에게 이전된다는 내용의 이른바 소유권유보의 특약을 한 경우, 대금이 모두 지급되는 것을 정지조건으로 하므로, 목적물이 매수인에게 인도되었다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 매도인은 대금이 모두 지급될 때까지 매수인 뿐만 아니라 제3자에 대하여도 유보된 목적물의 소유권을 주장할 수 있다.

대법원 1979.06.26. 77다2091

소(訴) 취하시에는 승소로 간주하여 성공사례금을 지급한다는 변호사와 사건의뢰인 간의 특약은 의뢰인의 신의에 반한 행위를 제지하기 위한 것이므로, 승소의 가망 있는 소송을 부당하게 취하여 변호사의 조건부 권리를 침해하는 경우에 한하여 적용되고, 승소가망이 전혀 없는 소송취하의 경우에는 적용이 없다.

(6) 조건부 법률행위의 효력

제148조 【조건부권리의 침해금지】

조건 있는 법률행위의 당사자는 조건의 성부가 미정한 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다.

제149조 【조건부권리의 처분 등】

조건의 성취가 미정한 권리의무는 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존 또는 담보로 할 수 있다.

- ① 조건부 권리의 의무자는 조건의 성부가 미정인 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다(제148조).
- ② 조건부 권리·의무는 일반규정에 따라 이를 처분·상속·보존·담보로 할 수 있다(제149조).
- ③ 조건부 권리의 의무자가 기대권자의 이익을 해(害)한 경우, 예컨대 정지조건부 증여계약의 목적물을 소유자가 제3자에게 매각하거나 훼손한 경우에는 기대권자는 조건의 성취를 전제로 그 소유자에게 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수 있다(학설대립 있음).
- ④ 조건성취의 효력은 원칙적으로 소급효가 없으나 예외적으로 당사자의 특약으로 소급효를 부여할 수 있다. 다만 제3자의 권리는 침해하지 못한다. 아울러 기한도래의 효력에는 절대적으로 소급효를 부여할 수 없다.

3. 기한

(1) 의의 및 종류

1) 의의

법률행위의 당사자가 법률행위의 효력의 발생·소멸 또는 채무의 이행을 장래에 발생할 것이 확실한 사실에 의존하게 하는 부관을 말한다.

2) 종류

① 시기와 종기

㉠ 시기 : 법률행위의 효력의 발생 또는 채무의 이행의 시기를 장래의 확정된 사실의 발생에 의존하는 기한을 말한다.

┃ 내년 1월 1일부터, 임대하겠다.

㉡ 종기 : 법률행위의 효력의 소멸을 장래의 확정된 사실의 발생에 의존하게 하는 기한을 말한다.

┃ 금년 말까지, 고용한다.

② 확정기한과 불확정기한

㉠ 확정기한 : 발생하는 시기가 확정되어 있는 기한을 말한다.

┃ 2025년 1월 1일부터, 이 건물을 임대하겠다.

㉡ 불확정기한 : 발생하는 시기가 확정되어 있지 않은 기한을 말한다.

┃ 甲이 사망하면, 이 토지를 매도하겠다.

(2) 기한을 붙일 수 없는 법률행위

기한을 붙일 수 없는 법률행위는 조건을 붙일 수 없는 법률행위와 대체로 같으며, 어음행위와 수표행위에는 시기를 붙이는 것이 허용된다.

(3) 기한부 법률행위의 효력

1) 기한도래 후의 효력

제152조 【기한도래의 효과】

① 시기 있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력이 생긴다.

② 종기 있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력을 잃는다.

- ① 시기부 법률행위의 효력은 기한이 도래한 때로부터 효력이 발생한다.
- ② 종기부 법률행위의 효력은 기한이 도래한 때로부터 효력이 소멸한다.
- ③ 기한도래의 효력에는 절대적으로 소급효를 부여할 수 없다.
- ④ 기한도래에 대해서는 기한도래의 이익을 받는 자가 증명책임을 진다.

2) 기한도래 전의 효력

제148조와 제149조를 기한부 법률행위에 준용한다.

(4) 기한의 이익

1) 기한의 이익

기한이 아직 도래하지 않음으로써 당사자가 받은 이익을 말한다.

2) 기한이익을 가지는 자

구분	채권자	채무자
이자부 소비대차	있음	있음
무이자 소비대차	없음	있음
이자부 정기예금	있음	있음
임치	있음	있음
무상임치	있음	없음

3) 기한이익의 추정

당사자의 특약이나 반대의 취지가 없는 한 기한의 이익은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다(제153조 제1항).

(5) 기한이익의 포기

제153조 【기한의 이익과 그 포기】

- ① 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ② 기한의 이익은 이를 포기할 수 있다. 그러나 상대방의 이익을 해하지 못한다.

제388조 【기한의 이익의 상실】

채무자는 다음 각 호의 경우에는 기한의 이익을 주장하지 못한다.

- 1. 채무자가 담보를 손상, 감소 또는 멸실하게 한 때
- 2. 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때

- ① 기한의 이익은 포기할 수 있으나 상대방의 이익을 해하지 못한다. 여기서 기한 이익의 포기는 상대방 있는 단독행위에 해당한다.
- ② 기한의 이익이 상대방을 위해서 존재하는 경우에는 상대방의 손해를 배상하고 포기할 수 있다는 것이 통설이다.

(6) 기한이익의 상실

당사자 간의 합의로 기한이익의 상실사유를 약정할 수 있으나, 법률은 다음과 같은 경우에는 채무자는 기한이익을 갖지 못한다고 규정하고 있다.

1) 채무자가 담보를 손상·감소·멸실하게 한 때(제388조 제1항)

- ① 인적·물적 담보를 불문한다.
- ② 채무자의 고의·과실을 요하지 아니한다.

2) 채무자가 담보제공의무를 이행하지 않은 때(제388조 제2항)

3) 채무자가 파산한 때(채무자회생 및 파산에 관한 법률)

중요판례

대법원 2002.09.04. 2002다28340

- [1] 기한이익 상실의 특약은 그 내용에 의하여 일정한 사유가 발생하면 채권자의 청구 등을 요함이 없이 당연히 기한의 이익이 상실되어 이행기가 도래하는 것으로 하는 정지조건부 기한이익 상실의 특약과 일정한 사유가 발생한 후 채권자의 통지나 청구 등 채권자의 행위를 기다려 비로소 이행기가 도래하는 것으로 하는 형성권적 기한이익 상실의 특약의 두 가지로 대별할 수 있고, 기한이익 상실의 특약이 위의 양자 중 어느 것에 해당하느냐는 당사자의 의사해석의 문제이지만 일반적으로 기한이익 상실의 특약이 채권자를 위하여 둔 것인 점에 비추어 명백히 정지조건부 기한이익 상실의 특약이라고 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 형성권적 기한이익 상실의 특약으로 추정된다.
- [2] 형성권적 기한이익 상실의 특약이 있는 경우에는 그 특약은 채권자의 이익을 위한 것으로서 기한이익의 상실 사유가 발생하였다고 하더라도 채권자가 나머지 전액을 일시에 청구할 것인가 또는 종래대로 할부변제를 청구할 것인가를 자유로이 선택할 수 있으므로, 이와 같은 기한이익 상실의 특약이 있는 할부채무에 있어서는 1회의 불이행이 있더라도 각 할부금에 대해 그 각 변제기의 도래시마다 그 때부터 순차로 소멸시효가 진행하고 채권자가 특히 잔존 채무 전액의 변제를 구하는 취지의 의사를 표시한 경우에 한하여 전액에 대하여 그 때부터 소멸시효가 진행된다.

대법원 1988.12.20. 88다카132

매매계약에 있어 매수인이 중도금을 약정한 일자에 지급하지 아니하면 그 계약을 무효로 한다고 하는 특약이 있는 경우 매수인이 약정한 대로 중도금을 지급하지 아니하면 그 불이행 자체로써 계약은 그 일자에 자동적으로 해제된 것으로 본다.

대법원 1982.12.14. 82다카861

계약해제권의 발생사유인 이행지체라 함은 채무의 이행이 가능한 데도 채무자가 그 이행기를 도과한 것을 말하고, 그 이행기 도래 전에는 이행지체란 있을 수 없으므로, 채무이행의 방법으로 교부한 어음이 지급기일에 지급불능이 예상된다 하더라도 잔대금의 이행기일이 경과하지 않은 이상 기한의 이익을 보유하고 있다고 할 것이므로 바로 잔대금지급을 최고하고 계약을 해제할 수 없다.

대법원 1989.06.27. 88다카10579

당사자가 불확정한 사실이 발생한 때를 이행기한으로 정한 경우에 있어서 그 사실이 발생한 때는 물론 그 사실의 발생이 불가능하게 된 때에도 이행기한은 도래한 것으로 보아야 한다.



6장 기간과 소멸시효

제1절 기간

1. 서론

- (1) 일정한 시점에서 일정한 시점까지의 계속된 시간의 흐름을 말한다.
- (2) 민법의 기간계산방법은 공·사법을 불문하고 적용되는 보충적인 규정이다(제155조).

2. 계산방법

(1) 자연적 계산법

- ① 정확하나 불편한 단점이 있으며 주로 단기간에 적용한다.
- ② 시·분·초를 단위로 하는 계산법으로서 즉시로부터 기산하여 정해진 시·분·초가 만료한 때를 만료점으로 한다(제156조).
 - ┃ 오전 10시 15분부터 10시간이라고 한다면 오후 8시 15분이 만료점이다.

(2) 역법적 계산법

- ① 부정확하나 편리하다는 장점이 있으며 주로 장기간에 적용한다.
- ② 일·주·월·년을 단위로 하는 계산법이다.

기산점	① 초일불산입의 원칙이 적용된다(제157조). ② 초일산입의 경우 ㉠ 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우(제157조) ㉡ 연령계산의 경우(제158조) ┃ ① 2023년 3월 5일 오후 2시부터 10일간이라면 3월 15일 24시에 기간이 만료한다(기산점은 3월 6일 오전 0시). ② 앞으로 도래할 9월 5일로부터 일주일이라면 9월 11일 24시에 기간이 만료한다(9월 5일 오전 0시부터 기산하므로 초일을 산입한 결과). ③ 2004년 7월 14일 오전 11시에 출생한 자의 성년이 되는 시기는 2023년 7월 14일 오전 0시에 성년이 된다(연령계산은 초일을 산입한 결과).
-----	--

만료점	① 기간을 일·주·월·년으로 정한 때에는 기간 말일의 종료로 기간이 만료한다(제159조). ② 주·월·년의 처음으로부터 기산하지 않는 때에는 최후의 주·월·년에서 기산일에 해당한 날의 전일로 기간이 만료한다(제160조 제2항). ■ 2월 13일에 앞으로 1개월이라고 한 때에는, 기산일은 2월 14일이며 그로부터 1개월 후인 3월 14일의 전일, 즉 3월 13일로 기간이 만료한다. ③ 월·년으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다(제160조 제3항). ■ 1월 31일 오전10시부터 1개월이라면 2월 31일 24시가 만료점이지만, 2월은 28일(윤년의 경우에는 29일)까지 뿐이므로 2월 28일 24시로 기간이 만료한다. ④ 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 익일로 만료한다. ⑤ 일정한 기산일로부터 거꾸로 소급하여 계산하는 기간의 역산의 경우에도 민법의 기간계산의 방법이 준용된다(다수설·판례). ■ 사단법인의 사원총회 소집일시가 2023년 9월 16일 오전 10시라고 한다면, 초일불산입의 원칙에 의해 16일을 뺀 15일부터 역으로 기산하여 1주일 전날인 9월 8일 자정까지는 발신을 완료하여야 한다(사단법인의 사원총회 소집의 통지는 발신주의).
-----	--

중요판례

대법원 1970.11.30. 70다1967

4월 3일부터 10일간이란 기간을 4월 1일에 공고하였다면 4월 12일에 기간이 종료한다.

대법원 1982. 02.23. 81누204

기간의 초일이 공휴일이라 하더라도 기간은 초일부터 기산한다.

대법원 1987.10.13. 87누53

원고가 1977년 10월 30일까지 피고에 대한 채무를 변제하지 못한다면 그 불변제를 조건으로 본건 토지대금을 450만 원으로 하여 그에서 원리금을 공제한 나머지 금액을 피고가 원고에게 지급하기로 하는 조건부 매매계약을 체결한 경우에 위 1977년 10월 30일이 공휴일이라면 특약이 없는 이상 민법 제161조를 준용하여 변제기는 그 익일까지 연장된다.

1. 시효의 의의

- (1) 일정한 사실상태가 일정한 기간 동안 계속됨으로써 권리의 취득 또는 소멸을 일어나게 하는 법률요건으로서 취득시효(물권편에서 규정)와 소멸시효(민법총칙에서 규정)가 있다.
- (2) 재산권에 대한 제도로써 강행규정성을 띠고 있다. 따라서 '소멸시효는 법률행위에 의하여 그 요건을 배제·연장·가중할 수 없으나, 단축 또는 경감할 수 있다.'

2. 소멸시효에 걸리지 않는 재산권

(1) 점유권

(2) 소유권 및 소유권에 의존하는 권리

- ① 상린권(제215조 이하)
- ② 공유물분할청구권
- ③ 대리권

(3) 담보물권

피담보채권이 소멸시효로 인해 소멸하면 담보물권은 따라서 소멸하며(附從性), 담보물권이 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다.

(4) 소유권

(5) 신분권

(6) 물권적 청구권

학설상의 대립은 있으나, 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않으나, 제한물권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸린다는 것이 판례이다.

(7) 형성권

형성권은 소멸시효가 아니라 제척기간에 걸린다는 것이 다수설과 판례의 입장이다.

(8) 인격권

중요판례

대법원 1991.03.22. 90다9797

- [1] 부동산에 대한 매매대금채권이 소유권이전등기청구권과 동시이행의 관계에 있다고 할지라도 매도인은 매매대금의 지급기일 이후 언제라도 그 대금의 지급을 청구할 수 있는 것이며, 다만 매수인은 매도인으로부터 그 이전등기에 관한 이행의 제공을 받기까지 그 지급을 거절할 수 있는데 지나지 아니하므로 매매대금청구권은 그 지급기일 이후 시효의 진행에 걸린다.
- [2] 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이므로 10년의 소멸시효에 걸리지만 매수인이 매매목적물인 부동산을 인도받아 점유하고 있는 이상 매매대금의 지급 여부와는 관계없이 그 소멸시효가 진행되지 아니한다.

대법원 2010.01.28.

부동산매수인의 등기청구권도 형식주의를 취하고 있는 현행 민법 하에서는 채권적 청구권이라고 해석되나 매수인이 매매목적물을 인도받아 점유하고 있는 경우에는 다른 채권과는 달리 소멸시효에 걸리지 않는다.

대법원 1999.03.18. 98다32175 전원합의체

부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용·수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리 행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 그 이전등기청구권의 행사 여부에 관하여 그가 그 부동산을 스스로 계속 사용·수익만 하고 있는 경우와 특별히 다를 바 없으므로 위 두 어느 경우에도나 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.

대법원 1981.03.24. 80다1888, 1889

공유물분할청구권은 공유관계에서 수반되는 형성권이므로 공유관계가 존속하는 한 그 분할 청구권만이 독립하여 시효로 소멸될 수 없다.

대법원 2010.02.11. 2008다16899

부동산실명법의 시행 이전에 부동산을 신탁한 명의신탁자는 언제든지 명의수탁자에 대하여 신탁계약을 해지하고 소유권이전등기 절차의 이행을 청구할 수 있으므로 이러한 등기청구권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.

3. 소멸시효기간

- (1) 보통의 채권 : 10년(제162조 제1항), 단, 채권 및 소유권 이외의 재산권은 20년
- (2) 상행위로 인한 채권 : 5년
- (3) 근로기준법상의 임금채권 : 3년
- (4) 3년의 단기소멸시효에 걸리는 권리(제163조)
 - ① 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권(1년 이내의 정기로 지급되는 채권, 1개월 단위로 지급되는 집합건물의 관리비채권 등)
 - ② 의사, 조산사, 간호사 및 약사의 치료, 근로 및 조제에 관한 채권
 - ③ 도급받은 자, 기사 기타 공사의 설계 또는 감독에 종사하는 자의 공사에 관한 채권
 - ④ 변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사 및 법무사에 대한 직무상 보관한 서류의 반환을 청구하는 채권
 - ⑤ 변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사 및 법무사의 직무에 관한 채권
 - ⑥ 생산자 및 상인이 판매한 생산물 및 상품의 대가
 - ⑦ 수공업자 및 제조업자의 업무에 관한 채권
- (5) 1년의 단기소멸시효에 걸리는 권리(제164조)
 - ① 여관, 음식점, 대석(貸席), 오락장의 숙박료, 음식료, 대석료, 입장료, 소비물의 대가 및 체당금(替當金)의 채권
 - ② 의복, 침구, 장구(葬具) 기타 동산의 사용료의 채권
 - ③ 노역인·연예인의 임금 및 그에 공급한 물건의 대금채권
 - ④ 학생 및 수업자의 교육, 의식, 유숙에 관한 교주(校主), 숙주(塾主), 교사의 채권
- (6) 판결 등으로 확정된 채권
 - ① 판결에 의해서 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년이다(제165조 제1항).

- ② 파산절차에 의하여 확정된 채권 및 재판상의 화해 또는 조정 기타 판결과 동일한 효력이 있는 것에 의하여 확정된 채권도 10년이다(제165조 제2항). 그러나 판결 확정 당시에 아직 변제기가 도래하지 않은 채권에 대해서는 예외이다(제165조 제3항).

중요판례

대법원 1981.03.24. 80다1888

단기의 소멸시효에 걸리는 것이라도 확정판결을 받은 권리의 소멸시효는 10년으로 한다는 뜻일 뿐, 10년보다 장기의 소멸시효를 10년으로 단축한다는 의미도 아니고 본래 소멸시효의 대상이 아닌 권리가 확정판결을 받음으로써 10년의 소멸시효에 걸린다는 뜻도 아니다.

대법원 2007.02.22. 2005다65821

민법 제163조 제1호에서 3년의 단기소멸시효에 걸리는 것으로 규정한 ‘1년 이내의 기간으로 정한 채권’이란 1년 이내의 정기로 지급되는 채권을 말하는 것으로서 1개월 단위로 지급되는 집합건물의 관리비채권은 이에 해당한다.

대법원 2021.7.22. 2019다277812 전원합의체

보험계약자가 다수의 계약을 통하여 보험금을 부정 취득할 목적으로 체결한 보험계약이 민법 제103조에 따라 무효인 경우, 보험회사의 보험금에 대한 부당이득반환청구권은 상법 제64조를 유추적용하여 5년의 상사 소멸시효기간이 적용된다.

대법원 1980.02.12. 79라2169

민법 제163조 제1호 규정의 1년 이내의 기간으로 정한 채권이라 함은 1년 이내의 정기에 지급되는 채권을 의미하는 것이고, 변제기가 1년 내의 채권이라는 의미가 아니다.

4. 소멸시효의 기산점

(1) 의의

소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다(제166조 제1항).

(2) 각종 권리의 소멸시효의 기산점

확정기한부 채권	기한이 도래한 때, 기한이 연기된 경우에는 그 연기된 기한이 새로운 기산점이 된다.
불확정기한부 채권	① 객관적으로 그 기한이 도래한 때부터 소멸시효가 진행된다. ② 채권자의 기한도래사실에 대한 知·不知는 불문한다.
기한의 정함이 없는 채권	채권이 성립한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
청구 또는 해지통고 후 상당기간이나 일정기간이 지나야 청구할 수 있는 권리	그 기간(유예기간)이 경과한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
기한이익의 상실특약이 있는 채권	할부금채무에서 채무자가 1회라도 변제를 지체하면 채권자가 전채무의 이행을 청구할 수 있는 특약을 한 경우에는 그 1회의 불이행시부터 잔액 전부에 대한 소멸시효가 진행된다는 것이 통설이나, 판례는 견해를 달리한다(판례참조).
정지조건부 권리	조건성취시부터 소멸시효가 진행된다.
위반위채권	위반행위시부터 소멸시효가 진행된다.
채무불이행으로 인한 손해배상청구권	학설은 대립이 있으며, 판례는 채무불이행시로부터 소멸시효가 진행된다고 한다. 다만, 시효기간은 본래 채권의 시효기간과 같다(통설·판례).
구상권	보증인의 구상권은 그 권리가 발생되어 행사할 수 있는 때로부터 소멸시효가 진행된다.

중요판례

대법원 1993.12.14. 93다27314

소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하며, '권리를 행사할 수 없는 때'라 함은 그 권리 행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이지 사실상 그 권리의 존재나 권리행사 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 있어서의 과실유무 등은 시효진행에 영향을 미치지 아니한다.

대법원 2009.12.24. 2009다60244

본래의 소멸시효 기산일과 당사자가 주장하는 기산일이 서로 다른 경우에는 변론주의의 원칙상 법원은 당사자가 주장하는 기산일을 기준으로 소멸시효를 계산하여야 하는데, 이는 당사자가 본래의 기산일보다 뒤의 날짜를 기산일로 하여 주장하는 경우는 물론이고, 특별한 사정이 없는 한 그 반대의 경우에 있어서도 마찬가지다.

대법원 2001.11.09. 2001다52568

민법 제163조 제2호 소정의 '의사의 치료에 관한 채권'에 있어서는, 특약이 없는 한 그 개개의 진료료가 종료될 때마다 각각의 당해 진료에 필요한 비용의 이행기가 도래하여 그에 대한 소멸시효가 진행된다고 해석함이 상당하고, 장기간 입원치료를 받는 경우라 하더라도 다른 특약이 없는 한 입원치료 중에 환자에 대하여 치료비를 청구함에 아무런 장애가 없으므로 퇴원시부터 소멸시효가 진행된다고 볼 수는 없다.

대법원 1979.05.15. 78다528

교통사고의 피해자들에게 손해배상을 한 공동불법행위자인 1인의 다른 공동불법행위자에 대한 구상금채권은 일반채권과 같이 구상권자가 현실로 피해자들에게 손해금을 지급한 때로부터 10년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

대법원 1990.11.09. 90다카22513

매매로 인한 부동산소유권 이전채무가 이행불능됨으로써 매수인이 매도인에 대하여 갖게 되는 손해배상청구권은 그 부동산소유권의 이전채무가 이행불능된 때에 발생하는 것이고, 그 계약체결일에 생기는 것은 아니므로 위 손해배상채권의 소멸시효는 계약체결일이 아닌 소유권이전채무가 이행불능된 때부터 진행한다.

☞ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 채무불이행시로부터 진행한다(대법원 2005.01.14. 2002다57119).

대법원 1992.12.22. 92다28822

소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하며 여기서 권리를 행사할 수 있는 때라 함은 권리행사에 법률상의 장애가 없는 때를 말하므로 정지조건부 권리의 경우에는 조건 미성취의 동안은 권리를 행사할 수 없는 것이어서 소멸시효가 진행되지 않는다.

대법원 2005.05.13. 2004다71881

불법행위에 기한 손해배상채권에 있어서 민법 제766조 제2항에 의한 소멸시효의 기산점이 되는 '불법행위를 한 날'이란 가해행위가 있었던 날이 아니라 현실적으로 손해의 결과가 발생한 날을 의미한다.

☞ 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년 또는 불법행위를 한 날로부터 10년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다(제766조)

5. 소멸시효의 중단

(1) 의의

- ① 소멸시효의 진행이 중단되면 그때까지 진행한 시효기간은 효력을 잃고 중단사유가 종료한 때로부터 새로이 소멸시효가 진행한다(제178조 제1항).
- ② 소멸시효의 정지는 시효의 진행이 일시적으로 정지하는 것에 불과하고 그때까지 경과한 시효기간은 그대로 효력이 유지된다는 점에서 중단과 구별된다.

(2) 중단사유

제168조 【소멸시효의 중단사유】

소멸시효는 다음 각호의 사유로 인하여 중단된다.

- 1. 청구
- 2. 압류 또는 가압류, 가처분
- 3. 승인

1) 청구

① 재판상의 청구(제170조)

제170조 【재판상의 청구와 시효중단】

- ① 재판상의 청구는 소송의 각하, 기각 또는 취하의 경우에는 시효중단의 효력이 없다.
- ② 전항의 경우에 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 압류 또는 가압류, 가처분을 한 때에는 시효는 최초의 재판상청구로 인하여 중단된 것으로 본다.

- ㉠ 訴의 제기를 의미한다. 상대방이 제기한 訴에 대하여 응소하는 경우를 포함한다.
- ㉡ 청구는 민사재판이어야 하고 행정소송·행정심판·형사재판의 경우에는 중단 사유가 되지 않는다는 것이 다수설과 판례의 태도이다.
- ㉢ 시효중단의 효력이 발생하는 시기는 訴 제기시로 본다.
- ㉣ 訴의 기각·각하·취하의 경우에는 중단의 효력이 없으나 6월 내에 다시 재판상의 청구, 파산절차참가, 압류, 가압류, 가처분을 행한 때에는 최초의 訴 제기시에 중단된 것으로 본다.
- ㉤ 訴의 종류는 이행의 訴, 확인의 訴, 형성의 訴, 反訴 등이 모두 해당한다.

② 파산절차참가(제171조)

채권자가 파산재단의 배당에 가입하기 위하여 자기 채권을 신고하는 것을 말한다.
신고한 때에 시효중단의 효력이 있다.

③ 지급명령신청(제172조)

지급명령신청을 관할 법원에 제출하였을 때 시효중단의 효력이 있다.

④ 화해를 위한 소환(제173조)

화해를 신청하면 시효는 중단한 것으로 본다.

⑤ 임의출석(제173조)

임의출석이란 당사자 쌍방이 임의로 법원에 출석하여 소송에 관하여 구두변론함으로써 訴를 제기하는 방법을 말한다.

⑥ 최고(제174조)

㉠ 채무자에 대해 이행을 청구하는 의사의 통지이다.

㉡ 최고 후 6월 내에 재판상의 청구 등 보다 강력한 방법을 취하지 않으면 시효중단의 효력이 없다.

제171조 【파산절차참가와 시효중단】

파산절차참가는 채권자가 이를 취소하거나 그 청구가 각하된 때에는 시효중단의 효력이 없다.

제172조 【지급명령과 시효중단】

지급명령은 채권자가 법정기간내에 가집행신청을 하지 아니함으로 인하여 그 효력을 잃은 때에는 시효중단의 효력이 없다.

제173조 【화해를 위한 소환, 임의출석과 시효중단】

화해를 위한 소환은 상대방이 출석하지 아니 하거나 화해가 성립되지 아니한 때에는 1월내에 소를 제기하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다. 임의출석의 경우에 화해가 성립되지 아니한 때에도 그러하다.

제174조 【최고와 시효중단】

최고는 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다.

2) 압류·가압류·가처분(제168조 제2호)

압류는 확정판결 기타 집행권원에 의해 행하는 강제집행행위이며, 가압류·가처분은 강제집행이 불가능할 때 그것을 보전하기 위하여 취하는 수단이다.

제175조 【압류, 가압류, 가처분과 시효중단】

압류, 가압류 및 가처분은 권리자의 청구에 의하여 또는 법률의 규정에 따르지 아니함으로 인하여 취소된 때에는 시효중단의 효력이 없다.

제176조 【압류, 가압류, 가처분과 시효중단】

압류, 가압류 및 가처분은 시효의 이익을 받은 자에 대하여 하지 아니한 때에는 이를 그에게 통지한 후가 아니면 시효중단의 효력이 없다.

3) 승인(제168조 제3호)

- ① 시효의 이익을 받을 당사자가 시효로 인해 권리를 잃을 자에 대하여 상대방의 권리를 인정한다는 일방적인 관념의 통지에 해당한다. 승인을 할 수 있는 자는 시효이익을 받을 자와 그 대리인이다(통설).
- ② 일정한 방식을 요하지 않으며 채권자의 대리인에 대해서도 행할 수 있다.
- ③ 승인을 함에 있어서는 상대방의 권리에 관하여 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다(제177조).
- ④ 승인은 시효의 완성 전에만 있을 수 있다.

(3) 시효중단의 효과

시효중단사유가 발생하면 시효의 완성이 저지되고, 그 때까지 경과한 시효기간은 무(無)로 된다.

제178조 【중단후에 시효진행】

- ① 시효가 중단된 때에는 중단까지에 경과한 시효기간은 이를 산입하지 아니하고 중단사유가 종료한 때로부터 새로이 진행한다.
- ② 재판상의 청구로 인하여 중단한 시효는 전항의 규정에 의하여 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다.

① 원칙

시효가 중단한 후에도, 시효의 기초가 되는 사실상태가 존재하는 이상, 새로이 시효가 진행된다(제178조 제1항).

② 시효의 기산점

- ㉠ 청구의 경우에는 판결이 확정된 때로부터 새로이 시효가 진행된다(제178조 제2항).
- ㉡ 압류가압류가처분의 경우에는 그 절차가 종료한 때 새로이 시효가 진행된다.
- ㉢ 승인의 경우에는 승인한 때로부터 새로이 시효는 진행된다.
- ③ 중단 후에 진행을 개시하는 시효는 새로운 시효이며, 시효기간은 영(0)에서 출발한다.

(4) 시효중단의 효과가 미치는 범위

① 원칙

시효의 중단은 당사자 및 승계인 사이에서만 그 효력이 발생한다(제169조).

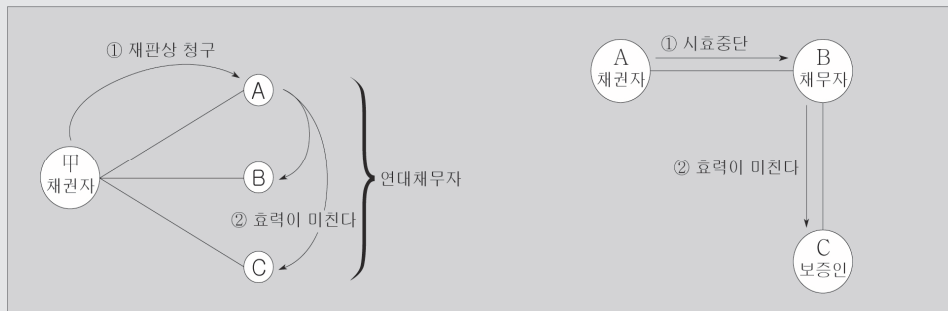
여기서 당사자란 시효중단행위에 참여한 자를 가리키고, 승계인에는 포괄승계인과 특정승계인을 포함한다.

② 원칙에 대한 예외

㉠ 중단의 효력이 확장되는 경우로서는 연대채무(제416조·제421조)·보증채무(제440조)가 있다.

㉡ 중단의 효력이 축소되는 경우로는 지역권(제295조·제296조)이 이에 해당한다.

✓ 시효중단의 효력이 미치는 인적 범위



중요판례

대법원 2006.04.14. 2004다70253

특정한 채무의 이행을 청구할 수 있는 기간을 제한하고 그 기간을 초과할 경우 채무가 소멸하도록 하는 약정은 소멸시효기간을 단축하는 약정으로서 특별한 사정이 없는 한 민법 제184조 제2항에 의하여 유효하다.

대법원 2006.08.24. 2004다26287

사망한 사람을 피신청인으로 한 가압류신청은 부적법하고 그 신청에 따른 가압류결정이 내려졌다고 하여도 그 결정은 당연 무효로서 그 효력이 상속인에게 미치지 않으며, 이러한 당연 무효의 가압류는 민법 제168조 제1호에 정한 소멸시효의 중단사유에 해당하지 않는다.

대법원 2011.05.13. 2011다10044

가압류를 시효중단사유로 정하고 있는 것은 가압류에 의하여 채권자가 권리를 행사하였다고 할 수 있기 때문인데 가압류에 의한 집행보전의 효력이 존속하는 동안은 가압류채권자에 의한 권리행사가 계속되고 있다고 보아야 할 것이므로 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류 집행보전의 효력이 존속하는 동안은 계속된다.

대법원 1994.1.11. 93다21477

채권자가 연대보증인 겸 물상보증인 소유의 담보부동산에 대하여 임의경매의 신청을 하여 경매개시결정에 따른 압류의 효력이 생겼다면 채권자는 그 압류의 사실을 통지하지 아니하더라도 연대보증인 겸 물상보증인에 대하여 시효의 중단을 주장할 수 있다.

그러나 시효의 중단은 시효중단행위에 관여한 당사자 및 그 승계인 사이에 효력이 있는 것이므로 주채무자에 대한 시효중단의 사유가 없는 이상 연대보증인 겸 물상보증인에 대한 시효중단의 사유가 있다 하여 주채무까지 시효중단되었다고 할 수는 없다.

대법원 2009.11.26. 2009다64383

- [1] 비법인사단의 사원총회가 그 총유물에 관한 매매계약의 체결을 승인하는 결의를 하였다면, 통상 그러한 결의에는 그 매매계약의 체결에 따라 발생하는 채무의 부담과 이행을 승인하는 결의까지 포함되었다고 봄이 상당하므로, 비법인사단의 대표자가 그 채무에 대하여 소멸시효 중단의 효력이 있는 승인을 하거나 그 채무를 이행할 경우에는 특별한 사정이 없는 한 별도로 그에 대한 사원총회의 결의를 거칠 필요는 없다고 보아야 한다.
- [2] 비법인사단이 총유물에 관한 매매계약을 체결하는 행위는 총유물 그 자체의 처분이 따르는 채무부담행위로서 총유물의 처분행위에 해당하나, 그 매매계약에 의하여 부담하고 있는 채무의 존재를 인식하고 있다는 뜻을 표시하는 데 불과한 소멸시효 중단사유로서의 승인은 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르는 행위가 아니어서 총유물의 관리·처분 행위라고 볼 수 없다.
- [3] 비법인사단의 대표자가 총유물의 매수인에게 소유권이전등기를 해주기 위하여 매수인과 함께 법무사 사무실을 방문한 행위는 소유권이전등기청구권의 소멸시효 중단의 효력이 있는 승인에 해당한다.

대법원 2010.04.29. 2009다99105

시효중단사유로서의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 그 시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자 또는 대리인에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 이 때 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또한 명시적이건 묵시적이건 불문한다.

대법원 1996.01.23. 95다39854

시효완성 전에 채무의 일부를 변제한 경우에는, 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 채무승인으로서의 효력이 있어 시효중단의 효과가 발생한다.

☞ 시효중단사유로서의 승인은 반드시 명시적일 것을 요하지 않는다. 원금의 일부변제, 이자의 지급, 증서의 재작성 등도 묵시적 승인으로 볼 수 있다.

대법원 2001.11.09. 2001다52568

소멸시효의 중단사유로서의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 그 권리의 존재를 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 것이므로 이는 소멸시효의 진행이 개시된 이후에만 가능하고 그 이전에 승인을 하더라도 시효가 중단되지는 않는다.

대법원 1997.04.25. 96다46484

시효중단의 효력은 당사자 및 그 승계인에게만 미치는 바, 여기서 당사자라 함은 중단행위에 관여한 당사자를 가리키고 시효의 대상인 권리 또는 청구권의 당사자는 아니며, 승계인이라 함은 “시효중단에 관여한 당사자로부터 중단의 효과를 받는 권리를 그 중단효과발생 이후에 승계한 자”를 뜻하고, 포괄승계인은 물론 특정승계인도 이에 포함된다.

대법원 1992.03.31. 91다32053 전원합의체

일반적으로 위법한 행정처분의 취소, 변경을 구하는 행정소송은 사권을 행사하는 것으로 볼 수 없으므로 사권에 대한 시효중단사유가 되지 못하는 것이나, 다만 오납한 조세에 대한 부당 이득반환청구권을 실현하기 위한 수단이 되는 과세처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 소는 그 소송물이 객관적인 조세채무의 존부확인으로서 실질적으로 민사소송인 채무부존재 확인의 소와 유사할 뿐 아니라, 과세처분의 유효 여부는 그 과세처분으로 납부한 조세에 대한 환급청구권의 존부와 표리관계에 있어 실질적으로 동일 당사자인 조세부과권자와 납세의무자 사이의 양면적 법률관계라고 볼 수 있으므로, 위와 같은 경우에는 과세처분의 취소 또는 무효확인청구의 소가 비록 행정소송이라고 할지라도 조세환급을 구하는 부당이득반환청구권의 소멸시효중단사유인 재판상 청구에 해당한다고 볼 수 있다.

대법원 2005.12.23. 2005다59383,59390

시효중단사유의 하나로 규정하고 있는 재판상의 청구라 함은, 통상적으로는 권리자가 원고로서 시효를 주장하는 자를 피고로 하여 주장하는 경우를 가리키지만, 시효의 이익을 받는 자가 원고가 되어 소를 제기한 데 대하여 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우도 마찬가지로 이에 포함된다.

☞ 채무자가 제기한 채무부존재확인소송에서 채권자가 피고로서 응소하여 적극적으로 권리를 주장하고, 그것이 법원에 의하여 받아들여진 경우에도 시효중단사유인 재판상의 청구에 해당한다.

대법원 1999.03.12. 98다18124

형사소송은 피고인에 대한 국가형벌권의 행사를 그 목적으로 하는 것이므로, 피해자가 가해자를 상대로 고소하거나 그 고소에 기하여 형사재판이 개시되어도 소멸시효의 중단사유인 재판상의 청구로 볼 수는 없다.

대법원 1992.04.10. 91다43695

한 개의 채권 중 일부에 관하여만 판결을 구한다는 취지를 명백히 하여 소송을 제기한 경우에는 소멸시효중단의 효력이 그 일부에 관하여만 발생하고, 나머지 부분에는 발생하지 아니하지만 비록 그 중 일부만을 청구한 경우에도 그 취지로 보아 채권 전부에 관하여 판결을 구하는 것으로 해석된다면, 그 채권의 동일성의 범위 내에서 그 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생한다.

대법원 2002.05.10. 2000다39735

채권자가 동일한 목적을 달성하기 위하여 복수의 채권을 갖고 있는 경우, 채권자로서는 그 선택에 따라 권리를 행사할 수 있되, 그 중 어느 하나의 청구권을 행사하는 것만으로는 다른 채권에 대한 소멸시효 중단의 효력이 없다.

대법원 1987.12.22. 87다카2337

- [1] 최고를 여러번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상 청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 발생한다.
- [2] 재판상의 청구는 그 소송이 취하된 경우에는 그로부터 6월내에 다시 재판상의 청구를 하지 않는 한 시효중단의 효력이 없고 다만 재판외의 최고의 효력만 있다.

대법원 2017.4.28. 2016다239840

시효가 중단된 때에는 중단까지에 경과한 시효기간은 이를 산입하지 아니하고 중단사유가

종료한 때로부터 새로이 진행하는데(민법 제178조 제1항), 소멸시효의 중단사유 중 '압류'에 의한 시효중단의 효력은 압류가 해제되거나 집행절차가 종료될 때 중단사유가 종료한 것으로 볼 수 있다.

6. 소멸시효의 정지

(1) 의의

시효기간이 거의 완성할 무렵에 권리자가 중단행위를 하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있는 경우에 일정기간 시효완성을 유예하는 것을 말한다. 따라서 시효기간의 진행을 일시적으로 정지케 하고 정지할 사정이 없어졌을 때 다시 나머지 기간을 진행 시키는 제도이다.

(2) 시효정지의 사유

1) 제한능력자의 권리의 경우

소멸시효의 기간만료 전 6개월 내에 제한능력자의 법정대리인이 없는 때에는 그가 능력자로 되거나 또는 법정대리인이 취임한 때로부터 6개월 내에는 시효가 완성되지 않는다(제179조).

2) 재산관리자에 대한 제한능력자의 권리의 경우

재산을 관리하는 부모 또는 후견인에 대한 제한능력자의 권리는 그가 능력자로 되거나 또는 후임의 법정대리인이 취임한 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성하지 않는다(제180조 제1항).

3) 부부간의 권리의 경우

부부의 한쪽이 다른 쪽에 대하여 가지는 권리는 혼인관계가 종료한 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성하지 않는다(제180조 제2항).

4) 상속재산에 관한 권리의 경우

상속재산에 속한 권리나 상속재산에 대한 권리는 상속인의 확정, 관리인의 선임 또는 파산선고가 있는 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성하지 않는다(제181조).

5) 천재·사변의 경우

천재 기타 사변으로 인하여 소멸시효를 중단할 수 없을 때에는 그 사유가 종료한 때로부터 1개월 내에는 시효가 완성하지 않는다(제182조).

7. 소멸시효완성의 효과

(1) 효과

제167조 【소멸시효의 소급효】

소멸시효는 그 기산일에 소급하여 효력이 생긴다.

제183조 【종속된 권리에 대한 소멸시효의 효력】

주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리에 그 효력이 미친다.

제184조 【시효의 이익의 포기 기타】

- ① 소멸시효의 이익은 미리 포기하지 못한다.
- ② 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제, 연장 또는 가중할 수 없으나 이를 단축 또는 경감할 수 있다.

- ① 소멸시효의 완성으로 권리는 소급적으로 소멸한다(제167조). 소멸시효로 채무를 면하게 되는 자는 기산일 이후의 이자지급을 요하지 아니한다.
- ② 주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리에도 그 효력이 미친다(제183조).
- ③ 소멸시효가 완성된 채권이 그 완성 전에 상계적상에 있는 때에는 채권자는 이를 자동채권으로 하여 상계할 수 있다(제495조).
- ④ 소멸시효의 이익은 미리 포기할 수 없다(제184조 제1항). 그러나 소멸시효완성 후에는 포기할 수 있다.
- ⑤ 당사자 사이에 시효요건을 가중, 배제 그리고 기간을 연장하는 특약은 무효이나, 단축 또는 경감하는 특약은 유효하다(제184조).
- ⑥ 시효이익의 포기는 일종의 의사표시이며, 상대방 있는 단독행위에 해당한다.
- ⑦ 시효이익의 포기는 명시적일 것을 요하지 않으며, 반드시 재판상으로 행사하여야 할 것을 요하지 아니한다. 그러나 시효이익의 포기를 위해서는 처분능력이나 처분 권한을 필요로 한다.

- ⑧ 시효이익의 포기의 효과는 상대적이다. 따라서 시효이익을 받을 자가 수인 있는 경우에 그 중 1인의 포기는 다른 자에게 그 효과가 미치지 아니한다.

(2) 절대적 소멸설(다수설·판례)과 상대적 소멸설(소수설)의 대립

절대적 소멸설은 소멸시효의 완성으로 권리가 당연히 소멸한다는 견해이며, 상대적 소멸설은 소멸시효의 완성으로 권리가 당연히 소멸하는 것이 아니라 당사자(시효이익을 받을 자)에게 그 권리소멸을 주장할 수 있는 원용권이 발생할 뿐이라는 견해이다.

중요판례

대법원 2007.11.29. 2007다54849

소멸시효를 원용할 수 있는 사람은 권리의 소멸에 의하여 직접 이익을 받는 자에 한정되는 바, 사해행위취소소송의 상대방이 된 사해행위의 수익자는, 사해행위가 취소되면 사해행위에 의하여 얻은 이익을 상실하고 사해행위취소권을 행사하는 채권자의 채권이 소멸하면 그와 같은 이익의 상실을 면하는 지위에 있으므로, 그 채권의 소멸에 의하여 직접 이익을 받는 자에 해당하는 것으로 보아야 한다.

☞ 독자적으로 소멸시효를 원용할 수 있는 자

- ① 시효가 완성된 채권의 채무자
- ② 담보가등기가 된 부동산의 양수인
- ③ 채권자취소소송(사해행위취소소송)에서의 수익자
- ④ 유치권이 성립된 부동산의 매수인
- ⑤ 물상보증인
- ⑥ 가등기가 경료된 부동산의 양수인

※ 채무자에 대한 일반채권자, 채권자대위소송의 제3채무자, 피담보채권을 담보하기 위해 저당권이 설정된 경우, 그 후순위 저당권자 등은 소멸시효를 원용할 수 있는 자에 해당하지 않는다.

대법원 1992.05.22. 92다4796

시효완성 후 채무를 승인한 채무자는 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것이라 추정할 수 있다.

대법원 1988.02.27. 97다53366

시효완성의 이익포기의 의사표시를 할 수 있는 자는 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 대리인에 한정된다고 할 것이고, 그 밖의 제3자가 시효완성의 이익포기의 의사표시를 하였다 하더라도 이는 시효완성의 이익을 받을 자에 대한 관계에서 아무 효력이 없다.

대법원 2001.12.14. 2001다45539

법령의 규정에 의하여 국가가 행하는 납입의 고지는 시효중단의 효력이 있다고 규정하여 민법의 시효중단의 효력에 대한 예외를 두고 있는바, 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 채권에 대하여 납입의 고지가 이루어진 경우에는 그 채권의 발생원인이 공법상의 것이건 사법상의 것이건 간에 시효중단의 효력이 생긴다.

8. 소멸시효와 제척기간

〈소멸시효와 제척기간의 비교〉

구분	소멸시효	제척기간
제도의 취지	일정한 사실상태의 존중을 통한 법률생활의 안정과 평화유지·증거보전의 곤란구제	일정한 권리를 중심으로 하는 법률관계의 조속한 확정
소급효	소멸시효로 인한 권리소멸은 소급한다.	권리소멸의 효과는 소급하지 않고 장래에 향하여 발생한다.
중단제도	인정	불인정
정지제도	인정	불인정(다수설)
법원의 직권고려 여부	재판의 기초로 하기 위하여는 당사자의 원용이 있어야 한다.	원용이 없어도 당연히 권리가 소멸한다. 따라서 법원은 당사자의 원용이 없어도 이를 직권으로 고려하여야 한다.
이익의 포기	시효기간 완성 후의 소멸시효이익의 포기 제도가 있다.	이익의 포기가 인정되지 않는다.
기간의 단축	법률행위에 의하여 이를 단축 또는 경감할 수 있다.	단축 또는 경감할 수 없다.

중요판례

대법원 1996. 09.20. 96다25371

민법 제146조가 규정하는 기간은 소멸시효기간이 아니라 제척기간으로서, 제척기간이 도과하였는지 여부는 당사자의 주장에 관계없이 법원이 당연히 조사하여 고려하여야 한다.

대법원 2001.06.12. 2001다3580

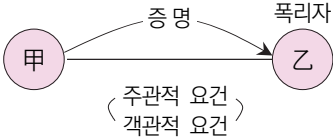
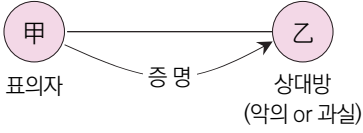
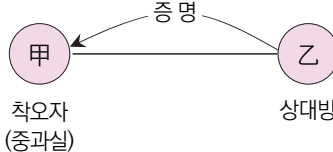
채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한

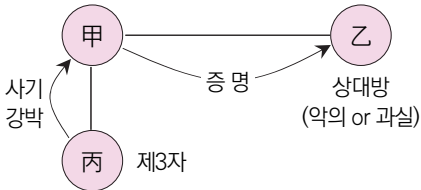
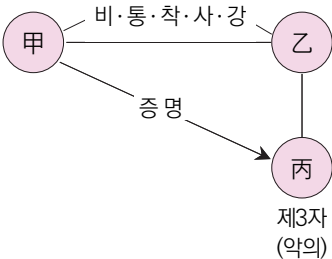
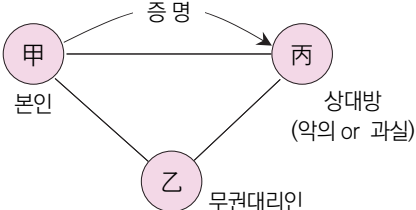
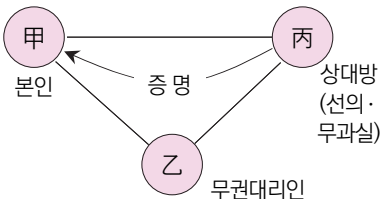
그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정되므로, 소멸시효가 완성된 채무를 피담보채무로 하는 근저당권이 실행되어 채무자 소유의 부동산이 경락되고 그 대금이 배당되어 채무의 일부변제에 충당될 때까지 채무자가 아무런 이의를 제기하지 아니하였다면, 경매절차의 진행을 채무자가 알지 못하였다는 등 다른 특별한 사정이 없는 한, 채무자는 시효완성의 사실을 알고 그 채무를 묵시적으로 승인하여 시효의 이익을 포기한 것으로 보아야 한다.

대법원 2011.10.13. 2011다10266

매도인에 대한 하자담보에 기한 손해배상청구권에 대하여는 민법 제582조의 제척기간이 적용되고, 이는 법률관계의 조속한 안정을 도모하고자 하는 데에 취지가 있다. 그런데 하자담보에 기한 매수인의 손해배상청구권은 권리의 내용·성질 및 취지에 비추어 민법 제162조 제1항의 채권 소멸시효의 규정이 적용되고, 민법 제582조의 제척기간 규정으로 인하여 소멸시효 규정의 적용이 배제된다고 볼 수 없으며, 이때 다른 특별한 사정이 없는 한 무엇보다도 매수인이 매매 목적물을 인도받은 때부터 소멸시효가 진행한다고 해석함이 타당하다.

〈민법총칙에서의 증명책임의 도해정리〉

① 불공정한 법률행위(제104조) 	[증명책임] ① 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 주관적 요건과 객관적 요건은 그 법률행위의 무효를 주장하는 자가 이를 증명하여야 한다. ② 급부와 반대급부가 현저히 불공정하다고 하여 공박·경솔·무경험이 추정되는 것은 아니기 때문이다(통설·판례).
② 진의 아닌 의사표시(제107조) 	[증명책임] 상대방의 악의 또는 과실유무에 대한 증명책임은 무효를 주장하는 자에게 있다(통설·판례).
③ 착오로 인한 의사표시(제109조) 	[증명책임] 표의자에게 중대한 과실이 있다는 점에 대한 증명책임은 표의자의 상대방이 부담한다.

④ 제3자에 의한 사기·강박(제110조) 	[증명책임] 상대방의 악의·과실에 대한 증명책임은 표의자가 부담한다.
⑤ 제3자에 대한 증명책임(제107 - 110조) 	[증명책임] ① 비진의·통정·착오·사기·강박에 의한 의사 표시의 무효나 취소를 가지고 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다. ② 제3자는 선의로 추정되므로 제3자가 악의라는 증명책임은 무효나 취소를 주장하는 자에게 있다.
⑥ 제125조·129조의 표현대리 	[증명책임] 제3자(무권대리인의 상대방)는 대리권의 부존재에 대하여 선의·무과실일 것. 이때 상대방의 악의 또는 과실에 대한 증명책임은 본인에게 있다.
⑦ 제126조의 표현대리 	[증명책임] 표현대리의 유효를 주장하는 상대방이 믿음에 상당한 사유가 있었음을 증명하여야 한다는 것이 판례의 태도이다.

P / A / R / T

02

물권법



제1장	물권변동
제2장	점유권
제3장	소유권
제4장	용익물권
제5장	담보물권



1장 물권변동

제1절 물권의 종류와 효력

1. 물권의 종류

(1) 현행법에서 인정되고 있는 물권

1) 민법상 물권의 종류와 분류

① 점유권·본권

㉠ 점유권 : 물건을 지배할 수 있는 법률상의 권원의 유무를 묻지 않고서 물건을 사실상 지배하고 있는 현재의 상태 그 자체를 보호하는 것을 목적으로 하는 권리이다.

㉡ 본권 : 물건에 대한 현실적 지배를 묻지 않고 그 물건을 지배할 수 있는 권리 (소유권·제한물권)로 구성된 것이다.

② 소유권·제한물권

㉠ 소유권 : 물건이 가지는 사용가치와 교환가치의 전부를 지배할 수 있는 권리이다.

㉡ 제한물권 : 물건의 사용가치나 또는 교환가치에 대해 제한적으로 지배할 수 있는 권리이다.

③ 용익물권·담보물권

㉠ 용익물권 : 사용가치의 지배를 목적으로 한다(지상권·지역권·전세권).

㉡ 담보물권 : 채권의 담보를 위하여 물건이 가지는 교환가치의 지배를 목적인다 (유치권·질권·저당권).

④ 부동산물권·동산물권 : 근본적으로 공시에 차이가 있다.

㉠ 부동산물권 : 점유권·소유권·유치권·지상권·지역권·전세권·저당권

㉡ 동산물권 : 점유권·소유권·유치권·질권

2) 민법 이외의 법률이 인정하는 물권

① 상법 : 상사유치권·주식질권·선박저당권 등

- ② 특별법 : 입목저당권·공장저당권·공장재단저당권·광업재단저당권·자동차저당권
·건설기계저당권·항공기저당권·광업권·어업권 등

(2) 관습법에 의해 인정되는 물건

1) 분묘기지권

타인의 토지에 분묘를 설치한 자는 일정한 요건 하에 그 분묘기지에 대하여 지상권에 유사한 물권을 취득한다.

2) 관습법상의 법정지상권

동일인의 소유에 속하는 토지와 그 지상의 건물이 매매 등으로 각각 소유자를 달리하게 된 경우에는 특히 그 건물을 철거한다는 별도의 특약이 없는 한, 건물의 소유자는 그 토지 위에 관습법상의 법정지상권을 취득한다.

2. 물권의 객체

(1) 특정되고 독립한 현존하는 물건

물권은 물건에 대한 직접적·배타적 지배를 내용으로 하므로 물권의 객체가 되는 것은 원칙적으로 특정되고 독립한 현존하는 물건이어야 한다. 그러나 용익물권은 토지나 건물의 일부위에도 설정될 수 있으므로 반드시 그 객체가 독립할 것을 요하지 않는다.

(2) 권리가 물권의 객체가 되는 경우

물권의 객체는 원칙적으로 물건이어야 하나, 예외적으로 권리가 물권의 객체가 되는 경우가 있다. 권리의 준점유(제210조), 주식이나 채권을 목적으로 하는 권리질권(제345조), 지상권과 전세권을 목적으로 하는 저당권(제371조 제1항) 등이 그 예이다.

중요판례

대법원 1996.06.14. 94다53006

- [1] 건물에 관한 소유권보존등기가 당해 건물의 객관적, 물리적 현황을 공시하는 등기로서 효력이 있는지의 여부는, 등기부에 표시된 소재, 지번, 종류, 구조와 면적 등이 실제 건물과에 사회통념상 동일성이 인정될 정도로 합치되는지의 여부에 따라 결정된다.
- [2] 건물이 증축된 경우에 증축 부분의 기존 건물에 부합 여부는 증축 부분이 기존 건물에 부착된 물리적 구조뿐만 아니라, 그 용도와 기능면에서 기존 건물과 독립한 경제적 효용을

가지고 거래상 별개의 소유권의 객체가 될 수 있는지의 여부 및 증축하여 이를 소유하는 자의 의사 등을 종합하여 판단하여야 한다.

- [3] 독립된 부동산으로서의 건물이라고 함은 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지면 법률상 건물이라고 할 수 있다.
- [4] 미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다.

대법원 2005.09.09. 2004마696

완공이 된 건물뿐 아니라 완공되지 아니하여 보존등기가 경료되지 아니하였거나 사용승인되지 아니한 건물이라고 하더라도 채무자의 소유로서 건물로서의 실질과 외관을 갖추고 그의 지면·구조·면적 등이 건축허가 또는 건축신고의 내용과 사회통념상 동일하다고 인정되는 경우에는 이를 부동산경매의 대상으로 삼을 수 있다고 할 것이다.

3. 일물일권주의(一物一權主義)

- ① 하나의 물건 위에 그 내용이 서로 용납되지 않은 물권은 하나밖에 존재할 수 없다는 원칙, 즉 하나의 물건 위에는 성질·범위·순위가 같은 물권은 성립할 수 없다는 원칙을 말한다. 예컨대, 하나의 토지위에 두 개의 소유권은 성립할 수 없으나 소유권과 지상권, 전세권과 저당권은 함께 성립할 수 있다.
- ② 이 원칙은 물권의 배타성에서 비롯되는 것이며, 공유(共有)는 1물1권주의에 반(反)하지 않는다.
- ③ 건물은 토지로부터 독립한 별개의 부동산이며, 다만 1동 건물의 일부분이 구조상과 이용상의 독립성이 인정될 때에는 구분소유권의 목적이 될 수 있다(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제1조).
- ④ 수목은 토지의 정착물로서 독립하여 물권의 객체가 되지 못함이 원칙이나, 등기된 수목의 집단은 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다(입목에 관한 법률).
- ⑤ 관습법상의 명인방법을 갖춘 수목의 집단이나 미분리의 과실은 독립하여 소유권의 객체가 된다.

대법원 1979. 08. 28. 79다784

적법한 경작권 없이 타인의 토지를 경작하였더라도, 그 경작한 입도가 성숙하여 독립한 물건으로서의 존재를 갖추었으면 그 입도의 소유권은 경작자에게 귀속한다.

대법원 2000. 10. 27. 2000다39582

- [1] 일물일권주의(一物一權主義)의 원칙상, 물건의 일부분, 구성부분에는 물권이 성립할 수 없는 것이어서 구분 또는 분할의 절차를 거치지 아니한 채 하나의 부동산 중 일부분만에 관하여 따로 소유권보존등기를 경료하거나, 하나의 부동산에 관하여 경료된 소유권보존 등기 중 일부분에 관한 등기만을 따로 말소하는 것은 허용되지 아니한다.
- [2] 구분소유의 목적이 되는 하나의 부동산에 대한 등기부상 표시 중 전유부분의 면적표시가 잘못된 경우, 이는 경정등기의 방법으로 바로 잡아야 하는 것이고 그 잘못 표시된 면적 만큼의 소유권보존등기의 말소를 구하는 소는 법률상 허용되지 아니하여 부적법하다.

대법원 1990. 12. 07. 90다카25208

토지의 개수는 지적법에 의한 지적공부상의 토지의 필수를 표준으로 하여 결정되는 것으로 1필지의 토지를 수필의 토지로 분할하여 등기하려면 먼저 위와 같이 지적법이 정하는 바에 따라 분할의 절차를 밟아 지적공부에 각 필지마다 등록이 되어야 하고 지적법상의 분필절차를 거치지 아니하는 한 1개의 토지로서 등기의 목적이 될 수 없는 것이며 설사 등기부에만 분필의 등기가 실행되었다 하여도 이로써 분필의 효과가 발생할 수는 없는 것이므로 결국 이러한 분필등기는 1부동산1등기용지의 원칙에 반하는 등기로서 무효라고 할 것이다.

대법원 2005. 12. 23. 2004다1691

물권의 객체인 토지 1필지의 공간적 범위를 특정하는 것은 지적도나 임야도의 경계이지 등기부의 표제부나 임야대장·토지대장에 등재된 면적이 아니므로, 토지등기부의 표제부에 토지의 면적이 실재와 다르게 등재되어 있다 하여도, 이러한 등기는 해당 토지를 표상하는 등기로서 유효하다.

4. 물권법정주의

제185조 【물권의 종류】

물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.

(1) 의의

물권의 종류와 그 내용은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다(제185조).

- ① 물권법에 있어서는 채권법에 있어서와 같이 계약자유 원칙이 인정되지 않으며, 물권법은 강행법규성을 띤다.
- ② 법률은 국회가 제정한 법률만을 의미하고 명령과 규칙 등은 제외된다.
- ③ 법률 또는 관습법이 인정하지 않는 새로운 종류의 물권을 만들지 못한다는 것과(종류강제), 법률 또는 관습법에서 인정하는 물권에도 법에서 규정한 내용과는 다른 내용을 부여하지 못한다는 것이(내용강제) 있다.

(2) 효력

- ① 제185조는 강행규정이므로 이에 위반하는 법률행위는 무효이다.
- ② 종류강제의 원칙에 위반한 법률행위는 전부무효이나 내용강제에 위반되는 법률행위는 일부무효의 법리가 적용된다.

(3) 종류

- ① 민법이 인정하는 물권은 점유권·소유권·지상권·지역권·전세권·유치권·질권·저당권의 8종류가 있다.
- ② 관습법상의 물권으로는 분묘기지권·관습법상의 법정지상권·동산의 양도담보권 등이 있다. 그러나 온천권, 사도통행권 등은 관습법상의 물권이 아니라는 것이 판례이다.

중요판례

대법원 2002.02.26. 2001다64165

[1] 민법 제185조는, "물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다."고 규정하여 이른바 물권법정주의를 선언하고 있고, 물권법의 강행법규성은 이를 중핵으로

하고 있으므로, 법률(성문법과 관습법)이 인정하지 않는 새로운 종류의 물권을 창설하는 것은 허용되지 아니한다.

[2] 관습상의 사도통행권 인정이 물권법정주의에 위배된다.

대법원 1972.8.29. 72다1243

온천에 관한 권리를 관습법상의 물권이라고 볼 수 없고, 온천수는 공용수 또는 생활상 필요한 용수에 해당하지 아니한다.

대법원 2022.7.21. 2017다236749 전원합의체

동일인 소유이던 토지와 그 지상 건물이 매매 등으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었을 때 그 건물 철거 특약이 없는 한 건물 소유자가 법정지상권을 취득한다는 관습법은 현재에도 그 법적 규범으로서의 효력을 여전히 유지하고 있다고 보아야 한다.

대법원 1995.2.28. 94다37912

타인 소유의 토지 위에 그 소유자의 승낙 없이 분묘를 설치한 자가 20년간 평온·공연히 그 분묘의 기지를 점유한 때에는 그 점유자는 시효에 의하여 그 토지 위에 지상권 유사의 물권을 취득하고 이에 대한 소유권을 취득하는 것은 아니다.

5. 물권적 청구권

(1) 의의

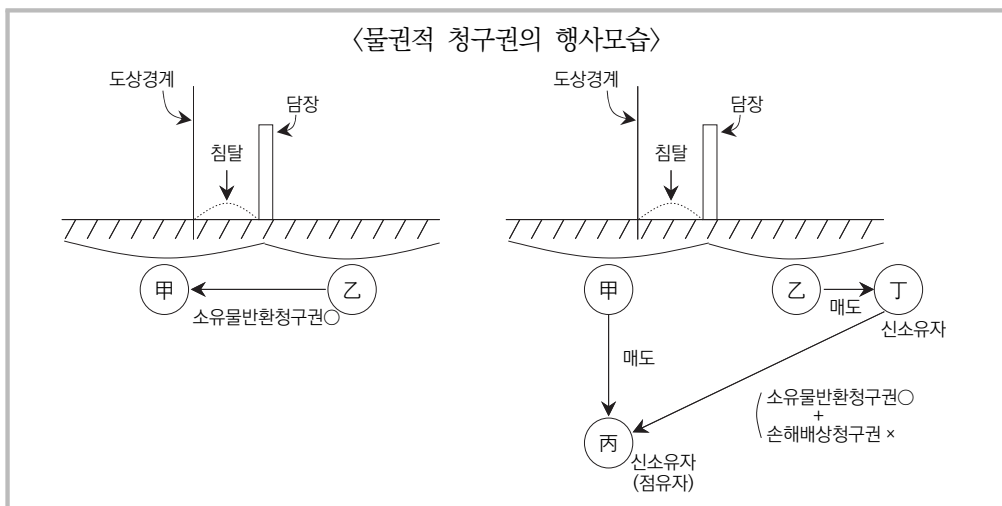
- ① 물권의 내용의 실현이 어떤 사정으로 인하여 방해당하고 있거나 방해당할 염려가 있는 경우에 그 방해의 제거 또는 예방에 필요한 일정한 행위를 청구할 수 있는 권리를 물권적 청구권이라고 한다.
- ② 점유권과 소유권에 관하여 명문의 규정을 두고 있고 소유권에 기인한 물권적 청구권을 다른 물권에도 준용한다. 아울러 유치권은 점유를 본체로 하는 점에서 점유권에 관한 점유보호청구권의 규정에 맡기고 있다.
- ③ 대항력을 갖춘 임차권은 물권적 청구권(방해배제청구권)을 인정한다는 것이 통설과 판례의 태도이다. 그러나 대항력 없는 임차인은 침해자에 대하여 임대인의 물권적 청구권을 대위 행사하거나 점유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 있을 뿐이다.

(2) 소멸시효의 적용

물권적 청구권은 물권과 독립해서는 소멸시효에 걸리지 않는다는 견해(다수설)와 소유권과 달리 제한물권에 기인한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸린다는 견해(판례)의 대립이 있다.

(3) 성질

- ① 물권적 청구권은 채권적 청구권에 우선하며, 물권과 운명을 같이하므로 물권이 이전되거나 소멸하면 물권적 청구권도 따라서 이전하거나 소멸한다.
- ② 물권적 청구권은 침해자(방해자)의 고의·과실(귀책사유)이 없는 때에도 인정된다. 그러나 불법행위로 인한 손해배상청구권을 행사하기 위해서는 손해가 현실로 발생하고 그것이 고의·과실에 의하여 발생할 것을 요한다. 따라서 고의·과실로 인한 물권침해가 있는 경우에는 물권적 청구권은 불법행위로 인한 손해배상청구권과 경합하여 행사할 수 있다.
- ③ 물권적 청구권의 청구권자는 현재의 물권자이며 청구의 상대방은 현재의 점유자이다. 따라서 미등기건물의 매수인은 현재의 물권자라 할 수 없으므로 건물의 불법점유자에 대하여 소유권에 기한 명도를 청구하지 못한다.
- ④ 지역권자와 저장권자에게는 물권적 반환청구권이 인정되지 아니한다.
- ⑤ 물권적 방해예방청구권은 물권이 현재 방해당하고 있지는 않지만 방해가 생길 객관적 염려가 있는 경우에 청구할 수 있는 권리로서 방해의 예방 또는 손해배상 담보를 선택적으로 행사할 수 있다.



대법원 1980. 09. 09. 80다7

소유권에 의하여 발생하는 물상청구권은 소유권과 분리하여 이를 소유권 없는 소유권자에게 유보하여 행사시킬 수 없는 것이고, 위와 같은 법리는 전소유자가 양수인에게 그 목적물을 인도할 의무가 있었다거나 그 소유권 이전이 소송 계속 중에 있었다고 하여 다를 수 없는 것이며, 따라서 소유권을 상실한 전소유자는 제3자인 불법점유자에게 물권적 청구권에 의한 방해배제를 청구할 수 없다.

대법원 1970. 09. 27. 70다1508

소유자는 불법점거의 형태에 관계없이 그 사실상의 지배자를 상대로 불법점거물의 물권적 반환청구를 할 수 있다. 불법점거자라 하여도 그 물건을 다른 사람에게 인도하여 현실적으로 점유를 하고 있지 않은 이상 그 자를 상대로 한 인도 또는 인도청구는 부당하다.

대법원 1998.06.26. 97다42823

토지의 매수인이 아직 소유권이전등기를 경료받지 아니하였다 하여도 매매계약의 이행으로 그 토지를 인도받은 때에는 매매계약의 효력으로서 이를 점유·사용할 권리가 생기게 된 것으로 보아야 하고, 또 매수인으로부터 위 토지를 다시 매수한 자는 위와 같은 토지의 점유·사용권을 취득한 것으로 봄이 상당하므로 매도인은 매수인으로부터 다시 위 토지를 매수한 자에 대하여 토지소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 없다.

제2절 부동산 물권변동

1. 부동산물권의 변동

(1) 법률행위에 의한 부동산물권의 변동

부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다(제186조).

(2) 법률의 규정에 의한 물권변동

제187조 【등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득】

상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.

상속(피상속인 사망시 물권변동)·공용징수(협의수용은 협의에서 정한 시기, 재결수용은 보상금지급을 정지조건으로 수용개시일에 물권변동)·판결(판결확정시 물권변동)·경매(매각대금 완납시 물권변동) 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 않으면 이를 처분하지 못한다(제187조).

☑ 기타 등기를 요하지 않는 물권변동

- ① 신축건물의 소유권 취득
 - ② 법정지상권의 취득
 - ③ 관습법상의 법정지상권의 취득
 - ④ 법정저당권의 취득
 - ⑤ 존속기간만료로 인한 용익물권의 소멸
 - ⑥ 혼동에 의한 물권의 소멸
 - ⑦ 피담보채권의 소멸로 인한 저당권의 소멸
 - ⑧ 법률행위의 무효·취소·해제로 인한 물권의 복구
 - ⑨ 법정대위로 인한 저당권의 이전
 - ⑩ 분묘기지권의 취득
 - ⑪ 재단법인으로의 출연재산의 귀속(출연자와 법인 사이)
 - ⑫ 포괄적 승계(포괄유증·회사의 합병)
- ※ 취득시효로 인한 물권변동은 법률의 규정에 의한 물권변동이지만 반드시 등기를 요한다(제245조).

2. 등기청구권

(1) 의의

- ① 등기권리자가 등기의무자에 대하여 등기절차에 협력할 것을 청구할 수 있는 권리로서 실체법상의 권리이며 사권(私權)이다. 따라서 등기관이라는 국가기관에 대한 공법상의 권리인 등기신청권과는 구별된다.
- ② 일정한 경우 등기의무자도 등기권리자에 대하여 등기청구권을 행사할 수 있다. 이를 등기인수청구권이라고도 한다.
- ③ 소유권보존등기는 등기의무자가 없으므로 등기신청권만 있을 뿐 등기청구권은 존재하지 않는다.

(2) 법률적 성질

1) 채권적 청구권

- ① 법률행위로 인한 물권변동에서의 등기청구권은 채권적 청구권이다(다수설·판례).
- ② 법률의 규정 중 취득시효로 인한 물권변동이 이에 해당한다.

2) 물권적 청구권

- ① 법률의 규정에 의한 물권변동에서의 등기청구권이 이에 해당한다.
- ② 등기와 실체관계가 불일치한 경우(위조문서에 의한 등기 등)에 발생하는 등기청구권도 물권적 청구권이라 할 수 있다(통설·판례).

중요판례

대법원 1970.06.30. 70다568

판결에 의한 부동산물권취득은 등기할 필요가 없으나 이때의 판결이란 판결 자체에 의하여 부동산 물권취득의 형성적 효력이 생기는 경우를 말하는 것이고 당사자 사이에 이루어진 어떠한 법률행위를 원인으로 하여 부동산 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 것과 같은 내용의 판결은 이에 포함되지 아니한다.

☞ 등기를 요하지 아니하는 물권변동으로서의 판결이란, 형성판결만을 의미하며 이행판결이나 확인판결은 이에 해당하지 아니한다. 형성판결에는 공유물분할판결, 사해행위취소판결, 상속재산분할판결 등이 있다.

대법원 1989.01.31. 87다카2358

토지의 소재나 지번의 표시에 착오나 유루가 있음을 이유로 한 경정등기의 허용은 토지를 표시하는 부동산등기에 있어서 소재지나 지번의 표시는 당해 토지의 동일성을 결정하는 요소라 할 것이므로 등기된 토지의 소재 또는 지번의 표시에 착오나 유루가 있다는 것을 이유로 한 경정은 그것을 허용해도 그 경정의 전후를 통하여 표시된 부동산의 동일성에 변함이 없는 것이라고 여겨질 정도로 위 착오 또는 유루의 표시가 경미하거나 극히 부분적일 때 한하여 허용된다.

대법원 1990.11.27. 89다카12398 전원합의체

이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로는 현재의 등기명의인을 상대로 그 등기의 말소를 구하는 외에 “진정한 등기명의를 회복”을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 직접 구하는 것도 허용된다.

대법원 2005.02.25. 2003다13048

등기관은 등기신청에 대하여 부동산등기법상 그 등기신청에 필요한 서면이 제출되었는지 여부 및 제출된 서면이 형식적으로 진정한 것인지 여부를 심사할 권한을 갖고 있으나 그 등기신청이 실체법상의 권리관계와 일치하는지 여부를 심사할 실질적인 심사권한은 없으므로, 등기관으로서 오직 제출된 서면 자체를 검토하거나 이를 등기부와 대조하는 등의 방법으로 등기신청의 적법 여부를 심사하여야 할 것이고, 이러한 방법에 의한 심사 결과 형식적으로 부진정한, 즉 위조된 서면에 의한 등기신청이라고 인정될 경우 이를 각하하여야 할 직무상의 의무가 있다고 할 것이지만, 등기관은 다른 한편으로 대량의 등기신청사건을 신속하고 적정하게 처리할 것을 요구받기도 하므로 제출된 서면이 위조된 것임을 간과하고 등기신청을 수리한 모든 경우에 등기관의 과실이 있다고는 할 수 없고, 위와 같은 방법의 심사 과정에서 등기업무를 담당하는 평균적 등기관이 보통 갖추어야 할 통상의 주의의무만 기울였어도 제출 서면이 위조되었다는 것을 쉽게 알 수 있었음에도 이를 간과한 채 적법한 것으로 심사하여 등기신청을 각하하지 못한 경우에 그 과실을 인정할 수 있다.

대법원 1976.11.06. 76다148 전원합의체

부동산매수인의 등기청구권도 형식주의를 취하고 있는 현행 민법하에서는 채권적 청구권이라고 해석되지만, 매수인이 매매목적물을 인도받은 경우에는 다른 채권과는 달리 소멸시효에 걸리지 않는다.

대법원 1966.10.21. 66다976

민법 제245조 제1항에 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기 함으로써 그 소유권을 취득한다고 규정하고 있으므로, 소유권취득기간의 만료만으로는 소유권취득의 효력은 없으나, 이를 원인으로 하여 소유권취득을 위한 등기청구권은 발생한다.

대법원 1999.03.18. 98다32175

부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받아 사용·수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 그 이전등기청구권의 행사 여부에 관하여 그가 그 부동산을 스스로 계속 사용·수익만 하고 있는 경우와 특별히 다를 바 없으므로 위 두 어느 경우에도 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.

대법원 2001.02.09. 2000다60708

통상의 채권채무관계에서는 채권자가 수령을 지체하는 경우 채무자는 공탁 등에 의한 방법으로 채무부담에서 벗어날 수 있으나 등기에 관한 채권채무관계에서는 이러한 방법을 사용할 수 없으므로, 등기의무자가 자기 명의로 있어서는 안될 등기가 자기 명의로 있음으로 인하여 사회생활상 또는 법상 불이익을 입을 우려가 있는 경우에는 訴의 방법으로 등기권리자를 상대로 등기를 인수받아 갈 것을 구하고, 그 판결을 받아 등기를 강제로 실현할 수 있도록 한 것이다.

☑ 채권적 청구권과 물권적 청구권

채권적 청구권	물권적 청구권
① 매수인의 이전등기청구권 ② 설정계약에 기한 저당권설정등기청구권 ③ 점유취득시효완성에 기한 소유권이전등기청구권 ④ 부동산임차인의 임차권등기청구권 ⑤ 환매권행사에 기한 소유권이전등기청구권 ⑥ 저당부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에 전(前)소유자의 저당권말소등기청구권 ⑦ 청구권 보전을 위한 가등기에 기한 본등기청구권	① 등기와 실체관계가 불일치한 경우(위조 등기)에 발생하는 말소등기청구권 ② 법정지상권자의 지상권설정등기청구권 ③ 법률행위의 무효·취소·해제에 기한 말소등기청구권 ④ 진정명의회복을 원인으로 하는 이전등기청구권 ⑤ 저당부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에 제3취득자의 저당권말소등기청구권 ⑥ 합의해제에 기한 말소등기청구권

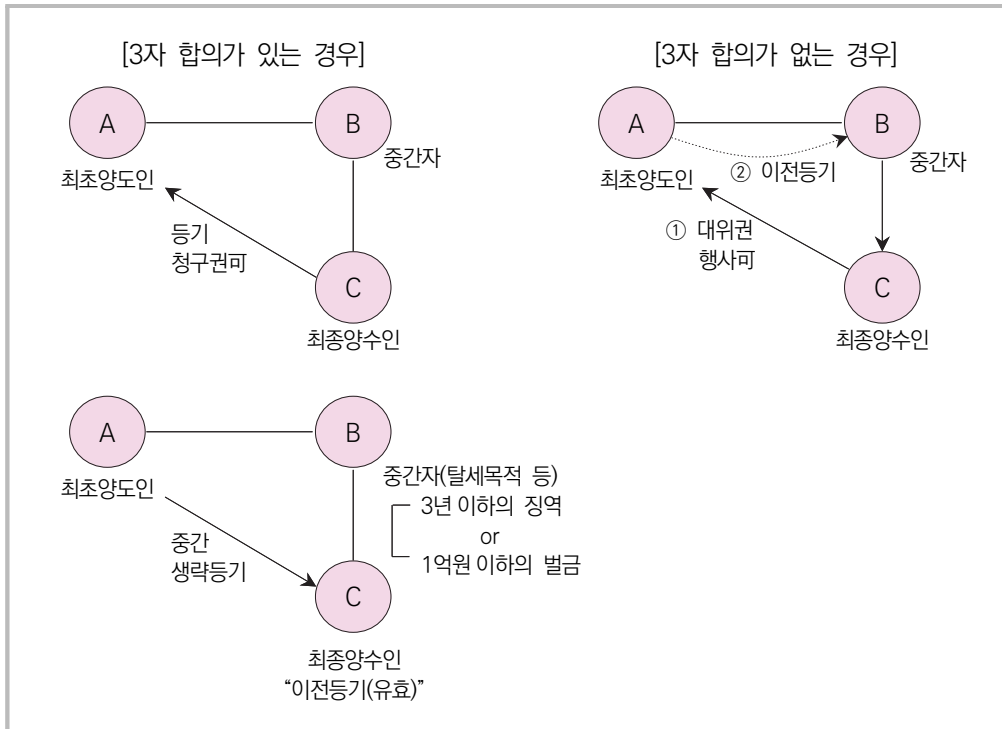
3. 중간생략등기

(1) 중간생략등기의 유형

- ① 신축건물의 경우에서 미등기부동산을 당사자 사이의 합의만으로 양도한 경우에 행하여진 양수인명의의 보존등기
- ② 상속재산을 양도하면서 피상속인으로부터 양수인에게로 한 이전등기
- ③ 부동산물권이 최초양도인으로부터 중간자에게, 중간자로부터 최종양수인에게 전전 유통되는 경우에 그 중간자에의 등기를 생략하고 최초양도인으로부터 직접 최종 양수인에게로 행하여지는 등기

(2) 중간생략등기의 유효성

- ① 3자의 합의가 있는 때에는 최종양수인은 최초양도인에 대하여 직접 소유권이전 등기를 청구할 수 있다. 이러한 합의는 묵시적으로도 할 수 있고, 또한 순차적으로도 할 수 있다.
- ② 합의가 없는 때에는 최종양수인은 최초양도인에 대하여 직접 소유권이전등기를 청구할 수 없다. 따라서 최종양수인은 최초양도인에 대하여 중간자를 대위하여 중간자명의의 소유권이전등기를 할 것을 청구할 수 있을 뿐이다.
- ③ 3자의 합의가 없더라도 이미 중간생략등기가 적법한 등기원인에 기하여 이루어진 때에는 실체관계와 부합하므로 유효하다는 것이 판례의 태도이다. 그리고 판례는 부동산등기특별조치법에서 미등기전매를 형사처벌하도록 하고 있으나, 이로써 순차 매도한 당사자 사이의 중간생략등기합의에 관한 사법상 효력까지 무효로 하는 것은 아니라고 한다(단속규정).



중요판례

대법원 2001.02.15. 99다66915 전원합의체

동일 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우에는 먼저 된 소유권보존등기가 원인무효가 되지 아니하는 한 나중 된 소유권보존등기는 1부동산 1용지주의를 채택하고 있는 현행 부동산등기법 아래에서는 무효이다.

대법원 1996.10.17. 96다12511 전원합의체

어느 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 소유권보존등기가 2중으로 경료된 경우 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아니어서 뒤에 된 소유권보존등기가 무효로 되는 때에는, 뒤에 된 소유권보존등기나 소유권이전등기를 근거로 등기부취득시효의 완성을 주장할 수는 없다.

대법원 1998.09.22. 98다23393

동일한 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없는 때에는 등기의 전후에 의하고, 등기의 전후는 등기용지의 동구에서 한 등기에 대하여는 순위번호에 의하므로, 동일한 부동산이나 동일한 지분에 관하여 이중으로 소유권 또는 지분이전등기가 경료된

경우, 선순위 등기가 원인무효이거나 직권말소될 경우에 해당하지 아니하는 한, 후순위등기는 실체적 권리관계에 부합하는지에 관계없이 무효이다.

대법원 2005.09.29. 2003다40651

- [1] 부동산 등기는 현재의 진실한 권리상태를 공시하면 그에 이른 과정이나 태양을 그대로 반영하지 아니하였어도 유효한 것으로서, 등기명의자가 전 소유자로부터 부동산을 취득함에 있어 등기부상 기재된 등기원인에 의하지 아니하고 다른 원인으로 적법하게 취득하였다고 하면서 등기원인 행위의 태양이나 과정을 다소 다르게 주장한다고 하여 이러한 주장만 가지고 그 등기의 추정력이 깨어진다고 할 수는 없다.
- [2] 최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 중간생략등기를 청구하기 위하여는 관계 당사자 전원의 의사합치가 필요하지만, 당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 일단 중간생략등기가 이루어진 이상 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로는 중간생략등기가 무효라고 할 수는 없다.
- [3] 부동산의 공유자 중 한 사람은 공유물에 대한 보존행위로서 그 공유물에 관한 원인무효의 등기 전부의 말소를 구할 수 있고, 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권과 무효등기의 말소청구권은 어느 것이나 진정한 소유자의 등기명의를 회복하기 위한 것으로서 실질적으로 그 목적이 동일하고 두 청구권 모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 그 법적 근거와 성질이 동일하므로, 공유자 중 한 사람은 공유물에 경료된 원인무효의 등기에 관하여 각 공유자에게 해당 지분별로 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 이행할 것을 단독으로 청구할 수 있다.

대법원 1995.12.26. 94다44675

미등기건물을 등기할 때에는 소유권을 원시취득한 자 앞으로 소유권보존등기를 한 다음 이를 양수한 자 앞으로 이전등기를 함이 원칙이라 할 것이나, 원시취득자와 승계취득자 사이의 합치된 의사에 따라 그 건물에 관하여 승계취득자 앞으로 직접 소유권보존등기를 경료하게 되었다면, 그 소유권보존등기는 실체적 권리관계에 부합되어 적법한 등기로서의 효력을 가진다.

대법원 1997.11.11. 97다33218

최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 최종 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다.

대법원 1995.08. 22. 95다15575

부동산이 전전양도된 경우에 중간생략등기의 합의가 없는 한 그 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 직접 자기명의로의 소유권이전등기를 청구할 수 없고, 부동산의 양도계약이 순차

이루어져 최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 그 소유권이 전등기 청구권을 행사하기 위하여는 관계 당사자 전원의 의사합치, 즉 중간생략등기에 대한 최초 양도인과 중간자의 동의가 있는 외에 최초 양도인과 최종 양수인 사이에도 그 중간등기 생략의 합의가 있었음이 요구되므로, 비록 최종 양수인이 중간자로부터 소유권이전등기 청구권을 양도받았다고 하더라도 최초 양도인이 그 양도에 대하여 동의하지 않고 있다면 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기 절차 이행을 청구할 수 없다.

대법원 2005.04.29. 2003다66431

중간생략등기의 합의란 부동산이 전전 매도된 경우 각 매매계약이 유효하게 성립함을 전제로 그 이행의 편의상 최초의 매도인으로부터 최종의 매수인 앞으로 소유권이전등기를 경료하기로 한다는 당사자 사이의 합의에 불과할 뿐이므로, 이러한 합의가 있다고 하여 최초의 매도인이 매매계약상의 매수인인 중간자에 대하여 갖고 있는 매매대금청구권의 행사가 제한되는 것은 아니다.

☞ 따라서 중간생략등기의 합의가 있는 후 최초매도인과 중간자 사이에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최초매도인은 최종 매수인에 대한 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다.

대법원 1993.01.26. 92다39112

부동산등기특별조치법상 조세포탈과 부동산투기 등을 방지하기 위하여 위 법률 제2조 제2항 및 제8조 제1호에서 등기하지 아니하고 제3자에게 전매하는 행위를 일정 목적범위 내에서 형사처벌하도록 되어 있으나 이로써 순차매도한 당사자 사이의 중간생략등기합의에 관한 사법상 효력까지 무효로 한다는 취지는 아니다.

☞ 탈세, 탈법 등을 목적으로 한 미등기전매행위는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으나, 중간생략등기의 사법적 효력은 그 유효성을 인정한다.

대법원 1997.11.11. 97다33218

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 허가구역 안에 있는 토지에 관한 매매계약을 체결하고자 하는 당사자는 공동으로 관할관청의 허가를 받아야 하는 바, 소유자인 최초 매도인이 중간 매수인에게 매도하고 이어 중간 매수인이 최종 매수인에게 순차 매도하였다면 각 매매계약의 당사자는 각각의 매매계약에 관하여 토지거래허가를 받아야 하는 것이며, 당사자들 사이에 최초의 매도인으로부터 최종 매수인 앞으로 직접 소유권이전등기를 경료하기로 하는 중간 생략등기의 합의가 있었다고 하더라도 이러한 중간생략등기의 합의란 부동산이 전전매도된 경우 각각의 매매계약이 유효하게 성립함을 전제로 그 이행의 편의상 최초의 매도인으로부터 최종의 매수인 앞으로 소유권이전등기를 경료하기로 한다는 당사자 사이의 합의에 불과할

뿐, 최초의 매도인과 최종의 매수인 사이에 매매계약이 체결되었다는 것을 의미하는 것은 아니므로 최초 매도인과 최종 매수인 사이에 매매계약이 체결되었다고 볼 수 없고, 설사 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 최종 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다.

대법원 1980.07.22. 80다791

부동산 등기는 현실의 권리관계에 부합하는 한 그 권리취득의 경위나 방법 등이 사실과 다르다고 하더라도 그 등기의 효력에는 아무런 영향이 없는 것이므로 증여에 의하여 부동산을 취득하였지만 등기원인을 매매로 기재하였다고 하더라도 그 등기의 효력에는 아무런 하자가 없다.

대법원 1964.11.24. 64다685

사망자 명의의 신청에 의하여 등기를 한 경우에도 실체상의 권리관계에 부합하고, 또 그 신청이 사망자의 생존시의 의사에 의하여 행해진 이상 그 등기는 유효하다.

대법원 1970. 07.24. 70다1005

증여로 인한 소유권이전등기가 되었다가 그 증여가 해제된 경우 그 증여자가 다시 소유권이전등기를 청구하였다고 하여 위법이라 할 수 없다.

대법원 1989.10.27. 87다카425

실질관계의 소멸로 무효로 된 등기의 유용은 그 등기를 유용하기로 하는 합의가 이루어지기 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 생기지 않은 경우에 한하여 허용된다.

대법원 2012.10.29. 자2012마1235

기존 건물이 멸실되고 새로이 건물이 세워진 경우 신축된 건물과 멸실된 건물이 그 재료, 위치, 구조 기타 면에 있어서 상호 유사한 면이 있다고 하더라도 그로써 신축된 건물이 멸실된 건물과 동일한 건물이라고는 할 수 없으므로, 그 등기는 신축건물에 대한 등기로서 유효하다고 할 수 없다.

☞ 무효등기의 유용은 권리관계에 관한 등기에 한하여 인정된다. 따라서 부동산의 표시, 즉 표제부의 무효등기의 유용은 인정되지 아니한다.

대법원 2000.03. 10. 99다65462

부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로

추정되고, 한편 부동산 등기는 현재의 진실한 권리상태를 공시하면 그에 이른 과정이나 태양을 그대로 반영하지 아니하였어도 유효한 것으로서, 등기명의자가 전 소유자로부터 부동산을 취득함에 있어 등기부상 기재된 등기원인에 의하지 아니하고 다른 원인으로 적법하게 취득하였다고 하면서 등기원인 행위의 태양이나 과정을 다소 다르게 주장한다고 하여 이러한 주장만 가지고 그 등기의 추정력이 깨어진다고 할 수는 없을 것이므로, 이러한 경우에도 이를 다투는 측에서 등기명의자의 소유권이전등기가 전 등기명의인의 의사에 반하여 이루어진 것으로서 무효라는 주장·증명을 하여야 한다.

대법원 1998.09.22. 98다29568

소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 이상 그 등기의 추정력은 인정될 수 없다.

대법원 2002.02.05. 2001다72029

전 등기명의인이 미성년자이고 당해 부동산을 친권자에게 증여하는 행위가 이해상반행위라 하더라도 친권자에게 이전등기가 경료된 이상, 그 이전등기에 관하여 필요한 절차를 적법하게 거친 것으로 추정된다.

대법원 2001.01.16. 98다20110

등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

4. 가등기

1) 의의

- ① 가등기란 본등기(종국등기)를 할 수 있을 만한 실체법적 또는 절차법적 요건을 완비하지 못한 경우 장래 그 요건이 완비된 때에 행하여질 본등기를 위하여 미리 그 순위를 보존해 두는 효력을 갖는 등기이다.
- ② 가등기를 하기 위해서는 아래의 경우와 같이 보전할 유효한 청구권이 존재하고 있어야 한다.
 - ㉠ 장차 권리변동을 발생하게 할 청구권을 보전하려 할 때
 - ㉡ 그러한 청구권이 시기부 또는 정지조건부인 때
 - ㉢ 기타 청구권이 장래에 있어서 확정될 것인 때

2) 가등기의 절차 및 효력

- ① 보존등기에 대하여는 청구권이 존재하지 않기 때문에 가등기를 할 수 없다.
- ② 본등기가 없는 한 가등기만으로는 아무런 실체법상의 효력도 생기지 않으며, 등기의 추정력도 인정되지 않는다. 따라서 가등기가 있더라도 본등기명의인은 부동산을 처분할 권리를 잃지 않는다.
- ③ 가등기에 기하여 본등기를 하는 때에 그 순위는 가등기의 순위에 의하지만 물건 변동의 효력은 본등기를 하는 때에 발생한다. 즉, 물건변동의 효력은 가등기시로 소급하지 않는다(통설·판례).
- ④ 가등기에 기하여 본등기가 이루어지면 이에 대항할 수 없는 중간등기는 직권말소되거나 후순위권리가 된다. 예컨대, 甲으로부터 乙에게 소유권이전의 가등기가 행하여지고 다시 甲으로부터 丙에게 소유권이전등기(또는 가압류등기 등)가 있는 후 乙이 가등기에 기하여 본등기를 하고자 할 때에는 乙은 甲(가등기의무자)을 상대로 본등기를 하여야 하며 乙의 본등기가 행하여지면 丙(제3취득자)의 등기는 등기관이 직권으로 말소하여야 한다.
- ⑤ 가등기의 가등기에 대하여 종래의 판례는 공시의 명확을 기할 수 없다는 점에서 부정하였으나, 현행 판례와 학설은 가등기의 가등기(가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기로 경료)를 대체로 긍정하고 있다.

중요판례

대법원 1962.12.24. 4292민상675

가등기 이후에 제3자에게 소유권이전의 본등기가 된 경우에 가등기자는 그 본등기를 경유하지 아니하고서는 가등기 이후에 이루어진 본등기의 말소를 청구할 수 없고 가등기의무자인 전소유자를 상대로 본등기청구권을 행사하여야 하고 가등기권리자가 그 소유권이전의 본등기를 한 경우에는 등기관은 부동산등기법 제175조 제1항, 제55조 제2호에 의하여 가등기 이후에 한 제3자의 본등기를 직권말소할 수 있다.

대법원 1998.10.07. 98마1333

국세 압류등기 이전에 소유권이전청구권 보전의 가등기가 경료되고 그 후 본등기가 이루어진 경우, 그 가등기가 매매예약에 기한 순위 보전의 가등기라면 그 이후에 경료된 압류등기는 효력을 상실하여 말소되어야 할 것이지만, 그 가등기가 채무담보를 위한 가등기, 즉 담보가 등기라면 그 후 본등기가 경료되더라도 가등기는 담보적 효력을 갖는데 그치므로 압류등기는 여전히 유효하므로 말소될 수 없다.

대법원 1982.06.22. 81다1298,1299

가등기는 그 성질상 본등기의 순위보전의 효력만이 있고 후일 본등기가 경료된 때에는 본등기의 순위가 가등기한 때로 소급함으로써 가등기후 본등기 전에 이루어진 중간처분이 본등기보다 후순위로 되어 실효될 뿐이고 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기한 때로 소급하여 발생하는 것은 아니다.

대법원 1998.11.19. 98다24105 전원합의체

가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물건변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부가등기의 형식으로 경료할 수 있다.

5. 무효등기의 유용의 문제

① 의의

무효등기의 유용이란 실제적 권리관계에 부합하지 않는 무효인 등기를 그 등기에 부합하는 실제적 권리관계가 있게 된 때에 유효한 등기로 하는 경우를 말한다. 무효등기의 유용은 무효행위의 전환의 일종이다.

② 유형

㉠ 가장매매를 원인으로 한 소유권이전등기는 무효이나, 후에 적법한 매매계약이 있게 되어 처음의 무효등기를 적법한 원인에 의한 등기로 유용하는 경우

㉡ 등기원인이 되는 행위가 유효하게 존재하였다가 후에 취소·해제된 경우와 같이 처음에는 물건행위에 부합하는 유효한 등기였지만, 후에 실제관계를 잃게 되어 무효로 되었으나 다시 내용상 처음과 비슷한 실제관계가 생긴 경우에 그 등기의 유용의 경우

③ 판례의 태도

실질관계의 소멸로 무효로 된 등기의 유용은 그 등기를 유용하기로 하는 합의가 이루어지기 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 생기지 않은 경우에는 허용된다. 그러나 멸실된 건물의 보존등기를 멸실 후에 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 사항란의 등기의 유용이 아니라 표제부의 등기의 유용이므로 무효이다.

대법원 1989.10.27. 87다카425

- [1] 실질관계의 소멸로 무효로 된 등기의 유용은 그 등기를 유용하기로 하는 합의가 이루어지기 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 생기지 않은 경우에 한하여 허용된다.
- [2] 가등기의 등기원인이 실효된 이후에 전소유자와의 무효등기의 유용에 관한 합의에 따라 가등기 명의인이던 갑 명의로 마쳐진 소유권이전의 본등기는 그 등기유용의 합의가 이루어지기 전에 이미 소유권이전등기를 한 등기상의 이해관계인인 을에 대한 관계에서는 실질관계를 결한 무효의 등기로 평가되므로, 위 갑 명의 소유권이전등기나 이 등기를 기초로 하여 마쳐진 병 명의의 소유권이전등기가 원인무효의 등기로 말소될 때에는, 직권말소된 을 명의 소유권이전등기에 관하여 등기공무원이 직권으로 그 말소등기의 회복등기를 하여야 하는 것으로서 그 말소회복등기가 되기 전이라도 을은 등기명의인으로서의 권리를 그대로 보유하고 있기 때문에 소유자로 추정된다.

대법원 2012.10.29. 자2012마1235

기존 건물이 멸실되고 새로이 건물이 세워진 경우 신축된 건물과 멸실된 건물이 그 재료, 위치, 구조 기타 면에 있어서 상호 유사한 면이 있다고 하더라도 그로써 신축된 건물이 멸실된 건물과 동일한 건물이라고는 할 수 없으므로, 그 등기는 신축건물에 대한 등기로서 유효하다고 할 수 없다.

☞ 무효등기의 유용은 권리관계에 관한 등기에 한하여 인정된다. 따라서 부동산의 표시, 즉 표제부의 무효등기의 유용은 인정되지 아니한다.

6. 등기의 효력

(1) 본등기의 효력

1) 권리변동적 효력(창설적 효력)

등기는 원칙적으로 부동산물권변동을 일으키는 효력을 가지는 바, 이것이 등기의 효력 중에서 가장 중요한 것이다. 물권변동의 효력은 등기를 신청한 때가 아니고, 실제로 등기부에 기록된 때에 발생한다.

2) 순위확정력

같은 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 등기한 순서에 따른다. 즉, 같은 구에서 일어난 등기의 순위는 순위번호에 의하고 다른 구에서 일어난

등기의 순위는 접수번호에 의하여 결정된다. 또한 부기등기의 순위는 주등기의 순위에 의하고, 부기등기 상호간의 순위는 그 등기 순서에 따른다.

3) 대항적 효력

부동산임차권·환매권 등이 등기된 때에는 제3자에 대하여서도 대항할 수 있게 된다. 또한 지상권·지역권·전세권·저당권에 있어서 그 존속기간·지료·이자·지급시기 등에 대해서도 마찬가지이다. 즉, 등기가 허용되는 일정한 사항에 관하여는 등기하지 않으면 당사자 사이에서의 채권적 효력이 있을 뿐이다. 이것을 등기한 때에는 당사자 이외의 제3자에 대해서도 주장할 수 있게 된다.

4) 공신력

등기에 공신력은 인정되지 않는다. 따라서 무권리자의 등기는 무효이고, 이 무권리자의 등기를 믿고 이전등기를 하더라도 무효이다. 예컨대, 乙이 서류를 위조하여 甲 소유의 부동산을 자기의 소유명의로 등기하여 이를 丙에게 매각 이전한 경우에, 丙이 아무리 등기를 신뢰하고 乙 소유의 것이라고 믿더라도, 丙은 권리를 취득하지 못한다.

5) 추정적 효력

① 의의

추정력이란 어떤 등기가 있으면 그에 대응하는 실체적 권리관계가 존재하는 것으로 추정하게 하는 효력을 말한다. 민법은 등기의 추정력에 대한 명문규정을 두고 있지 않으나, 이를 인정하는 것이 통설과 판례이다. 단순한 추정에 지나지 않기 때문에 반증에 의하여 뒤집어질 수 있음은 당연하다.

② 추정력이 미치는 범위

㉠ 권리의 적법추정 : 소유자로 등기되어 있는 자는 일단 적법한 소유권을 가진 것으로 추정된다. 따라서 등기명의자가 소유자가 아니라고 다투는 자가 있다면 그 다투는 자가 그 등기의 무효사유를 증명하여야 한다.

㉡ 등기원인의 적법추정 : 등기의 추정력은 등기부에 기재된 등기원인에도 미치는 것에 대하여 학설은 대립하나, 판례는 긍정한다(대판 2002.2.5. 2001다 72029). 아울러 등기의 추정력은 등기부상의 기재사항에도 미친다. 예컨대 근저당권설정등기가 되어 있으면 근저당권의 존재외에도 그에 상응하는 피담보 채권도 존재하는 것으로 추정된다.

㉔ 권리변동의 당사자 간의 등기추정력 : 부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우에는 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐 아니라 그 전소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정되는 것이므로 이를 다투는 측에서 그 무효사유를 주장·입증하여야 한다(대법원 1994.9.13, 94다10160). 예컨대 매매를 원인으로 甲에서 乙로 이전등기가 되었는데, 甲이 乙에 대하여 매매계약의 부존재를 이유로 등기말소를 청구하는 경우에, 乙은 등기의 추정력을 주장할 수 있다.

③ 추정의 효과

- ㉕ 법률상의 권리추정이므로, 그 등기명의자가 소유자가 아니라고 다투는 자가 있다면 그 다투는 자가 그 등기의 무효사유를 증명하여야 한다.
- ㉖ 등기추정의 부수적 효과로서, 등기의 내용을 신뢰하는 것은 선의인데 과실이 없었던 것(무과실)으로 추정되고, 부동산물권을 취득하려는 자는 등기내용을 알고 있었던 것(악의)으로 추정된다.

중요판례

대법원 1997.04.08. 97다416

소유권이전등기가 전 등기명의인의 직접적인 처분행위에 의한 것이 아니라 제3자가 그 처분행위에 개입된 경우 현 등기명의인이 그 제3자가 전 등기명의인의 대리인이라고 주장 하더라도 현 소유명의인의 등기가 적법히 이루어진 것으로 추정되므로, 그 등기가 원인무효 임을 이유로 그 말소를 청구하는 전 등기명의인으로서는 그 반대사실, 즉 그 제3자에게 전 소유명의인을 대리할 권한이 없었다던가, 또는 제3자가 전 소유명의인의 등기서류를 위조하였다는 등의 무효사실에 대한 입증책임을 진다.

대법원 2000.03.10. 99다65462

부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정되고, 한편 부동산 등기는 현재의 진실한 권리상태를 공시하면 그에 이르는 과정이나 태양을 그대로 반영하지 아니하였어도 유효한 것으로서, 등기명의자가 전 소유자로부터 부동산을 취득함에 있어 등기부상 기재된 등기원인에 의하지 아니하고 다른 원인으로 적법 하게 취득하였다고 하면서 등기원인 행위의 태양이나 과정을 다소 다르게 주장한다고 하여 이러한 주장만 가지고 그 등기의 추정력이 깨어진다고 할 수는 없을 것이므로, 이러한 경우

에도 이를 다투는 측에서 등기명의자의 소유권이전등기가 전 등기명의인의 의사에 반하여 이루어진 것으로서 무효라는 주장입증을 하여야 한다.

대법원 1998.09.22. 98다29568

소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 이상 그 등기의 추정력은 인정될 수 없다.

대법원 2002.02.05. 2001다72029

전 등기명의인이 미성년자이고 당해 부동산을 친권자에게 증여하는 행위가 이해상반행위라 하더라도 친권자에게 이전등기가 경료된 이상, 그 이전등기에 관하여 필요한 절차를 적법하게 거친 것으로 추정된다.

대법원 2001.01.16. 98다20110

등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

(2) 가등기의 효력

1) 본등기 후의 효력

- ① 본등기 순위보전의 효력이 있다. 가등기란 본등기(종국등기)를 할 수 있을 만한 요건을 갖추지 못한 경우 장래 그 요건이 갖추어 질 때에 행하여질 본등기를 위하여 미리 그 순위를 보존해 두는 효력을 갖는 등기이다. 후에 요건을 갖추어서 본등기를 하게 되면 그 본등기의 순위는 가등기의 순위로 된다.
- ② 甲으로부터 乙에게 소유권이전의 가등기가 행하여지고 다시 甲으로부터 丙에게 소유권이전등기가 있는 후 乙이 가등기에 기하여 본등기를 하고자 할 때에는 乙은 甲(가등기의무자)을 상대로 본등기를 하여야 하며 乙의 본등기가 행하여지면 丙(제3취득자)의 등기는 등기관이 직권으로 말소하여야 한다.
- ③ 가등기에 기하여 본등기를 하는 때에 그 순위는 가등기의 순위에 의하지만 물권 변동의 효력은 본등기를 하는 때에 발생한다. 즉, 물권변동의 효력은 가등기시로 소급하지 않는다(통설·판례).

2) 본등기 전의 효력

- ① 청구권의 보전력을 주장하는 견해가 있으나, 판례는 본등기가 없는 한 가등기만으로는 아무런 실체법상의 효력도 생기지 않는다고 한다. 따라서 가등기가 있더라도 본등기명의인은 부동산을 처분할 권리를 잃지 않는다.
- ② 가등기에는 추정력도 인정되지 않는다. 예컨대 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다고 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다(대법원 1979.5.22., 79다239).

중요판례

대법원 1972.12.24. 4292민상675

가등기 이후에 제3자에게 소유권이전의 본등기가 된 경우에 가등기자는 그 본등기를 경유하지 아니하고서는 가등기 이후에 이루어진 본등기의 말소를 청구할 수 없고 가등기의무자인 전소유자를 상대로 본등기청구권을 행사하여야 하고 가등기권리자가 그 소유권이전의 본등기를 한 경우에는 등기관은 부동산등기법 제175조 제1항, 제55조 제2호에 의하여 가등기 이후에 한 제3자의 본등기를 직권말소할 수 있다.

대법원 1998.10.07. 98마1333

국세 압류등기 이전에 소유권이전청구권 보전의 가등기가 경료되고 그 후 본등기가 이루어진 경우, 그 가등기가 매매예약에 기한 순위 보전의 가등기라면 그 이후에 경료된 압류등기는 효력을 상실하여 말소되어야 할 것이지만, 그 가등기가 채무담보를 위한 가등기, 즉 담보가 등기라면 그 후 본등기가 경료되더라도 가등기는 담보적 효력을 갖는데 그치므로 압류등기는 여전히 유효하므로 말소될 수 없다.

대법원 1982.11.23. 81다카1110

- [1] 부동산등기법 제3조에서 말하는 청구권이란 동법 제2조에 규정된 물권 또는 부동산임차권의 변동을 목적으로 하는 청구권을 말하는 것이라 할 것이므로 부동산등기법상의 가등기는 위와 같은 청구권을 보전하기 위해서만 가능하고 이같은 청구권이 아닌 물권적 청구권을 보존하기 위해서는 할 수 없다.
- [2] 매매계약이 해제되면 그 계약의 이행으로 변동이 생겼던 물권은 당연히 그 계약이 없었던 원상태로 복귀하나, 매매계약 해제 이전에 매매목적물에 관하여 제3자에게 소유권이전등기가 경료된 뒤에 계약이 해제된 경우에는 계약해제의 효과로서 당연히 그 소유권이 매도인에게 복귀하지 않으므로 매도인은 소유권에 기하여 매수인 명의의 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 없다.

대법원 1992.09.25. 92다21258

- [1] 취득시효완성에 의한 등기를 하기 전에 먼저 소유권이전등기를 경료하여 부동산소유권을 취득한 제3자에 대하여는 그 제3자 명의의 등기가 무효가 아닌 한 시효취득을 주장할 수 없다.
- [2] 가등기는 그 성질상 본등기의 순위보전의 효력만이 있어 후일 본등기가 경료된 때에는 본등기의 순위가 가등기한 때로 소급하는 것 뿐이지 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기한 때로 소급하여 발생하는 것은 아니다.
- [3] 사망자를 상대로 한 확정판결에 기하여 소유권이전등기를 한 경우라 하더라도 실제적 권리관계에 부합한다면 이를 유효라 할 것이다.
- [4] 제3자 명의의 가등기가 경료된 부동산에 대하여 소유권이전등기청구권을 피보전권리로 하는 처분금지가처분결정이 된 경우에 위 가등기에 기한 본등기가 경료되면 그 가등기나 그에 기한 본등기가 원인무효이거나 종전 소유권자가 소유권을 되찾아 올 수 있는 등 특별한 사유가 없는 한 처분금지가처분결정은 그에 대항할 수 없다.
- [5] 가등기에 터잡아 본등기를 하는 것은 그 가등기에 기하여 순위보전된 권리의 취득(권리의 증대 내지 부가)이지 가등기상의 권리 자체의 처분(권리의 감소 내지 소멸)이라고는 볼 수 없으므로 가등기에 기한 본등기를 금지한다는 취지의 가처분은 부동산등기법 제2조에 규정된 등기할 사항에 해당하지 아니하고, 그러한 본등기금지가처분이 잘못으로 기입 등기되었다 하더라도 그 기재사항은 아무런 효력을 발생할 수 없으므로, 가처분권자는 이러한 무효인 가처분결정의 기입등기로서 부동산의 적법한 전득자에게 대항할 수 없다.

대법원 1998.11.19. 98다24105 전원합의체

가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물건변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다.

제3절 동산 물권변동

1. 권리자로부터의 취득

(1) 성립요건주의

동산에 관한 물권변동은 인도하여야 효력이 생긴다(제188조 제1항).

(2) 인도(引渡)의 의미

제188조 【동산물권양도의 효력, 간이인도】

- ① 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다.
- ② 양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다.

제189조 【점유개정】

동산에 관한 물권을 양도하는 경우에 당사자의 계약으로 양도인이 그 동산의 점유를 계속하는 때에는 양수인이 인도받은 것으로 본다.

제190조 【목적물반환청구권의 양도】

제3자가 점유하고 있는 동산에 관한 물권을 양도하는 경우에는 양도인이 그 제3자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도함으로써 동산을 인도한 것으로 본다.

〈인도의 종류〉

현실의 인도	물건을 교부하는 것과 같이 물건에 대한 사실상의 점유를 이전하는 것
간이인도	양수인 乙이 이미 목적물을 점유하고 있는 때에, 양도인 甲과의 사이에서 점유를 이전하는 합의만으로 이전하는 것 乙이 甲 소유의 노트북을 차임 10만원을 주고 사용하던 중, 이를 매수하였다.
점유개정	甲이 乙에게 매각한 물건을 다시 乙로부터 임차하여 점유하는 것과 같이, 양도인이 양도한 후에도 목적물을 계속 점유하는 경우 甲이 노트북을 乙에게 매도하였으나, 1개월간 차임 10만원을 주기로 하고 그 노트북을 계속하여 사용하기로 하였다.
반환청구권의 양도	甲이 丙에게 빌려준 물건을, 빌려준 채로 乙에게 양도하는 것 甲이 자기 소유의 자전거 1대를 丙에게 빌려주었는데, 이를 친구 乙에게 매도하고 甲이 乙에게 부탁하여 丙이 계속하여 사용하고 있다.

(3) 인도의 원칙에 대한 예외

동산에 관한 물권변동이지만 인도를 공시방법으로 하지 않는 경우도 있다.

1) 선박

20톤 이상의 기선 및 범선, 100톤 이상의 부선은 등기가 공시방법이며, 그 미만의 선박도 등록을 공시방법으로 한다(상법 제743조).

2) 자동차·건설기계·항공기

자동차·항공기 및 건설기계의 권리변동은 등록을 공시방법으로 한다.

2. 선의취득(무권리자로부터의 취득)

(1) 의의

무권리자의 동산의 점유를 믿고 매수한 경우에 매수자가 그 물건의 소유권을 취득하는 것과 같이 동산거래의 안전을 확보하기 위하여 동산점유에 공신력을 인정하는 제도를 말한다.

(2) 요건

1) 목적물은 동산에 한한다.

- ① 등기·등록으로 공시되는 동산은 제외한다.
- ② 화물상환증 또는 증권에 의하여 표상되는 동산은 원칙적으로 적용되지 않는다.
- ③ 증권적 채권(지시채권 등)도 원칙적으로 적용되지 않는다.
- ④ 금전도 선의취득의 적용이 되지 않는 것이 원칙이나 단순한 물건으로서 거래되는 금전의 경우에는 선의취득의 적용을 받는다.

2) 양도인이 목적물의 점유자일 것

- ① 양도인의 점유는 직접점유·간접점유임을 불문한다.
- ② 양도인의 점유는 자주점유·타주점유임을 불문한다.

3) 거래행위에 의하여 점유를 승계하였을 것

- ① 유효한 거래행위에 의하여 취득하였어야 한다.
- ② 상속 등 포괄승계에 의한 취득에는 인정되지 아니한다.
- ③ 점유의 취득방법은 현실의 인도에 한하지 않으며, 간이인도 및 반환청구권의 양도에 의한 방법도 가능하다는 것이 통설이나 점유개정에 의한 선의취득은 다수설과 판례는 부정한다.

4) 양도인이 무권리자일 것

- ① 양도인이 임차인이나 수치인, 점유보조자 등인 경우를 말한다.
- ② 양도인이 무권대리인인 경우에는 선의취득이 적용되지 아니한다. 단, 대리권이 있지만 본인이 무권리자인 경우에는 선의취득의 적용이 될 수 있다.

5) 평온·공연·선의·무과실로 취득할 것

- ① 취득자에게는 평온·공연·선의가 추정(제197조)되므로 스스로 증명책임을 부담하지 아니한다.
- ② 무과실은 추정되지 않으므로 이에 대한 증명책임에 대하여 견해의 대립이 있다.
 - ㉠ 다수설 : 제200조의 권리의 적법추정을 근거로 취득자에게 무과실도 추정된다고 한다.
 - ㉡ 소수설·판례 : 무과실에 대하여는 추정의 규정이 없으므로 선의취득자가 증명책임을 부담해야 한다는 입장이다.

(3) 효과

- ① 취득자는 동산 위에 외형상 존재하는 소유권 또는 질권을 취득한다(제249조·제343조).
- ② 선의취득에 의한 물권의 취득은 원시취득이라는 것이 통설과 판례의 견해이다.
- ③ 선의취득자는 원권리자에 대하여 부당이득반환의무를 부담하지 아니한다는 것이 통설의 입장이다. 단, 선의취득이 무상행위(無償行爲)로 인한 경우에는 그 이익을 반환하여야 한다는 것이 다수설의 태도이다.

3. 도품 및 유실물에 관한 특칙

- ① 동산이 도품이나 유실물인 때에는 선의취득의 요건을 갖추더라도 피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년 내에 취득자에 대하여 무상으로 그 물건의 반환을 청구할 수 있다(제250조).
- ② 위의 그 동산이 매매되거나, 공개시장이나 동종류의 물건을 판매하는 상인의 수중에 들어가 이들로부터 매각된 경우에는 그 매수인에 대하여 그 자가 지급한 대가를 변상하여야만 반환을 청구할 수 있다(제251조). 이는 거래안전의 보호를 위한 규정이다.

4. 사기·공갈·횡령

- ① 사기 또는 횡령의 경우에는 하자가 있더라도 권리자의 의사에 의하여 점유가 이전 되었으므로 도품·유실물이 아니다. 따라서 제250조가 적용되지 않는다.
- ② 점유보조자의 횡령의 경우에도 제250조의 적용이 없다고 보는 것이 다수설·판례의 입장이다.

중요판례

대법원 1995.06.29. 94다22071

동산의 선의취득은 양도인이 무권리자라고 하는 점을 제외하고는 아무런 흠이 없는 거래행위이어야 성립한다.

대법원 1978. 01.17. 77다1872

선의취득에 필요한 점유의 취득은 현실적 인도가 있어야 하고 점유개정으로 인한 점유취득 만으로는 그 요건을 충족할 수 없다.

대법원 1981. 08.20. 80다2530

동산의 선의취득에 필요한 점유의 취득은 이미 현실적인 점유를 하고 있는 양수인에게는 간이인도에 의한 점유취득으로 그 요건은 충족된다.

대법원 1991. 03.22. 91다70

민법 제249조가 규정하는 선의무과실의 기준시점은 물권행위가 완성되는 때이므로 물권적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물권적 합의보다 먼저 행하여지면 물권적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다.

대법원 2003.07.25. 2002다39616

채무자 이외의 자의 소유에 속하는 동산을 경매한 경우에도 경매절차에서 그 동산을 경락받아 경락대금을 납부하고 이를 인도받은 경락인은 특별한 사정이 없는 한 소유권을 선의취득한다고 할 것이지만, 그 동산의 매득금은 채무자의 것이 아니어서 채권자가 이를 배당을 받았다고 하더라도 채권은 소멸하지 않고 계속 존속하므로, 배당을 받은 채권자는 이로 인하여 법률상 원인 없는 이득을 얻고, 소유자는 경매에 의하여 소유권을 상실하는 손해를 입게 되었다고 할 것이니, 그 동산의 소유자는 배당을 받은 채권자에 대하여 부당이득으로서 배당받은 금원의 반환을 청구할 수 있다.

대법원 1999.01.26. 97다48906

양도인이 소유자로부터 보관을 위탁받은 동산을 제3자에게 보관시킨 경우에 양도인이 그 제3자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도하고 지명채권 양도의 대항요건을 갖추었을 때에는 동산의 선의취득에 필요한 점유의 취득 요건을 충족한다.

대법원 1991.03.22. 91다70

제250조는 목적물이 진정한 권리자의 의사에 반하거나 의사에 의하지 않고 그 점유를 이탈한 도품·유실물인 때에 피해자, 유실자는 선의취득자에 대하여 2년간 그 물건의 반환을 청구할 수 있는 제도에 관한 규정인 바, 여기에 도품·유실물이란 위에서 본 제도적 취지에 비추어 원권리자로부터 점유를 수탁한 사람이 적극적으로 제3자에게 부정처분한 경우와 같은 위탁물 횡령의 경우는 포함되지 아니하고, 또한 점유보조자의 횡령처럼 형사법상 절도죄가 되는 경우도, 진정한 권리자와 선의의 거래상대방 간의 이익형량의 필요성에 있어서 위탁물횡령의 경우와 다를 바 없으므로, 이 역시 민법 제250조의 도품·유실물에 해당하지 아니한다.

제4절 물권의 소멸

1. 물건 공통의 소멸사유

(1) 목적물의 멸실

목적물의 멸실은 모든 물권의 공통된 소멸사유에 해당한다.

(2) 소멸시효

점유권·소유권 그리고 담보물권은 소멸시효의 대상이 되지 아니한다. 그러므로 소멸시효에 걸리는 물권은 용익물권만이 해당한다.

(3) 물권의 포기

- ① 물권을 포기한다는 의사표시는 단독행위이다.
- ② 부동산물권의 포기는 등기를 하여야 효력이 발생한다.

(4) 공용징수

당해 토지의 편익을 위해 존재하는 지역권은 당해 토지가 수용되더라도 소멸하지 아니한다.

(5) 혼동

2. 혼동으로 인한 물권의 소멸

제191조 【혼동으로 인한 물권의 소멸】

- ① 동일한 물건에 대한 소유권과 다른 물권이 동일한 사람에게 귀속한 때에는 다른 물권은 소멸한다. 그러나 그 물권이 제3자의 권리의 목적이 된 때에는 소멸하지 아니한다.
- ② 전항의 규정은 소유권이외의 물권과 그를 목적으로 하는 다른 권리가 동일한 사람에게 귀속한 경우에 준용한다.
- ③ 점유권에 관하여는 전2항의 규정을 적용하지 아니한다.

(1) 의의

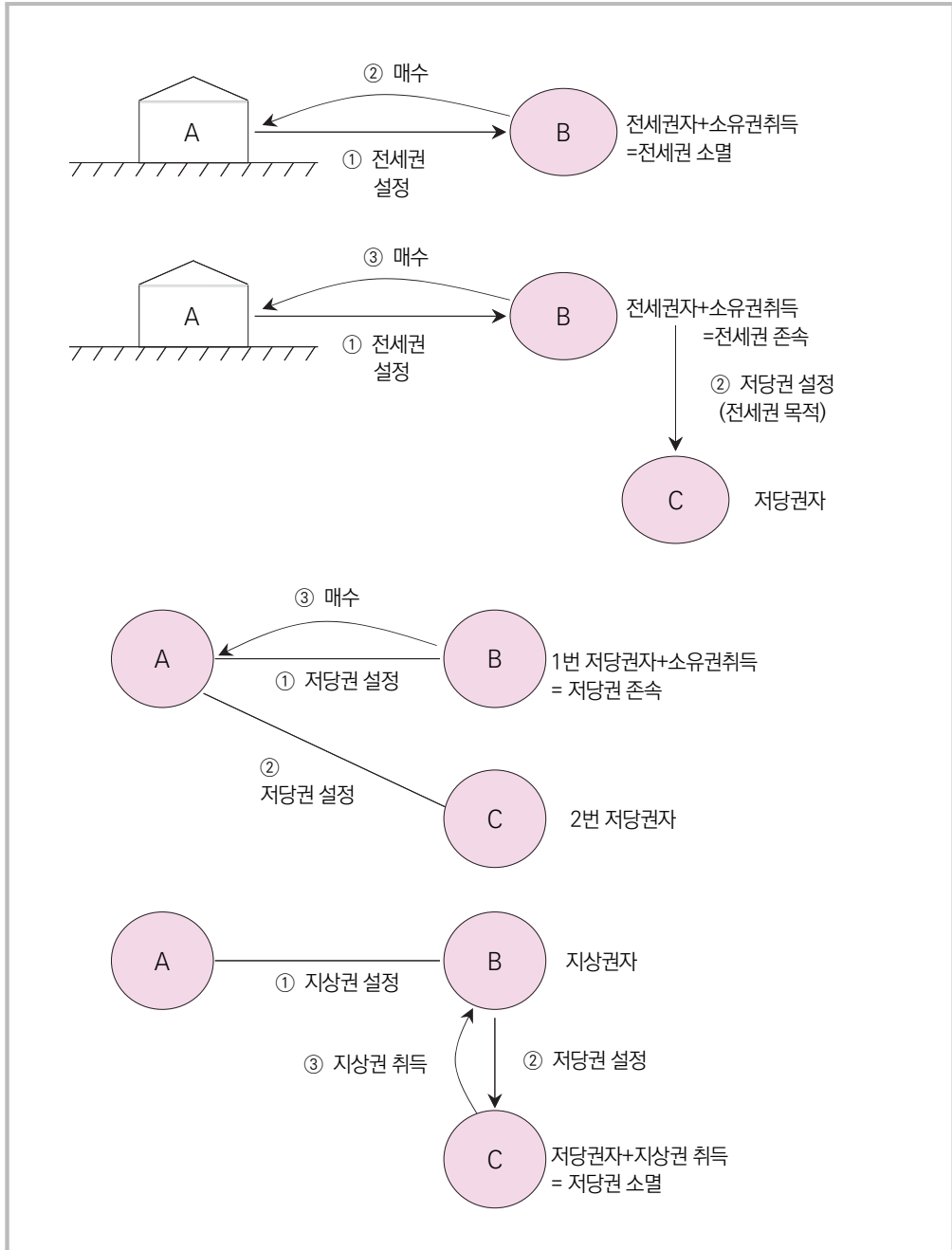
혼동이란 양립할 가치가 없는 두 개의 법률상의 지위가 동일인에게 귀속하는 것을 말하며 이는 물권과 채권의 공통된 소멸사유에 해당한다.

(2) 혼동의 모습

소유권과 제한물권의 혼동	(원칙) 소멸 - 토지의 지상권자가 그 토지의 소유권을 취득할 경우 지상권은 혼동으로 소멸한다. (예외) 존속 - 제한물권이 제3자의 권리의 목적으로 된 경우 - 전세권이 저당권의 목적이 된 경우 전세권자가 소유권을 취득하여도 전세권은 존속한다. - 제3자에게 부당한 이익이나 손해를 주게 되는 경우 - 하나의 토지에 둘 이상의 저당권이 설정된 경우에 선순위 저당권자가 소유권을 취득하여도 순위승진을 막기 위하여 그 선순위 저당권은 존속한다. - 저당권이 설정된 부동산에 가압류등기가 된 후 그 저당권자가 소유권을 취득한 경우 저당권은 존속한다. - 부동산에 지상권(또는 대항력을 갖춘 임차권)이 설정된 후 저당권이 설정되고 그 후 지상권자가 그 부동산의 소유권을 취득한 경우, 지상권은 존속한다. - 하나의 토지위에 지상권과 저당권이 순차로 설정된 경우, 저당권자가 그 토지의 소유권을 취득하면 저당권은 소멸한다. - 점유권은 성질상 혼동에 걸리지 아니한다. - 광업권은 토지소유권과는 독립되는 물권으로서 혼동에 걸리지 아니한다.
제한물권과 제한물권의 혼동	(원칙) 소멸 지상권 위에 저당권을 가지는 자가 그 지상권을 취득한 경우에는 저당권은 소멸한다. (예외) 혼동으로 소멸할 수 있는 제한물권이 제3자의 권리의 목적으로 되어 있을 때에는 소멸하지 않는다.

(3) 혼동의 효과

혼동에 의하여 물권은 절대적으로 소멸한다. 그러나 혼동으로 소멸된 권리라 하더라도 그 법률행위가 무효·취소·해제된 경우에는 다시 혼동이전의 상태로 복귀한다.



중요판례

대법원 1971. 08.31. 71다1386

근저당권자가 소유권을 취득하면 그 근저당권은 혼동에 의하여 소멸하지만 그 뒤 그 소유권 취득이 무효인 것이 밝혀지면 소멸하였던 근저당권은 당연히 부활한다.

대법원 2001.05.15. 2000다12693

부동산에 대한 소유권과 임차권이 동일인에게 귀속하게 되는 경우 임차권은 혼동에 의하여 소멸하는 것이 원칙이지만, 그 임차권이 대항요건을 갖추고 있고 또한 그 대항요건을 갖춘 후에 저당권이 설정된 때에는 혼동으로 인한 물권소멸 원칙의 예외 규정에 따라 임차권은 소멸하지 않는다.



2장 점유권

제1절 점유제도와 점유권

1. 점유제도

(1) 점유제도의 존재이유

- ① 물건에 대한 사실상의 지배를 '점유'라 하고, 이러한 점유가 있으면 그것을 정당화할 권리(본권)가 있느냐 없느냐를 불문하고 그 점유라는 사실을 기초로 하여 '점유권'이라는 물권을 인정한다.
- ② 사회질서와 평화를 위하여 인정한다.

(2) 법적 효과

- ① 점유의 침해에 대한 점유보호청구권 인정 (제204조 이하)
- ② 점유의 침해에 대한 자력구제권 인정 (제209조)
- ③ 점유물에 대한 권리는 적법한 것으로 추정 (제200조)
- ④ 선의점유자의 과실수취권 (제201조)
- ⑤ 점유물에 지출한 비용상환청구권 (제203조)
- ⑥ 점유는 동산물권변동의 성립 내지 효력발생요건
- ⑦ 점유의 공신력 인정

2. 점유권과 본권

점유권	• 사실상의 지배를 내용으로 하는 권리이다. • 배타성도 없고 우선적 효력도 인정되지 아니한다.
본권	• '점유할 수 있는 권리'를 말한다. • 소유권·지상권·지역권·전세권·유치권 등이 본권에 해당한다.

중요판례

대법원 2001.01.16. 98다20110

물건에 대한 점유란 사회관념상 어떤 사람의 사실적 지배에 있다고 보여지는 객관적 관계를 말하는 것으로서 사실상의 지배가 있다고 하기 위하여는 반드시 물건을 물리적, 현실적으로 지배하는 것만을 의미하는 것이 아니고, 물건과 사람과의 시간적, 공간적 관계와 본권관계, 타인지배의 배제 가능성 등을 고려하여 사회통념에 따라 합목적적으로 판단하여야 한다.

제2절 점유의 모습

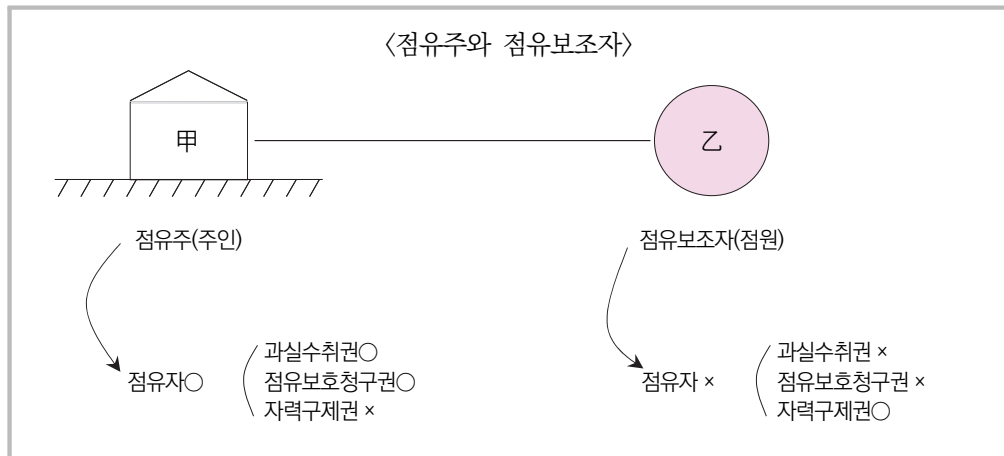
1. 점유의 모습

(1) 점유의 의의와 점유보조자

제195조 【점유보조자】

가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다.

- ① 일정한 점유의사는 필요로 하지 않으나, 적어도 사실적 지배관계를 가지려는 의사(점유설정 의사)는 필요하다는 것이 통설이다.
- ② 점유보조자란 가사상·영업상 기타 이와 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 자를 말하다(제195조).
- ③ 점유보조자는 점유자가 아니며, 점유주만이 점유자이므로 점유보조자에게는 점유권의 효력이 인정되지 아니한다. 따라서 과실수취권이나 점유보호청구권을 행사할 수 없다. 그러나 점유보조자도 자력구제권을 행사할 수 있다.



(2) 간접점유자

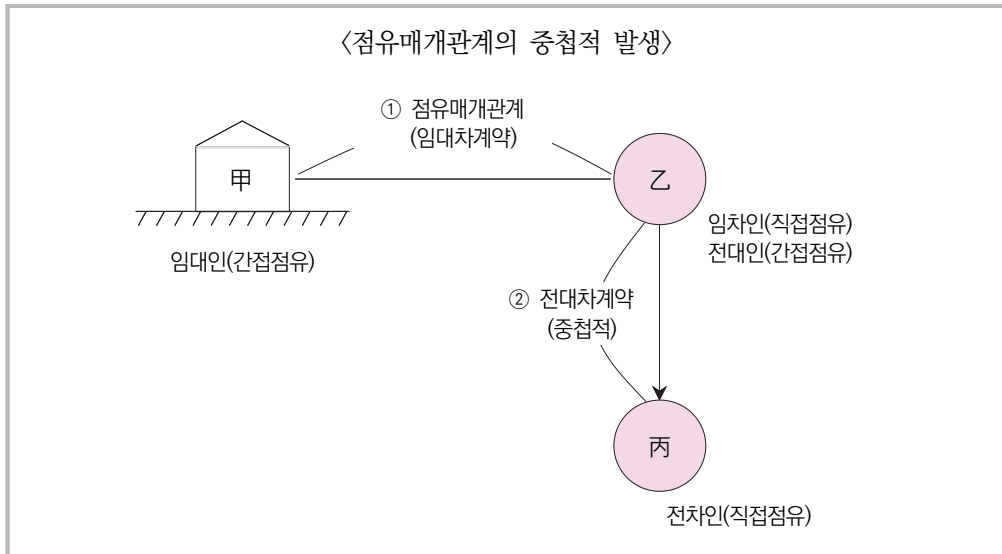
제194조 【간접점유】

지상권, 전세권, 질권, 사용대차, 임대차, 임치 기타의 관계로 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다.

간접점유란 사실상 물건에 대한 지배가 없는데도 점유자로 인정되는 것, 즉 타인의 직접점유에 매개되어 점유하는 것을 말한다.

간접점유자	직접점유자
지상권설정자	지상권자
전세권설정자	전세권자
질권설정자	질권자
임치인	수치인
임대인	임차인
사용대주	사용차주

- ① 직접점유자와 간접점유자 사이에 지상권·전세권 등의 법률관계, 즉 법률매개관계가 존재하여야 한다. 아울러 점유매개관계는 중첩적으로 발생할 수 있다.
- ② 간접점유자는 직접점유자에 대하여 반환청구권을 가지고 있으며, 반환청구권을 제3자에게 양도함으로써 간접점유를 승계시킬 수 있다.
- ③ 간접점유자도 점유권을 가지며(제194조), 점유보호청구권도 있으나(제207조), 다만 침탈자에 대하여 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있을 뿐이다.
- ④ 간접점유자는 직접점유자에게 점유보호청구권이나 자력구제권을 행사할 수 없고, 점유매개관계나 물권에 기인한 청구권만 행사할 수 있다.
- ⑤ 간접점유자에게는 자력구제권이 인정되지 않는다는 것이 다수설의 태도이다.



중요판례

대법원 2013.06.27. 2011다5813

불법점유를 이유로 하여 부동산의 인도를 청구하는 경우에는 현실적인 점유자를 상대로 하여야 하는 것과 달리, 약정에 의하여 인도를 청구하는 경우에는 그 상대방이 직접점유자로 제한되지 아니하며 간접점유자를 상대로 하는 청구도 허용된다.

대법원 1998. 2. 24. 96다8888

취득시효의 요건인 점유는 직접점유뿐만 아니라 간접점유도 포함하는 것이고, 점유매개 관계는 법률의 규정, 국가행위 등에 의해서도 발생하는 것인데, 자연공원법의 개정으로 국립공원관리공단이 설립되어 1987. 7. 1.부터 북한산 국립공원의 관리업무가 지방자치단체에서 그 공단에 인계되어 그 후부터 그 공단이 당해 임야를 포함한 북한산 국립공원의 관리 업무를 수행하였다고 하더라도, 같은 법 제49조의16 제2항이 "지방자치단체는 당해 행정구역 안에 있는 국립공원의 관리에 사용된 토지, 건물 등의 부동산을 국립공원관리공단으로 하여금 무상으로 사용하게 할 수 있다."고 규정하고 있음에 비추어 지방자치단체는 그 임야에 관하여 국립공원관리공단에게 반환을 청구할 수 있는 지위에 있고 따라서 1987. 7. 1. 이후에는 그 임야에 대하여 간접점유를 취득하였다고 할 것이다.

대법원 1987.04.14. 85다카2230

자주점유는 소유자와 동일한 지배를 하려는 의사를 가지고 하는 점유를 의미하는 것이지 소유권을 가지고 있거나 또는 소유권이 있다고 믿고서 하는 점유를 의미하는 것은 아니다.

대법원 1990.11.27. 90다카27280

점유에 있어 소유의 의사 유무는 점유취득의 원인인 권원에 의하여 외형적·객관적으로 정해져야 하는 것이므로 매매계약에 기하여 목적토지의 점유를 취득한 경우에는 매수인의 점유는 소유의 의사로써 하는 것이다.

대법원 2008.05.08. 2007다77279

취득시효에 있어서 자주점유의 요건인 소유의 의사는 객관적으로 점유권원의 성질에 의하여 그 존부를 결정하는 것이나, 다만 그 점유권원의 성질이 분명하지 않을 때에는 민법 제197조 제1항에 의하여 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로 점유자가 스스로 그 점유권원의 성질에 의하여 자주점유임을 증명할 책임이 없고, 점유자의 점유가 소유의 의사 없는 타주 점유임을 주장하는 상대방에게 타주점유에 대한 증명책임이 있다.

대법원 2013.03.28. 2012다68750

공유부동산의 경우에 공유자 중의 1인이 공유지분권에 기초하여 부동산 전부를 점유하고 있다고 하여도 다른 특별한 사정이 없는 한 권원의 성질상 다른 공유자의 지분비율의 범위 내에서는 타주점유이다.

대법원 2004.09.24. 2004다27273

- [1] 부동산을 타인에게 매도하여 그 인도 의무를 지고 있는 매도인의 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유로 변경된다.
- [2] 부동산매매계약이 해제되면 매수인의 매매목적물에 대한 점유는 계약해제일로부터 타주 점유로 된다.
- [3] 경락에 의한 소유권이전등기가 있으면 종전소유자는 경락인에게 경락부동산을 인도할 의무가 있으므로 종전소유자의 점유는 자주점유에서 타주점유로 전환된다.

대법원 2003.08.22. 2001다23225

민법 제197조 제1항에 의하면 물건의 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로 점유자의 점유가 소유의 의사 없는 타주점유임을 주장하는 상대방에게 타주점유에 대한 증명책임이 있는 것이고, 점유자가 스스로 매매 등과 같은 자주점유의 권원을 주장한 경우 이것이 인정되지 않는다는 이유만으로 자주점유의 추정이 반복된다거나 또는 점유권원의 성질상 타주점유로 볼 수는 없다 할 것이나, 점유자가 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었거나, 점유자가 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 행사하는 의사를 가지고 점유하는 것으로 볼 수 없는 객관적 사정, 즉 외형적·객관적으로 보아 점유자가 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 아니하였던 것이라고 볼 만한 사정이 증명된 경우에 그 추정은 깨어지는

것이고, 점유자가 점유 개시 당시 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것이 증명된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 할 것이므로 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어졌다고 보아야 한다.

대법원 2015.04.23. 2013다89358

민법 제197조 제1항에 의하면, 물건의 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로 점유자가 취득시효를 주장하는 경우 스스로 소유의 의사를 증명할 책임은 없고, 그 점유자의 점유가 소유의 의사가 없는 점유임을 주장하여 취득시효의 성립을 부정하는 자에게 그 증명 책임이 있다. 그리고 점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인지는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유 취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 결정되어야 하기 때문에 점유자가 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었거나, 점유자가 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 하려는 의사를 가지고 점유하는 것으로 볼 수 없는 객관적 사정, 즉 점유자가 진정한 소유자라면 통상 취하지 아니할 태도를 나타내거나 소유자라면 당연히 취하였을 것으로 보이는 행동을 취하지 아니한 경우 등 외형적·객관적으로 보아 점유자가 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 아니하였던 것이라고 볼 만한 사정이 증명된 경우에 한하여 그 추정은 깨지는 것이다.

대법원 2000.09.29. 99다58570, 58587

토지를 매수·취득하여 점유를 개시함에 있어서 매수인이 인접 토지와와의 경계선을 정확하게 확인하여 보지 아니하여 착오로 인접 토지의 일부를 그가 매수·취득한 토지에 속하는 것으로 믿고서 인접 토지의 일부를 현실적으로 인도받아 점유하고 있다면 인접 토지의 일부에 대한 점유는 소유의 의사에 기한 것이다.

대법원 1983.07.12. 82다708, 709 전원합의체

점유자가 취득시효기간이 경과한 후에 상대방에게 토지의 매수를 제의한 일이 있다고 하여도 일반적으로 점유자는 취득시효가 완성한 후에도 소유권자와의 분쟁을 간편히 해결하기 위하여 매수를 시도하는 사례가 허다함에 비추어 이와 같은 매수제의를 하였다는 사실을 가지고 위 점유자의 점유를 타주점유라고 볼 수 없다.

대법원 2000.12.08. 2000다14934

진정 소유자가 자신의 소유권을 주장하며 점유자 명의의 소유권이전등기는 원인무효의

등기라 하여 점유자를 상대로 토지에 관한 점유자 명의의 소유권이전등기의 말소등기청구 소송을 제기하여 그 소송사건이 점유자의 패소로 확정되었다면, 그 점유자는 민법 제197조 제2항의 규정에 의하여 그 소송의 제기시부터는 토지에 대한 악의의 점유자로 간주되고, 또 이러한 경우 토지 점유자가 소유권이전등기 말소등기청구소송의 직접 당사자가 되어 소송을 수행하였고 결국 그 소송을 통해 대지의 정당한 소유자를 알게 되었으며, 나아가 패소판결의 확정으로 점유자로서는 토지에 관한 점유자 명의의 소유권이전등기에 관하여 정당한 소유자에 대하여 말소등기의무를 부담하게 되었음이 확정되었으므로, 단순한 악의점유의 상태와는 달리 객관적으로 그와 같은 의무를 부담하고 있는 점유자로 변한 것이어서 점유자의 토지에 대한 점유는 패소판결 확정 후부터는 타주점유로 전환되었다고 보아야 한다.

☞ 선의의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시부터 악의의 점유자로 간주된다.

(3) 자주점유와 타주점유

- ① 소유의 의사로써 하는 점유를 자주점유라 하며(■ 소유자·무효인 매매의 매수인·도둑(盜人) 등), 소유의 의사 없는 점유를 타주점유라 한다(■ 지상권자·전세권자·임차인 등).
- ② 점유자가 주장하는 권원이 불분명한 경우에는 점유자는 소유의 의사로써 점유하는 것으로 추정된다(제197조 제1항).
- ③ 점유자는 소유의 의사로 선의·평온·공연·계속 그리고 적법하게 점유한 것으로 추정된다. 단, 무과실은 추정되지 않으므로 점유자가 스스로 증명하여야 한다는 것이 판례의 태도이다.

중요판례

대법원 1987.04.14. 85다카2230

자주점유는 소유자와 동일한 지배를 하려는 의사를 가지고 하는 점유를 의미하는 것이지 소유권을 가지고 있거나 또는 소유권이 있다고 믿고서 하는 점유를 의미하는 것은 아니다.

대법원 1990.11.27. 90다카27280

점유에 있어 소유의 의사 유무는 점유취득의 원인인 권원에 의하여 외형적·객관적으로 정해져야 하는 것이므로 매매계약에 기하여 목적토지의 점유를 취득한 경우에는 매수인의 점유는 소유의 의사로써 하는 것이다.

대법원 2008.05.08. 2007다77279

취득시효에 있어서 자주점유의 요건인 소유의 의사는 객관적으로 점유권원의 성질에 의하여 그 존부를 결정하는 것이나, 다만 그 점유권원의 성질이 분명하지 않을 때에는 민법 제197조 제1항에 의하여 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로 점유자가 스스로 그 점유권원의 성질에 의하여 자주점유임을 입증할 책임이 없고, 점유자의 점유가 소유의 의사 없는 타주 점유임을 주장하는 상대방에게 타주점유에 대한 입증책임이 있다.

대법원 2013.03.28. 2012다68750

공유부동산의 경우에 공유자 중의 1인이 공유지분권에 기초하여 부동산 전부를 점유하고 있다고 하여도 다른 특별한 사정이 없는 한 권원의 성질상 다른 공유자의 지분비율의 범위 내에서는 타주점유이다.

대법원 2004.09.24. 2004다27273

- [1] 부동산을 타인에게 매도하여 그 인도 의무를 지고 있는 매도인의 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유로 변경된다.
- [2] 부동산매매계약이 해제되면 매수인의 매매목적물에 대한 점유는 계약해제일로부터 타주 점유로 된다.
- [3] 경락에 의한 소유권이전등기가 있으면 종전소유자는 경락인에게 경락부동산을 인도할 의무가 있으므로 종전소유자의 점유는 자주점유에서 타주점유로 전환된다.

대법원 2003.08.22. 2001다23225

점유자가 스스로 매매 등과 같은 자주점유의 권원을 주장한 경우 이것이 인정되지 않는다는 이유만으로 자주점유의 추정이 반복된다거나 또는 점유권원의 성질상 타주점유로 볼 수는 없다 할 것이나, 점유자가 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었거나, 점유자가 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 행사하는 의사를 가지고 점유하는 것으로 볼 수 없는 객관적 사정, 즉 외형적·객관적으로 보아 점유자가 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 아니하였던 것이라고 볼 만한 사정이 증명된 경우에 그 추정은 깨어지는 것이고, 점유자가 점유 개시 당시 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것이 입증된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 할 것이므로 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어졌다고 보아야 한다.

대법원 2015.04.23. 2013다89358

민법 제197조 제1항에 의하면, 물건의 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로 점유자가 취득시효를 주장하는 경우 스스로 소유의 의사를 증명할 책임은 없고, 그 점유자의 점유가 소유의 의사가 없는 점유임을 주장하여 취득시효의 성립을 부정하는 자에게 그 증명

책임이 있다. 그리고 점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인지는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유 취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 결정되어야 하기 때문에 점유자가 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었거나, 점유자가 타인의 소유권을 배제하여 자기의 소유물처럼 배타적 지배를 하려는 의사를 가지고 점유하는 것으로 볼 수 없는 객관적 사정, 즉 점유자가 진정한 소유자라면 통상 취하지 아니할 태도를 나타내거나 소유자라면 당연히 취하였을 것으로 보이는 행동을 취하지 아니한 경우 등 외형적·객관적으로 보아 점유자가 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 아니하였던 것이라고 볼 만한 사정이 증명된 경우에 한하여 그 추정은 깨지는 것이다

대법원 2000. 09. 29. 99다58570, 58587

토지를 매수취득하여 점유를 개시함에 있어서 매수인이 인접 토지와와의 경계선을 정확하게 확인하여 보지 아니하여 착오로 인접 토지의 일부를 그가 매수취득한 토지에 속하는 것으로 믿고서 인접 토지의 일부를 현실적으로 인도받아 점유하고 있다면 인접 토지의 일부에 대한 점유는 소유의 의사에 기한 것이다.

대법원 1983. 07.12. 82다708, 709 전원합의체

점유자가 취득시효기간이 경과한 후에 상대방에게 토지의 매수를 제의한 일이 있다고 하여도 일반적으로 점유자는 취득시효가 완성한 후에도 소유권자와의 분쟁을 간편히 해결하기 위하여 매수를 시도하는 사례가 허다함에 비추어 이와 같은 매수제의를 하였다는 사실을 가지고 위 점유자의 점유를 타주점유라고 볼 수 없다.

대법원 2000.12.08. 2000다14934

진정 소유자가 자신의 소유권을 주장하며 점유자 명의의 소유권이전등기는 원인무효의 등기라 하여 점유자를 상대로 토지에 관한 점유자 명의의 소유권이전등기의 말소등기청구 소송을 제기하여 그 소송사건이 점유자의 패소로 확정되었다면, 그 점유자는 민법 제197조 제2항의 규정에 의하여 그 소송의 제기시부터는 토지에 대한 악의의 점유자로 간주되고, 또 이러한 경우 토지 점유자가 소유권이전등기 말소등기청구소송의 직접 당사자가 되어 소송을 수행하였고 결국 그 소송을 통해 대지의 정당한 소유자를 알게 되었으며, 나아가 패소판결의 확정으로 점유자로서는 토지에 관한 점유자 명의의 소유권이전등기에 관하여 정당한 소유자에 대하여 말소등기의무를 부담하게 되었음이 확정되었으므로, 단순한 악의점유의 상태와는 달리 객관적으로 그와 같은 의무를 부담하고 있는 점유자로 변한 것이어서 점유자의 토지에 대한 점유는 패소판결 확정 후부터는 타주점유로 전환되었다고 보아야 한다.

☞ 선의의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시부터 악의의 점유자로 간주된다. 그러나 타주점유로 전환되는 시기는 패소판결 확정 후부터이다.

(4) 선의점유와 악의점유

선의점유	본권이 없음에도 불구하고 있다고 오신(誤信)하여 하는 점유를 말한다.
악의점유	본권이 없음을 알면서 하는 점유 또는 본권의 존재에 대해 의심을 품으면서 하는 점유를 말한다.
구별실익	• 취득시효 • 과실수취권 • 점유자의 회복자에 대한 책임 • 선의취득

(5) 과실 있는 점유와 과실 없는 점유

선의임에 과실이 있느냐 없느냐에 따른 구분이며 취득시효·선의취득에 구별의 실익이 있다.

2. 점유자와 회복자와의 관계

(1) 점유물의 멸실·훼손

- ① 점유자가 점유물을 멸실·훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며, 선의의 자주점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하면 된다.
- ② 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다.

(2) 점유자의 비용상환청구권

- ① 점유자(선의·악의 불문)는 점유물을 유지·보존하기 위하여 지출한 필요비의 상환을 회복자에 대하여 청구할 수 있다. 다만, 점유자가 과실을 취득한 때에는 통상의 필요비는 청구할 수 없다.
- ② 점유물의 개량을 위하여 지출한 유익비는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 점유자는 비용의 상환을 받을 때까지 점유물을 유지할 수 있으나 법원은 회복자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여(許與)할 수 있으며 이 경우 점유자의 유지권은 소멸한다.

- ④ 선의의 점유자는 점유물에서 생기는 과실(果實)을 취득할 수 있다(제201조 제1항).
그러나 악의의 점유자는 수취한 과실(果實)을 반환하여야 할 뿐만 아니라, 이미 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 과실(果實)의 대가를 보상하여야 한다(제201조 제2항).
- ⑤ 선의의 점유자라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 그 訴가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 간주된다.

중요판례

대법원 1983.10.11. 83다카531

부동산의 등기부시효취득에 있어서 점유의 시초에 과실이 없었음을 필요로 하며, 이와 같은 무과실에 대하여는 그 주장자에게 증명책임이 있다.

대법원 2002.02.26. 99다72743

- [1] 민법 제197조 제1항에 의하면, 물건의 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로, 점유자가 취득시효를 주장하는 경우 스스로 소유의 의사를 증명할 책임은 없다.
- [2] 점유의 승계가 있는 경우 전 점유자의 점유가 타주점유라 하여도 점유자의 승계인이 자기의 점유만을 주장하는 경우에는 현 점유자의 점유는 자주점유로 추정된다.
- [3] 점유자가 스스로 매매 또는 증여와 같이 자주점유의 권원을 주장하였으나 이것이 인정되지 않는 경우에도, 원래 자주점유의 권원에 관한 증명책임이 점유자에게 있지 아니한 이상 그 주장의 점유권원이 인정되지 않는다는 사유만으로 자주점유의 추정이 반복된다거나 또는 점유권원의 성질상 타주점유라고 볼 수 없다.

대법원 1982.04.13. 81다780

점유자의 권리추정의 규정은 특별한 사정이 없는 한 부동산 물권에 대하여는 적용되지 아니하고 다만 그 등기에 대하여서만 추정력이 부여된다.

☞ 권리의 적법추정은 동산의 점유에 한하고, 부동산물권에는 등기에 권리의 적법추정력이 인정된다.

대법원 2000.03.10. 99다63350

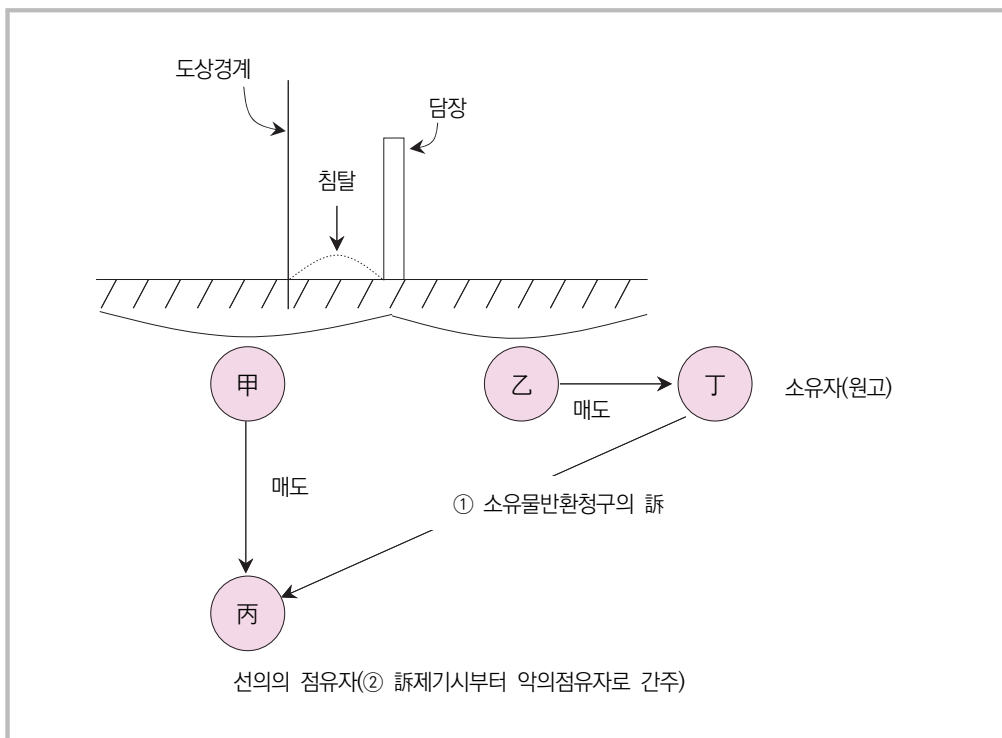
- [1] 민법 제201조 제1항은 “선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.”라고 규정하고 있는 바, 여기서 선의의 점유자라 함은 과실수취권을 포함하는 권원이 있다고 오신한 점유자를 말하고, 다만 그와 같은 오신을 함에는 오신할 만한 정당한 근거가 있어야 한다.
- [2] 민법 제197조에 의하여 점유자는 선의로 점유한 것으로 추정되고, 권원 없는 점유였음이 밝혀졌다고 하여 그동안의 점유에 대한 선의의 추정이 깨어지는 것은 아니다.

대법원 1996.01.26. 95다44290

민법 제201조 제1항에 의하면 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다고 규정하고 있는 바, 건물을 사용함으로써 얻는 이득은 그 건물의 과실에 준하는 것이므로, 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입었다고 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이득을 반환할 의무는 없다.

대법원 1981.08.20. 80다2587

과실취득권이 있는 선의의 점유자란 과실취득권을 포함하는 권원인 소유권·지상권·임차권 등이 있다고 오신한 점유자를 말한다.



3. 점유보호청구권

(1) 의의

점유보호청구권은 점유를 침해·방해당하거나 방해당할 염려가 있는 경우에 점유자가 침해자(방해자)에 대하여 그 침해의 배제 및 손해배상 또는 그 담보를 청구하는 권리로서 물권적 청구권의 일종이다.

(2) 점유보호청구권의 당사자

1) 주체

직접점유자는 물론 간접점유자도 포함된다. 그러나 점유보조자는 점유자가 아니므로 점유보호청구권을 행사할 수 없다.

2) 상대방

현재 방해(또는 침해)를 하거나 방해할 염려가 있는 자이다.

(3) 유형

1) 점유물반환청구권

점유물을 침탈한 경우에 그 물건의 반환을 청구하는 권리이다. 침탈자 또는 그의 포괄승계인에 대하여 청구할 수 있는 것이 원칙이며, 침탈자의 특정승계인에 대하여서는 그 자가 침탈의 사실을 알고 있는 경우에만 청구할 수 있다. 그리고 이 권리는 침탈을 당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.

2) 점유물방해제거청구권

점유침탈 이외의 방법으로 점유를 방해당한 경우에 그 방해의 제거를 청구하는 권리이다. 방해자뿐만 아니라 그 방해상태가 그 자의 지배권 내에 있다고 생각되는 자에 대하여서도 행사할 수 있다. 이 권리는 방해가 끝난 날로부터 1년이 지나면 행사하지 못하며, 또한 침해가 공사에 의하여 생긴 때에는 공사착수 후 1년이 지났거나 공사가 완성된 후에는 역시 행사하지 못한다.

3) 점유물방해예방청구권

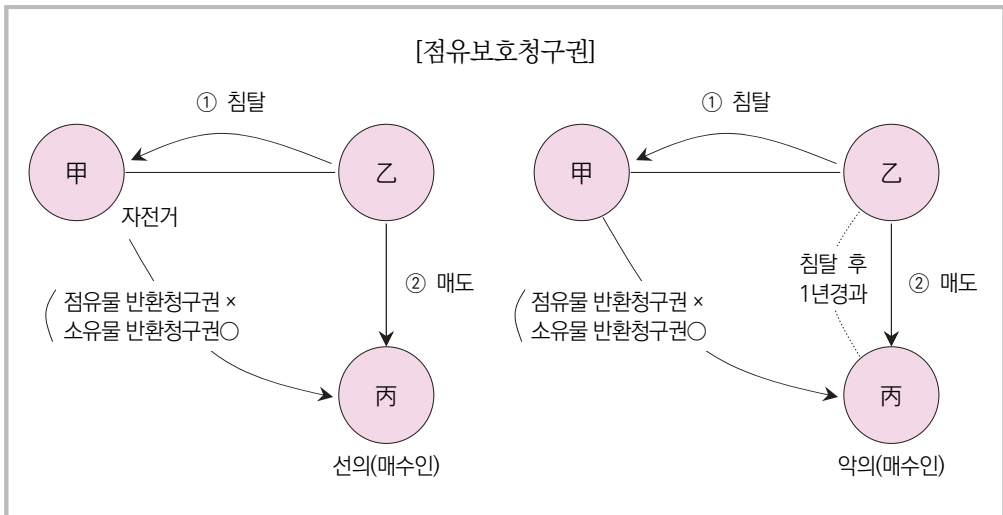
점유의 방해를 받을 염려가 있는 경우에 그 예방을 청구하는 권리이다. 이 권리의

행사기간에는 제한이 없으나, 다만 방해의 염려가 공사로 생긴 때에는 공사착수 후 1년 내 또는 공사의 완성 전에 한하여 행사할 수 있다.

4) 위의 점유보호청구권은 점유침해사실의 제거나 예방을 청구하는 외에 손해배상 또는 그 담보를 청구하는 것도 그 내용으로 한다. 그러나 손해배상청구권은 침해자(방해자)의 귀책사유가 있는 경우에 행사할 수 있다.

5) 점유보호청구권을 행사하기 위해서는 침탈자 또는 방해자의 고의나 과실을 요하지 않으나, 손해배상청구권을 행사하기 위해서는 고의 또는 과실을 요한다.

구분	요건	내용	제척기간
점유물반환 청구권	- 점유를 침탈당하였을 것 - 침탈자의 고의·과실은 불문함 - 선의의 특별승계인에게는 행사하지 못함	목적물반환 및 손해배상청구	침탈당한 날로부터 1년
점유물방해 제거청구권	- 점유의 방해를 받았을 것 - 방해자의 고의·과실은 불문함 - 정당한 방해, 수인한도 내의 것이 아닐 것	방해의 제거 및 손해배상청구	방해가 종료한 날로부터 1년
점유물방해 예방청구권	- 점유를 방해받을 염려가 있을 것 - 염려의 존부는 사회통념으로 판단	방해예방 또는 손해배상담보의 선택적 청구	방해염려의 존속 중은 언제나 행사 가능



대법원 1992. 02.25. 91다17443

사기에 의한 의사표시에 의해 건물을 명도해 준 것이라면, 건물을 침탈당한 것이 아니므로 피해자는 점유보호청구권을 행사하지 못한다.

대법원 1993.03.09. 92다5300

직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다.

대법원 1987.06.09. 86다카2942

- [1] 점유권에 의한 방해배제청구권은 물건 자체에 대한 사실상의 지배상태를 점유침탈 이외의 방법으로 침해하는 방해행위가 있을 때 성립된다.
- [2] 방해예방청구권에 있어서 점유를 방해할 염려나 위험성이 있는지의 여부는 구체적인 사정하에 일반 경험법칙에 따라 객관적으로 판정되어야 할 것이다.

대법원 2002.04.26. 2001다8097, 8103

점유를 침탈당하거나 방해를 받은 자의 침탈자 또는 방해자에 대한 청구권은 그 점유를 침탈당한 날 또는 점유의 방해행위가 종료된 날로부터 1년 내에 행사하여야 하는 것으로 규정되어 있는데, 여기에서 제척기간의 대상이 되는 권리는 형성권이 아니라 통상의 청구권인 점과, 점유의 침탈 또는 방해의 상태가 일정한 기간을 지나게 되면 그대로 사회의 평온한 상태가 되고 이를 복구하는 것이 오히려 평화질서의 교란으로 볼 수 있게 되므로 일정한 기간을 지난 후에는 원상회복을 허용하지 않는 것이 점유제도의 이상에 맞고 여기에 점유의 회수 또는 방해제거 등 청구권에 단기의 제척기간을 두는 이유가 있는 점 등에 비추어 볼 때, 위의 제척기간은 재판 외에서 권리행사하는 것으로 족한 기간이 아니라 반드시 그 기간 내에 訴를 제기하여야 하는 이른바 출소기간으로 본다.

제3절 점유권의 취득과 소멸

1. 점유권의 취득

(1) 점유권의 원시취득

물건에 대한 사실상의 지배가 성립하면 점유권은 당연히 원시적으로 취득된다.

(2) 점유권의 승계취득

점유권은 특정승계나 포괄승계에 의하여 취득할 수 있다. 따라서 점유권도 상속인에게 이전한다(제193조).

(3) 승계의 효과

제199조 【점유의 승계의 주장과 그 효과】

- ① 점유자의 승계인은 자기의 점유만을 주장하거나 자기의 점유와 전점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있다.
- ② 전점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 하자도 계승한다.

- ① 점유의 승계인은 그 선택에 좇아 자기의 이익을 위하여 자기만의 점유를 주장할 수도 있고, 또는 자기의 점유와 전점유자의 점유를 함께 주장할 수도 있다. 이를 점유의 분리·병합이라 한다.
- ② 전주(前主)의 점유를 함께 주장하는 경우에는 전주의 점유의 하자도 승계한다.
- ③ 포괄승계의 경우에도 점유의 분리·병합을 인정하는가에 대하여 다수설은 분리·병합 모두를 긍정하나 판례는 점유의 분리에 대하여는 부정하고 있다.

* A가 악의로 13년간 점유를 계속한 후에, B가 선의로 8년의 점유를 계속한 경우에는 B는 악의의 21년의 점유를 주장할 수도 있고, 8년의 선의의 점유를 주장할 수도 있다.

2. 점유권의 소멸

점유권은 물권일반의 소멸원인에 의하여 소멸하지만, 그 성질상 혼동이나 소멸시효에 의하여 소멸하지는 않는다. 직접점유에 있어서는 점유물에 대한 사실상의 지배를 잃음으로써 소멸하며, 일시 점유를 잃더라도 1년 내에는 점유물반환청구권으로 점유를 회수하면 점유는 계속된 것으로 된다(제192조).

3. 점유의 소(訴)와 본권의 소(訴)

(1) 의의

점유권에서 생기는 물권적 청구권에 기인하는 소를 '점유의 소'라고 하고, 소유권 등의 본권에 기인하는 소를 '본권의 소'라고 한다.

(2) 양자의 관계

1) 점유의 소와 본권의 소는 서로 영향을 미치지 않는다(제208조 제1항).

- ① 소유자가 점유하고 있던 물건을 빼앗긴 경우에 소유자는 소유물반환청구권과 점유물반환청구권에 기인한 소를 동시에 또는 이시(異時)에 제기할 수 있다.
- ② 어느 하나에 패소하더라도 다른 소를 제기할 수 있다.

2) 점유의 소는 본권에 관한 것을 이유로 재판하지 못한다(제208조 제2항).

임대인이 기간만료 후에 목적물을 명도하지 않는 임차인으로부터 목적물을 탈환한 경우에 임차인이 점유물반환청구의 소를 제기하였다면 임대인이 임차인은 그 물건을 반환할 의무가 있다고 주장하여도 이를 이유로 점유물반환청구의 소를 기각하지 못한다.

중요판례

대법원 대판 2002.04.26. 2001다8097, 8103

점유를 침탈당하거나 방해 받은 자의 침탈자 또는 방해자에 대한 청구권은 그 점유를 침탈당한 날 또는 점유의 방해행위가 종료된 날로부터 1년 내에 행사하여야 하는 것으로 규정되어 있는데, 여기에서 제척기간의 대상이 되는 권리는 형성권이 아니라 통상의 청구권인 점과, 점유의 침탈 또는 방해의 상태가 일정한 기간을 지나게 되면 그대로 사회의 평온한 상태가 되고 이를 복구하는 것이 오히려 평화질서의 교란으로 볼 수 있게 되므로 일정한 기간을 지난 후에는 원상회복을 허용하지 않는 것이 점유제도의 이상에 맞고 여기에 점유의 회수 또는 방해제거 등 청구권에 단기의 제척기간을 두는 이유가 있는 점 등에 비추어 볼 때, 위의 제척기간은 재판 외에서 권리행사하는 것으로 족한 기간이 아니라 반드시 그 기간 내에 訴를 제기하여야 하는 이른바 출소기간으로 본다.

4. 점유자의 자력구제권

(1) 의의

- ① 정당한 권리자가 그의 권리를 침해당한 경우에 자력으로서 이를 구제할 수 있는 권리를 말한다. 공력구제가 원칙이며 자력구제는 극히 예외적으로 인정한다.
- ② 직접점유자와 점유보조자에게는 자력구제권이 인정되나, 간접점유자에게는 없는 것으로 해석한다.

(2) 자력방위권

점유자는 그 점유를 부정하게 침탈 또는 방해하려는 행위에 대하여 자력으로써 스스로 이를 방위할 수 있다(제209조 제1항).

(3) 자력탈환권

점유를 침탈당한 경우에 점유자는 실력으로 이를 탈환할 수 있다(제209조 제2항).

1. 의의

재산권을 사실상 행사하는 것을 말하며, 점유의 규정을 준용한다(제210조).

2. 요건

- ① 재산권을 사실상 행사하는 것으로서 소유권·지상권·전세권·질권·임차권 등과 같이 점유를 수반하는 재산권에는 성립될 여지가 없다.
- ② 점유를 수반하지 않는 채권·지역권·저당권·특허권·상표권·어업권·광업권 등에 준점유가 인정된다.

3. 효과

- ① 점유에 관한 규정(권리의 적법추정·비용상환청구권·점유보호청구권 등)이 준용된다.
- ② 선의취득은 준점유에는 적용되지 아니한다.
- ③ 채권의 준점유자에 대한 선의·무과실의 변제는 유효하다(제470조).



3장 소유권

제1절 소유권 일반

1. 소유권의 법률적 성질

제212조 【토지소유권의 범위】

토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.

소유권이라 함은 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용·수익·처분할 수 있는 권리이다(제211조). 소유권은 물건을 전면적으로 지배하는 권리이며, 각종 제한물권의 근원을 이루는 모든 물권의 기본이 되는 권리이다. 소유자가 제한물권을 설정하여 소유권의 사용가치나 교환가치가 제한을 받더라도 그 제한은 모두 일시적으로 유한한 것이므로 소유권은 전면적 지배를 회복하는 탄력성이 있고 소멸시효에도 걸리지 않는 항구성을 가진다.

전면성	• 물건을 전면적으로 지배할 수 있는 권리이다. • 물건의 사용가치만 지배 : 용익물권 • 물건의 교환가치만 지배 : 담보물권
혼일성	• 사용권·수익권·처분권의 단순한 집합이 아니라 그것들의 총화이다. • 혼동에 의해 제한물권이 소멸하는 것도 혼일성에서 비롯된다.
탄력성	소유권은 제한물권의 설정에 의하여 그 행사가 제한되나 제한물권이 소멸하면 원래의 완전한 지배상태로 복귀한다.
항구성	소유권은 존속기간의 제한이 없으며, 소멸시효에도 걸리지 않는다.
관념성	물건에 대한 사실적 지배(점유)와 소유권은 분리한다.
대물적 지배성	소유권은 물건에 대한 지배권이다.

2. 소유권의 내용과 그 제한

(1) 소유권의 내용

소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용·수익·처분할 권리가 있다(제211조).

(2) 토지소유권의 범위

‘토지의 소유권은 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다’(제212조). 즉, 토지의 소유권은 토지의 완전한 이용을 확보하기 위하여 지표뿐만 아니라 지상과 지하에 미친다. 그러나 그것은 무한하게 공중과 지하에 미치는 것이 아니라 지표를 이용하는 데 정당한 이익이 있는 필요한 범위 내에서 지상·지하에 미치는 것이다. 다만, 지하의 광물은 광업권의 객체가 되므로 토지소유권에 포함되지 않는다.

제2절 상린관계

1. 서설

(1) 의의

서로 인접하는 부동산소유권의 상호이용을 조절하기 위한 민법의 규정(제215조 이하)으로서 소유권의 확장 또는 제한의 의미를 가진다.

(2) 상린관계와 지역권의 비교

구분	상린관계	지역권
성질	소유권의 내제적 제한	독립한 용익물권
성립	법률의 규정	법률행위
등기	요하지 않음	등기요함
관계	부동산이용자와 이용자사이의 관계	두 개의 토지 사이의 관계
소멸시효	걸리지 않음	걸림
인접관계	반드시 인접을 요함	인접을 요하지 않음

(3) 상린관계의 준용

- ① 본래 소유자 상호간의 관계이지만, 지상권과 전세권에도 준용된다(제290조·제319조).
- ② 명문의 규정은 없으나, 토지임차권에도 준용된다.

2. 상린관계의 내용

(1) 인지사용청구권(제216조)

- ① 토지소유자가 경계나 그 근방에서 담·건물을 축조하거나 수선하려는 때에는 필요한 범위 내에서 이웃 토지의 사용을 청구할 수 있다.
- ② 이웃의 주거에 들어가려면 승낙을 요한다.

(2) 생활방해(Immission·안온방해·안정방해)의 금지와 인용(제217조)

- ① 토지소유자는 매연·액체·열기체·음향·진동 기타 이와 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나 이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 않도록 적당히 조치할 의무가 있다.
- ② 그러한 사태가 통상의 용도에 적당한 것일 때에는 이웃 거주자는 이를 인용할 의무가 있다. 통상의 용도에 적당한 것인가의 여부는 사회관념에 따라 결정되어야 할 것이다.
- ③ 이 규정에 위반하여 타인에게 손해를 준 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다.
- ④ 피해자는 물권에 기인한 물권적 청구권을 행사하여 적당한 조치를 청구하거나 방해의 금지 또는 중지를 청구할 수 있다.

(3) 수도 등의 시설권(제218조)

- ① 토지소유자는 타인의 토지를 통과하지 않으면 필요한 수도·송수관·가스관·전선 등을 시설할 수 없거나, 또는 과도한 비용을 요하는 경우에는 타인의 토지를 통과하여 이를 시설할 수 있다.
- ② 이와 같은 시설을 위하여 타인의 토지를 사용하는 경우에는 토지소유자에게 주는 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여 시설하여야 한다. 또 이러한 공사로 인하여 시설통과지의 소유자에게 손해를 준 경우에는 그의 청구에 의하여 손해를 보상하여야 한다.

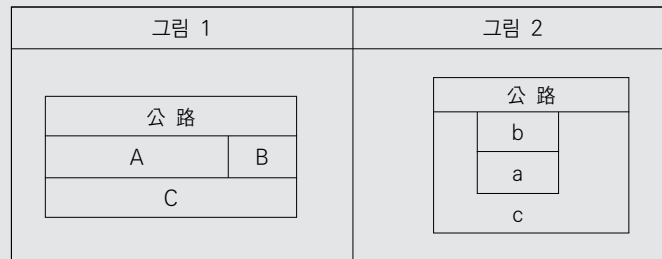
(4) 주위토지의 통행권(제219조)

- ① 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지 소유자는 공로에 출입하기 위하여 이웃 토지를 통행할 수 있고, 필요한 경우에는 통로를 개설할 수도 있다.
- ② 이 경우 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 하며, 통행 또는 통로개설로 인하여 통행지 소유자에게 손해를 주었을 경우에는 통행권자는 그 손해를 보상하여야 한다.

- ③ 본래는 공로로 통하고 있었던 토지가 분할 또는 일부의 양도로 공로로 통하지 못하게 된 경우에는, 그 토지소유자는 다른 분할자의 토지 또는 양도인의 토지를 통행할 수 있고, 이때에는 보상의무가 없다.

☑ 토지의 일부양도와 주위토지통행권

[CASE] 그림 1의 C지와 그림 2의 a지와 같이 포위된 토지가 생긴 경우에, 그 포위된 토지소유자의 주위토지통행권에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)



- ① 그림 1에서 C지의 소유자는 B지에 비하여 넓은 A지에 대해서만 통행권을 행사할 수 있다.
 ② 그림 1에서 甲이 자신의 소유이던 1필의 토지를 B지와 C지로 분할하여 C지를 乙에게 양도한 경우, 乙은 甲소유의 B지에 대하여만 통행권을 행사할 수 있다.
 ③ 그림 1에서 C지의 소유자에게 A지에 대한 주위토지통행권이 인정된 경우에는, 그 후 C지에 접하는 공로가 새로 개설되었더라도 위 통행권은 소멸하지 않는다.
 ④ 그림 2에서 甲이 1필의 토지를 a지와 b지로 분할한 후에 a지를 乙에게 양도한 경우, b지에 甲이 거주하고, c지가 공지(空地)인 때에는 乙은 b지에 대해서는 통행권을 행사할 수 없으나 c지에 대해서는 통행권을 행사할 수 있다.
 ⑤ 그림 2에서 甲이 1필의 토지를 스스로 a지와 b지로 분할한 후에 b지를 乙에게 양도한 경우, 甲은 b지에 대해서 통행권을 행사할 수 없다.

중요판례

대법원 2006.09.22. 2006다24971

지적법에 의하여 어떤 토지가 지적공부에 1필지의 토지로 등록되면 그 토지의 경계는 다른 특별한 사정이 없는 한 이 등록으로써 특정되고, 다만 지적공부를 작성함에 있어 기술적인 착오로 지적공부상의 경계가 진실한 경계선과 다르게 잘못 작성된 특별한 사정이 있는 경우에는 그 토지의 경계는 지적공부에 의하지 않고 실제의 경계에 의하여 확정하여야 하지만, 그 후 그 토지에 인접한 토지의 소유자 등 이해관계인들이 그 토지의 실제의 경계선을 지적공부상의 경계선에 일치시키기로 합의하였다면 지적공부상의 경계에 의하여 그 토지의 공간적 범위가 특정된다.

지적도상의 경계와 실제의 경계에 차이가 있는 경우에는 도상경계를 경계로 보나, 지적 공부상의 경계등록에 명백한 오류가 있음이 입증될 때에는 실제의 경계를 경계로 볼 수 있다.

대법원 2009.06.11. 2008다75300

- [1] 주위토지통행권은 통행을 위한 지역권과는 달리 그 통행로가 항상 특정한 장소로 고정되어 있는 것은 아니고, 주위토지 소유자가 그 용법에 따라 기존 통행로로 이용되던 토지의 사용방법을 바꾸었을 때에는 대지 소유자는 그 주위토지 소유자를 위하여 보다 손해가 적은 다른 장소로 옮겨 통행할 수밖에 없는 경우도 있다.
- [2] 주위토지통행권은 공로와의 사이에 그 용도에 필요한 통로가 없는 토지의 이용이라는 공익목적을 위하여 피통행지 소유자의 손해를 무릅쓰고 특별히 인정되는 것이므로, 그 통행로의 폭이나 위치 등을 정함에 있어서는 피통행지의 소유자에게 가장 손해가 적게 되는 방법이 고려되어야 하고, 어느 정도를 필요한 범위로 볼 것인가는 구체적인 사안에서 사회통념에 따라 쌍방 토지의 지형적·위치적 형상과 이용관계, 부근의 지리상황, 상린지 이용자의 이해득실 기타 제반 사정을 기초로 판단하여야 한다. 한편, 주거는 사람의 사적인 생활공간이자 평온한 휴식처로서 인간생활에서 가장 중요한 장소라고 아니할 수 없어 우리 헌법도 주거의 자유를 보장하고 있는바, 주위토지통행권을 행사함에 있어서는 이러한 주거의 자유와 평온 및 안전을 침해하여서는 아니 된다.

대법원 2006.06.02. 2005다70144

- [1] 민법 제219조에 규정된 주위토지통행권은 공로와의 사이에 그 용도에 필요한 통로가 없는 토지의 이용이라는 공익목적을 위하여 피통행지 소유자의 손해를 무릅쓰고 특별히 인정되는 것이므로, 그 통행로의 폭이나 위치 등을 정함에 있어서는 피통행지의 소유자에게 가장 손해가 적게 되는 방법이 고려되어야 할 것이고, 어느 정도를 필요한 범위로 볼 것인가는 구체적인 사안에서 사회통념에 따라 쌍방 토지의 지형적·위치적 형상 및 이용관계, 부근의 지리상황, 상린지 이용자의 이해득실 기타 제반 사정을 기초로 판단하여야 하며, 토지의 이용방법에 따라서는 자동차 등이 통과할 수 있는 통로의 개설도 허용되지만 단지 토지이용의 편의를 위해 다소 필요한 상태라고 여겨지는 정도에 그치는 경우까지 자동차의 통행을 허용할 것은 아니다.
- [2] 주위토지통행권의 본래적 기능발휘를 위해서는 그 통행에 방해가 되는 담장과 같은 축조물도 위 통행권의 행사에 의하여 철거되어야 한다.

대법원 2008.05.08. 2007다22767

민법 제219조에 정한 주위토지통행권은 인접한 토지의 상호이용의 조절에 기한 권리로서 토지의 소유자 또는 지상권자, 전세권자 등 토지사용권을 가진 자에게 인정되는 권리이다.

따라서 명의신탁자에게는 주위토지통행권이 인정되지 아니한다.

대법원 1992.12.22. 92다30528

주위토지통행권은 주위토지 소유자의 토지에 대한 독점적 사용권을 제한하는 권리로서 인접한 토지 소유자간의 이해를 조정하는 데 목적이 있으므로 사람이 출입하고 다소의 물건을 공로로 운반할 정도의 폭만 확보할 수 있다면 주위 토지 소유자의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 하고, 또 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이지 더 나아가 장차의 이용상황까지를 미리 대비하여 통행로를 정할 것은 아니다.

대법원 1995.06.13. 95다1088,1095

- [1] 주위토지통행권은 그 소유 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 한하여 인정되는 것이므로, 이미 그 소유 토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 사용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소로 통행할 권리를 인정할 수 없다.
- [2] 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 민법 제245조의 규정을 준용하도록 되어 있으므로, 통행지역권은 요역지의 소유자가 승역지 위에 도로를 설치하여 승역지를 사용하는 객관적 상태가 민법 제245조에 규정된 기간 계속된 경우에 한하여 그 시효취득을 인정할 수 있다.

대법원 1995.09.29. 94다43580

주위토지통행권은 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에, 그 토지 소유자가 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 않으면 공로에 전혀 출입할 수 없는 경우뿐 아니라 과도한 비용을 요하는 때에도 인정될 수 있다.

대법원 1994.06.24. 94다14193

주위토지통행권은 어느 토지가 타인 소유의 토지에 둘러싸여 공로에 통할 수 없는 경우 뿐만 아니라, 이미 기존의 통로가 있더라도 그것이 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서의 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에도 인정된다.

대법원 2002.05.31. 2002다9202

분할 또는 토지의 일부 양도로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 생긴 경우에 그 포위된 토지를 위한 통행권은 분할 또는 일부 양도 전의 종전토지에만 있고, 그 경우 통행에 대한 보상의 의무가 없다고 하는 무상주위통행권에 관한 민법 제220조의 규정은 토지의 직접 분할자 또는 일부 양도의 당사자 사이에만 적용되고 포위된 토지 또는 피통행지의 특정 승계인에게서는 적용되지 않는바, 이러한 법리는 분할자 또는 일부 양도의 당사자가 무상주위

통행권에 기하여 이미 통로를 개설해 놓은 다음 특정승계가 이루어진 경우라 하더라도 마찬가지라 할 것이다.

대법원 2013.01.17. 2010다71578 전원합의체

1동의 건물에 대하여 구분소유가 성립하기 위해서는 객관적·물리적인 측면에서 1동의 건물이 존재하고, 구분된 건물부분이 구조상·이용상 독립성을 갖추어야 할 뿐 아니라, 1동의 건물 중 물리적으로 구획된 건물부분을 각각 구분소유권의 객체로 하려는 구분행위가 있어야 한다. 여기서 구분행위는 건물의 물리적 형질에 변경을 가함이 없이 법률관념상 건물의 특정 부분을 구분하여 별개의 소유권의 객체로 하려는 일종의 법률행위로서, 그 시기나 방식에 특별한 제한이 있는 것은 아니고 처분권자의 구분의사가 객관적으로 외부에 표시되면 인정된다. 따라서 구분건물이 물리적으로 완성되기 전에도 건축허가신청이나 분양계약 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있고, 이후 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다.

대법원 2000.11.16. 98다45652, 45669 전원합의체

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분·합필 및 환지절차의 지연, 각 세대당 지분비용 결정의 지연 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 수분양자를 거쳐 양수인 앞으로 경료되고, 대지지분에 대한 소유권이전등기는 상당기간 지체되는 경우가 종종 생기고 있는데, 이러한 경우 집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지지분을 함께 분양의 형식으로 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료받고 대지지분에 대하여는 위와 같은 사정 으로 아직 소유권이전등기를 경료받지 못한 자는 매매계약의 효력으로써 전유부분의 소유를 위하여 건물의 대지를 점유·사용할 권리가 있는 바, 매수인의 지위에서 가지는 이러한 점유·사용권은 단순한 점유권과는 차원을 달리하는 본권으로서 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제2조 제6호 소정의 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리인 대지사용권에 해당한다고 할 것이고, 수분양자로부터 전유부분과 대지지분을 다시 매수하거나 증여 등의 방법으로 양수받거나 전전 양수받은 자 역시 당초 수분양자가 가졌던 이러한 대지사용권을 취득한다.

대법원 2006.03.27. 2004마978

집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지지분을 함께 분양의 형식으로 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전 등기만 마치고 대지지분에 대하여는 아직 소유권이전등기를 마치지 못한 자는 매매계약의

효력으로써 전유부분의 소유를 위하여 건물의 대지를 점유·사용할 권리가 있는바, 매수인의 지위에서 가지는 이러한 점유·사용권은 단순한 점유권과는 차원을 달리하는 본권으로서 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제2조 제6호 소정의 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리인 대지사용권에 해당한다.

대법원 2010.10.14. 2009다95967

하나의 단지 내에 있는 여러 동의 건물 전부를 일괄하여 재건축하고자 하는 경우라도 재건축결의의 요건 충족 여부는 각각의 건물마다 별개로 따져야 하므로, 일부 동의 대하여는 재건축결의의 요건을 갖추지 못하였지만 나머지 동의 대하여는 재건축결의의 요건을 갖춘 경우 그 나머지 동의 대하여는 적법한 재건축결의가 성립한다.

대법원 2013.07.25. 2012다18038

1동의 건물에 대하여 구분소유가 성립하기 위해서는 객관적·물리적인 측면에서 1동의 건물이 존재하고 구분된 건물 부분이 구조상·이용상 독립성을 갖추어야 할 뿐 아니라 1동의 건물 중 물리적으로 구획된 건물 부분을 각각 구분소유권의 객체로 하려는 구분행위가 있어야 한다.

대법원 2007.02.22. 2005다65821

집합건물의 공용부분은 전체 공유자의 이익에 공여하는 것이어서 공동으로 유지·관리해야 하고 그에 대한 적정한 유지·관리를 도모하기 위하여는 소요되는 경비에 대한 공유자 간의 채권은 이를 특히 보장할 필요가 있어 공유자의 특별승계인에게 그 승계여사의 유무에 관계 없이 청구할 수 있도록 집합건물법 제18조에서 특별규정을 두고 있는바, 위 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 위 규정에 터잡은 것으로서 유효하다고 할 것이므로, 집합건물의 특별승계인은 전 입주자의 체납관리비 중 공용부분에 관하여는 이를 승계한다.

대법원 2005.11.10. 2003다45496

'집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률' 제23조 제1항의 관리단은 어떠한 조직행위를 거쳐야 비로소 성립되는 단체가 아니라 구분소유관계가 성립하는 건물이 있는 경우 당연히 그 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 성립되는 단체라 할 것이므로, 집합건물의 분양이 개시되고 입주가 이루어져서 공동관리의 필요가 생긴 때에는 그 당시의 미분양된 전유부분의 구분소유자를 포함한 구분소유자 전원을 구성원으로 하는 관리단이 설립된다.

대법원 1991.04.23. 91다4478

입주자대표회의는 단체로서의 조직을 갖추고 의사결정기관과 대표자가 있을 뿐만 아니라, 또 현실적으로도 자치관리기구를 지휘, 감독하는 등 공동주택의 관리업무를 수행하고 있으므로 특별한 다른 사정이 없는 한 법인 아닌 사단으로서 당사자능력을 가진다.

(5) 물의 상린관계(제221조 이하)

1) 배수에 관한 상린관계

① 자연적 배수

㉠ 토지소유자는 이웃 토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막지 못한다. 단, 인접지의 지반을 높임으로써 흘러내려오는 물에 대하여는 승수(承水)의무가 없다.

㉡ 흐르는 물이 저지에서 막힌 경우 고지소유자는 자비로 소통에 필요한 공사를 할 수 있다.

② 인공적 배수

㉠ 물을 인공적 시설에 의하여 타인의 토지에 버리는 것은 금지된다.

㉡ 토지소유자는 처마물이 이웃에 직접 낙하하지 않도록 적당한 시설을 하여야 한다.

2) 여수급여청구권

토지소유자는 가용(家用)이나 토지이용에 필요한 물을 얻기 곤란한 때에는 이웃 토지 소유자에게 보상하고 여수의 급여를 요구할 수 있다.

3) 유수에 관한 상린관계

구거 기타 수류지의 소유자는 대안의 토지가 타인의 소유인 때에는 그 수로나 수류의 폭을 변경하지 못한다. 그러나 양안의 토지가 수류지소유자의 소유일 때에는 이를 변경할 수 있다. 다만, 이 경우에 타인의 소유지로 흘러가는 하류에서는 자연의 수로와 일치하도록 하여야 한다. 수류변경에 관하여 따로 관습이 있으면 이에 의한다 (제229조).

4) 공유하천용수권

공유하천의 연안에서 농·공업을 영위하는 자는 농·공업에 이용하기 위하여 타인의 용수를 방해하지 않는 범위 내에서 필요한 인수를 할 수 있으며, 또 이 인수를 하기 위하여 필요한 공작물을 설치할 수도 있는 바, 이것이 공유하천용수권이다.

* 물에 관한 상린관계는 관습과 판례로 인정하여 오던 것을 민법이 명문화한 것이다.

(6) 경계에 관한 상린관계

1) 경계표 및 담의 설치권(제237조·제238조)

- ① 인접하여 토지를 소유한 자는 공동비용으로 통상의 경계표나 담을 설치할 수 있다.
이 경우에 경계는 이미 확정되어 있어야 하며, 경계표나 담의 설치로 경계가 정하여지는 것은 아니다.
- ② 경계에 관한 다툼이 있을 때에는 경계확인의 訴에 의하여 결정되어야 한다.
- ③ 경계표 또는 담의 설치비용은 쌍방이 절반하여 부담하나, 측량비용은 토지의 면적에 비례하여 부담한다. 그러나 이와 다른 관습이 있으면 그 관습에 따른다.
- ④ 상린자 중의 한사람이 비용의 증액을 부담한다면 통상보다 양호한 재료를 쓰거나 그 높이를 통상보다 높게 할 수 있고 또는 방화벽 기타의 특수시설을 할 수 있다.

2) 경계선상의 공작물의 소유관계(제239조)

- ① 경계에 설치된 경계표·담·구거(도랑) 등은 상린자의 공유로 추정한다.
- ② 경계표·담·구거(도랑) 등이 상린자 일방의 단독비용으로 설치된 경우에는 그 비용을 부담한 자의 소유에 속하고, 담이 건물의 일부인 경우 그 담은 건물소유자의 소유에 속한다.

(7) 경계를 넘는 수지(樹枝)·목근(木根)에 관한 상린관계(제240조)

- ① 인접지의 나뭇가지 경계를 넘는 때에는 그 소유자에 대하여 가지의 제거를 청구할 수 있다. 이 청구에 응하지 않으면 청구한 자가 그 가지를 제거할 수 있다.
- ② 인접지의 나무뿌리가 경계를 넘는 때에는 임의로 제거할 수 있다.

(8) 토지의 심굴(深堀)에 관한 상린관계(제241조)

토지소유자는 인접지의 지반이 무너질 정도로 자기의 토지를 깊이 파지 못한다. 그러나 충분한 방어공사를 한 때에는 깊이 파도 무방하다.

(9) 경계선 부근의 공작물설치에 관한 상린관계

1) 건물에 대한 거리제한(제242조)

- ① 건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야

한다. 이러한 거리를 두지 않고 건물을 축조한 자에 대하여는 건물의 변경 또는 철거를 청구할 수 있다.

- ② 건축에 착수한 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만을 청구할 수 있다.

2) 관망에 대한 제한(제243조)

경계로부터 2미터 이내의 거리에서 이웃 주택의 내부를 관망할 수 있는 창이나 마루를 설치하는 경우에는 적당한 차면시설을 하여야 한다.

3) 건물 이외의 공작물에 대한 거리제한(제244조)

- ① 우물을 파거나 용수·하수 또는 오물 등을 저장할 지하시설을 하는 때에는 경계로부터 2미터 이상의 거리를 두어야 한다.
- ② 저수지·구거(도랑) 또는 지하실공사에는 경계로부터 그 깊이의 반 이상의 거리를 두어야 한다.
- ③ 이러한 공사를 함에는 토지가 붕괴하거나 하수 또는 오액(汚液)이 이웃에 흐르지 않도록 적당한 조치를 하여야 한다.

제3절 소유권의 취득

1. 소유권의 취득원인

소유권의 취득원인은 크게 법률행위와 법률의 규정 두 가지가 있다. 전자에 관해서는 법률행위에 의한 물건변동의 원칙이 그대로 적용된다. 그런데 민법은 제245조 이하에서 취득시효·선의취득·무주물선점·유실물습득·매장물발견·점부(부합·혼화·가공)에 관해 규정한다.

2. 취득시효

(1) 의의

- ① 일정한 사실상태가 일정기간 지속된 경우에 이 상태가 진실한 권리관계와 일치하느냐를 묻지 않고, 권리관계로 인정하려는 제도이다.
- ② 취득시효에 의하여 취득할 수 있는 권리는 소유권(제245조·제246조)과 그밖의 재산권(제248조)이다.
- ③ 부동산소유권의 취득시효에는 점유만으로 소유권을 취득하는 점유취득시효와 부동산의 소유자 아닌 자가 소유자로 등기되어 있는 경우에 소유권을 취득하는 등기부취득시효의 두 가지가 있다.

(2) 부동산의 점유취득시효

1) 요건

- ① 20년간 소유의 의사로 평온·공연(공공연, 이하 같음)하게 점유하고 등기함으로써 소유권을 취득한다(제245조 제1항). 점유자는 소유의 의사로 평온·공연하게 점유한 것으로 추정되므로 취득시효 주장자의 소유의 의사·평온·공연은 추정을 받으며, 선의·악의는 묻지 않는다.
- ② 부동산 명의신탁에 있어서 명의수탁자에게 소유의 의사가 인정되는지에 관하여 판례는 자주점유가 아니라고 한다.
- ③ 타인의 물건에 대해서만 취득시효를 인정하는가에 대하여는 명문의 규정은 없으나 자기의 소유물에도 시효취득이 인정된다는 것이 판례의 태도이다.

- ④ 점유취득시효에 있어서는 부동산의 일부에 대한 시효취득도 인정되며, 이러한 경우에는 점유취득시효가 완성된 부분에 대한 분필절차를 받은 후에 취득시효의 등기를 하여야 한다.
- ⑤ 취득시효가 완성된 이후 제3자의 명의로 이전등기(또는 저당권 설정)가 된 경우에는 그 자가 악의자라 하더라도 취득시효의 완성으로 대항하지 못한다(대법원 1992.9.25. 92다9968). 다만, 부동산을 취득한 제3자가 매도인의 불법행위에 적극 가담하였다면 매도인의 배임행위에 적극 가담한 이중매매로서 무효가 된다(대법원 1994.4.12. 93다60779).
- ⑥ 취득시효기간의 만료 전에 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우라 하더라도 취득시효의 완성에는 영향을 미치지 않는다. 따라서 시효취득완성자는 그 기간만료 당시의 등기명의자인 제3자를 상대로 취득시효를 주장하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다(대법원 1989.4.11. 88다카5843).
- ⑦ 국유재산 가운데 행정재산이 아닌 사적 거래의 대상이 되는 일반재산(구 잡종재산)은 시효취득의 대상이 된다.
- ⑧ 원래 일반재산(구 잡종재산)이던 것이 행정재산으로 된 경우 일반재산일 당시에 취득시효가 완성되었다고 하더라도 행정재산으로 된 이상 이를 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 없다(대법원 1997.11.14. 96다10782).

2) 효과

- ① 취득시효는 법률의 규정에 의한 물권변동이지만 예외적으로 등기하여야 소유권을 취득한다.
- ② 등기를 하면 점유를 개시한 때에 소급하여 그 부동산의 소유권을 원시적으로 취득한다(제247조 제1항).

(3) 부동산의 등기부취득시효

제245조 【점유로 인한 부동산소유권의 취득기간】

- ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.
- ② 부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

1) 요건

- ① 부동산의 소유자가 아닌 자가 소유자로 등기하고 10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 선의·무과실로 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다(제245조 제2항).
- ② 부동산의 비소유자가 소유자로 등기되어 있고(■ 소유권이전등기 후에 매매계약이 취소된 경우) 그 점유는 10년간 계속되어야 한다. 점유기간은 전주(前主)의 점유와 합산할 수 있으나(제199조 제1항), 등기기간에 관하여는 그러한 규정이 없다. 판례는 종전에는 등기기간과 점유기간이 때를 같이하여 10년이어야 한다고 하여, 등기의 합산을 인정하지 않았으나, 이를 바꾸어 10년간이란 반드시 자기 명의로 등기되어야 하는 것은 아니고 전주(前主)의 등기기간을 합산하여 10년이 되면 족하다고 판결하였다(전합 1989.12.26. 87다카2176). 따라서 등기의 승계를 인정하게 되었다.
- ③ 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유하여야 한다. 무과실은 추정되지 않으므로 시효취득을 주장하는 자가 무과실을 증명하여야 한다. 그리고 선의·무과실은 점유개시시에만 있으면 충분하고, 전(全) 시효기간을 통하여 계속될 필요는 없다(통설·판례).
- ④ 상속등기를 경로 하지 아니한 상속인이 등기부취득시효를 할 수 있는지의 여부에 관하여 피상속인의 명의로 소유권등기가 10년 이상 경로 되어 있는 이상, 상속인은 제245조 제2항의 '부동산의 소유자로 등기한 자'에 해당한다는 것이 판례의 태도이다. 그 이유는 상속에 의한 물권변동은 이전등기를 행하지 않아도 피상속인의 사망 시 물권변동의 효과가 발생한다는 점을 들고 있다(제187조).

2) 효과

점유자는 점유를 개시한 때에 소급하여 부동산의 소유권을 원시적으로 취득한다(제247조 제1항).

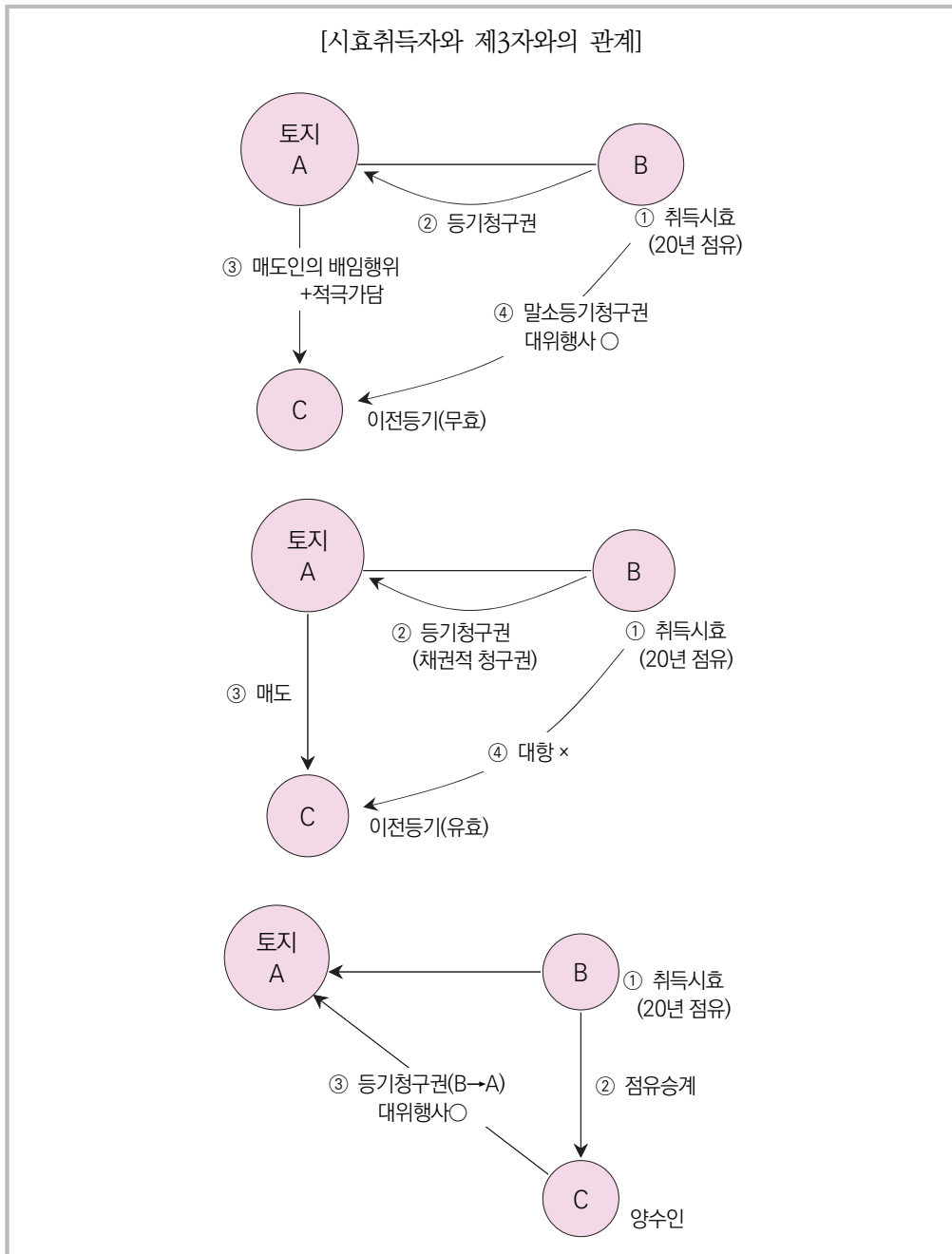
(4) 동산의 취득시효

1) 점유취득시효

10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하면 소유권을 취득한다(제246조 제1항).

2) 선의취득시효

5년간 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유하면 소유권을 취득한다(제246조 제2항).



〈취득시효의 정리〉

부 동 산	점유 취득시효	• 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하고 등기함으로써 소유권을 취득한다. • 등기하면 점유개시시로 소급하여 소유권을 획득한다(원시취득). • 부동산의 일부에 대한 취득시효도 인정된다. • 등기명의인을 상대로 등기청구권을 행사한다. • 취득시효가 완성된 이후 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우에는 그 자가 악의자라 하더라도 취득시효의 완성으로 대항하지 못한다(대법원 1992.9.25. 92다9968). 다만, 부동산을 취득한 제3자가 매도인의 불법행위에 적극 가담하였다면 매도인의 배임행위에 적극 가담한 이중매매로서 무효가 된다(대법원 1994.4.12. 93다60779). • 취득시효기간의 만료 전에 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우라 하더라도 취득시효의 완성에는 영향을 미치지 않는다. 따라서 시효취득완성자는 그 기간만료 당시의 등기명의자인 제3자를 상대로 취득시효를 주장하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다(대법원 1989.4.11. 88다카5843).
	등기부 취득시효	• 무권리자가 권리자로 등기되고 10년간 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유한 때에는 소유권을 취득한다. • 무과실은 추정되지 않으므로 취득시효를 주장하는 자가 증명하여야 한다. • 선의·무과실은 점유개시시에만 있으면 족하다(통설·판례).
동 산	일반 취득시효	10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하면 소유권을 취득한다.
	선의 취득시효	5년간 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유하면 소유권을 취득한다.

중요판례

대법원 2013.04.25. 2012다115243

민법 제197조 제1항에 의하면 물건의 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로 점유자가 취득시효를 주장하는 경우 스스로 소유의 의사를 증명할 책임은 없고, 오히려 그 점유자의 점유가 소유의 의사가 없는 점유임을 주장하여 점유자의 취득시효의 성립을 부정하는 사람에게 그 증명책임이 있다.

대법원 1995.07.11. 94다4509

[1] 취득시효가 완성된 후 점유자가 그 취득시효를 주장하거나 이로 인한 소유권이전등기 청구를 하기 이전에는, 특별한 사정이 없는 한 그 등기명의인인 부동산 소유자로서는

그 시효취득 사실을 알 수 없는 것이므로, 이를 제3자에게 처분하였다고 하더라도 불법 행위가 성립하는 것은 아니다.

- [2] 부동산 점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산 소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권·채무관계가 성립하는 것은 아니므로, 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행 책임을 물을 수 없다.

대법원 1989.04.11. 88다카5843

취득시효기간 완성 후 아직 그것을 원인으로 소유권이전등기를 경료하지 아니한 자는 종전 소유자로부터 그 부동산에 대한 등기부상 소유명의를 넘겨받은 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 없으나 취득시효기간 만료 전에 등기명의를 넘겨 받은 시효완성당시의 등기명의자에 대하여는 그 소유권취득을 주장할 수 있다.

대법원 1998.07.10. 97다45402

부동산에 대한 점유취득시효가 완성되었다고 하더라도 이를 등기하지 아니하고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자에게 소유권이전등기가 마쳐지면 점유자는 그 제3자에게 대항할 수 없는 것이고, 이 경우 제3자의 이전등기 원인이 점유자의 취득시효완성 전의 것이라 하더라도 마찬가지이다.

대법원 1995.03.28. 93다47745 전원합의체

- [1] 원래 취득시효제도는 일정한 기간 점유를 계속한 자를 보호하여 그에게 실체법상의 권리를 부여하는 제도이므로, 부동산을 20년 간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유한 자는 민법 제245조 제1항에 의하여 점유부동산에 관하여 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 취득하게 되며, 점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 이상, 그 후 점유를 상실하였다고 하더라도 이를 시효이익의 포기로 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 아니한다.
- [2] 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과까지 승계하는 것은 아니므로 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권 이전등기를 청구할 권원은 없다.

대법원 2001.07.13. 2001다17572

취득시효는 당해 부동산을 오랫동안 계속하여 점유한다는 사실상태를 일정한 경우에 권리관계로 높이려고 하는 데에 그 존재이유가 있는 점에 비추어 보면, 시효취득의 목적물은 타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있다.

대법원 2007.10.11. 2007다43894

부동산에 관한 점유취득시효기간이 경과하였다고 하더라도 그 점유자가 자신의 명의로 등기하지 아니하고 있는 사이에 먼저 제3자 명의로 소유권이전등기가 경료되어 버리면, 특별한 사정이 없는 한 그 제3자에 대하여는 시효취득을 주장할 수 없으나, 그 제3자가 취득시효기간 만료 당시의 등기명의인으로부터 신탁 또는 명의신탁받은 경우라면 종전 등기명의인으로서는 언제든지 이를 해지하고 소유권이전등기를 청구할 수 있고, 점유시효취득자로서는 종전 등기명의인을 대위하여 이러한 권리를 행사할 수 있으므로, 그러한 제3자가 소유자로서의 권리를 행사하는 경우 점유자로서는 취득시효완성을 이유로 이를 저지할 수 있다.

대법원 1993.05.25. 92다51280

부동산에 대한 취득시효가 완성되면 점유자는 소유명의자에 대하여 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 있고 소유명의자는 이에 응할 의무가 있으므로 점유자가 소유권이전등기를 경료하지 아니하여 아직 소유권을 취득하지 못하였다고 하더라도 소유명의자는 점유자에 대하여 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다.

대법원 1998.05.22. 96다24101

취득시효완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다 하더라도 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다.

대법원 1992.09.01. 92다26543

점유로 인한 부동산 소유권의 취득기간이 경과한 뒤에 점유자가 소유자에게 그 부동산을 매수하자고 제의한 일이 있었다는 것만으로는 점유자가 위 부동산이 그 소유자의 소유임을 승인하여 타주점유로 전환되었다거나 시효의 이익을 포기하였다고는 볼 수 없다.

대법원 1998.04.10. 97다56822

취득시효의 기초가 되는 점유가 법정기간 이상으로 계속되는 경우, 취득시효는 그 기초가 되는 점유가 개시된 때를 기산점으로 하여야 하고 취득시효를 주장하는 사람이 임의로 기산일을 선택할 수는 없으나, 점유가 순차 승계된 경우에 있어서는 취득시효의 완성을 주장하는 자는 자기의 점유만을 주장하거나 또는 자기의 점유와 전 점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있는 선택권이 있으며, 전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에도 어느 단계의 점유자의 점유까지를 아울러 주장할 것인가도 이를 주장하는 사람에게 선택권이 있고, 다만 전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 점유의 개시시기를 어느 점유자의 점유기간 중의 임의의 시점으로 선택할 수는 없다.

대법원 1995.06.16. 94다4615

등기부상만으로 어떤 토지 중 일부가 분할되고 그 분할된 토지에 대하여 지번과 지적이 부여되어 등기되어 있어도 지적공부 소관청에 의한 지번, 지적, 지목, 경계확정 등의 분필절차를 거친 바가 없다면 그 등기가 표상하는 목적물은 특정되었다고 할 수는 없으니, 그 등기부에 소유자로 등기된 자가 그 등기부에 기재된 면적에 해당하는 만큼의 토지를 특정하여 점유하였다고 하더라도, 그 등기는 그가 점유하는 토지부분을 표상하는 등기로 볼 수 없어 그 점유자는 등기부취득시효의 요건인 “부동산의 소유자로 등기한 자”에 해당하지 아니하므로 그가 점유하는 부분에 대하여 등기부시효취득을 할 수는 없다.

대법원 1997.08.21. 95다28625 전원합의체

점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위가 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것임이 증명된 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 할 것이므로 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어진다.

대법원 1994.12.09. 94다25025

취득시효가 완성된 토지가 수용됨으로써 취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기 의무가 이행불능이 된 경우에는, 그 소유권이전등기청구권자는 대상청구권의 행사로서, 그 토지의 소유자가 그 토지의 대가로서 지급받은 수용보상금의 반환을 청구할 수 있다.

대법원 2009.07.16. 2007다15172 전원합의체

부동산에 대한 점유취득시효가 완성된 후 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 경료된 경우라 하더라도 당초의 점유자가 계속 점유하고 있고 소유자가 변동된 시점을 기산점으로 삼아도 다시 취득시효의 점유기간이 경과한 경우에는 점유자로서는 제3자 앞으로의 소유권 변동시를 새로운 점유취득시효의 기산점으로 삼아 2차의 취득시효의 완성을 주장할 수 있다.

대법원 1994.03.22. 93다46360

취득시효를 주장하는 자는 점유기간 중에 소유자의 변동이 없는 토지에 관하여는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있다.

대법원 2004.06.25. 2004다13052

등기부취득시효에서 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유 취득에 관한 것으로서 그 무과실에 관한 증명책임은 시효취득을 주장하는 쪽에 있고, 부동산을 취득한 자는 부동산을 양도하는 자가 처분할 권한이 있는지 여부를 조사하여야 할 것이며, 이를 조사하였더

라면 양도인에게 처분권한이 없음을 알 수 있었음에도 불구하고 이러한 조사를 하지 아니하고 양수하였다면 그 부동산의 점유에 대하여 과실이 있다.

대법원 2001.01.16. 98다20110

등기부취득시효에 관하여 민법 제245조 제2항은 “부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.”고 규정하고 있는데, 위 규정에 의하여 소유권을 취득하는 자는 10년간 반드시 그의 명의로 등기되어 있어야 하는 것은 아니고 앞 사람의 등기까지 아울러 그 기간 동안 부동산의 소유자로 등기되어 있으면 되고, 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는 것이므로, 등기부취득시효가 완성된 후에 그 부동산에 관한 점유자 명의의 등기가 말소되거나 적법한 원인 없이 다른 사람 앞으로 소유권이전등기가 경료되었다 하더라도, 그 점유자는 등기부취득시효의 완성에 의하여 취득한 소유권을 상실하는 것은 아니다.

대법원 1996.10.17. 96다12511 전원합의체

소유권보존등기가 2중으로 경료된 경우 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아니어서 뒤에 된 소유권보존등기가 무효로 되는 때에는, 뒤에 된 소유권보존등기나 소유권이전 등기를 근거로 하여서는 등기부취득시효의 완성을 주장할 수 없다.

대법원 2002.04.26. 2001다8097

명의신탁에 의하여 부동산의 소유자로 등기된 자는 그 사실만으로 당연히 부동산을 점유하는 것으로 볼 수 없음은 물론이고 설사 그의 점유가 인정된다고 하더라도 그 점유권원의 성질상 자주점유라 할 수 없다.

☞ 명의수탁자의 점유는 자주점유가 아니므로 명의수탁자는 취득시효를 주장하지 못한다.

3. 선점·습득·발견

(1) 무주물선점(無主物先占)

제252조 【무주물의 귀속】

- ① 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.
- ② 무주의 부동산은 국유로 한다.
- ③ 야생하는 동물은 무주물로 하고 사양하는 야생동물도 다시 야생상태로 돌아가면 무주물로 한다.

제255조 【문화재의 국유】

- ① 학술, 기예 또는 고고의 중요한 재료가 되는 물건에 대하여는 제252조 제1항 및 전2조의 규정에 의하지 아니하고 국유로 한다.
- ② 전항의 경우에 습득자, 발견자 및 매장물이 발견된 토지 기타 물건의 소유자는 국가에 대하여 적당한 보상을 청구할 수 있다.

- ① 무주물이란 현재 소유자가 없는 물건을 말한다. 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자가 그 소유권을 가지는 것을(제252조 제1항) 무주물선점이라 한다. 이는 사실행위이며, 제한능력자의 선점도 유효하다. 무주의 부동산은 국유로 하므로(제252조 제2항) 이는 선점하지 못한다. 선점물이 문화재(학술·기예 또는 고고의 중요한 자료가 되는 물건)인 때에도 국유로 하고 이때에 선점자는 국가에 보상을 청구할 수 있다(제255조).
- ② 야생하는 동물은 무주물이 되며, 사육하는 야생동물도 야생상태로 돌아가면 이를 유실물로 하지 않고 무주물이 된다. 따라서 선점의 대상이 된다.

(2) 유실물습득(遺失物拾得)

제253조 【유실물의 소유권취득】

유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다.

- ① 유실물은 법률이 정한 바에 의하여 공고한 후 6월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다(제253조).
- ② 유실물이란 점유자의 의사에 기하지 않고서 그의 점유를 떠난 물건으로서 도둑이 아닌 것을 말한다.
- ③ 유실물이 문화재인 경우에는 습득자가 소유권을 취득하지 못하고 국유가 된다(제255조 제1항), 그러나 습득자는 국가에 대하여 적당한 보상을 청구할 수 있다(제255조 제2항).

(3) 매장물발견

제254조 【매장물의 소유권취득】

매장물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.

- ① 매장물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견한 매장물은 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다(제254조). 보상금은 유실물에 있어서와 같다.
- ② 매장물이 문화재인 때에는 국유가 되며 이때에는 국가에 대하여 적당한 보상을 청구할 수 있다(제255조 제2항).
- ③ 매장물은 보통 동산이나, 반드시 동산에만 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 땅속에 묻힌 고대건물의 발견의 경우에는 매장물이 부동산에 해당함은 당연하다.
- * 매장물의 발견자가 누구인가 하는 것은 구체적 사정에 따라 결정하여야 한다. 매장물 발견을 위한 작업 중 피용자가 발견하였을 때에는 사용자가 발견자이며 다른 목적을 위한 작업중 우연히 발견한 경우에는 피용자가 된다고 보아야 할 것이다.

4. 첨부(添附)

(1) 첨부의 의미

- ① 부합·혼화·가공을 총칭하여 첨부라고 한다.
- ② 첨부에 의하여 생긴 물건은 1개의 물건으로 존속하며 분리나 원상복구를 인정하지 아니한다(강행규정). 원상으로 돌리기 어렵거나(부합·혼화의 경우) 원상으로 돌아가게 한다면 사회·경제적으로 불이익이 생기기 때문이다(가공의 경우).
- ③ 첨부에 의한 물건에 대해서는 새로이 소유자가 결정되며 소멸한 물건의 소유자는 부당이득에 의한 보상을 청구할 수 있다(임의규정).

(2) 부 합

1) 부합의 의의

소유자를 달리하는 두 개 이상의 물건이 결합되어 과다한 비용을 지출하지 않고는 분리할 수 없게 된 상태를 말한다(제256조·제257조). 부합에 의한 소유권 변동은 주장하는 자는 그 요건이 되는 사실을 주장하고 이를 증명할 책임이 있다(대법원 1970.9.22. 69라446).

2) 부동산에의 부합

제256조 【부동산에의 부합】

부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다.

- ① 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건(동산)의 소유권을 취득한다. 부합의 원인은 인위적이든 자연적이든 무방하다.
- ② 부합되는 물건은 동산에 한한다는 것이 통설의 입장이나 판례는 부동산도 부합될 수 있다고 한다(대법원 1991.4.12. 90다11967).
- ③ 부합된 동산이 타인의 권원(전세권·임차권 등)에 의하여 부합된 경우에는 부속시킨 자의 소유로 남는다(제256조 단서). 권원이란 지상권·전세권·임차권 등과 같이 타인의 부동산에 자기의 동산을 부속시켜서 그 부동산을 이용할 수 있는 권리를 말한다. 한편 권원이 있더라도 그 물건이 독립성을 구비하지 못한 경우, 즉 부동산의 구성부분으로 되는 경우에는 부합이 성립한다(대법원 1975.4.8. 74다1743).
- ④ 타인의 토지에 권원 없이 농작물을 경작한 경우, 그 농작물의 소유권귀속에 대하여 경작자의 소유가 된다는 것이 판례의 태도이다(대법원 1968.6.4. 68다613·614).
- ⑤ 임차인이 임대인의 동의를 받아 증·개축한 부분이 경제적으로 독립성이 인정될 경우에는 임차인의 소유로 남는다(대법원 1977.5.24. 76다464).
- ⑥ 부합으로 소유권을 취득한 자는 부당이득의 법리에 따라 소유권을 잃은 자에게 보상을 하여야 한다. 적법한 행위에 의한 손실이므로 배상이 아니라 보상이다.

3) 동산간의 부합

제257조 【동산간의 부합】

동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.

- ① 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 원칙적으로 주물(主物)의 소유자에게 귀속한다(제257조 제1항). 단, 주종을 구별할 수 없는 경우에는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다(제257조 제2항).
- ② 부합으로 소유권을 취득한 자는 부당이득의 법리에 따라 소유권을 잃은 자에게 보상을 하여야 한다.

(3) 혼화

- ① 각각 다른 소유자에게 속하는 동산이 혼화하여 식별할 수 없게 된 경우를 말하여 이에에는 고형물(곡물·금전)의 혼합과 유동물(술·기름)의 용화가 있다.
- ② 혼화에 대해서는 동산간의 부합에 관한 규정이 준용된다(제258조).

(4) 가공

제259조 【가공】

- ① 타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다. 그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.
- ② 가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 전항의 증가액에 가산한다.

- ① 타인의 동산에 노력을 가하여 새로운 물건을 만들어 내는 것을 가공이라 한다.
- ② 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 귀속하나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액(多額)인 때에는 가공자의 소유가 된다(제259조).
- ③ 가공에 관한 민법의 규정은 자본과 노동의 결합에는 적용되지 않는다. 따라서 공장생산의 경우에는 고용계약 또는 근로계약에 의하여 규율된다.

대법원 1995.06.29. 94다6345

주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크를 토지로부터 분리하는 데 과도한 비용이 들고 이를 분리하여 발굴할 경우 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것이 분명한 경우에 그 유류저장탱크는 토지에 부합한다. 또한 주유소의 주유기가 비록 독립된 물건이기는 하나 유류저장탱크에 연결되어 유류를 수요자에게 공급하는 기구로서 주유소 영업을 위한 건물이 있는 토지의 지상에 설치되었고 그 주유기가 설치된 건물은 당초부터 주유소 영업을 위한 건물로 건축되었다는 점 등을 종합하여 볼 때, 그 주유기는 계속해서 주유소 건물 자체의 경제적 효용을 다하게 하는 작용을 하고 있으므로 주유소 건물의 상용에 공하기 위하여 부속시킨 종물이다.

대법원 2000.10.28. 자2000마5527

토지 지하에 설치된 유류저장탱크와 건물에 설치된 주유기가 토지에 부합되거나 건물의 상용에 공하기 위하여 부속시킨 종물로서 토지 및 건물에 대한 경매의 목적물이 된다.

대법원 2007.07.27. 2006다39270

어떠한 동산이 부동산에 부합된 것으로 인정되기 위해서는 그 동산을 훼손하거나 과도한 비용을 지출하지 않고서는 분리할 수 없을 정도로 부착·합체되었는지 여부 및 그 물리적 구조, 용도와 기능면에서 기존 부동산과는 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권의 객체가 될 수 있는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이고, 부합물에 관한 소유권 귀속의 예외를 규정한 민법 제256조 단서의 규정은 타인이 그 권원에 의하여 부속시킨 물건이라 할지라도 그 부속된 물건이 분리하여 경제적 가치가 있는 경우에 한하여 부속시킨 타인의 권리에 영향을 없다는 취지이지 분리하여도 경제적 가치가 없는 경우에는 원래의 부동산 소유자의 소유에 귀속되는 것이고, 경제적 가치의 판단은 부속시킨 물건에 대한 일반 사회통념상의 경제적 효용의 독립성 유무를 그 기준으로 하여야 한다.

대법원 2009.08.20. 2008두8727

부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립된 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인의 권원에 의하여 이를 부합시킨 경우에도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다.

대법원 2012.04.30. 자2011마1525

건물이 증축된 경우에 증축 부분이 기존 건물에 부합된 것으로 볼 것인가 아닌가 하는 점은 증축 부분이 기존건물에 부착된 물리적 구조뿐만 아니라, 그 용도와 기능의 면에서 기존 건물과 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권 객체가 될 수 있는지의 여부 및 증축하여 이를 소유하는 자의 의사 등을 종합하여 판단하여야 한다.

대법원 1992.12.8. 92다26772, 26789

건물의 증축부분이 기존건물에 부합하여 기존건물과 분리하여서는 별개의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 이상 기존건물에 대한 근저당권은 민법 제358조에 의하여 부합된 증축 부분에도 효력이 미치는 것이므로 기존건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니하였다고 할지라도 경락인은 부합된 증축부분의 소유권을 취득한다.

제4절 소유권에 기한 물권적청구권

민법은 소유권에 관하여 소유물반환청구권·소유물방해제거청구권·소유물예방청구권의 세 가지를 모두 인정하고 이들 물권적 청구권을 다른 물권에 준용하고 있다.

☑ 물권적청구권의 구체적 내용

1. 소유물반환청구권

(1) 의의

소유자는 그의 소유에 속하는 물건을 점유하는 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다(제213조).

(2) 청구권자와 상대방

① 이 청구권의 주체는 점유를 잃은 소유자이다.

② 이 청구권의 상대방은 물건을 점유함으로써 소유자의 점유를 방해하고 있는 자이다.

따라서 타인의 물건을 침탈한 자이더라도 현재 점유하고 있지 않으면 이 청구권의 상대방이 되지 못한다. 상대방이 점유를 취득한 이유는 묻지 않으며 또한 그에게 고의나 과실이 있어야 하는 것도 아니다.

(3) 내용

소유물의 반환(점유의 이전)을 청구할 수 있다. 침해로 인하여 손해가 생긴 경우에는 일반 불법행위의 원칙에 따라서 손해배상을 청구할 수 있다.

2. 소유물방해제거청구권

(1) 의의

소유권이 점유의 침탈 이외의 방법으로 방해된 때에는, 소유자는 방해자에 대하여 그 방해의 제거를 청구할 수 있다(제214조).

(2) 청구권자와 상대방

① 이 청구권의 주체는 점유의 침탈 이외의 방법으로 소유권을 방해당하고 있는 소유자이다.

② 이 청구권의 상대방은 현재 방해를 발생하게 하는 사실을 그의 지배 내에 가지고 있는 자이다. 그의 고의·과실은 요건이 아니며 또한 방해가 반드시 그 자의 행위에 의하여 발생하고 있어야 하는 것도 아니다.

(3) 내용

방해자에 대하여 방해를 제거할 것을 요구하는 것이다. 방해로 인하여 손해가 생긴 경우에는 일반 불법행위의 원칙에 따라서 손해배상을 청구할 수 있다.

3. 소유물방해예방청구권

(1) 의의

소유자는 소유권을 방해할 염려가 있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(제214조).

(2) 청구권자와 상대방

- ① 이 청구권의 주체는 현재 소유권을 방해당하고 있지는 않더라도 장래 방해당할 것을 염려하고 있는 자이다.
- ② 이 청구권의 상대방은 장차 소유권을 방해할 가능성이 있는 자이다.

(3) 내용

소유권방해의 염려가 있는 원인을 제거하여 방해를 미리 방지조치를 취하여 줄 것 또는 미리 손해배상의 담보를 제공할 것을 청구하는 것이다.

중요판례

대법원 2003.03.28. 2003다5917

- [1] 소유권에 기한 방해배제청구권에 있어서 '방해'라 함은 현재에도 지속되고 있는 침해를 의미하고, 법의 침해가 과거에 일어나서 이미 종결된 경우에 해당하는 '손해'의 개념과는 다르다 할 것이어서, 소유권에 기한 방해배제청구권은 방해결과의 제거를 내용으로 하는 것이 되어서는 아니 되며(이는 손해배상의 영역에 해당한다 할 것이다) 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 한다.
- [2] 쓰레기 매립으로 조성한 토지에 소유권자가 매립에 동의하지 않은 쓰레기가 매립되어 있다 하더라도 이는 과거의 위법한 매립공사로 인하여 생긴 결과로서 소유권자가 입은 손해에 해당한다 할 것일 뿐, 그 쓰레기가 현재 소유권에 대하여 별도의 침해를 지속하고 있다고 볼 수 없으므로 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 없다.

제5절 공동소유

1. 의의

하나의 물건을 2인 이상의 다수인이 공동으로 소유하는 것을 공동소유라고 한다. 그런데 민법은 공동소유의 유형으로서 공유·합유·총유의 3가지를 인정한다.

〈공유·합유·총유의 비교〉

형태 내용	공유	합유	총유
인적 결합형태	공동소유자 사이에 아무런 인적 결합관계가 없는 개인 주의적인 소유형태 ❖ 1필지 토지를 여러 사람이 공동으로 매수하는 경우	조합체(제271조) ❖ 공장을 함께 경영할 목적 으로 여러 사람이 공동 으로 토지를 매수하는 경우	권리능력 없는 사단 (제275조) ❖ 문중 또는 종중이 선산을 매수하는 경우
지분의 처분	각 공유자는 그 지분을 자유롭게 처분할 수 있다 (제263조).	조합원 이외의 제3자의 침입을 방지하기 위하여 지분의 처분 등은 제한된다 (제277조).	지분을 갖지 못한다.
분할청구	각 공유자는 언제든지 분할 을 청구하여 공유관계를 종 료시킬 수 있다(제268조).	합유관계가 존속하는 한 합 유물의 분할은 청구할 수 없다. 다만, 조합이 해산한 경우에는 청산절차에 따라 합유물을 분할하여 각 조합 원에게 분배할 수 있다.	할 수 없다.
보존행위	각자 단독으로 할 수 있다.	각자 단독으로 할 수 있다.	사원총회의 결의에 의한다.
관리행위	지분의 과반수로 결정한다.	조합계약 기타 규약의 정함 에 따른다.	사원총회의 결의에 의한다.
사용·수익	지분의 비율로 사용한다.	조합계약 기타 규약의 정함 에 따른다.	정관 기타 규약의 정함에 따른다.
처분·변경	공유자 전원의 동의가 있어 야 한다.	합유자 전원의 동의가 있어 야 한다.	사원총회의 결의가 있어야 한다.
등기방식	공유자 전원의 명의로 등기 하되 그 지분을 기재한다.	합유자 전원의 명의로 등기 하되 합유의 취지를 기재하 여야 한다.	권리능력 없는 사단 자체의 명의로 등기하나 대표자의 이름을 첨기한다.

2. 공유(共有)

(1) 공유의 성립

제262조 【물건의 공유】

- ① 물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다.
- ② 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.

1물1권주의의 원칙상 하나의 소유권이 분량적으로 분할되어서 여러 사람의 소유로 되는 것을 공유라고 하며, 공유지분이란 각 공유자가 가지는 권리로서 하나의 소유권의 분량적 일부분이다. 아울러 공유는 법률행위에 의한 성립과 법률의 규정에 의한 성립이 있다.

1) 법률행위에 의한 성립

하나의 물건을 수인이 공동의 소유로 한다는 뜻의 의사의 합치에 의해 공유는 성립한다. 이때 그 물건이 부동산인 때에는 공유의 등기와 지분의 등기를 하여야 한다.

2) 법률의 규정에 의한 성립

- ① 수인 공동의 무주물선점(제252조)·유실물습득(제253조)·타인의 토지 속에서의 매장물발견(제254조 단서)
- ② 주종을 구별할 수 없는 동산의 부합(제257조 후단)·혼화(제258조)
- ③ 공유물의 과실(제102조)
- ④ 건물의 구분소유에 있어서의 공용부분(제215조 제1항 ; 집합건물의소유및관리에 관한법률 제10조 제1항, 제3조 제1항) 및 경계에 설치된 경계표·담·구거(도랑) 등(제239조)
- ⑤ 공동상속재산(제1006조)

(2) 공유의 내부관계

1) 지분의 비율

각 공유자의 지분의 비율은 공유자의 의사표시 또는 법률의 규정에 의하여 정하여지나 불명확한 경우에는 균등한 것으로 추정된다(제262조 제2항).

2) 지분의 탄력성

공유자 중 어느 한 사람이 그의 지분을 포기하거나, 상속인 없이 사망한 때에는 그 자의 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다(제267조).

3) 공유물의 이용관계

- ① 사용·수익 : 각 공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있다(제263조 후단).
- ② 관리 : 공유물의 관리에 관한 사항, 즉 목적물의 이용 및 개량을 목적으로 하는 행위는 지분의 과반수로써 결정한다(제265조 본문). 그러나 보존행위는 각자가 단독으로 할 수 있다(제265조 단서). 보존행위는 공유자 전체의 이익이 되는 것이 보통이기 때문이다.
- ③ 변경·처분 : 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다(제264조). 다른 공유자의 동의 없이 처분을 한 경우에는 그 처분은 무효이다.
- ④ 비용의 부담 : 공유물의 관리비용 기타 의무는 공유자가 그 지분의 비율로 부담한다(제266조 제1항). 공유자가 1년 이상 그 의무의 이행을 지체한 때에는 타 공유자는 상당한(적절한) 가액으로 지분을 매수할 수 있다(제266조 제2항). 이 매수권은 일종의 형성권이다.

4) 지분의 주장

공유자는 지분을 자유로이 처분할 수 있다(제263조 전단). 즉, 지분의 양도·담보제공·포기 등을 할 수 있다. 다만 용익물권의 설정과 같은 처분은 공유물 전체의 처분이 되므로 단독으로 하지 못한다. 그리고 구분건물소유자는 그가 소유하는 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분 또는 대지사용권에 대한 지분을 처분할 수 없다(집합건물 소유 및 관리에 관한 법률 제13조).

(3) 공유의 외부관계

1) 반환청구

공유자는 그의 지분의 비율에 따른 점유의 반환을 청구할 수 있을 뿐 아니라 그 지분에 기하여 단독으로 모든 공유자를 위하여 자기에게 전부의 인도를 청구할 수 있다.

2) 방해제거청구

제3자가 공유물에 대하여 방해하는 때에는 각 공유자는 단독으로 공유물 전부에 대한 방해제거청구를 할 수 있다.

중요판례

대법원 2006.11.24. 2006다49307

공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있고 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하는 것이므로 공유물의 구체적인 사용·수익의 방법에 관하여 공유자들 사이에 지분 과반수의 합의 없이 공유자 중의 1인이 이를 배타적으로 점유·사용하고 있다면 다른 공유자에 대하여는 그 지분에 상응하는 부당이익을 하고 있는 것이 된다.

대법원 1969. 03. 04. 69다21

토지의 공유자는 단독으로 그 토지의 불법점유자에 대하여 명도를 구할 수 있다.

대법원 1970. 03.24. 70다133

공유지분은 공유물 전부에 효력이 미치므로 다른 지분권자가 공유지분을 다투거나 침해하였다면 보존행위로서 지분권의 확인 및 방해제거를 청구할 수 있다.

대법원 1996.12.23. 95다48308

공유지분이 과반수에 미달하는 공유자도 공유물의 보존행위로서 다른 공유자와의 합의 없이 공유물을 배타적으로 점유·사용하고 있는 공유자에 대하여 공유물의 인도나 명도를 구할 수 있다.

대법원 2015.03.26. 2014다233428

공유물의 분할은 공유자 간에 협의가 이루어지는 경우에는 방법을 임의로 선택할 수 있으나 협의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할을 하게 되면 현저히 가액이 감소될 염려가 있는 때에 비로소 물건의 경매를 명하여 대금분할을 할 수 있는 것이므로, 위와 같은 사정이 없는 한 법원은 각 공유자의 지분비율에 따라 공유물을 현물 그대로 수개의 물건으로 분할하고 분할된 물건에 대하여 각 공유자의 단독소유권을 인정하는 판결을 하여야 한다. 그리고 분할의 방법은 당사자가 구하는 방법에 구애받지 아니하고 법원의 재량에 따라 공유관계나 객체인 물건의 제반 상황에 따라 공유자의 지분비율에 따른 합리적인 분할을 하면 되는데, 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할청구자의 지분한도

안에서 현물분할을 하고 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남는 방법도 허용된다. 그러나 분할청구자가 상대방들을 공유로 남기는 방식의 현물분할을 청구하고 있다고 하여, 상대방들이 그들 사이만의 공유관계의 유지를 원하고 있지 아니한데도 상대방들을 여전히 공유로 남기는 방식으로 현물분할을 하여서는 아니 된다.

대법원 2020.5.21. 2018다287522 전원합의체

- [1] 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다.
- [2] 자신의 지분권에 기초하여 공유물에 대한 방해 상태를 제거하거나 공동 점유를 방해하는 행위의 금지 등을 청구할 수 있다.

대법원 2002.5.14. 2002다9738

- [1] 공유자 사이에 공유물을 사용·수익할 구체적인 방법을 정하는 것은 공유물의 관리에 관한 사항으로서 공유자의 지분의 과반수로써 결정하여야 할 것이고, 과반수 지분의 공유자는 다른 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관한 협의가 없었다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있으므로, 과반수 지분의 공유자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익하기로 정하는 것은 공유물의 관리방법으로서 적법하다고 할 것이므로, 과반수 지분의 공유자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 소수 지분의 공유자는 그 점유자가 사용·수익하는 건물의 철거나 퇴거 등 점유배제를 구할 수 없다.
- [2] 과반수 지분의 공유자는 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관하여 협의가 없었다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있으므로 과반수 지분의 공유자는 그 공유물의 관리방법으로서 그 공유토지의 특정된 한 부분을 배타적으로 사용·수익할 수 있으나, 그로 말미암아 지분은 있으며 그 특정 부분의 사용·수익을 전혀 하지 못하여 손해를 입고 있는 소수지분권자에 대하여 그 지분에 상응하는 임료 상당의 부당이득을 하고 있다 할 것이므로 이를 반환할 의무가 있다 할 것이나, 그 과반수 지분의 공유자로부터 다시 그 특정 부분의 사용·수익을 허락받은 제3자의 점유는 다수 지분권자의 공유물관리권에 터잡은 적법한 점유이므로 그 제3자는 소수지분권자에 대하여도 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있다고는 볼 수 없다.

대법원 2009.6.25. 2009다22235

과반수 지분의 공유자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익하기로 정하는 것은 공유물의 관리방법으로서 적법하다고 할 것이므로, 과반수 지분의 공유자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 소수 지분의 공유자는 점유자가 사용·수익하는 건물의 철거나 퇴거 등 그 점유의 배제를 구할 수 없다.

대법원 2010.01.14. 2009다67429

부동산의 공유자의 1인은 당해 부동산에 관하여 제3자 명의로 원인무효의 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우 공유물에 관한 보존행위로서 제3자에 대하여 그 등기 전부의 말소를 구할 수 있다.

대법원 2001.12.11. 2000다13948

토지의 공유자는 각자의 지분 비율에 따라 토지 전체를 사용·수익할 수 있지만, 그 구체적인 사용·수익 방법에 관하여 공유자들 사이에 지분 과반수의 합의가 없는 이상, 1인이 특정 부분을 배타적으로 점유·사용할 수 없는 것이므로, 공유자 중의 일부가 특정 부분을 배타적으로 점유·사용하고 있다면, 그들은 비록 그 특정 부분의 면적이 자신들의 지분 비율에 상당하는 면적 범위 내라고 할지라도, 다른 공유자들 중 지분은 있으나 사용·수익은 전혀 하지 않고 있는 자에 대하여는 그 자의 지분에 상응하는 부담이득을 하고 있다고 보아야 할 것인바, 이는 모든 공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 권리가 있기 때문이다.

대법원 2005.5.12. 2005다1827

공유자 간의 공유물에 대한 사용수익·관리에 관한 특약은 공유자의 특정승계인에 대하여도 당연히 승계된다고 할 것이나, 민법 제265조는 “공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다.”라고 규정하고 있으므로, 위와 같은 특약 후에 공유자에 변경이 있고 특약을 변경할 만한 사정이 있는 경우에는 공유자의 지분의 과반수의 결정으로 기존 특약을 변경할 수 있다.

대법원 2013.1.17. 2010다71578 전원합의체

1동의 건물이 구조상·이용상으로 구분되어 독립성을 갖추고 있더라도 분양 면적 또는 매도 면적에 해당하는 비율로 공유지분등기를 마쳐 줌으로써 그 건물 각 층의 구분소유자들 사이에 상호명의신탁관계 내지 구분소유적 공유관계가 성립할 수 있다.

대법원 2022.8.25. 2017다257067 전원합의체

공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있으므로 공유토지의 일부를 배타적으로 점유하면서 사용·수익하는 공유자는 그가 보유한 공유지분의 비율에 관계없이 다른 공유자에 대하여 부담이득반환의무를 부담한다. 그런데 일반 건물에서 대지를 사용·수익할 권원이 건물의 소유권과 별개로 존재하는 것과는 달리, 집합건물의 경우에는 대지사용권인 대지지분이 구분소유권의 목적인 전유부분에 종속되어 일체화되는 관계에 있으므로, 집합건물 대지의 공유관계에서는 이와 같은 민법상 공유물에 관한 일반 법리가 그대로 적용될 수 없고, 이는 대지 공유자들 중 구분소유자 아닌 사람이 있더라도 마찬가지이다.

집합건물에서 전유부분 면적 비율에 상응하는 적정 대지지분을 가진 구분소유자는 그 대지 전부를 용도에 따라 사용·수익할 수 있는 적법한 권원을 가지므로, 구분소유자 아닌 대지 공유자는 그 대지 공유지분권에 기초하여 적정 대지지분을 가진 구분소유자를 상대로는 대지의 사용·수익에 따른 부당이득반환을 청구할 수 없다.

(4) 공유물의 분할

1) 분할의 자유와 금지

- ① 각 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구하여 공유관계를 종료시킬 수 있다(제268조 제1항). 그러나 특히 공유자 사이의 계약에 의할 때에는 5년을 넘지 않는 한도에서 분할의 자유를 제한하는 것을 인정한다. 이 계약은 갱신할 수 있지만, 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다(제268조 제2항). 이 특약은 등기되어 있을 때에만 지분의 양수인에게 그 효력이 미친다(등기법 제89조).
- ② 구분건물의 공용부분(제215조)·경계선상의 경계표(제239조)에 대하여는 그 성질상 분할이 인정되지 않는다.

2) 분할의 방법

각 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다(제268조 제1항). 이 분할 청구권은 일종의 형성권이라는 것이 다수설이다. 그러나 분할의 청구에 의하여 당연히 분할이 되는 것은 아니고, 법정의 방법에 의하여 구체적으로 분할을 실현시켜야 할 법률관계가 당사자 사이에 발생한다. 따라서 각 공유자는 분할의 방법에 관하여 협의할 의무를 부담하게 되며 협의가 이루어지지 않을 때에는 분할청구자는 다른 공유자 전원을 상대로 법원에 그 분할을 청구할 수 있다. 즉, 분할의 방법은 협의분할과 재판상 분할이 있다.

3) 분할의 효과

- ① 분할로 각 공유자는 단독소유자가 된다.
- ② 분할로 어떤 공유자가 취득한 부분에 하자가 있을 때에는 다른 공유자는 매도인의 담보책임을 진다.

☑ 협의분할과 재판상 분할

(1) 협의분할

공유물의 분할은 우선 협의에 의하여 이를 행한다(제268조 제1항·제269조 제1항). 분할 방법으로는 현물분할이 원칙이지만, 경우에 따라서는 공유물을 매각하여 그 대금을 나누는 대금분할이나, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 지분을 양수하여 그 가격을 지급하고 단독소유자가 되는 가격배상에 의한 분할의 방법을 이용할 수도 있다.

(2) 재판상 분할

분할의 방법에 관하여 협의가 성립되지 아니한 때에는, 공유자는 법원에 그 분할을 청구할 수 있다(제269조 제1항).

① 요 건

공유물분할의 訴를 제기하려면 공유자 사이에 협의가 성립하지 않아야 한다. 따라서 전 공유자의 합의에 의한 분할의 약정이 있는 때에는 재판상의 분할청구는 인정되지 않는다.

② 訴의 성질

이 訴는 법원의 구체적 자유재량에 의한 분할이라는 법률관계의 형성을 내용으로 하는 것으로서, 형성의 訴이다. 따라서 그 판결의 확정으로 물건변동의 효과가 발생한다(제187조). 즉, 공유토지의 분할로 단독소유권을 취득한 경우에는, 분필등기를 거친 다음에 이전등기를 하는 절차를 취하지만 이러한 등기를 한 때에 물건변동의 효력이 발생하는 것은 아니다.

③ 訴의 당사자

이 訴는 이른바 필요적 공동소송이며, 공유자 전원이 소송의 당사자로 되어야 한다. 따라서, 피고가 되는 자는 원고를 제외한 그 밖의 다른 공유자 전원이다.

④ 판결의 내용(분할방법)

현물분할을 원칙으로 하며, 그것이 불가능하거나 또는 현물분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감손될 염려가 있는 때에는 법원은 목적물의 경매를 명하고 그 대금을 분할하는 대금분할에 의한다.

☑ 공유물분할에 따른 제반문제

(1) 공유자 사이의 담보책임

① 분할에 의하여 각 공유자 사이에는 실질적으로는 각자의 지분에 대하여 교환 또는 매매가 행하여진 것이 된다. 따라서 각 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 관하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임을 부담한다(제270조).

② 담보책임의 내용도 매도인의 담보책임의 내용(제570조 이하)과 동일하여 대금감액과 손해배상의 청구는 언제나 가능하지만 해제(공유물분할의 문제이므로 재분할의 문제)

된다)에 관해서는 의문이 있는데, 협의상의 분할에 있어서는 해제할 수 있지만 법원에 의한 분할의 경우에는 해제는 할 수 없다고 해석하는 것이 다수설이다. 해제에 의하여 재판의 결과를 뒤집는 것은 허용될 수 없기 때문이다.

(2) 분할효과의 불소급

분할의 효과는 소급하지 않는다. 그러나 공동상속재산의 분할의 효과만은 상속개시시에 소급한다(제1015조).

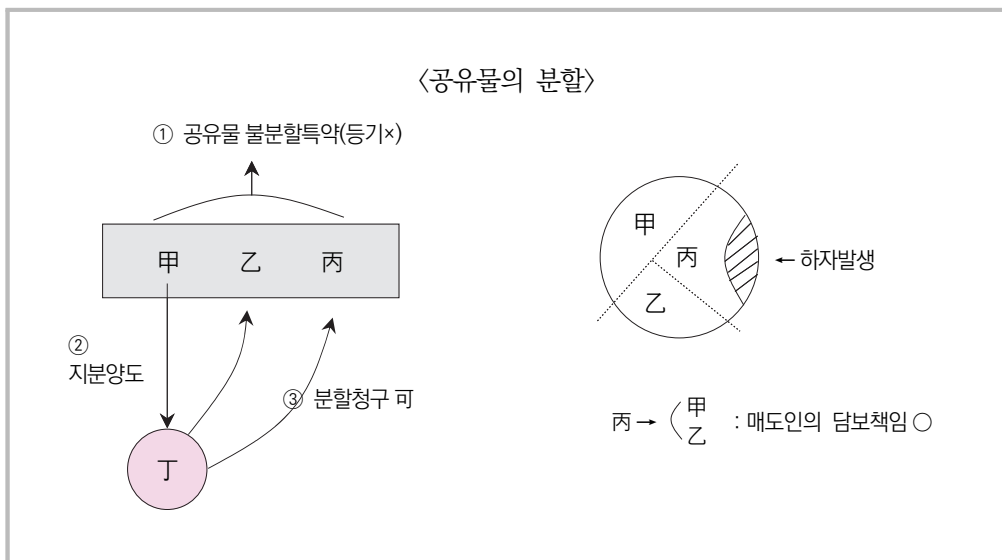
(3) 지분상의 담보물권

분할이 지분 위에 존재하는 담보물권에 어떠한 영향을 미치느냐에 관하여 민법에는 명문의 규정이 없으나, 혼동의 규정(제191조)을 유추하여 다음과 같이 해석하는 것이 통설이다.

- ① 담보물권의 목적이 된 지분을 가지는 자가 공유물의 전부를 취득하는 경우에는 그 지분은 소멸하지 않고 이 지분 위에 담보물권은 존속한다.
- ② 그 지분을 가지는 자가 공유물의 일부를 취득한 경우에는 공유물 전부 위에 지분은 소멸하지 않고 이 지분 위에 담보물권은 존속한다.
- ③ 공유물의 전부가 제3자(대금분할의 경우) 또는 다른 공유자(가액배상의 경우)에게 귀속하고, 그 지분을 가지는 자가 대금 또는 가격을 취득하는 경우에는 담보물권은 그 타인에게 귀속한 물건의 지분 위에 존속하고, 또는 담보물권자는 물상대위(제342조·제370조)에 의하여 이 대금 또는 가액위에 권리를 행사할 수 있다.

(4) 공유물 위의 용익물권

공유물 위의 용익물권은 분할된 각 부분에 존속하고 공유물 일부 위의 용익물권은 그 부분 위에만 존속한다(제293조 제2항).



대법원 1981.03.24. 80다1888·1889

공유물분할청구권은 공유관계에서 수반되는 형성권이므로 공유관계가 존속하는 한 그 분할 청구권만이 독립하여 시효로 소멸될 수 없다.

대법원 2003.12.12. 2003다44615

공유물분할청구의 소는 분할을 청구하는 공유자가 원고가 되어 다른 공유자 전부를 공동 피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이다.

☞ 공유물의 분할은 협의에 의한 분할이거나 재판상의 분할이거나를 막론하고 공유자 전원이 분할절차에 참여하여야 한다. 따라서 상속재산의 협의분할도 공동상속인간의 일종의 계약으로서 공동상속인 전원이 참여하여야 하고 일부상속인만으로 한 협의분할은 무효이다.

대법원 2012.03.29. 2011다74932

부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 저당권의 공동 담보가 된다.

☞ 甲, 乙의 공유인 부동산 중 甲의 지분 위에 설정된 근저당권 등 담보물권은 특단의 합의가 없는 한 공유물분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 전부의 위에 그대로 존속하고 근저당권설정자인 甲 앞으로 분할된 부분에 당연히 집중되는 것은 아니다.

대법원 1995.01.12. 94다30348,30355

공유물분할은 협의분할을 원칙으로 하고 협의가 성립되지 아니한 때에는 재판상 분할을 청구할 수 있으므로 공유자 사이에 이미 분할에 관한 협의가 성립된 경우에는 일부 공유자가 분할에 따른 이전등기에 협조하지 않거나 분할에 관하여 다툼이 있더라도 그 분할된 부분에 대한 소유권이전등기를 청구하든가 소유권확인을 구함은 별문제이나 또다시 소로써 그 분할을 청구하는 것은 허용되지 않는다.

대법원 2002.04.12. 2002다4580

재판에 의한 공유물분할은 각 공유자의 지분에 따른 합리적인 분할을 할 수 있는 한 현물 분할을 하는 것이 원칙이나, 대금분할에 있어 '현물로 분할할 수 없다.'는 요건은 이를 물리적으로 엄격하게 해석할 것은 아니고, 공유물의 성질, 위치나 면적, 이용상황, 분할 후의 사용 가치 등에 비추어 보아 현물분할을 하는 것이 곤란하거나 부적당한 경우를 포함한다 할 것

이고, '현물로 분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 경우'라는 것도 공유자의 한 사람이라도 현물분할에 의하여 단독으로 소유하게 될 부분의 가액이 분할 전의 공유지분 가액보다 현저하게 감소될 염려가 있는 경우도 포함한다.

☞ 공유지분비율에 따라 현물분할할 경우 공유자 1인이 소유할 부분이 너무 작아서 지상에 건축이 불가능하게 된다면 그 대지부분의 가액은 분할 전 건축이 가능한 대지의 지분 가액보다 현저하게 감소될 것이 명백하여 공정한 분할이라고 보기 어렵다는 것이 판례이다. 아울러 공유토지를 현물분할하는 경우에도 반드시 공유지분의 비율대로 토지면적을 분할해야 하는 것은 아니고 토지의 형상이나 위치, 이용상황이나 경제적 가치 등 제반 사정을 고려하여 경제적 가치가 지분비율에 상응하도록 분할할 수 있다.

대법원 2013.11.21. 2011두1917 전원합의체

공유물분할의 소송절차 또는 조정절차에서 공유자 사이에 공유토지에 관한 현물분할의 협의가 성립하여 그 합의사항을 조서에 기재함으로써 조정이 성립하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 재판에 의한 공유물분할의 경우와 마찬가지로 그 즉시 공유관계가 소멸하고 각 공유자에게 그 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것은 아니고, 공유자들이 협의한 바에 따라 토지의 분필절차를 마친 후 각 단독소유로 하기로 한 부분에 관하여 다른 공유자의 공유지분을 이전받아 등기를 마침으로써 비로소 그 부분에 대한 대세적 권리로서의 소유권을 취득하게 된다고 보아야 한다.

3. 합유(合有)

(1) 합유의 법률적 성질

제271조 【물건의 합유】

- ① 법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인의 조합체로서 물건을 소유하는 때에는 합유로 한다.
합유자의 권리는 합유물 전체에 미친다.
- ② 합유에 관하여는 전항의 규정 또는 계약에 의하는 외에 다음 3조의 규정에 의한다.

수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태를 말한다(제271조). 합유는 단체적 단일성은 약하고 구성원의 개별성이 강한 점에서 법인이나 법인격 없는 사단과 다르다. 합유에 있어서도 공유에서와 같이 합유자는 지분을 가지고 있으나, 각 합유자 사이에는 공동 목적을 위한 단체적 구속이 있기 때문에 지분처분의 자유와 분할청구권이 없는 점에서 공유와 다르다.

(2) 합유의 성립

합유관계는 법률의 규정 또는 계약에 의하여 존재하게 된 조합체가 어떤 물건의 소유권을 취득한 경우에 성립한다.

(3) 합유의 법률관계

1) 합유지분

합유자의 권리, 즉 지분은 합유물 전부 위에 미친다(제271조 제1항). 그밖에 합유관계의 내용은 합유자 사이의 계약에 의하여 정해지나, 그 약정이 없는 경우에는 다음의 제272조 내지 제274조의 규정에 의해 규율된다(제271조 제2항). 따라서 제272조 내지 제274조의 규정은 임의규정이다.

2) 합유물의 처분·변경·보존

합유물의 보존행위는 각 합유자가 단독으로 할 수 있으나, 합유물을 처분 또는 변경하는 데에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다(제272조).

3) 지분처분의 제한·합유물의 분할금지

합유자는 전원의 동의 없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못하며(제273조 제1항), 합유물의 분할을 청구하지 못한다(제273조 제2항).

4) 합유의 종료

합유물의 분할은 원칙적으로 금지되어 있기 때문에 합유관계가 종료하는 것은 합유물의 양도로 조합재산이 없게 되는 때와 조합체의 해산이 있게 되는 때이다(제274조 제1항). 조합체의 해산으로 합유관계를 종료하게 되면 합유재산은 이를 분할하게 되는데 그 분할에는 공유물의 분할에 관한 규정이 준용된다(제274조 제2항).

중요판례

대법원 1996.12.10. 96다23238

부동산의 합유자 중 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자의 상속인은 합유자로서의 지위를 승계하지 못하므로, 해당 부동산은 잔존 합유자가 2인 이상일 경우에는 잔존 합유자의 합유로 귀속되고 잔존 합유자가 1인인 경우에는 잔존 합유자의 단독소유로 귀속된다.

대법원 1997.09.09. 96다16896

- [1] 합유지분 포기가 적법하다면 그 포기된 합유지분은 나머지 잔존 합유지분권자들에게 균분으로 귀속하게 되지만 그와 같은 물권변동은 합유지분권의 포기라고 하는 법률행위에 의한 것이므로 등기하여야 효력이 있고 지분을 포기한 합유지분권자로부터 잔존 합유지분권자들에게 합유지분권 이전등기가 이루어지지 아니하는 한 지분을 포기한 지분권자는 제3자에 대하여 여전히 합유지분권자로서의 지위를 가지고 있다고 보아야 한다.
- [2] 합유물에 관하여 경료된 원인무효의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송은 합유물에 관한 보존행위로서 합유자 각자가 할 수 있다.

4. 총유(總有)

제275조 【물건의 총유】

- ① 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.
- ② 총유에 관하여는 사단의 정관 기타 계약에 의하는 외에 다음 2조의 규정에 의한다.

제276조 【총유물의 관리, 처분과 사용, 수익】

- ① 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.
- ② 각사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용, 수익할 수 있다.

제277조 【총유물에 관한 권리의무의 득상】

총유물에 관한 사원의 권리의무는 사원의 지위를 취득상실함으로써 취득상실된다.

(1) 총유의 법률적 성질

- ① 법인이 아닌 사단의 재산소유형태이다(제275조 제1항).
- ② 소유권의 내용 중 관리·처분 등의 권능은 구성원의 총체에 속하고 사용·수익 등의 권능은 각 구성원에게 속한다. 지분이 없다는 점에서 다른 공동소유형태와 구별된다.

(2) 총유의 주체

법인 아닌 사단, 즉 종중·문중·교회·입주자 대표회의 등이 이에 해당한다.

(3) 총유의 법률관계

총유관계는 사단의 정관 기타 규약에 의하여 정하여지거나 이들 정관 기타 규약으로 정한 바가 없는 때에는 제276조와 제277조의 규정에 의한다. 따라서 이들 민법의 규정은 임의규정이다.

- ① 총유물의 관리·처분은 사원총회의 결의에 의한다(제276조 제1항).
- ② 각 사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용·수익할 수 있다(제276조 제2항).
- ③ 총유물에 관한 사원의 권리의무, 즉 총유물의 관리·처분에 참여하고 총유물을 사용·수익하는 것은 사원의 지위를 취득·상실함으로써 취득·상실한다(제277조).

대법원 2011.07.28. 2010다97044

비법인사단이 총유재산에 관한 소송을 제기할 때에는 정관에 다른 정함이 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 사원총회 결의를 거쳐야 하는 것이므로, 비법인사단이 이러한 사원총회 결의 없이 그 명의로 제기한 소송은 소송요건이 흠결된 것으로서 부적법하다.

☞ 총유물의 보존에 있어서는 공유물의 보존에 관한 민법 제265조의 규정(공유물의 보존 행위는 각자가 할 수 있다)이 적용될 수 없고, 특별한 사정이 없는 한 사원총회의 결의를 거쳐야 하고 이는 대표자의 정함이 있는 비법인사단인 교회가 그 총유재산에 대한 보존 행위로서 대표자의 이름으로 소송행위를 하는 경우에도 적용된다.

대법원 2005.09.15. 2004다44971 전원합의체

민법 제276조 제1항은 "총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.", 같은 조 제2항은 "각 사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용·수익할 수 있다."라고 규정하고 있을 뿐 공유나 합유의 경우처럼 보존행위는 그 구성원 각자가 할 수 있다는 민법 제265조 단서 또는 제272조 단서와 같은 규정을 두고 있지 아니한바, 이는 법인 아닌 사단의 소유 형태인 총유가 공유나 합유에 비하여 단체성이 강하고 구성원 개인들의 총유재산에 대한 지분권이 인정되지 아니하는 데에서 나온 당연한 귀결이라고 할 것이므로 총유재산에 관한 소송은 법인 아닌 사단이 그 명의로 사원총회의 결의를 거쳐 하거나 또는 그 구성원 전원이 당사자가 되어 필수적 공동소송의 형태로 할 수 있을 뿐 그 사단의 구성원은 설령 그가 사단의 대표자라거나 사원총회의 결의를 거쳤다 하더라도 그 소송의 당사자가 될 수 없다.

5. 준공동소유

수인이 소유권 이외의 재산권을 공동으로 소유하는 경우에 이를 준공동소유라고 한다. 준공동소유에는 준공유·준합유·준총유의 3가지가 있는 바, 이에는 각각 공유·합유·총유에 관한 민법의 규정이 준용된다.

제1관 서설

1. 명의신탁의 의의

대내적 관계에서는 신탁자가 소유권을 보유하여 이를 관리수익하면서 공부(公簿)상의 소유명의만을 수탁자로 하여 두는 것을 말한다. 명의신탁은 공부에 의하여 소유관계를 표시하는 경우에 가능하므로 동산에 관해서는 명의신탁이 성립할 수 없다. 그러나 채권에 관해서는 명의신탁이 성립할 수 있다.

2. 명의신탁의 발생유형

명의신탁은 과거 종중재산과 관련하여 주로 형성되었으나 최근에는 조세포탈, 투기, 재산은닉, 탈법의 목적으로 명의신탁이 행하여지는 경우가 많다. 그리고 1필지의 토지의 일부를 매수하였으나 당사자가 합의하여 1필지의 전부에 관하여 소유권이전 등기를 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 매수하지 않은 부분에 관하여 명의신탁이 이루어진 것으로 본다.

3. 부동산실명법의 시행

부동산실명법 제1조 【목적】

이 법은 부동산에 관한 소유권과 그 밖의 물권을 실체적 권리관계와 일치하도록 실권리자 명의(名義)로 등기하게 함으로써 부동산등기제도를 악용한 투기·탈세·탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하고 부동산 거래의 정상화와 부동산 가격의 안정을 도모하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(약칭: 부동산실명법)은 원칙적으로 명의신탁을 금지시키고 이를 무효로 하면서도, 이를 제3자에게는 대항할 수 없다고 하여 여전히 제3자는 선의·악의를 불문하고 보호한다(제4조 제3항).

제2관 명의신탁의 적용범위

1. 명의신탁약정의 존재

명의신탁약정이라 함은 부동산에 관한 물권(소유권 기타의 물권)을 보유한 자 또는 사실상 취득하거나 취득하려고 하는 자(실권리자)가 타인과의 사이에서 대내적으로는 실권리자가 부동산에 관한 물권을 보유하거나 보유하기로 하고 그에 관한 등기(가등기를 포함)는 그 타인의 명의로 하기로 하는 약정을 말한다.

2. 명의신탁약정에서 제외되는 경우(부동산실명법 제2조 제1호)

동산실명법 제2조 【정의】

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

① "명의신탁약정"(名義信託約定)이란 부동산에 관한 소유권이나 그 밖의 물권(이하 "부동산에 관한 물권"이라 한다)을 보유한 자 또는 사실상 취득하거나 취득하려고 하는 자[이하 "실권리자"(實權利者)라 한다]가 타인과의 사이에서 대내적으로는 실권리자가 부동산에 관한 물권을 보유하거나 보유하기로 하고 그에 관한 등기(가등기를 포함한다. 이하 같다)는 그 타인의 명의로 하기로 하는 약정[위임·위탁매매의 형식에 의하거나 추인(追認)에 의한 경우를 포함한다]을 말한다. 다만, 다음 각 목의 경우는 제외한다.

- ㉠ 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 물권을 이전(移轉)받거나 가등기하는 경우
- ㉡ 부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 공유로 등기하는 경우
- ㉢ 「신탁법」 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁재산인 사실을 등기한 경우

② "명의신탁자"(名義信託者)란 명의신탁약정에 따라 자신의 부동산에 관한 물권을 타인의 명의로 등기하게 하는 실권리자를 말한다.

③ "명의수탁자"(名義受託者)란 명의신탁약정에 따라 실권리자의 부동산에 관한 물권을 자신의 명의로 등기하는 자를 말한다.

④ "실명등기"(實名登記)란 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행 전에 명의신탁약정에 따라 명의수탁자의 명의로 등기된 부동산에 관한 물권을 법률 제4944호 부동산실권리자명의등기에관한법률 시행일 이후 명의신탁자의 명의로 등기하는 것을 말한다.

- ① 신탁법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁재산인 사실을 등기한 경우

② 가등기담보설정계약 또는 양도담보설정계약

채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 물권을 이전받거나 가등기하는 경우는 명의신탁약정이 아니다.

③ 상호명의신탁(구분명의신탁)

부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 공유로 등기하는 경우를 말하며, 이러한 경우에는 내부적으로는 구분소유, 외부적으로는 공유가 된다.

3. 종중·배우자에 대한 특례

부동산실명법 제8조 【종중, 배우자 및 종교단체에 대한 특례】

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 조세 포탈, 강제집행의 면탈(免脫) 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우에는 제4조부터 제7조까지 및 제12조제1항부터 제3항까지를 적용하지 아니한다.

- ① 종중(宗中)이 보유한 부동산에 관한 물권을 종중(종중과 그 대표자를 같이 표시하여 등기한 경우를 포함한다) 외의 자의 명의로 등기한 경우
- ② 배우자 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우
- ③ 종교단체의 명의로 그 산하 조직이 보유한 부동산에 관한 물권을 등기한 경우

조세포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 종중 명의신탁(종중과 그 대표자를 같이 표시하여 등기한 경우를 포함) 및 배우자 명의신탁, 그리고 종교단체 명의신탁에 대하여는 부동산실명법 제4조를 포함한 일부 규정을 적용하지 않는다(부동산실명법 제8조).

제3관 명의신탁의 유효성

부동산실명법 제4조 【명의신탁약정의 효력】

- ① 명의신탁약정은 무효로 한다.
- ② 명의신탁약정에 따른 등기로 이루어진 부동산에 관한 물권변동은 무효로 한다. 다만, 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약에서 명의수탁자가 어느 한쪽 당사자가 되고 상대방 당사자는 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항 및 제2항의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다.

① 약정의 무효

명의신탁약정은 무효이다(부동산실명법 제4조 제1항).

② 물권변동의 무효

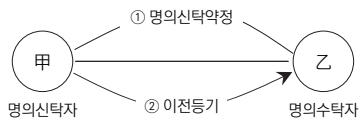
명의신탁약정에 따라 행하여진 등기에 의한 부동산에 관한 물권변동은 무효가 된다. 다만 부동산에 관한 물권을 취득하기 위한 계약에서 명의수탁자가 그 한쪽 당사자가 되고 상대방 당사자는 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 명의신탁약정은 무효이나, 부동산물권변동의 효력은 유효하다(부동산실명법 제4조 제2항).

③ 제3자의 보호

명의신탁약정의 무효 및 그에 따른 물권변동의 무효는 제3자에게 대항하지 못한다(부동산실명법 제4조 제3항). 따라서 명의수탁자로부터 부동산을 전득한 제3자는 선의·악의를 불문하고 명의신탁부동산의 소유권을 취득한다.

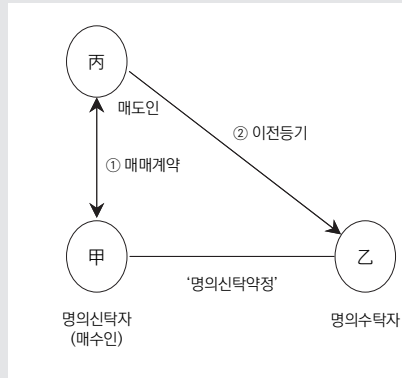
✓ 명의신탁의 3가지 유형

(1) 양자(兩者)간 명의신탁



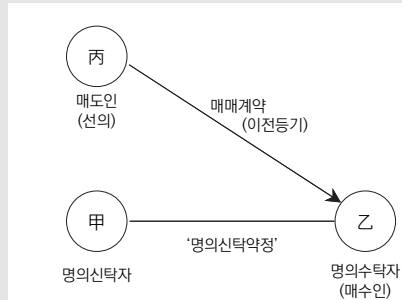
- ① 甲과 乙의 명의신탁약정과 이전등기는 무효이다.
- ② 신탁자가 소유권자이므로 수탁자명의의 이전등기는 원인무효로서 말소되어야 한다.
- ③ 명의신탁약정의 유효를 전제로 한 甲의 乙에 대한 해지권 행사 및 그로 인한 소유권이전등기신청은 등기의 각하사유에 해당한다.

(2) 3자간 명의신탁(중간생략등기형 명의신탁)



- ① 명의신탁약정과 등기는 모두 무효이므로 명의 신탁된 부동산은 매도인 소유로 복귀된다. 따라서 丙은 乙에 대하여 말소등기를 청구하거나, 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 丙과 甲의 매매계약은 유효하므로 甲은 丙에 대하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 甲은 丙을 대위하여 乙에게 등기의 말소를 청구할 수 있다.

(3) 계약명의신탁



- ① 매도인 丙이 선의인 경우에는 甲과 乙사이의 명의신탁약정은 무효이지만 丙의 보호를 위해 乙명의의 이전등기는 유효하다.
- ② 乙은 丙 및 甲에 대한 관계에서도 유효하게 소유권을 취득한다는 것이 판례의 태도이다.
- ③ 다만 甲은 乙에 대해 매매대금상당의 부당이득 반환청구권을 행사할 수 있다.

중요판례

대법원 2013.1.24. 2011다99498

부동산신탁법 제8조 제2호에 따라 부부간 명의신탁이 일단 유효한 것으로 인정되었다면 그 후 배우자 일방의 사망으로 부부관계가 해소되었다 하더라도 그 명의신탁약정은 사망한 배우자의 다른 상속인과의 관계에서도 여전히 유효하게 존속한다고 보아야 한다.

대법원 1992.9.8. 92다18184

중증재산이 여러 사람에게 명의신탁된 경우 그 수탁인들 상호간에는 형식상 공유관계가 성립한다.

대법원 2022.4.28. 2019다300422

명의신탁약정이 3자간 등기명의신탁인지 아니면 계약명의신탁인지의 구별은 계약당사자가

누구인가를 확정하는 문제로 귀결되는데, 계약명의자가 명의수탁자로 되어 있다 하더라도 계약당사자를 명의신탁자로 볼 수 있다면 이는 3자간 등기명의신탁이 된다. 따라서 계약 명의자인 명의수탁자가 아니라 명의신탁자에게 계약에 따른 법률효과를 직접 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면 명의신탁자가 계약당사자이고, 이 경우의 명의신탁 관계는 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다.

대법원 2021.9.9. 2018다284233 전원합의체

3자 간 등기명의신탁에서 명의수탁자가 제3자에게 부동산을 매도하거나 부동산에 근저당권을 설정하는 등으로 처분행위를 하여 제3자가 부동산에 관한 권리를 취득하는 경우, 명의신탁자가 명의수탁자를 상대로 직접 부당이득반환을 청구할 수 있다.

대법원 1989.04.25. 88다카7184

토지 중 일부를 특정하여 매수하고 다만 그 소유권이전등기만을 편의상 토지 전체에 관하여 공유지분이전등기로 한 경우 그 특정부분 이외의 부분에 관한 등기는 상호 명의신탁관계에 있다.

☞ 상호명의신탁은 '부동산실명법'상의 규제받는 명의신탁에 해당되지 않는다.

대법원 2005.11.10. 2005다34667,34674

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조 제3항에서 "제3자"라고 함은 명의신탁 약정의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 명의수탁자가 물권자임을 기초로 그와의 사이에 직접 새로운 이해관계를 맺은 사람을 말한다.

대법원 2008.05.15. 2007다74690

명의신탁자와 명의수탁자가 이른바 계약명의신탁약정을 맺고 명의수탁자가 당사자가 되어 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못하는 소유자와의 사이에 부동산에 관한 매매계약을 체결한 후 그 매매계약에 따라 당해 부동산의 소유권이전등기를 수탁자 명의로 마친 경우에는 명의신탁자와 명의수탁자 사이의 명의신탁약정의 무효에도 불구하고 그 명의수탁자는 당해 부동산의 완전한 소유권을 취득하게 되고, 다만 명의수탁자는 명의신탁자에 대하여 부당이득반환의무를 부담하게 될 뿐이라 할 것인데, 그 계약명의신탁약정이 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률 시행 후인 경우에는 명의신탁자는 애초부터 당해 부동산의 소유권을 취득할 수 없었으므로 위 명의신탁약정의 무효로 인하여 명의신탁자가 입은 손해는 당해 부동산 자체가 아니라 명의수탁자에게 제공한 매수자금이라 할 것이고, 따라서 명의수탁자는 당해 부동산 자체가 아니라 명의신탁자로부터 제공받은 매수자금을 부당이득하였다고 할 것이다.

대법원 2019.6.20. 2013다218156 전원합의체

부동산실명법을 위반하여 무효인 명의신탁약정에 따라 명의수탁자 명의로 등기를 하였다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 단정할 수는 없다. 이는 농지법에 따른 제한을 회피하고자 명의신탁을 한 경우에도 마찬가지이다.

대법원 2022. 3. 31. 2021다215589, 215596

구분소유적 공유자가 그 권리를 타인에게 처분하는 경우에는 구분소유의 목적인 특정 부분을 처분하면서 등기부상 공유지분을 그 특정 부분에 대한 표상으로서 이전하는 경우와 등기부의 기재대로 1필지 전체에 대한 진정한 공유지분을 처분하는 경우가 있을 수 있다. 전자의 경우에는 구분소유적 공유관계가 승계되나, 후자의 경우에는 그 매수인이 부동산 전체에 대한 공유지분을 취득하고, 구분소유적 공유관계는 소멸된다.



4장 용익물권

제1절 지상권

1. 의의 및 성질

(1) 의의

제279조 【지상권의 내용】

지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리가 있다.

건물 기타의 공작물(도로·교량·광고탑·전주·지하철·터널 등)이나 수목을 소유하기 위하여 타인의 토지를 사용할 수 있는 용익물권을 말한다.

(2) 성질

- ① 타인의 토지를 사용하는 물권으로서 지표나 지상에 한하지 않고, 지하의 사용을 내용으로 할 수 있다. 지상권의 객체인 토지는 1필의 토지의 일부 위에도 설정될 수 있다.
- ② 건물 기타의 공작물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 권리이다.
- ③ 지상권은 물권으로서 양도성과 상속성이 있다.
- ④ 지료의 지급은 지상권성립의 요소가 아니다. 따라서 무상(無償)의 지상권도 설정이 가능하다.
- ⑤ 직접 토지를 지배하는 권리이다.

중요판례

대법원 2013.09.12. 2013다43345

지료액 또는 그 지급시기 등 지료에 관한 약정은 이를 등기하여야만 제3자에게 대항할 수 있는 것이므로, 지료의 등기를 하지 아니한 이상 토지소유자는 구 지상권자의 지료연체 사실을 들어 지상권을 이전받은 자에게 대항하지 못한다.

대법원 2006.06.15. 2006다6126

지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물 소유권만을 양도할 수도 있고 지상물 소유권을 유보한 채 지상권만을 양도할 수도 있는 것이어서 지상권자와 그 지상물의 소유권자가 반드시 일치하여야 하는 것은 아니며, 또한 지상권설정시에 그 지상권이 미치는 토지의 범위와 그 설정 당시 매매되는 지상물의 범위를 다르게 하는 것도 가능하다.

대법원 1991.03.12. 90다카27570

토지를 매수하여 그 명의로 소유권이전청구권보전을 위한 가등기를 경료하고 그 토지상에 타인이 건물 등을 축조하여 점유 사용하는 것을 방지하기 위하여 지상권을 설정하였다면 이는 위 가등기에 기한 본등기가 이루어질 경우 그 부동산의 실질적인 이용가치를 유지 확보할 목적으로 전소유자에 의한 이용을 제한하기 위한 것이라고 봄이 상당하다고 할 것이고 그 가등기에 기한 본등기청구권이 시효의 완성으로 소멸하였다면 그 가등기와 함께 경료된 위 지상권 또한 그 목적을 잃어 소멸되었다고 봄이 상당하다.

2. 지상권과 임차권의 비교

타인의 토지를 사용하기 위한 방법으로는 지상권의 설정 이외에 토지의 임대차(제618조 이하)에 의하는 방법이 있다. 그러나 물권인 지상권이 임차권에 비하여 그 효력이 강하기 때문에 경제적 강자인 토지소유자는 자기에게 불리한 지상권의 설정을 꺼리는 결과 실제에 있어서는 지상권은 거의 이용되지 않고 있는 실정이다.

(1) 권리의 성질

지상권은 물권이고, 임차권은 채권이다.

(2) 대항력

지상권은 등기하여야 효력이 생기며, 제3자에게도 대항력이 있으므로 토지소유자에게 불리하나, 토지임차권은 등기하여야 대항력이 생기고 반대약정이 없으면 임대인은 등기협력의무가 있으나(제621조 제1항) 지상권자보다 임차인의 지위는 불리하다.

(3) 투하자본의 회수

지상권은 양도·임대할 수 있고(제282조), 지상권 위에 저당권도 설정할 수 있으나(제371조) 임차권은 임대인의 동의 없이 양도·전대하지 못한다(제629조).

(4) 존속기간

- ① 지상권은 최단기간의 제한이 있으나, 최장기간의 제한이 없다. 임차권은 20년의 최장기간의 규정이 있으나(제651조) 위헌결정이 있었고(2013.12.26. 2011헌바234), 최단기간의 제한은 민법은 그 제한을 두지 않고 특별법에 제한이 있다.
- ② 존속기간을 정하지 않은 경우에 지상권은 토지의 사용목적에 따라서 30년·15년·5년으로 하는데(제281조), 임차권은 언제나 해지통고가 가능하다.
- ③ 존속기간의 법정갱신에 관하여는, 지상권은 규정한 바 없으나 임차권은 이를 규정하고 있다(제639조).

(5) 대가관계

- ① 지상권은 지료가 그 요소가 아니나(제279조), 차임은 임대차의 요소이다(제618조).
- ② 지상권의 경우에는 지상권자가 2년 이상 지료지급을 지체한 때에 한하여 그 소멸청구를 할 수 있으나(제287조), 임차권의 경우에는 연체액이 2기의 차임액에 달하면 해지가 가능하다(제640조·제641조).

(6) 물권적 청구권

지상권이 침해되면 물권적 청구권이 생기고, 임차권의 침해에는 점유권에 기한 배제청구권이 생기며, 임차물의 인도를 받기 전에는 임대인의 물권적 청구권을 대위 행사할 수 있다.

3. 지상권의 취득

(1) 법률행위에 의한 취득

- ① 지상권은 원칙적으로 당사자 간의 계약(물권적 합의)과 등기를 함으로써 취득된다. 즉, 지상권은 토지소유자와 지상권을 설정하여 그 토지를 이용하고자 하는 자와의 설정계약과 등기를 함으로써 취득되는 것이 원칙이다.
- ② 지상권은 유언 또는 지상권의 양도에 의한 취득도 있을 수 있다.

(2) 법률의 규정에 의한 취득

상속·판결·경매·공용징수 등에 의하여 지상권은 취득될 수 있다. 즉, 이 경우는 법률의 규정에 의한 지상권의 취득으로 등기를 요하지 아니한다(필요하지 않다).(제187조)

(3) 법정지상권에 의한 취득

305조 【건물의 전세권과 법정지상권】

- ① 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.
- ② 전항의 경우에 대지소유자는 타인에게 그 대지를 임대하거나 이를 목적으로 한 지상권 또는 전세권을 설정하지 못한다.

제366조 【법정지상권】

저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.

1) 서설

- ① 의의 : 지상권은 설정계약으로 취득되는 것이 원칙이다. 그러나 처음에는 토지와 그 지상건물이 동일소유자에게 속하였으나, 그 후에 토지와 건물이 소유자를 달리하게 되면 건물소유자를 위하여 법률상 당연히 지상권이 설정된 것으로 보는데 이를 법정지상권이라 한다.
- ② 인정이유 : 민법은 토지와 건물을 각각 별개의 부동산으로 취급하여 독립하여 처분할 수 있도록 하였다. 그런데 토지 및 건물이 동일한 소유자에 속하는 경우에는 문제가 없고, 당사자의 의사에 의하여 어느 하나가 양도되는 경우에도 당사자가 스스로 이용권을 설정함으로써 현실화할 수 있다. 그러나 당사자 간에 이러한 이용권을 설정할 기회가 없이 소유자를 달리하게 될 경우, 법률이 토지이용관계를 조절하여 주어서 위의 잠재적 관계를 현실화하여 줄 필요가 있다. 이와 같은 우리 법제의 특수성 때문에 건물소유자에게 토지에 대한 이용권을 인정하여 주려는 것이 법정지상권제도이다.
- ③ 법적 성질 : 이와 같이 법정지상권은 건물소유자의 이용권을 보호함으로써 토지소유권을 제한하는 것이므로, 용익권과 소유권과의 조화의 관점에서 본 제도를 생각하여야 할 것이며, 따라서 민법 제305조, 제366조는 공익상의 이유로 지상권의 설정을 강제하는 강행법규이며, 법률의 규정에 의한 부동산물권의 취득이므로 등기 없이도 효력을 발생한다.

2) 제366조의 법정지상권

① 의의 : 저당물의 경매로 인하여 토지와 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에 발생하는 법정지상권이다.

② 성립요건

㉠ 저당권설정 당시에 토지 위에 건물이 있었을 것 : 설정 후에 건물을 축조한 경우도 포함된다는 견해가 있지만, 후에 건물을 축조하여 법정지상권의 제한을 받게 된다면 그 토지의 교환가치가 크게 감소되어 저당권자에게 손해를 줄 우려가 있고, 따라서 토지의 담보가치는 그 후의 건물을 위한 법정지상권의 부담이 있다는 전제하에 평가되게 되어 그 가치가 부당하게 저하되므로 이를 인정하지 않음이 통설·판례이다. 그러나 설정 당시에 존재하였던 건물이 멸실되어 재축·개축하는 경우는 상관없다.

㉡ 저당권설정 당시에 토지와 건물이 동일한 소유자에 속할 것

㉢ 각각 다른 소유자에 속하였더라면 이미 건물을 위한 이용권이 성립하였을 것이기 때문이다.

㉣ 그러나 설정 당시에는 동일인에 속하였다가 그 후에 토지와 건물이 각각 소유자를 달리하게 되어도 무방하다.

㉤ 경락의 결과 토지와 건물의 소유자가 달라질 것 : 이러한 결과가 생기는 한 토지와 건물이 함께 저당권의 목적이 되었든, 어느 일방만이 목적이 되었든 무방하다.

③ 내용 : 법정지상권도 지상권이므로 그 내용도 일반지상권의 경우와 다르지 않다.

㉠ 법정지상권의 발생시기 : 경매에 의하여 그 소유권이 경락인에게 이전하는 때 (즉, 매각대금지급시) 성립한다.

㉡ 권리의 범위 : 건물의 대지에 한정되는 것은 아니며 그 건물이용에 적당한 범위에 미친다.

㉢ 지료와 존속기간 : 지료는 당사자의 협의에 의하여 정하고, 그렇지 못한 경우에는 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다(제366조 단서). 존속기간은 그 약정이 없는 지상권으로 보아 제281조에 따라 결정한다.

㉣ 등기 : 등기를 요하지 않으나, 다만 등기 없이는 이를 처분할 수 없다. 법정 지상권 발생 당시의 토지소유자에 변동이 있어 그 토지를 특별승계한 자에 대하여도 등기 없이 지상권을 주장할 수 있다.

3) 제305조의 법정지상권

- ① 의의 : 대지와 건물이 동일소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정하였고 그 대지소유권만이 양도되었을 때에 그 전세권설정자가 양수인에 대하여 취득하는 법정지상권을 말한다.
- ② 성립요건
 - ㉠ 건물에 전세권을 설정할 당시 토지와 건물이 동일소유자에 속할 것
 - ㉡ 토지소유권이 타인에게 이전되거나 또는 건물이 경매됨으로써 건물과 토지의 소유자가 달라질 것. 대지소유자가 그 대지를 처분한 것이라면 대지 양수인과의 사이에 이용권에 관한 합의가 있었을 것이므로, 제305조는 그러한 조치를 취하지 않은 경우를 위한 규정이다.
- ③ 내용 : 법정지상권을 취득하는 자는 건물소유자이고 전세권자가 아니다(왜냐하면 지상권은 지상물을 소유하기 위한 권리이기 때문이다). 법정지상권의 취득에 등기를 요하지 않음은 제366조와 같다. 지료·존속기간·강행규정성은 제366조의 경우와 다를 바 없다.

(4) 기타

1) 관습법상의 법정지상권

- ① 의의 : 동일인에 속하는 토지와 건물을 임의로 타인에게 매각하거나 그 외의 원인으로(증여 등) 양자의 소유자가 다르게 되었을 때는, 특히 그 건물을 철거한다는 합의가 없는 한 그 건물의 소유자는 그 토지 위에 소위 관습법상의 법정지상권을 취득하게 된다.
- ② 내용 : 제366조에 의하면 매매·증여 등에 의하여 토지와 건물의 소유권이 달라졌을 때에는 법정지상권의 보호를 받지 못하는 입법적 결함을 해결하기 위하여 생긴 것으로서 성립요건에 경매 이외의 원인(매매·증여 등)을 포함하는 것 외에는 그 내용에 있어서 제366조와 다를 바 없다.

2) 입목에 관한 법률에 의한 법정지상권

입목에 관한 법률 제6조 【법정지상권】

- ① 입목의 경매 기타 사유로 인하여 토지와 그 입목이 각각 다른 소유자에게 속하게 되는 경우에는 토지소유자는 입목소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ② 전항의 경우에 지료에 관하여는 당사자의 약정에 따른다.

- ① 의의 : 토지에 부착된 수목의 집단으로서 그 소유자가 '입목에 관한 법률'에 의하여 소유권보존등기를 받은 것을 입목이라 하며, 이 입목은 독립의 부동산으로 취급되므로, 토지와 분리하여 양도하거나 저당권의 목적으로 할 수 있다. 그러므로 민법상의 건물과 토지와의 관계에서 나타날 수 있는 법률관계가 이 경우에도 생기며, 동법은 제6조에서 입목의 경매 기타 사유로 인하여 토지와 그 입목이 각각 다른 소유자에게 속하게 되는 경우에 법정지상권을 인정하고 있다.
- ② 내용 : 제366조와 다른 점은 경매뿐만 아니라 기타의 사유를 그 원인으로 들고 있으므로, 매매·증여 등도 이에 포함되고 있다고 해석된다. 이 점은 관습법상의 법정지상권과 같다. 그 외의 성립요건과 내용은 민법상의 법정지상권과 다를 바 없으나, 다만 지료에 관하여는 당사자의 약정에 따른다고 하여 민법 제366조 단서와는 약간 다르게 규정하고 있다.

3) 가등기담보에 관한 법률에 의한 법정지상권

가등기담보 등에 관한 법률 제10조 【법정지상권】

토지와 그 위의 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우 그 토지나 건물에 대하여 제4조 제2항에 따른 소유권을 취득하거나 담보가등기에 따른 본등기가 행하여진 경우에는 그 건물의 소유를 목적으로 그 토지 위에 지상권이 설정된 것으로 본다. 이 경우 그 존속기간과 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다.

동법 제10조에서는 '토지 및 그 지상의 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우에 그 토지 또는 건물에 대하여 제4조 제2항의 규정에 의한 소유권을 취득하거나 담보가등기에 기한 본등기가 행하여진 경우에는 그 건물의 소유를 목적으로 그 토지 위에 지상권이 설정된 것으로 본다. 이 경우 존속기간 및 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다'라고 규정하고 있다. 이는 민법 제366조의 특별규정을 의미한다.

법률행위로 인한 취득	① 지상권설정의 물권적 합의와 등기에 의한 취득 ② 지상권의 양도에 의한 취득
법률의 규정에 의한 취득	① 상속·판결·경매·공용징수·취득시효 등에 의한 취득 ② 법정지상권에 의한 취득 ③ 대지와 건물이 동일소유자에게 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다(제305조).

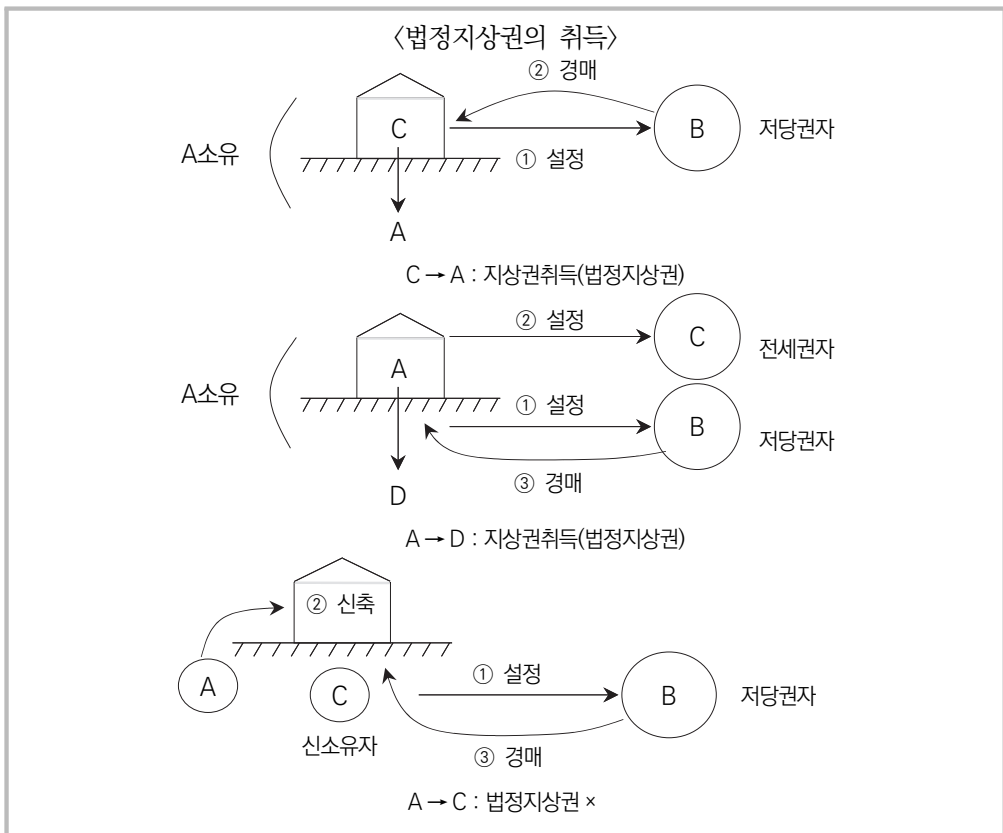
㉔ 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다(제366조).

(성립요건)

- ㉕ 저당권설정 당시에 건물이 존재할 것
- ㉖ 저당권설정 당시 토지와 건물이 동일소유자에게 속할 것
- ㉗ 경매의 결과로 입목소유자와 토지소유자가 다르게 된 경우 입목소유자는 법정지상권을 취득한 것으로 본다(입목법 제6조).
- ㉘ 토지와 건물이 동일소유자에게 속하는 경우, 그 토지 또는 건물에만 가등기담보·양도담보 등이 설정되고 이들의 실행으로 토지와 건물의 소유자가 다르게 된 때 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.

※ 법정지상권의 취득은 등기를 요하지 않으나 제3자에게 처분하기 위해서는 등기를 하여야 한다.

※ 법정지상권에 관한 규정은 강행규정이므로 당사자의 특약으로 그 성립을 막지 못한다.



대법원 1988.10.25. 87다카1564

민법 제366조는 가치권과 이용권의 조절을 위한 공익상의 이유로 지상권의 설정을 강제하는 것이므로, 저당권설정의 당사자 간의 특약으로 저당목적물인 토지에 대하여 법정지상권을 배제하는 약정을 하더라도 그 특약은 효력이 없다.

대법원 1990. 07.10. 90다카6399

민법 제366조 소정의 법정지상권이 성립하려면 저당권의 설정 당시, 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재한 이상, 그 이후 건물을 개축증축하는 경우에도 법정지상권이 성립한다.

대법원 1985. 04. 09. 84다카1131·1132

법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 법정지상권까지 양도받기로 한 자는, 채권자대위의 법리에 따라 전건물소유자 및 대지 소유자에 대하여 차례로 지상권의 설정등기 및 이전등기의 절차이행을 구할 수 있다.

대법원 2004.06.11. 2004다13533

민법 제366조의 법정지상권은 저당권 설정 당시 동일인의 소유에 속하던 토지와 건물이 경매로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에 건물의 소유자를 위하여 발생하는 것으로서, 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 토지 소유자에 의하여 그 지상에 건물을 건축 중이었던 경우 그것이 사회관념상 독립된 건물로 볼 수 있는 정도에 이르지 않았다 하더라도 건물의 규모·종류가 외형상 예상할 수 있는 정도까지 건축이 진전되어 있었고, 그 후 경매절차에서 매수인이 매각대금을 다 낸 때까지 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지는 등 독립된 부동산으로서 건물의 요건을 갖추면 법정지상권이 성립하며, 그 건물이 미등기라 하더라도 법정지상권의 성립에는 아무런 지장이 없는 것이다.

대법원 2002.06.20. 2002다9660 전원합의체

[1] 민법 제366조의 법정지상권은 저당권설정 당시에 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물이 저당권의 실행에 의한 경매로 인하여 각기 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물의 소유를 위하여 인정되는 것이므로, 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전받지 못하고 있다가, 대지에 대하여 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에는, 그 저당권의 설정 당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다.

[2] 관습상의 법정지상권은 동일인의 소유이던 토지와 그 지상건물이 매매 기타 원인으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었으나 그 건물을 철거한다는 등의 특약이 없으면 건물소유자로 하여금 토지를 계속 사용하게 하려는 것이 당사자의 의사라고 보아 인정되는 것이므로 토지의 점유-사용에 관하여 당사자 사이에 약정이 있는 것으로 볼 수 있거나 토지소유자가 건물의 처분권까지 함께 취득한 경우에는 관습상의 법정지상권을 인정할 까닭이 없다할 것이어서, 미등기건물을 그 대지와 함께 매도하였다면 비록 매수인에게 그 대지에 관하여만 소유권이전등기가 경료되고 건물에 관하여는 등기가 경료되지 아니하여 형식적으로 대지와 건물이 그 소유명의자를 달리하게 되었다 하더라도 매도인에게 관습상의 법정지상권을 인정할 이유가 없다.

대법원 1997.12.26. 96다34665

법정지상권자라 할지라도 대지 소유자에게 지료를 지급할 의무는 있는 것이고, 법정지상권이 있는 건물의 양수인으로서 장차 법정지상권을 취득할 지위에 있어 대지소유자의 건물 철거나 대지인도청구를 거부할 수 있다 하더라도 그 대지를 점유사용함으로써 인하여 얻은 이익은 부당이익으로서 대지소유자에게 반환할 의무가 있다.

대법원 1979.08.28. 79다1087

건물 소유를 위하여 법정지상권을 취득한 자로부터 경매에 의하여 그 건물의 소유권을 이전 받은 경락인은 위 지상권도 당연히 이전받았다 할 것이고 이는 그에 대한 등기가 없어도 그 후에 담보토지를 전득한 자에 대하여 유효하다.

대법원 2014. 9. 4. 2011다73038,73045

동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 지상 건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에, 신축건물의 소유자가 토지의 소유자와 동일하고 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해주는 등 특별한 사정이 없는 한, 저당물의 경매로 인하여 토지와 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다. 이는 건물이 철거된 후 신축된 건물에 토지와 동순위의 공동저당권이 설정되지 아니하였는데도 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 해석하게 되면, 공동저당권자가 법정지상권이 성립하는 신축건물의 교환가치를 취득할 수 없게 되는 결과 법정지상권의 가액 상당 가치를 되찾을 길이 막혀 당초 토지에 관하여 아무런 제한이 없는 나대지로서의 교환가치 전체를 실현시킬 수 있다고 기대하고 담보를 취득한 공동저당권자에게 불측의 손해를 입게 하기 때문으로서, 이러한 법리는 집합건물의 전부 또는 일부 전유부분과 대지 지분에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상 집합건물이 철거되고 새로운 집합건물이 신축된 경우에도 마찬가지로 보아야 한다.

대법원 1999.11.23. 99다52602

토지에 저당권을 설정할 당시 토지의 지상에 건물이 존재하고 있었고 그 양자가 동일 소유자에게 속하였다가 그 후 저당권의 실행으로 토지가 낙찰되기 전에 건물이 제3자에게 양도된 경우, 건물을 양수한 제3자는 건물을 철거하여야 하는 손해를 입게 되는 점 등에 비추어 위와 같은 경우 건물을 양수한 제3자는 민법 제366조 소정의 법정지상권을 취득한다.

대법원 2001.12.27. 2000다1976

민법 제366조 소정의 법정지상권은 토지와 그 토지상의 건물이 같은 사람의 소유에 속하였다가 그 중의 하나가 경매 등으로 인하여 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 그 건물의 유지, 존립을 위하여 특별히 인정된 권리이기는 하지만 그렇다고 하여 위 법정지상권이 건물의 소유에 부속되는 종속적인 권리가 되는 것이 아니며 하나의 독립된 법률상의 물건으로서의 성격을 지니고 있는 것이기 때문에 건물의 소유자가 건물과 법정지상권 중 어느 하나만을 처분하는 것도 가능하다.

4. 지상권의 존속기간

(1) 약정에 의한 존속기간

최단기간	① 다음 연한보다 단축하지 못한다. • 석조, 석회조, 연와조 기타 견고한 건물이나 수목의 소유 : 30년 • 기타의 건물(목조 등) : 15년 • 건물 이외의 공작물의 소유 : 5년 ② 이상의 기간보다 짧은 약정기간은 위의 최단기간으로 연장된다.
최장기간	명문규정이 없으며, 영구무한의 지상권설정여부에 대해서는 학설의 대립이 있으나 인정설이 판례의 태도이고 부정설이 다수설이다.

(2) 약정이 없는 경우의 존속기간

- ① 지상물의 종류와 구조에 따라 제280조의 최단존속기간을 그 기간으로 한다.
- ② 지상권설정 당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 않은 경우에는 15년으로 한다.

(3) 계약의 갱신과 존속기간

1) 갱신계약

존속기간이 만료되면 당사자는 그 기간을 갱신할 수 있다. 이 때에 갱신기간은 제280조의 최단기간보다 단기로 약정하지는 못한다(제284조).

2) 갱신청구권

지상권이 존속기간의 만료로 소멸한 경우에 건물 기타의 공작물이나 수목이 현존하는 경우 지상권자는 계약의 갱신을 청구할 수 있다(제283조 제1항).

3) 지상물매수청구권(형성권)

지상권자의 갱신청구가 있을 때 지상권설정자는 이를 거절할 수 있다. 그러나 이 경우 지상권자는 상당한(적절한) 가액으로 지상물을 매수할 것을 청구할 수 있다(제283조 제1항). 여기서 상당한(적절한) 가액이란 사회거래상 인정될 수 있는 가액을 말하며, 이 규정은 지상권자의 보호를 위한 강행규정이다.

4) 강행규정

지상권자에게 불리한 것은 효력이 없다. 즉, 편면적 강행규정이다.

5. 지상권의 효력

(1) 토지사용권과 상린관계

지상권자는 설정행위로 정하여진 목적의 범위 안에서 토지를 사용할 수 있다. 그러나 토지의 영구적 손해를 가져오는 변경은 할 수 없다. 상린관계에 관한 규정은 지상권자와 이웃 토지의 이용자 사이에 준용된다(제290조).

(2) 물권적 청구권

지상권의 내용의 실현이 방해된 경우에는 반환청구권·방해제거청구권·방해예방청구권을 행사할 수 있다.

(3) 지상권의 처분(투자자본의 회수)

- ① 지상권자는 지상권을 양도할 수 있고 또한 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다(제282조). 이 규정은 강행규정으로서 이를 금지하는 특약은 무효이다.
- ② 지상권은 저당권의 목적이 된다(제371조).

(4) 지료증감청구권(사정변경의 원칙)

지료액이 결정된 후 토지에 관한 조세 기타의 부담의 증감이나 지가의 변동으로 종래의 지료액이 불합리한 것으로 되는 때에는 당사자는 서로 그 증감을 청구할 수 있다(제286조). 이 권리는 형성권이므로 토지소유자가 증액청구를 하거나 또는 지상권자가 감액청구를 하면 곧 지료는 증액 또는 감액되고, 지상권자는 그 증액된 지료를 지급할 의무를 부담하게 된다. 그러나 이러한 증감청구에 대하여 상대방이 다투는 경우에는 결국 법원이 결정하게 될 것이나, 이때에 법원이 결정해 주는 지료의 증감은 그 증감 청구를 한 때에 소급하여 효력이 생긴다.

(5) 지료체납의 효과

제287조 【지상권소멸청구권】

지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.

제288조 【지상권소멸청구와 저당권자에 대한 통지】

지상권이 저당권의 목적인 때 또는 그 토지에 있는 건물, 수목이 저당권의 목적이 된 때에는 전조의 청구는 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과함으로써 그 효력이 생긴다.

지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 않은 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다(제287조).

(6) 강행규정성

지료증감청구권과 지료체납의 효과를 규정한 제286조와 제287조는 강행규정이므로 지상권자에게 불리한 약정은 무효이다(제289조).

6. 지상권의 소멸

(1) 소멸사유

1) 지상권 일반의 소멸사유

지상권은 물권일반의 소멸, 즉 토지의 멸실·존속기간의 만료·혼동·소멸시효·경매 등에 의하여 소멸한다.

2) 지상권 특유의 소멸사유

- ① 지상권소멸청구권 : 정기의 지료를 지급하여야 하는 지상권자가 2년 이상의 지료를 체납한 경우에 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다(제287조). 이 소멸청구권은 형성권이라고 보는 것이 통설이다. 다만, 지상권이 저당권의 목적인 때 또는 그 토지에 있는 건물·수목이 저당권의 목적이 된 때에는 저당권자에게 이를 통지한 후 상당한 기간이 경과해야만 소멸하는 제한이 있다(제288조). 그리고 지상권소멸청구에 의한 지상권의 소멸은 법률행위로 인한 물권변동으로서 말소 등기를 요한다.
- ② 지상권의 포기 : 지상권은 지상권자가 단독으로 포기할 수 있다. 이 때 말소등기를 해야 소멸된다. 다만, 지상권 자체가 저당권의 목적으로 되어 있는 경우는 저당권자의 동의 없이 포기할 수 없다(제371조 제2항).
- ③ 약정소멸사유 : 지상권자와 지상권설정자간에 약정으로 소멸사유를 정할 수 있다. 그러나 강행규정으로 되어 있는 경우 지상권자에게 불리한 약정은 무효이다. 즉, 지료를 3년간 체납한 때 소멸청구할 수 있다는 식의 약정은 유효하나, 1년만 체납한 경우에도 소멸청구를 할 수 있다는 약정은 무효이다.

〈지상권의 소멸사유〉

물권 일반의 소멸사유	• 토지의 멸실 • 존속기간의 만료 • 소멸시효 • 혼 동 • 지상권에 우선하는 저당권의 실행으로 인한 경매 • 토지수용
지상권의 특유한 소멸사유	• 지상권설정자의 소멸청구(제287조) • 지상권의 포기(제156조 제2항·제371조 제2항 참조) • 약정소멸사유의 발생

(2) 지상권소멸의 통지

지상권이 저당권의 목적으로 되어 있는 경우 또는 그 토지 위에 있는 건물이나 수목이 저당권의 목적으로 되어 있는 경우에는 설정자의 지상권소멸청구는 저당권자에게 그것을 통지한 후 상당한 기간이 경과함으로써 비로소 그 효력이 생긴다(제288조).

(3) 소멸의 효과

1) 지상물수거권과 지상물매수청구권(형성권)

지상권이 소멸하면 지상권자는 건물 기타의 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상에 회복하여야 한다. 이 때에 토지소유자가 상당한 가액을 제공하여 공작물이나 수목의 매수를 청구하는 때에는 지상권자는 정당한 이유 없이 이를 거절하지 못한다(제285조).

2) 유익비상환청구권

지상권자에게 필요비상환청구권은 인정되지 않으나 유익비상환청구권은 인정된다고 보는 것이 통설의 입장이다. 지상권자에게 필요비상환청구권을 인정하지 않는 이유는 임대인은 임차권의 사용·수익에 필요한 상태유지의 의무가 있으나, 지상권설정자에게는 이러한 의무가 없다. 따라서 지상권자가 토지에 투입한 필요비를 상환해 줄 의무는 없다. 그러나 유익비를 지출한 경우에는 그만큼 토지의 가치가 증가되었다고 볼 것이다. 따라서 이것을 설정자에게 그대로 취득시킨다면 부당이득이 된다. 그래서 유익비의 상환청구는 인정해야 한다는 것이다. 이 때 지상권자는 지상권소멸 시에 토지소유자의 선택에 좇아 지출금액이나 현존하는 증가액을 상환하게 할 수 있고, 법원은 토지소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다(제626조 제2항).

〈편면적 강행규정〉

- ① 지상권의 존속기간(제280조)
- ② 지상권의 양도, 임대를 정한 규정(제282조)
- ③ 계약갱신청구권(제283조)
- ④ 지상물매수청구권(제283조)
- ⑤ 지료증감청구권(제286조)
- ⑥ 지상권소멸청구권(제287조)

중요판례

대법원 1972. 07. 25. 72다653

매수청구권은 형성권으로서 그 형성권 행사에 의하여 그 매수의 효력이 즉시 발생하며 그 가격은 매수청구권 행사 당시의 시가상당액이다.

대법원 1972. 12. 26. 72다2085

지상권자가 2년간 지료를 지급하지 아니하여 지상권소멸청구를 당한 경우에는 지상물에 대한 매수청구권을 행사하지 못한다.

7. 특수지상권

(1) 분묘기지권

1) 의의

타인의 토지에 분묘를 설치한 때에는 그 분묘기지에 대하여 지상권에 유사한 일종의 물권을 취득한다.

2) 성립요건과 지료의 지급

- ① 소유자의 승낙을 얻어 그의 소유지 안에 분묘를 설치한 때 취득한다. 이 경우 지료는 약정에 의하되 약정이 없으면 무상이다.
- ② 타인 토지에 승낙 없이 분묘를 설치한 경우에는 20년간 평온·공연하게 그 분묘기지를 점유함으로써 분묘기지권을 시효로 취득한다. 이 경우 지료는 유상이다 (2021.4.29 대법원 판례변경).
- ③ 자기 소유의 토지에 분묘를 설치한 자가 후에 그 분묘기지에 대한 소유권을 유보하거나 그 분묘를 이장한다는 특약 없이 토지를 매매 등으로 처분한 때에는 그 분묘를 소유하기 위한 분묘기지권을 취득한다. 이 경우 지료는 유상이다.

3) 문제점

- ① 분묘기지권은 등기가 없이도 성립하고 대항할 수 있게 되므로, 분묘가 설치되어 있는 토지를 취득하게 되는 자가 뜻밖의 피해를 입을 염려가 있다.
- ② 분묘기지권의 취득에는 등기를 요하지 않으며, 제187조 단서의 규정도 적용의 여지가 없다. 그리고 평장·암장·가묘의 경우에는 분묘기지권이 인정되지 아니한다.

4) 분묘기지권의 존속기간

존속기간의 약정이 있는 경우에는 약정기간에 의하고 약정이 없는 경우에는 분묘의 수호와 봉사를 계속하고 있는 한 그 분묘가 존속하고 있는 동안 존속한다.

중요판례

대법원 2017.1.19. 2013다17292 전원합의체

- [1] 분묘기지권을 둘러싼 전체적인 법질서 체계에 중대한 변화가 생겨 분묘기지권의 시효 취득에 관한 종래의 관습법이 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 부합하지 아니하거나 정당성과 합리성을 인정할 수 없게 되었다고 보기도 어렵다.

- [2] 화장물 증가 등과 같이 전통적인 장사방법이나 장묘문화에 대한 사회 구성원들의 의식에 일부 변화가 생겼더라도 여전히 우리 사회에 분묘기지권의 기초가 된 매장문화가 자리 잡고 있고 사설묘지의 설치가 허용되고 있으며, 분묘기지권에 관한 관습에 대하여 사회 구성원들의 법적 구속력에 대한 확신이 소멸하였다거나 그러한 관행이 본질적으로 변경되었다고 인정할 수 없다.
- [3] 타인 소유의 토지에 분묘를 설치한 경우에 20년간 평온, 공연하게 분묘의 기지를 점유 하면 지상권과 유사한 관습상의 물권인 분묘기지권을 시효로 취득한다는 점은 오랜 세월 동안 지속되어 온 관습 또는 관행으로서 법적 규범으로 승인되어 왔고, 이러한 법적 규범이 장사 등에 관한 법률(장사법, 법률 제6158호) 시행일인 2001. 1. 13. 이전에 설치된 분묘에 관하여 현재까지 유지되고 있다고 보아야 한다.

대법원 1996.06.14. 96다14036

타인 소유의 토지에 소유자의 승낙 없이 분묘를 설치한 경우에는 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유하면 지상권 유사의 관습상의 물권인 분묘기지권을 시효로 취득하는데, 이러한 분묘기지권은 봉분 등 외부에서 분묘의 존재를 인식할 수 있는 형태를 갖추고 있는 경우에 한하여 인정되고, 평장되어 있거나 암장되어 있어 객관적으로 인식할 수 있는 외형을 갖추고 있지 아니한 경우에는 인정되지 않으므로, 이러한 특성상 분묘기지권은 등기 없이 취득한다.

대법원 2011.11.10. 2011다63017

분묘기지권은 분묘를 수호하고 봉제사하는 목적을 달성하는 데 필요한 범위 내에서 타인의 토지를 사용할 수 있는 권리를 의미하는 것으로서, 분묘기지권은 분묘의 기지 자체 뿐만 아니라 분묘의 설치목적인 분묘의 수호 및 제사에 필요한 범위 내에서 분묘 기지 주위의 공지를 포함한 지역에까지 미치는 것이다.

대법원 2021.4.29. 2017다228007 전원합의체

타인의 토지에 분묘를 설치하여 20년간 평온·공연하게 분묘의 기지를 점유함으로써 분묘 기지권을 시효로 취득한 경우, 분묘기지권자는 토지소유자가 지료를 청구하면 그 청구한 날부터의 지료를 지급할 의무가 있다.

대법원 2015.7.23. 2015다206850

자기 소유의 토지 위에 분묘를 설치한 후 토지의 소유권이 경매 등으로 타인에게 이전되면서 분묘기지권을 취득한 자가, 판결에 따라 분묘기지권에 관한 지료의 액수가 정해졌음에도 책임 있는 사유로 판결확정 전후에 걸쳐 2년분 이상의 지료지급을 지체한 경우, 새로운 토지소유자는 분묘기지권의 소멸을 청구할 수 있다.

대법원 2013.01.16. 2011다38592

분묘기지권은, 당사자 사이에 그 존속기간에 관한 약정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한, 권리자가 분묘의 수호와 봉사를 계속하며 그 분묘가 존속하고 있는 동안 존속하는 것이고, 그 분묘를 다른 곳에 이장하면 그 분묘기지권은 소멸된다. 그리고 분묘기지권에는 그 효력이 미치는 지역의 범위 내라고 할지라도 기존의 분묘 외에 새로운 분묘를 신설할 권능은 포함되지 아니한다.

대법원 2007.06.28. 2005다44114

분묘기지권은 분묘를 수호하고 봉제사하는 목적을 달성하는 데 필요한 범위 내에서 타인의 토지를 사용할 수 있는 권리를 의미하는 것으로서, 이 분묘기지권에는 그 효력이 미치는 지역의 범위 내라고 할지라도 기존의 분묘 외에 새로운 분묘를 신설할 권능은 포함되지 아니하는 것이므로, 부부 중 일방이 먼저 사망하여 이미 그 분묘가 설치되고 그 분묘기지권이 미치는 범위 내에서 그 후에 사망한 다른 일방을 쌍분 또는 단분 형태로 합장하여 분묘를 설치하는 것도 허용되지 않는다.

대법원 2001.08.21. 2001다28367

토지소유자의 승낙을 얻어 분묘가 설치된 경우 분묘소유자는 분묘기지권을 취득하고, 분묘기지권의 존속기간에 관하여는 당사자 사이에 약정이 있는 등 특별한 사정이 있으면 그에 따를 것이나, 그러한 사정이 없는 경우에는 권리자가 분묘의 수호와 봉사를 계속하며 그 분묘가 존속하고 있는 동안 존속한다고 해석함이 타당하다. 또, 분묘가 멸실된 경우라고 하더라도 유골이 존재하여 분묘의 원상회복이 가능하여 일시적인 멸실에 불과하다면 분묘기지권은 소멸하지 않고 존속한다.

대법원 1969. 01.28. 68다1920

타인 소유의 토지 위에 그 소유자의 승낙 없이 분묘를 설치한 자가 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유한 때에는 그 점유자는 시효에 의하여 그 토지 위에 지상권 유사의 물권을 취득하고 이에 대한 소유권을 취득하는 것은 아니다.

(2) 관습법상의 법정지상권

1) 의의

동일인 소유의 토지와 건물 중의 어느 한쪽이 매매 기타의 원인으로 소유자를 달리하게 된 경우, 당사자 사이에 특약이 없는 한 건물소유자는 당연히 지상권을 취득한다.

2) 성립요건

- ① 토지와 건물의 소유자가 동일인일 것
- ② 토지와 건물 중 어느 한쪽이 매매·증여 등으로 소유자를 달리 할 것
- ③ 당사자 사이에 건물을 철거한다는 특약이 없을 것

3) 내용

민법의 지상권에 관한 규정은 관습법상의 법정지상권에 준용된다.

- ① 토지사용권의 범위에 대해서는 지상권에 관한 규정을 준용하며 그 건물의 사용에 필요한 범위에 효력이 미친다.
- ② 관습법상의 법정지상권은 기간을 정하지 않은 것으로 보아 민법의 최단존속기간에 관한 규정이 적용된다.
- ③ 지료는 약정에 의하고 약정이 없을 때에는 법원에서 정한다.

중요판례

대법원 1991.08.13. 91다16631

토지와 그 지상의 건물이 동일한 소유자에게 속하였다가 토지 또는 건물이 매매나 기타 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에는 그 건물을 철거하기로 하는 합의가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 건물소유자는 지상소유자에 대하여 그 건물을 위한 관습상의 지상권을 취득하게 되고, 그 건물은 반드시 등기가 되어 있어야만 하는 것이 아니고 무허가건물이라고 하여도 상관이 없다.

대법원 1988.09.27. 87다카279

- [1] 토지 또는 건물이 동일한 소유자에게 속하였다가 건물 또는 토지가 매매 기타의 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에 그 건물을 철거하기로 하는 합의가 있었다는 등 특별한 사정이 없는 한 건물소유자는 토지소유자에 대하여 그 건물을 위한 관습상의 지상권을 취득하게 되고 건물을 철거하기로 하는 합의가 있었다는 등의 특별한 사정의 존재에 관한 주장입증책임은 그러한 사정의 존재를 주장하는 쪽에 있다.
- [2] 관습법상의 법정지상권은 법률행위로 인한 물권의 취득이 아니므로 등기를 필요로 하지 않는다.
- [3] 법정지상권을 취득한 건물소유자가 법정지상권의 설정등기를 경료함이 없이 건물을 양도 하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 건물과 함께 지상권도 양도하기로 하는 채권적 계약이 있었다고 할 것이므로 법정지상권자는 지상권설정등기를 한 후에 건물양수인에게 이의 양도등기절차를 이행하여 줄 의무가 있는 것이고 따라서 건물양수인은 건물양도인을 순차대위하여 토지소유자에 대하여 건물소유자였던 최초의 법정지상권자에의 법정지상권 설정등기절차이행을 청구할 수 있다.

- [4] 법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 지상권까지 양도받기로 한 사람에 대하여 대지소유자가 소유권에 기하여 건물철거 및 대지의 인도를 구하는 것은 지상의 부담을 용인하고 그 설정등기절차를 이행할 의무있는 자가 그 권리자를 상대로 한 청구라 할 것이어서 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다.

대법원 2012.10.18. 2010다52140 전원합의체

- [1] 동일인의 소유에 속하고 있던 토지와 그 지상 건물이 강제경매 또는 국세징수법에 의한 공매 등으로 인하여 소유자가 다르게 된 경우에는 그 건물을 철거한다는 특약이 없는 한 건물소유자는 토지소유자에 대하여 그 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권을 취득한다. 원래 관습상 법정지상권이 성립하려면 토지와 그 지상 건물이 애초부터 원시적으로 동일인의 소유에 속하였을 필요는 없고, 그 소유권이 유효하게 변동될 당시에 동일인이 토지와 그 지상 건물을 소유하였던 것으로 족하다.
- [2] 강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권이 성립하는가 하는 문제에 있어서는 그 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 하여 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다.

대법원 1999. 12.10. 98다58467

- [1] 건물 철거의 합의가 관습상의 법정지상권 발생의 소극적 요건이 되는 이유는 그러한 합의가 없을 때라야 토지와 건물의 소유자가 달라진 후에도 건물소유자로 하여금 그 건물의 소유를 위하여 토지를 계속 사용하게 하려는 묵시적 합의가 있는 것으로 볼 수 있다는 데 있고, 한편 관습상의 법정지상권은 타인의 토지 위에 건물을 소유하는 것을 본질적 내용으로 하는 권리가 아니라, 건물의 소유를 위하여 타인의 토지를 사용하는 것을 본질적 내용으로 하는 권리여서, 위에서 말하는 ‘묵시적 합의’라는 당사자의 추정 의사는 건물의 소유를 위하여 ‘토지를 계속 사용한다’는 데 중점이 있는 의사라 할 것이므로, 건물 철거의 합의에 위와 같은 묵시적 합의를 깨뜨리는 효력, 즉 관습상의 법정 지상권의 발생을 배제하는 효력을 인정할 수 있기 위하여서는, 단지 형식적으로 건물을 철거한다는 내용만이 아니라 건물을 철거함으로써 토지의 계속 사용을 그만두고자 하는 당사자의 의사가 그 합의에 의하여 인정될 수 있어야 한다.
- [2] 토지와 건물의 소유자가 토지만을 타인에게 증여한 후 구 건물을 철거하되 그 지상에 자신의 이름으로 건물을 다시 신축하기로 합의한 경우, 그 건물 철거의 합의는 건물 소유자가 토지의 계속 사용을 그만두고자 하는 내용의 합의로 볼 수 없어 관습상의 법정 지상권의 발생을 배제하는 효력이 인정되지 않는다.

대법원 1995.07.28. 95다9075,9082

관습법상의 법정지상권이 성립된 토지에 대하여는 법정지상권자가 건물의 유지 및 사용에 필요한 범위를 벗어나지 않은 한 그 토지를 자유로이 사용할 수 있는 것이므로, 지상건물이 법정지상권이 성립한 이후에 증축되었다 하더라도 그 건물이 관습법상의 법정지상권이 성립하여 법정지상권자에게 점유·사용할 권한이 있는 토지 위에 있는 이상 이를 철거할 의무는 없다.

대법원 2002.06.20. 2002다9660 전원합의체

- [1] 민법 제366조의 법정지상권은 저당권설정 당시에 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물이 저당권의 실행에 의한 경매로 인하여 각기 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물의 소유를 위하여 인정되는 것이므로, 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전받지 못하고 있다가, 대지에 대하여 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에는, 그 저당권의 설정 당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다.
- [2] 관습상의 법정지상권은 동일인의 소유이던 토지와 그 지상건물이 매매 기타 원인으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었으나 그 건물을 철거한다는 등의 특약이 없으면 건물소유자로 하여금 토지를 계속 사용하게 하려는 것이 당사자의 의사라고 보아 인정되는 것이므로 토지의 점유·사용에 관하여 당사자 사이에 약정이 있는 것으로 볼 수 있거나 토지소유자가 건물의 처분권까지 함께 취득한 경우에는 관습상의 법정지상권을 인정할 까닭이 없다할 것이어서, 미등기건물을 그 대지와 함께 매도하였다면 비록 매수인에게 그 대지에 관하여만 소유권이전등기가 경료되고 건물에 관하여는 등기가 경료되지 아니하여 형식적으로 대지와 건물이 그 소유명의자를 달리하게 되었다 하더라도 매도인에게 관습상의 법정지상권을 인정할 이유가 없다.

대법원 1993.06.29. 93다10781

관습상의 법정지상권에 대하여는 다른 특별한 사정이 없는 한 민법의 지상권에 관한 규정을 준용하여야 할 것이므로 지상권자가 2년분 이상의 지료를 지급하지 아니하였다면 관습상의 법정지상권도 민법 제287조에 따른 지상권소멸청구의 의사표시에 의하여 소멸한다.

대법원 1993.04.13. 92다55756

토지공유자의 한 사람이 다른 공유자의 지분 과반수의 동의를 얻어 건물을 건축한 후 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우 토지에 관하여 관습법상의 법정지상권이 성립되는 것으로 보게 되면 이는 토지공유자의 1인으로 하여금 자신의 지분을 제외한 다른 공유자의 지분에 대하여서까지 지상권설정의 처분행위를 허용하는 셈이 되어 부당하다.

대법원 2022. 8. 31. 2018다218601

토지 및 그 지상 건물 모두가 각 공유에 속한 경우 토지 및 건물공유자 중 1인이 그 중 건물 지분만을 타에 증여하여 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우에도 해당 토지 전부에 관하여 건물의 소유를 위한 관습법상 법정지상권이 성립된 것으로 보게 된다면, 이는 토지공유자의 1인으로 하여금 다른 공유자의 의사에 기하지 아니한 채 자신의 지분을 제외한 다른 공유자의 지분에 대하여서까지 지상권설정의 처분행위를 허용하는 셈이 되어 부당하다.

대법원 1979.06.05. 79다572

동일인 소유였던 토지와 그 지상건물의 소유권이 분리되어 건물소유자가 관습상의 법정 지상권을 취득한 후 토지소유자와 간에 건물소유를 위한 임대차계약을 체결하고 임차권을 취득한 경우에는 관습법상의 법정지상권을 포기한 것으로 보아야 한다.

대법원 2014.09.04. 2011다13463

동일한 소유자에 속하는 대지와 그 지상건물이 매매에 의하여 각기 소유자가 달라지게 된 경우에는 특히 건물을 철거한다는 조건이 없는 한 건물소유자는 대지 위에 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득하는 것이고, 한편 건물 소유를 위하여 법정지상권을 취득한 자로부터 경매에 의하여 건물의 소유권을 이전받은 경락인은 경락 후 건물을 철거한다는 등의 매각조건하에서 경매되는 경우 등 특별한 사정이 없는 한 건물의 경락취득과 함께 위 지상권도 당연히 취득한다. 이러한 법리는 압류, 가압류나 체납처분압류 등 처분제한의 등기가 된 건물에 관하여 그에 저촉되는 소유권이전등기를 마친 사람이 건물의 소유자로서 관습상의 법정지상권을 취득한 후 경매 또는 공매절차에서 건물이 매각되는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

대법원 2001.05.08. 2001다4101

환지로 인하여 새로운 분할지적선이 그려진 결과 환지 전에는 동일인에게 속하였던 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라졌다 하더라도 환지의 성질상 건물의 부지에 관하여 소유권을 상실한 건물 소유자가 환지된 토지(건물부지)에 대하여 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득한다거나 그 환지된 토지의 소유자가 그 건물을 위한 관습상의 법정지상권의 부담을 안게 된다고는 할 수 없다.

(3) 구분지상권

제289조의2 【구분지상권】

- ① 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 이 경우 설정행위로써 지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 구분지상권은 제3자가 토지를 사용·수익할 권리를 가진 때에도 그 권리자 및 그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있으면 이를 설정할 수 있다. 이 경우 토지를 사용·수익할 권리를 가진 제3자는 그 지상권의 행사를 방해하여서는 아니 된다.

제290조 【준용규정】

- ① 제213조, 제214조, 제216조 내지 제244조의 규정은 지상권자간 또는 지상권자와 인지 소유자간에 이를 준용한다.
- ② 제280조 내지 제289조 및 제1항의 규정은 제289조의2의 규정에 의한 구분지상권에 관하여 이를 준용한다.

1) 의의

구분지상권이란 토지의 지상 또는 지하의 공간을 입체적으로 구분하여 건물 기타의 공작물 등을 소유할 것을 목적으로 설정하는 지상권을 말한다. 1984년의 민법개정으로 일반지상권 이외에 구분지상권이 신설되었다. 신설된 이유는 토지이용을 경제적으로 활용하자는 데 있다. 즉, 일반지상권은 토지소유권이 미치는 상하의 범위전체에 대한 권리이어서, 그것이 설정되면 비록 그것이 지표에 대한 평면적 이용을 주로 하는 것 일지라도 토지소유자의 토지이용은 전면적으로 배제되게 된다. 이것은 필요 이상으로 토지이용을 제한하게 되어 비경제적인 것이다. 그래서 토지의 상하 중 일정범위를 지정, 그 범위에만 지상권의 효력이 미치도록 하여 그 이외의 토지부분을 이용할 수 있도록 하자는 취지에서 구분지상권의 제도가 신설된 것이다.

2) 내용

- ① 지하 또는 지상의 공간을 입체적으로 구분하여 각각 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 따라서 토지소유자 또는 지상권자가 지표에 건물 기타 공작물 등을 소유하고 있더라도 다시 그 토지의 지하 또는 공중에 다른 사람이 구분지상권을 설정할 수 있다. 수목의 소유를 위한 구분지상권의 설정은 허용되지 않는다.

- ② 구분지상권도 부동산물권이므로 당사자 간의 설정행위와 등기를 갖추어야 한다.
- ③ 제3자가 사용·수익할 권리를 가진 어떤 토지에 구분지상권을 설정하려면 그 권리자 및 그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있어야 한다(제289조의2 제2항 전단). 이것은 이미 존재하고 있는 제3자의 권리, 예컨대 지상권·지역권·전세권·임차권 및 저당권 등을 보호하기 위함이다. 구분지상권의 목적 토지 위에 이미 사용·수익권을 가지고 있던 자가 구분지상권의 설정에 승낙한 후에는 그 지상권의 행사를 방해하여서는 아니 된다(제289조의2 제2항 후단).
- ④ 구분지상권의 존속기간·양도·임대·갱신청구권·매수청구권·수거의무·지료증감청구권·지상권소멸청구권 등에 관하여는 일반지상권의 규정을 준용한다(제290조 제2항).

3) 상린관계

구분지상권자와 토지소유자 등의 관계는 수직적으로 인접하고 있기 때문에 상린관계의 규정이 준용된다.

제2절 지역권

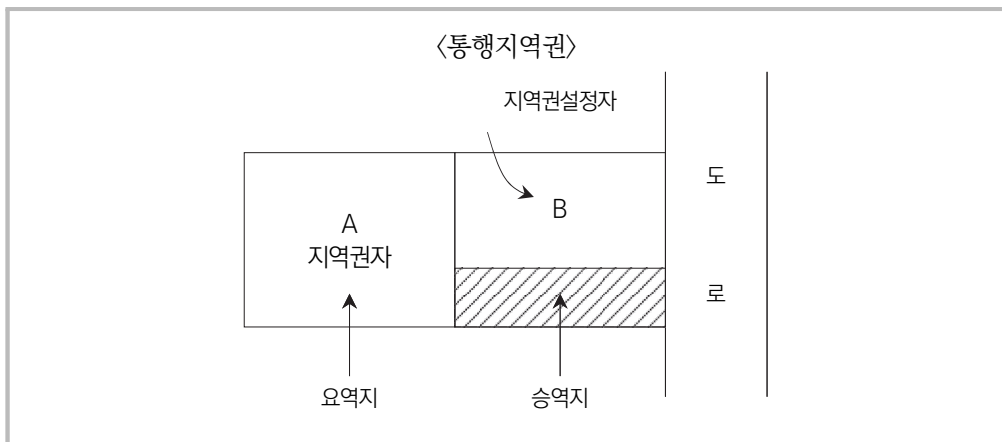
1. 지역권의 의의와 성질

(1) 의의

제291조 【지역권의 내용】

지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리가 있다.

설정행위로서 정한 일정한 목적(통행·인수·관망 등)을 위하여 타인의 토지를 자기의 토지의 편익에 이용하는 용익물권이다. 여기서 편익을 얻는 토지를 요역지라고 하며, 편익을 제공하는 토지를 승역지라고 한다. 자기의 토지의 편익을 위하여 타인의 토지를 통행하고 타인의 토지로부터 물을 끌어오거나, 또는 타인의 토지에 관망을 방해하는 공작물을 축조하지 못하게 하는 것 등은 그 예이다. 지역권에 의하여 승역지 소유권의 내용은 제한되고 일정한 이용행위를 하지 못하게 되며, 또는 타인의 일정한 침해행위를 인용하여야 한다.

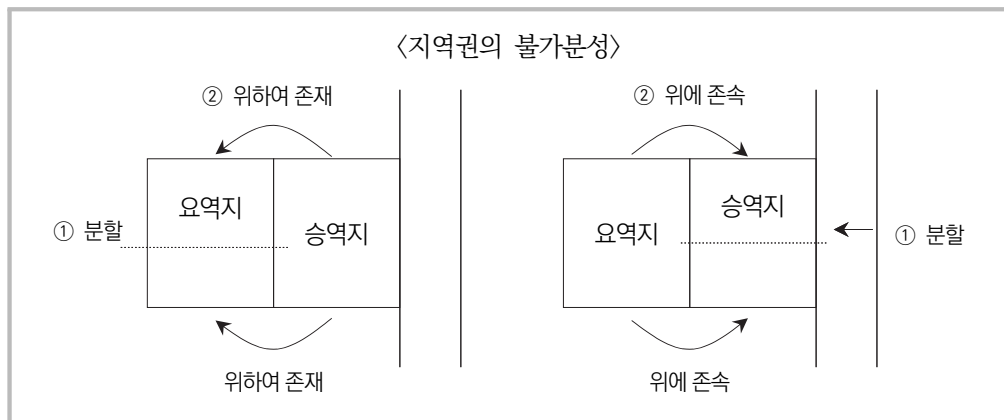


(2) 성질

- ① 편익을 받는 것은 토지이어야 하며 '편익에 이용한다'는 것은 요역지의 사용가치를 증가시킨다는 것을 뜻한다. 편익의 종류에는 제한이 없다.

- ② 지역권은 유상으로 하거나 무상으로 하거나 무방하다.
- ③ 지상권자·전세권자·임차인은 그들이 이용하는 토지의 편익을 위하여 그 권한 내에서 유효하게 지역권을 설정받을 수 있다.
- ④ 요역지는 1필의 토지이어야 하고 토지의 일부를 위하여 지역권을 설정할 수 없으나, 승역지는 토지의 일부라도 무방하다.
- ⑤ 요역지소유권의 처분은 지역권의 처분을 수반한다(부종성). 즉 요역지소유권이 이전되거나 또는 다른 권리의 목적으로 된 때에는 지역권도 그와 법률적 운명을 같이 한다. 그러나, 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 따른다(제292조).
- ⑥ 지역권은 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.
- ⑦ 계속되고 표현된 지역권에 한하여 시효취득의 대상이 된다(통로가 설치된 통행 지역권, 지상에 노출된 인수지역권).
- ⑧ 토지공유자의 1인은 자기의 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담하고 있는 지역권을 소멸하게 하지 못한다(제293조①).
- ⑨ 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다(제295조①).
- ⑩ 요역지를 공유하고 있는 경우에 공유자의 1인을 위한 소멸시효의 중단 또는 정지가 있는 경우에는 그 중단 또는 정지의 사유는 다른 공유자를 위해서도 효력이 있다(제296조).
- ⑪ 요역지가 분할된 경우 승역지는 요역지의 각 부분을 위하여, 승역지가 분할된 경우 지역권은 승역지 각 부분위에 존속한다.

* ⑧ ⑨ ⑩ ⑪은 지역권의 불가분성에 대한 설명이다.



2. 상린관계와 지역권의 비교

〈상린관계와 지역권의 비교〉

구분	상린관계	지역권
성질	소유권의 내재적 제한	독립한 용익물권
성립	법률의 규정	법률행위
동기	불필요	필요
관계	부동산이용자와 이용자 사이의 관계	두 개의 토지 사이의 관계
소멸시효	걸리지 않음	걸림
인접관계	반드시 인접을 요함	인접을 요하지 않음

3. 지역권의 존속기간

지역권의 존속기간은 당사자의 약정으로 자유로이 정할 수 있으며, 그것을 등기함으로써 제3자에게 대항할 수 있다. 그리고 지역권의 성질로 보아 영구무한의 지역권도 설정할 수 있다고 하는 것이 통설과 판례의 태도이다.

4. 지역권의 종류

작위 지역권	지역권자가 일정한 행위를 할 수 있고, 승역지 이용자가 이를 인용할 의무를 부담하는 지역권 통행지역권, 인수지역권
부작위 지역권	승역지이용자가 일정한 행위를 하지 않을 의무를 부담하는 지역권 관망지역권
계속 지역권	지역권의 행사가 끊임없이 계속되는 것 통로를 개설한 통행지역권
불계속 지역권	지역권을 행사할 때마다 지역권자의 행위를 필요로 하는 것 통로를 개설하지 않은 통행지역권
표현 지역권	지역권의 행사에 외부에서 인식할 수 있는 외형적 사실을 수반하는 것 통행지역권
불표현 지역권	외형적 사실을 수반하지 않는 것 관망지역권

5. 지역권의 취득

취득사유	• 설정계약과 등기에 의해 취득됨이 원칙이며, 양도·유언·상속 등에 의해서도 취득된다. • 양도는 요역지의 소유권 기타의 권리와 함께 하여야 한다.
취득시효	• 계속되고 표현된 지역권에 한하여 취득시효의 대상이 된다. • 등기하여야 효력이 생기며, 공유자의 1인이 지역권을 시효취득하면 모든 공유자를 위하여 시효취득의 효과가 발생한다.

6. 지역권의 효력

(1) 지역권자의 권능

지역권자는 설정행위의 내용 또는 취득시효의 요건이 되는 점유의 내용에 의하여 정하여진 범위 내에서 지역권을 행사하여 승역지를 사용할 수 있다. 그러나 지역권은 그 목적이 여러 개의 토지 사이의 이용을 조절하여 그 이용가치를 높이는 데 있으므로, 그것을 행사함에 있어서는 승역지의 이익을 존중하여 지역권의 목적을 달성하는 데 필요한 것이다. 따라서 승역지 이용자에게 가장 손해가 적은 범위에 그쳐야 한다. 이러한 취지에서 민법은 다음과 같은 규정을 두고 있다.

- ① 용수지역권의 승역지의 수량이 요역지 및 승역지의 수요에 부족한 때에는 그 수요 정도에 의하여 먼저 가용에 공급하고 남는 것을 다른 용도에 공급하여야 한다. 그러나 설정행위에 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다(제297조 제1항). 이 다른 약정은 등기하지 않으면 제3자에게 대항하지 못한다.
- ② 승역지의 소유자(이용권자 포함)는 지역권의 행사를 방해하지 않는 범위 내에서 지역권자가 지역권의 행사를 위하여 승역지에 설치한 공작물을 사용할 수 있다(제300조 제1항). 그러나 이 경우에는 승역지의 소유자는 수익정도의 비율로 공작물의 설치·보존의 비용을 분담하여야 한다(제300조 제2항).
- ③ 지역권은 물권이므로 먼저 성립한 지역권이 후에 성립하는 지역권보다 우선한다. 따라서 승역지에 수개의 용수지역권이 설정된 때에는 후순위의 지역권자는 선순위의 지역권자의 용수를 방해하지 못한다(제297조 제2항).

(2) 승역지 이용권자의 의무

- ① 승역지 이용권자는 승역지가 요역지의 편익에 이용되는 범위에서 인용·부작위 또는 작위의 의무를 진다. 따라서 계약에 의하여 승역지 소유자가 자기의 비용으로 지역권의 행사를 위하여 공작물의 설치 또는 수선의 의무를 부담한 때에는 승역지 소유자의 특별승계인도 그 의무를 부담한다(제298조).
- ② 승역지소유자는 지역권에 필요한 부분의 토지소유권을 지역권자에게 위기(委棄)하여 이 의무를 면할 수 있다(제299조). 이때의 위기는 토지소유권을 지역권자에게 이전한다는 일방적 의사표시이며, 위기에 의하여 소유권이 지역권자에게 이전하면 지역권은 혼동에 의하여 소멸한다(제191조 제1항).

(3) 지역권에 기인한 물권적 청구권

지역권은 일정한 목적에 따라 승역지에서 편익을 받는 권리이므로 편익을 받는 것이 방해되는 경우에는 방해배제 또는 방해예방의 물권적 청구권이 생긴다. 그러나 지역권은 승역지의 점유를 수반하는 권리가 아니므로 반환청구권은 인정되지 않는다.

7. 지역권의 소멸

물권 일반의 소멸사유	① 요역지 또는 승역지의 멸실 ② 지역권자의 지역권의 포기 ③ 혼동 ④ 존속기간의 만료 ⑤ 약정소멸사유의 발생 ⑥ 소멸시효
지역권 특유의 소멸원인	① 승역지소유자의 위기(委棄)(제298조·제299조) 위기란 토지소유권을 지역권자에게 이전한다는 일방적 의사표시로서 물권적 단독행위이다. 위기에 의하여 지역권은 혼동으로 소멸한다. ② 승역지의 시효취득 승역지의 점유자가 지역권의 존재를 승인하면서 점유를 계속한 때에는 지역권은 승역지의 시효취득에 의하여 소멸하지 않는다. ③ 승역지의 수용

대법원 1982.01.29. 79다1704

甲이 자기소유의 토지에 도로를 개설하여 乙로 하여금 영구히 사용하게 한다고 약정하고 그 대금을 수령한 경우 위의 약정은 지역권설정에 관한 합의라고 본다.

대법원 2015.03.20. 2012다17479

- [1] 지역권은 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기 토지의 편익에 이용하는 권리로써 계속되고 표현된 것에 한하여 취득시효에 관한 민법 제245조의 규정을 준용하도록 되어 있다. 따라서 통행지역권은 요역지의 소유자가 승역지 위에 도로를 설치하여 요역지의 편익을 위하여 승역지를 늘 사용하는 객관적 상태가 민법 제245조에 규정된 기간 계속된 경우에 한하여 그 시효취득을 인정할 수 있다.
- [2] 그리고 취득시효기간을 계산할 때에, 점유기간 중에 해당 부동산의 소유권자가 변동된 경우에는 취득시효를 주장하는 자가 임의로 기산점을 선택하거나 소급하여 20년 이상 점유한 사실만 내세워 시효완성을 주장할 수 없으며, 법원이 당사자의 주장에 구애됨이 없이 소송자료에 의하여 인정되는 바에 따라 진정한 점유의 개시시기를 인정하고, 그에 터 잡아 취득시효 주장의 당부를 판단하여야 한다. 한편 점유가 순차 승계된 경우에는 취득시효의 완성을 주장하는 자가 자기의 점유만을 주장하거나 또는 자기의 점유와 전 점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있는 선택권이 있다. 소유권의 취득시효에 관한 위와 같은 법리는 통행지역권의 취득시효에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

제3절 전세권

1. 전세권의 의의와 법률적 성질

(1) 의의

제303조 【전세권의 내용】

- ① 전세권자는 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하며, 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다.
- ② 농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다.

전세금을 지급하고 타인의 부동산을 그 용도에 좇아 사용·수익하는 용익물권임과 동시에 전세금의 우선변제를 받을 수 있는 담보물권성을 가진 권리이다. 즉, 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하며, 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금에 관한 우선변제권이 인정되는 특수한 용익물권이다(제303조 제1항). 말하자면, 그것은 타인의 부동산을 사용·수익한다는 용익물권이지만, 한편으로는 담보물권으로서의 특질도 아울러 가지고 있는 특수한 물권이다. 그러나 전세권의 주된 성격은 용익물권성에 있으며, 담보물권성은 전세금반환의 확보를 위한 부수적인 것이다.

(2) 법률적 성질

1) 타인의 토지 및 건물에 대한 권리이다.

- ① 1필의 토지 또는 1동의 건물의 일부분 위에도 설정이 가능하다. 다만 전세권의 목적이 부동산의 일부인 때에는 등기신청시에 도면을 첨부하여야 한다(등기법 제139조 제2항).
- ② 농경지는 전세권의 목적물이 되지 못한다(제303조 제2항).

2) 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.

- ① 증감청구권이 서로에게 인정되며, 증액청구는 연 20분의 1을 초과하지 못한다.

- ② 보증금(정지조건부 반환채무를 부담하는 금전 소유권이전)과 신용의 수수로서의 성질을 가진다.

3) 용익물권으로서의 전세권

- ① 설정계약과 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하는 물권이다.
- ② 소유권의 상린관계의 규정이 준용된다.
- ③ 전세권은 양도·임대·전전세·담보로 제공할 수 있다.

4) 담보물권성(경매권·우선변제권)을 가지는 권리이다.

- ① 전세권자에게 우선변제권과 경매청구권 그리고 투하자본의 회수를 위하여 전전세권이 인정된다.
- ② 전세권의 담보물권성에 의하여 담보물권의 통유성인 물상대위성·불가분성·부종성 등이 인정된다.

2. 전세권의 취득과 존속기간

(1) 전세권의 취득

전세권은 설정계약과 등기에 의하여 취득된다(제816조). 다른 물권의 성립과 다른 점은 전세금의 지급이 전세권의 요소를 이루므로, 당사자의 설정계약과 등기 이외에 약정된 전세금의 수수가 있을 때에 비로소 전세권은 성립한다는 점이다. 설정자가 목적부동산을 인도하는 것은 전세권의 성립요건이 아니다. 따라서 설정계약, 전세금의 수수, 등기만 있으면 아직 목적부동산의 인도가 없더라도 전세권은 유효하게 성립된다.

(2) 전세권의 존속기간

1) 존속기간을 약정한 경우

- ① 최장기간 : 전세권의 존속기간은 당사자가 설정행위에서 임의로 정할 수 있다. 그러나 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못하며, 당사자의 약정기간이 10년을 넘는 때에는 10년으로 단축된다.
- ② 최단기간 : 건물에 대한 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다(제312조 제2항). 이 최단기간은 건물전세권에만 적용되고 토지전세권에는 적용되지 않는다.

③ 존속기간의 갱신

- ㉠ 약정한 존속기간이 만료한 때에는 갱신할 수 있으나, 그 기간은 갱신한 날로부터 10년을 넘지 못한다.
- ㉡ 묵시의 갱신 : 건물의 전세권설정자가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월 까지 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 아니 하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 아니 한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다. 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정함이 없는 것으로 본다.

2) 존속기간의 약정이 없는 경우

당사자가 존속기간을 약정하지 않은 경우에는 각 당사자는 언제든지 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 통고가 도달한 날로부터 6개월이 지나면 전세권은 소멸한다(제313조). 이 때에도 말소등기를 하여야만 전세권은 소멸한다.

취득	① 설정계약 + 등기 + 전세금의 수수에 의하여 취득되며 목적부동산의 인도는 전세권 성립의 요소가 아니다. ② 시효취득에 의하여 취득할 수 있다(실제상으로는 가능성 희박).
존속기간	① 최장기간 : 10년을 넘지 못한다(갱신하여도 동일). ② 최단기간 : 건물에 대한 전세권의 존속기간은 1년 미만으로 하지 못한다. ③ 건물의 전세권에 있어서의 법정갱신 건물의 전세권설정자가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월까지의 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지나 또는 조건을 변경하지 않으면 갱신하지 않겠다는 뜻의 통지를 하지 않은 경우에는 존속기간이 만료된 때에 전전세권의 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다(이 때 존속기간은 정하지 않은 것으로 본다). ④ 존속기간은 등기하지 않으면 제3자에게 대항력이 없으며 존속기간을 정하지 않은 것으로 다루어진다. ⑤ 전세권자에게 '계약갱신청구권'은 인정되지 않는다. ⑥ 존속기간을 정하지 않은 경우에는 언제든지 소멸통고를 할 수 있고, 소멸통고가 상대방에게 도달된 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다.

3. 전세권의 효력

(1) 전세권자의 사용·수익권

1) 타인의 토지 위의 건물에 대한 전세권

타인의 토지 위에 있는 건물에 전세권을 설정한 경우에는, 그 건물의 사용·수익을 확보하기 위하여 전세권의 효력은 건물의 소유를 목적으로 한 지상권이나 임차권에도 미친다. 이를 위해 전세권설정자는 지상권이나 임차권을 전세권자의 동의없이 소멸시키지 못한다(제304조).

2) 설정자의 소멸청구권

전세권자가 설정계약 또는 그 부동산의 성질에 의해 결정되는 용법에 따라서 사용·수익하지 않은 경우에는, 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다. 이 경우 설정자는 그의 선택에 따라 전세권자에 대하여 원상회복 또는 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 수선유지의무

1) 전세권설정자

목적물의 사용·수익을 방해해서는 안될 인용의 의무가 있다(소극적 의무).

2) 전세권자

목적물의 현상을 유지하고 통상의 관리에 속한 수선을 해야 할 의무가 있다(필요비용 상환청구권은 전세권자에게는 인정되지 않음).

(3) 상린관계의 규정의 준용

인접하는 토지와와의 이용의 조절을 꾀하는 상린관계의 규정은 당연히 전세권자와 인접지 소유자, 전세권자와 인접지 전세권자 또는 지상권자 사이에도 준용된다(제319조).

(4) 물권적 청구권

전세금의 내용이 실현이 방해된 때에 전세권자는 물권적 청구권으로서 반환청구권·방해제거청구권·방해예방청구권을 행사할 수 있다(제319조).

(5) 전세금증감청구권

전세금이 목적부동산에 관한 조세·공과금 기타 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다(제312조의2). 다만, 증액의 경우는 약정한 전세금의 20분의 1을 초과하지 못하고, 또 전세권설정계약이 있는 날 또는 약정한 전세금의 증액이 있는 날로부터 1년 이내에는 이를 하지 못한다.

4. 전세권의 처분

전세권자는 전세권을 타인에게 양도하거나 담보로 제공할 수 있고, 또한 그 존속기간 내에서 그 목적물을 타인에게 전전세 또는 임대할 수 있다(제306조 전단). 전세권의 처분은 원칙적으로 자유이나 당사자가 설정행위로서 이를 금지할 수 있다(제306조 단서). 그러나 이 처분금지의 특약은 이를 등기하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

서설	전세권자는 전세권을 양도·임대·전전세·담보로 제공할 수 있다(제306조).
양도	양도의 합의와 등기를 함으로써 효력이 발생한다.
임대	금지특약이 없는 한 존속기간 내에 목적물을 임대할 수 있다.
담보제공	전세권은 저당권의 목적이 된다.
전전세	① 의의 전세권자의 전세권은 그대로 존속하면서 그 전세권을 목적으로 하는 전세권을 다시 설정하는 것을 말한다. ② 요건 ㉠ 설정자의 동의를 요하지 않으며 설정계약과 등기(부기등기)로서 성립한다. ㉡ 전전세금의 지급을 요하며, 원전세금의 한도를 초과할 수 없다(다수설). ㉢ 전전세권의 존속기간은 원전세권의 존속기간 내이어야 한다. ③ 효과 ㉠ 전전세권의 설정은 원전세권의 효력에 영향을 미치지 아니한다. ㉡ 원전세권이 소멸하면 전전세권도 따라서 소멸한다. ㉢ 전세권자는 전전세하지 않았더라면 면할 수 있었을 불가항력에 대한 손해에 대해서도 책임을 진다. ㉣ 전전세권자에게도 제한적이나마 경매권이 인정된다.

5. 전세권의 소멸

(1) 전세권의 소멸사유

전세권은 물권 일반의 소멸원인에 의해 소멸한다(■ 존속기간의 만료·혼동·소멸시효 등). 그 밖에 전세권에 특유한 소멸원인으로서 문제가 되는 것은 전세권설정자의 소멸청구·전세권의 소멸통고·목적부동산의 멸실·전세권의 포기가 있다.

1) 전세권설정자의 소멸청구

전세권자가 설정계약 또는 목적부동산의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용·수익하지 않은 경우에는 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다(제311조 제1항). 설정행위로서 전세권의 양도 등을 금지하였는데도 전세권자가 양도 등을 하거나(제306조 단서), 전세권자가 목적물의 유지·수선의무를 이행하지 않는 경우(제309조) 등이 이에 해당한다. 이 경우 전세권설정자는 전세권자에 대하여 원상회복 또는 손해배상을 청구할 수 있다(제311조 제2항). 이 소멸청구는 전세권의 소멸을 목적으로 하는 물권적 단독행위로서 그 등기를 하여야 효력이 생긴다(제186조).

2) 전세권의 소멸통고

전세권의 존속기간을 약정하지 않은 경우에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6개월이 경과하면 전세권은 소멸한다(제313조). 이 소멸통고도 물권적 단독행위로서 그 등기를 하여야 효력이 생긴다(제186조)

3) 목적부동산의 멸실

- ① 전부멸실의 경우 : 전세권의 목적물 전부가 멸실한 때에는 그 사유를 불문하고 전세권은 소멸한다(제314조 제1항). 다만, 그 멸실이 전세권자의 귀책사유로 생긴 때에는 전세권자는 손해배상책임을 지며(제315조 제1항), 이 때 전세권설정자는 전세금으로 이를 충당하고 나머지가 있으면 반환하여야 하나 부족이 있으면 그 부족액을 청구할 수 있다(제315조 제2항).
- ② 일부멸실의 경우 : 전세권의 목적물의 일부가 멸실한 때에는 그 사유가 무엇이든 그 멸실된 부분의 전세권은 소멸한다(제314조 제1항). 다만, 불가항력으로 인한 일부멸실의 경우에, 전세권자가 그 잔존부분으로 전세권의 목적을 달성할 수 없는

때에는 전세권설정자에 대하여 전세권 전부의 소멸을 통고하고 전세금의 반환을 청구할 수 있다(제314조 제2항). 이 때의 소멸통고에는 그 성질상 6개월의 기간은 요구되지 않는다고 할 것이다(통설). 전세권자의 귀책사유로 일부 멸실된 경우에 관해서는 민법은 규정하고 있지 않으나, 이 때에도 전세권 전부의 소멸을 통고할 수 있다고 봄이 타당하다. 다만, 이 때에는 전세권자는 그 일부멸실에 대해 손해 배상책임을 진다(제315조).

4) 전세권의 포기

전세권도 원칙적으로 자유로이 포기할 수 있다. 그러나 전세권이 제3자의 권리의 목적으로 되어 있는 경우에는, 그 제3자의 동의 없이는 포기할 수 없다(제371조 제2항 참조). 한편 전세권의 포기가 전세금의 포기도 포함하는 지는 당사자의 의사해석의 문제이다. 전세권의 포기는 물권적 단독행위이므로, 그 등기를 하여야 효력이 생긴다(제186조).

〈전세권의 소멸사유〉

물권일반의 소멸원인	• 목적물의 멸실 • 존속기간의 만료 • 혼동 • 소멸시효 • 전세권에 우선하는 저당권의 실행에 의한 경매 • 공용징수
전세권의 특유한 소멸원인	• 전세권설정자의 소멸청구(전세권자의 용법위반시에 행사) • 전세권의 소멸통고 - 존속기간을 약정하지 않은 경우 각 당사자가 상대방에게 행사한다. - 통고받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다. - 목적물의 일부멸실로 인한 소멸통고는 즉시 소멸한다. • 전세권의 포기(전세권이 제3자의 권리의 목적으로 된 경우에는 포기할 수 없음) • 기타 약정소멸사유의 발생

6. 전세권소멸의 효과

전세권이 소멸하면 전세권자는 전세권 설정자에게 목적물을 반환하여야 하며, 전세권 설정자는 전세권자에게 전세금을 반환하여야 하는데, 이에 관하여 민법은 다음과 같은 규정을 두고 있다.

동시이행항변권	목적물의 인도 및 전세권말소등기서류 교부와 전세금의 반환은 동시이행의 관계에 있다(제317조).
경매청구권	설정자가 전세금의 반환을 지체하는 경우 행사할 수 있다(제318조).
전세권자의 부속물매수청구권	설정자의 동의를 얻어 부속시킨 경우 또는 설정자로부터 매수한 부속물인 경우에 설정자에 대하여 부속물의 매수를 청구할 수 있다(일종의 형성권)(제316조 제2항).
유익비상환청구권	가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여 지출액 또는 증가액의 상환을 청구할 수 있다(제310조 제1항).
원상회복의무와 부속물수거권	전세권자는 목적물을 원상에 회복하여야 하고, 부속물을 수거할 수 있다(제316조 제1항).
전세권자의 손해배상책임	목적물의 전부 또는 일부가 전세권자의 귀책사유로 인하여 멸실된 때에는 전세권자는 손해를 배상할 책임이 있다(제315조 제1항).
전세권설정자의 부속물매수청구권	설정자도 전세권자에 대하여 부속물의 매수를 청구할 수 있다(일종의 형성권)(제316조 제1항 단서).

중요판례

대법원 2009.01.30. 2008다67217

전세권이 용익물권적 성격과 담보물권적 성격을 겸비하고 있다는 점 및 목적물의 인도는 전세권의 성립요건이 아닌 점 등에 비추어 볼 때, 당사자가 주로 채권담보의 목적으로 전세권을 설정하였고, 그 설정과 동시에 목적물을 인도하지 아니한 경우라 하더라도, 장차 전세권자가 목적물을 사용·수익하는 것을 완전히 배제하는 것이 아니라면, 그 전세권의 효력을 부인할 수는 없다 할 것이고, 한편 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다.

대법원 2004.04.28. 2003다61542

담보권의 수반성이란 피담보채권의 처분이 있으면 언제나 담보권도 함께 처분된다는 것이 아니라 채권담보라고 하는 담보권 제도의 존재 목적에 비추어 볼 때 특별한 사정이 없는 한 피담보채권의 처분에는 담보권의 처분도 당연히 포함된다고 보는 것이 합리적이라는 것일

뿐이므로, 피담보채권의 처분이 있음에도 불구하고, 담보권의 처분이 따르지 않는 특별한 사정이 있는 경우에는 채권양수인은 담보권이 없는 무담보의 채권을 양수한 것이 되고 채권의 처분에 따르지 않은 담보권은 소멸한다.

대법원 2006.05.11. 2006다6072

전세권이 성립한 후 전세목적물의 소유권이 이전된 경우 민법이 전세권 관계로부터 생기는 상환청구, 소멸청구, 갱신청구, 전세금증감청구, 원상회복, 매수청구 등의 법률관계의 당사자로 규정하고 있는 전세권설정자 또는 소유자는 모두 목적물의 소유권을 취득한 신 소유자로 새길 수밖에 없다고 할 것이므로, 전세권은 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신 소유자 사이에서 계속 동일한 내용으로 존속하게 된다고 보아야 할 것이고, 따라서 목적물의 신 소유자는 구 소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금 반환의무를 부담하게 된다.

대법원 2007.08.24. 2006다14684

토지와 건물을 함께 소유하던 토지·건물의 소유자가 건물에 대하여 전세권을 설정하여 주었는데 그 후 토지가 타인에게 경락되어 민법 제305조 제1항에 의한 법정지상권을 취득한 상태에서 다시 건물을 타인에게 양도한 경우, 그 건물을 양수하여 소유권을 취득한 자는 특별한 사정이 없는 한 법정지상권을 취득할 지위를 가지게 되고, 다른 한편으로는 전세권 관계도 이전받게 되는바, 민법 제304조 등에 비추어 건물 양수인이 토지 소유자와의 관계에서 전세권자의 동의 없이 법정지상권을 취득할 지위를 소멸시켰다고 하더라도, 그 건물 양수인은 물론 토지 소유자도 그 사유를 들어 전세권자에게 대항할 수 없다.

대법원 1977.04.13. 77마90

전세권자의 전세목적물 인도 의무 및 전세권설정등기 말소등기의무와 전세권설정자의 전세금반환의무는 서로 동시이행의 관계에 있으므로 전세권자인 채권자가 전세목적물에 대한 경매를 청구하려면 우선 전세권설정자에 대하여 전세목적물의 인도 의무 및 전세권설정등기 말소 의무의 이행제공을 완료하여 전세권설정자를 이행지체에 빠뜨려야 한다.

대법원 2002.02.05. 2001다62091

전세권설정자는 전세권이 소멸한 경우 전세권자로부터 그 목적물의 인도 및 전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부를 받는 동시에 전세금을 반환할 의무가 있을 뿐이므로, 전세권자가 그 목적물을 인도하였다고 하더라도 전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류를 교부하거나 그 이행의 제공을 하지 아니하는 이상, 전세권설정자는 전세금의 반환을 거부할 수 있고, 이 경우 다른 특별한 사정이 없는 한 그가 전세금에 대한 이자 상당액의 이득을 법률상 원인 없이 얻는다고 볼 수 없다.

대법원 2001.07.02. 2001마212 결정

건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 그 건물전부에 대하여 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세권의 우선변제를 받을 권리가 있고, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다.

대법원 2010.06.24. 2009다40790

주택임차인이 그 지위를 강화하고자 별도로 전세권설정등기를 마치더라도 주택임대차보호법상 임차인으로서 우선변제를 받을 수 있는 권리와 전세권자로서 우선변제를 받을 수 있는 권리는 근거규정 및 성립요건을 달리하는 별개의 권리라고 할 것인 점 등에 비추어 보면, 주택임대차보호법상 임차인으로서의 지위와 전세권자로서의 지위를 함께 가지고 있는 자가 그 중 임차인으로서의 지위에 기하여 경매법원에 배당요구를 하였다면 배당요구를 하지 아니한 전세권에 관하여는 배당요구가 있는 것으로 볼 수 없다.

대법원 2010.03.25. 2009다35743

전세권이 법정갱신된 경우 이는 법률의 규정에 의한 물권의 변동이므로 전세권갱신에 관한 등기를 필요로 하지 아니하고, 전세권자는 등기 없이도 전세권설정자나 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 갱신된 권리를 주장할 수 있다.

대법원 2008.03.13. 2006다29372

실제로는 전세권설정계약이 없으면서도 임대차계약에 기한 임차보증금 반환채권을 담보할 목적으로 임차인과 임대인 사이의 합의에 따라 임차인 명의로 전세권설정등기를 경료한 후 그 전세권에 대하여 근저당권이 설정된 경우, 그것이 통정허위표시에 해당하여 무효라 하더라도 이로써 위 전세권설정계약에 의하여 형성된 법률관계를 토대로 별개의 법률원인에 의하여 새로운 법률상 이해관계를 갖게 된 근저당권자에 대하여는 그와 같은 사정을 알고 있었던 경우에만 그 무효를 주장할 수 있다.

대법원 2005.03.25. 2003다35659

전세권설정등기를 마친 민법상의 전세권은 그 성질상 용익물권적 성격과 담보물권적 성격을 겸비한 것으로서, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권의 용익물권적 권능은 전세권설정 등기의 말소 없이도 당연히 소멸하고 단지 전세금반환채권을 담보하는 담보물권적 권능의 범위 내에서 전세금의 반환시까지 그 전세권설정등기의 효력이 존속하는 것이고, 이와 같이 존속기간의 경과로서 본래의 용익물권적 권능이 소멸하고 담보물권적 권능만 남은 전세권에 대해서도 그 피담보채권인 전세금반환채권과 함께 제3자에게 이를 양도할 수 있다.

대법원 2015.11.17. 2014다10694

전세권이 존속기간의 만료나 합의해지 등으로 종료하면 전세권의 용익물권적 권능은 소멸하고 단지 전세금반환채권을 담보하는 담보물권적 권능의 범위 내에서 전세금의 반환 시까지 전세권설정등기의 효력이 존속한다.

대법원 1999. 9. 17. 98다31301

- [1] 전세권이 기간만료로 종료된 경우 전세권은 전세권설정등기의 말소등기 없이도 당연히 소멸하고, 저당권의 목적물인 전세권이 소멸하면 저당권도 당연히 소멸하는 것이므로 전세권을 목적으로 한 저당권자는 전세권의 목적물인 부동산의 소유자에게 더 이상 저당권을 주장할 수 없다.
- [2] 전세권에 대하여 저당권이 설정된 경우 그 저당권의 목적물은 물권인 전세권 자체이지 전세금반환채권은 그 목적물이 아니고, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권은 소멸하므로 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 되고, 이러한 경우에는 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 압류 및 추심명령 또는 전부명령을 받거나 제3자가 전세금반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사하여 비로소 전세권설정자에 대해 전세금의 지급을 구할 수 있다.
- [3] 원래 전세권에 있어 전세권설정자가 부담하는 전세금반환의무는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전세권자에 대해 전세금을 지급함으로써 그 의무이행을 다할 뿐이라는 점에 비추어 볼 때, 전세권저당권이 설정된 경우에도 전세권이 기간만료로 소멸되면 전세권설정자는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전세권자에 대하여만 전세금반환의무를 부담한다고 보아야 한다.

대법원 2002.08.23. 2001다69122

전세권은 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 그 용도에 따라 사용·수익하는 권리로서 전세금의 지급이 없으면 전세권은 성립하지 아니하는 등으로 전세금은 전세권과 분리될 수 없는 요소일 뿐 아니라, 전세권에 있어서는 그 설정행위에서 금지하지 아니하는 한 전세권자는 전세권 자체를 처분하여 전세금으로 지출한 자본을 회수할 수 있도록 되어 있으므로 전세권이 존속하는 동안은 전세권을 존속시키기로 하면서 전세금반환채권만을 전세권과 분리하여 확정적으로 양도하는 것은 허용되지 않는 것이며, 다만 전세권 존속 중에는 장래에 그 전세권이 소멸하는 경우에 전세금 반환채권이 발생하는 것을 조건으로 그 장래의 조건부 채권을 양도할 수 있을 뿐이라 할 것이다.



5장 담보물권

제1절 총설

1. 담보물권의 의의

(1) 담보물권의 의의 및 종류

1) 의의

채무자의 일반재산은 모든 채권자가 평등하게 변제받을 수 있는 채권자평등의 원칙이 지배되므로 채권의 담보로서는 불충분하다. 이에 대비하여 자기채권의 실현을 확보하기 위하여 마련된 제도가 담보제도이다. 즉, 채권자의 일반 재산보다도 강력한 변제수단의 확보가 필요하게 되므로 채권담보제도가 나타나게 된 것이다.

2) 담보의 종류

- ① 인적 담보제도 : 보증채무·연대채무·불가분채무 등과 같이 채무자의 책임재산뿐 아니라 제3자의 책임재산도 추가하는 방법에 의한 담보제도를 말한다.
- ② 물적 담보제도 : 채무자 또는 제3자가 제공한 특정재산에 대한 담보제도로써 그 재산의 교환가치를 담보하는 것을 말한다. 따라서 채무자의 채무불이행시 담보물로부터 우선변제를 받는 것을 그 내용으로 한다. 통상적으로 모르는 사람 사이에서의 담보제도로써 유용한 제도라 할 수 있다. 물적 담보제도에는 제한물권설정의 법리에 의한 담보제도와 소유권이전의 법리에 의한 담보제도가 있다.

(2) 담보물권의 비교

담보물권 내용	유치권	질권	저당권
성립	일정한 요건이 성립하면 당연히 성립하는 법정담보물권	• 설정계약+인도(양도) • 약정담보물권	• 설정계약+등기 • 약정담보물권
목적물	동산·부동산·유가증권	동산·권리	부동산·권리

내용 \ 담보물권	유치권	질권	저당권
우선적 효력	없음(실질적 : 인정)	있음	있음
경매권	있음	있음	있음
유치적 효력	있음	있음	없음
수익적 효력	없음	없음	없음
간이변제충당권	법원의 허가를 얻어 행할 수 있음	유치권과 동일	없음
물상대위성	없음	있음	있음

2. 담보물권의 통유성

(1) 부종성

피담보채권이 존재해야만 담보물권도 존재하는 것을 말한다. 즉, 피담보채권이 성립하지 않거나 소멸한 때에는 담보물권도 성립하지 않거나 소멸한다. 유치권에서는 엄격히 요구되나 질권·저당권에는 다소 완화된다.

(2) 수반성

피담보채권이 이전되면 담보물권도 이전되고, 피담보채권 위에 부담이 생기면 담보물권도 역시 부담을 받는 것을 말한다. 부종성의 한 내용으로 파악하기도 한다.

(3) 불가분성

민법은 담보물권의 효력을 강하게 하기 위하여, 담보물권자는 피담보채권의 전부를 변제받을 때까지 목적물의 전부에 대하여 그 담보권을 행사할 수 있게 하고 있는 바, 이를 불가분성이라고 한다. 모든 담보물권에 다 적용된다. 민법은 유치권에 관하여 규정을 하고 질권·저당권에 준용을 하고 있다.

(4) 물상대위성

담보물권은 그 목적물이 멸실·훼손·공용징수로 인하여 담보물권설정자(목적물 소유자)가 받을 금전 기타 물건(보험금·배상금·보상금 등 교환가치를 대표하는 것)에 대하여도

행사할 수 있다. 즉, 담보물권이 그 대표물 위에 존속한다. 담보물권은 교환가치를 취득하는 것을 내용으로 하므로 인정한 것이다. 따라서 유치적 효력만 있는 유치권에는 물상대위성이 인정되지 않고 우선변제를 받을 수 있는 질권·저당권에만 인정된다.

〈통유성의 내용〉

통유성	내용
물상대위성	• 목적물의 멸실·훼손·공용징수에 의하여 채무자가 받게 될 보험금·손해배상금·보상금 위에 담보물권의 효력이 존속하는 성질을 말한다. • 유치권에는 인정되지 않는다. • 질물이나 저당물의 매각대금이나 차임 등은 담보물권의 추급력으로 인하여 물상대위의 객체가 되지 아니한다.
불가분성	• 담보물권자는 피담보채권의 전액을 변제받을 때까지 목적물 전부 위에 담보물권을 행사할 수 있다는 성질을 말한다. • 공동저당은 예외이다.
타물권	• 담보물권은 타인의 물건 위에 설정될 수 있다는 성질을 말한다. • 혼동의 예외로서 소유자저당의 현상을 보이는 경우는 있다.
부종성	• 피담보채권과 담보물권은 법률적 운명을 같이 한다는 성질을 말한다. • 근저당은 부종성이 특히 완화되고 있다.
수반성	피담보채권이 이전하면 담보물권도 당연히 이전된다는 성질을 말한다.

1. 유치권의 의의와 성질

(1) 의의

타인의 물건 또는 유가증권을 점유하는 자가 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치하여 우선변제를 간접적으로 강제하는 법정담보물권을 말한다.

(2) 법률적 성질

- ① 법정담보물권이다.
- ② 부종성·수반성·불가분성이 인정되나 추급력과 물상대위성은 부정된다.
- ③ 우선변제권은 법적으로 부정되나 실질적으로는 인정되는 것과 같다.
- ④ 별제권이 인정된다(채무자회생 및 파산에 관한 법률).

(3) 항변권과의 비교

- ① 동시이행의 항변권은 채권계약인 쌍무계약의 효력으로서 상대방의 청구에 대한 항변권을 내용으로 하지만, 유치권은 물권으로서 물건의 직접지배의 결과 그 인도가 거부되게 되는 것이다. 따라서 동시이행의 항변권은 계약의 상대방에 대해서만 행사할 수 있는 데 반하여, 유치권은 어느 누구에 대해서도 행사할 수 있다.
- ② 동시이행의 항변권과 유치권은 모두 공평의 원칙에 기인하는 것이다. 그렇지만 전자는 채권계약의 쌍무성에서 당사자의 일방만의 선이행의 강요를 피하는 것을 그 목적으로 하는 데 반하여, 후자는 유치권자의 채권담보를 그 목적으로 한다. 따라서 상당한 담보를 제공하여 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ③ 동시이행의 항변권에 의하여 거절할 수 있는 급부에는 제한이 없다. 그러나 유치권에 의하여 거절할 수 있는 급부는 물건 또는 유가증권의 인도에 한한다.
- ④ 동시이행의 항변권에 의하여 보호되는 채권은 동일한 쌍무계약에 의하여 발생한 것에 한하지만, 유치권에서의 채권은 그 발생 원인을 묻지 않으며, 계약관계 없이도 발생할 수 있다.

구분	유치권	동시이행의 항변권
성질	• 독립한 물건 • 절대적 대세권	• 쌍무계약의 효력(작용) • 상대적 대인권
대항력	있음	없음
목적	채권담보를 목적으로 함	일방당사자만이 선이행을 요구당함을 지지함이 목적
관계	대가적 관계가 없음	대가적 관계가 있음
타담보	타담보를 제공하고 소멸시킬 수 있음	타담보를 제공하고 소멸시킬 수 없음
경매권	있음	없음

※ 공평의 원리에 입각하여 인정된 것이며 양자는 서로 배척하지 않고 병존할 수 있다.

2. 유치권의 성립요건과 효력

제320조 【유치권의 내용】

- ① 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다.
- ② 전항의 규정은 그 점유가 불법행위로 인한 경우에 적용하지 아니한다.

제322조 【경매, 간이변제충당】

- ① 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.
- ② 정당한 이유 있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 유치권자는 미리 채무자에게 통지하여야 한다.

제323조 【과실수취권】

- ① 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다.
- ② 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그 잉여가 있으면 원본에 충당한다.

제324조 【유치권자의 선관의무】

- ② 유치권자는 채무자의 승낙 없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다.

제325조 【유치권자의 상환청구권】

- ① 유치권자가 유치물에 관하여 필요비를 지출한 때에는 소유자에게 그 상환을 청구할 수 있다.

- ② 유치권자가 유치물에 관하여 유익비를 지출한 때에는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출한 금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다.

성 립 요 건	① 유치권의 목적물은 부동산·동산·유가증권이다. ② 채권과 목적물과의 관련성이 있어야 한다. 그러나 채권과 '목적물의 점유'와의 관련성을 요하지는 않는다. 따라서 채권이 목적물에 관하여 발생한 경우라면 그 후 채권자가 그 목적물의 점유를 취득하더라도 유치권은 성립한다. ㉠ 물건의 수선비청구권 ㉡ 목적물에 지출한 비용상환청구권 ㉢ 목적물로부터 받은 손해배상청구권 ㉣ 서로 물건을 바꾸어 간 경우 ㉤ 매매계약이 취소된 경우 부당이득에 의한 대금반환청구권 ③ 채권이 변제기에 있어야 한다. 아울러 민법은 유익비의 상환청구권에 관하여 법원이 상당한 기간을 허여(許與)할 수 있도록 규정하고 있는데, 이 경우 채무자에게 기한이 허여되면 채권자의 유치권은 소멸한다. ④ 점유가 계속되어야 한다. ㉠ 직접, 간접점유를 불문한다. ㉡ 불법행위로 인한 점유가 아니어야 한다. 예컨대, 도인(盜人)이 그의 도품에 비용을 지출하여도 그 비용의 상환청구권에 관하여 유치권을 취득하지 못한다. ⑤ 유치권의 발생을 배제하는 특약이 없어야 한다. 즉, 유치권의 발생에 관한 민법의 규정은 임의규정이다(통설·판례).
효 력	유치권자의 권리 ① 목적물을 유치할 수 있다. 토지의 임차인이 비용상환청구권에 관하여 유치권을 행사하는 경우는 종전의 사용상태를 계속하는 것이 유치의 방법이라고 할 수밖에 없지만 그 동안의 이득은 부당이득으로 반환해야 할 것이다. ② 경매권을 행사할 수 있다. 경매의 경우에 매수인(경락인)은 유치물에 관한 채권을 변제해야만 유치물을 수취할 수 있으므로 실제로는 유치권자에게 우선변제권이 인정되는 것과 다름이 없다. ③ 간이변제충당권이 인정된다. 정당한 이유가 있을 때에는(목적물의 가치가 너무 적어 비용을 들여 경매에 붙이는 것이 불합리한 경우) 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다(제322조). ④ 과실수취권이 인정된다. 유치물의 과실을 수취하여 1차적으로 이자에 충당하고 2차적으로는 원본에 충당하여야 한다.

		⑤ 유치물의 사용권이 있다. 따라서 유치물의 보존범위 내에서의 사용은 채무자의 승낙을 요하지 아니한다. ⑥ 비용상환청구권이 인정된다. 따라서 필요비용상환청구권은 전액을, 유익비상환청구권은 지출금액 또는 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
	유치권자의 의무	① 선량한 관리자의 주의의무로 유치물을 보관하여야 한다. ② 채무자의 승낙 없는 유치물의 사용·대여·담보제공행위는 할 수 없다. 채무자와 소유자가 동일인이 아닐 때에는 소유자의 승낙이 있어야 한다. 이러한 의무에 위반하면 소유자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제324조 제3항).

3. 유치권의 소멸

- ① 유치권은 소멸시효에 걸리지 않으며 피담보채권이 소멸시효에 걸려 소멸하면 부종성에 의해 유치권도 소멸한다. 아울러 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효진행에 영향을 미치지 아니한다.
- ② 유치권자가 그의 의무에 위반한 경우 채무자의 소멸청구로 유치권은 소멸한다. 예컨대, 유치권자가 소유자의 승낙 없이 목적물을 임대 또는 담보로 제공한 경우에 채무자가 의무위반을 이유로 유치권의 소멸을 청구하면 유치권은 즉시 소멸한다(제324조).
- ③ 다른 담보의 제공 또는 점유의 상실로 유치권은 소멸한다.

중요판례

대법원 1972.01.31. 71다2414

유치권자의 점유하에 있는 유치물의 소유자가 변동하더라도 유치권자의 점유는 유치물에 대한 보존행위로서 하는 것이므로 적법하고 그 소유자변동 후 유치권자가 유치물에 관하여 새로이 유익비를 지급하여 그 가격의 증가가 현존하는 경우에는 이 유익비에 대하여도 유치권을 행사할 수 있다. 유치권자가 유치물에 대한 보존행위로서 목적물을 사용하는 것은 적법행위이므로 불법점유로 인한 손해배상책임이 없는 것이다.

대법원 2009.09.24. 2009다40684

민법 제324조에 의하면, 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하고, 소유자의 승낙 없이 유치물을 보존에 필요한 범위를 넘어 사용하거나 대여 또는 담보제공을 할 수 없으며, 소유자는 유치권자가 위 의무를 위반한 때에는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다고 할 것인바, 공사대금채권에 기하여 유치권을 행사하는 자가 스스로 유치물인 주택에

거주하며 사용하는 것은 특별한 사정이 없는 한 유치물인 주택의 보존에 도움이 되는 행위로서 유치물의 보존에 필요한 사용에 해당한다고 할 것이다. 그리고 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다.

대법원 1976.05.25. 76다482

부동산의 점유가 불법행위로 인하여 시작되었을 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.

대법원 1976.05.11. 75다1305

건물의 임대차에 있어서 임차인의 임대인에게 지급한 보증금반환청구권이나 임대인이 건물 시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용 못한 것을 이유로 하는 손해 배상청구권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없다.

대법원 1975.04.22. 73다2010

건물의 임차인이 임대차관계 종료시에는 건물을 원상으로 복구하여 임대인에게 명도하기로 약정한 것은 건물에 지출한 각종 유익비 또는 필요비의 상환청구권을 미리 포기하기로 한 취지의 특약이라고 볼 수 있어 임차인은 유치권 주장을 할 수 없다.

대법원 1994.10.14. 93다62119

임대인과 임차인 사이에 건물명도시 권리금을 반환하기로 하는 약정이 있었다 하더라도 그와 같은 권리금반환청구권은 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다.

☞ 임차보증금반환채권이나 권리금반환채권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 유치권의 성립요건인 '채권과 목적물의 견련성'에 해당하지 아니한다.

대법원 2017.2.8. 2015마2025

어느 부동산에 관하여 경매개시결정등기가 된 뒤에 비로소 점유를 이전받아 유치권을 취득한 사람은 경매절차에서 그의 유치권을 주장할 수 없다.

대법원 2008.05.30. 자 2007마98

건물의 신축공사를 한 수급인이 그 건물을 점유하고 있고 또 그 건물에 관하여 생긴 공사금 채권이 있다면, 수급인은 그 채권을 변제받을 때까지 건물을 유치할 권리가 있는 것이지만, 건물의 신축공사를 도급받은 수급인이 사회통념상 독립한 건물이라고 볼 수 없는 정착물을 토지에 설치한 상태에서 공사가 중단된 경우에 위 정착물은 토지의 부합물에 불과하여 이러한 정착물에 대하여 유치권을 행사할 수 없는 것이고, 또한 공사중단시까지 발생한 공사금 채권은 토지에 관하여 생긴 것이 아니므로 위 공사금 채권에 기하여 토지에 대하여 유치권을 행사할 수도 없다.

대법원 2007.9.7. 2005다16942

다세대주택의 창호 등의 공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 위 다세대주택 중 한 세대를 점유하여 유치권을 행사하는 경우, 그 유치권은 위 한 세대에 대하여 시행한 공사대금만이 아니라 다세대주택 전체에 대하여 시행한 공사대금채권의 잔액 전부를 피담보채권으로 하여 성립한다.

대법원 2008.04.11. 2007다27236

유치권의 성립요건이자 존속요건인 유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 관계가 없으나, 다만 유치권은 목적물을 유치함으로써 채무자의 변제를 간접적으로 강제하는 것을 본체적 효력으로 하는 권리인 점 등에 비추어, 그 직접점유자가 채무자인 경우에는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당하지 않는다.

대법원 2011.12.13. 2009다5162

점유자가 점유물을 보존하거나 개량하기 위하여 지출한 필요비나 유익비에 관하여 민법 제 203조는 '점유자가 점유물을 반환할 때'에 상환을 청구할 수 있도록 규정하고 있으므로, 그 상환청구권은 점유자가 회복자에게서 점유물 반환을 청구받은 때에 비로소 이를 행사할 수 있는 상태가 되고 또한 이때부터 유치권을 행사할 수 있다.

대법원 2014.12.30. 자2014마1407

유치권자는 경락인에 대하여 그 피담보채권의 변제가 있을 때까지 유치목적물인 부동산의 인도를 거절할 수 있을 뿐이고 그 피담보채권의 변제를 청구할 수는 없다.

대법원 1972. 05.30. 72다548

유치권자는 점유를 상실하면 곧 유치권을 상실하므로 유치권자로부터 점유를 승계한 자가 유치권자를 대위하여 유치권을 주장할 수 없다.

제3절 질권

1. 질권의 의의와 성질

(1) 의의

채권자가 그 채권을 담보하기 위하여 채무자 또는 제3자 소유의 동산 또는 권리를 채무가 변제될 때까지 유치함으로써 채무자를 간접적으로 강제하는 동시에 변제가 없는 경우에는 그 목적물로부터 우선적으로 변제받는 것을 내용으로 하는 약정담보물권이다.

(2) 법률적 성질

- ① 약정담보물권이다.
- ② 타물권이다. 즉, 교환가치를 지배한다.
- ③ 부종성·수반성·불가분성·물상대위성을 가진다.
- ④ 유치적 효력과 우선변제적 효력을 갖는다.

2. 질권과 저당권의 비교

사항		질권	저당권
본질		목적물의 점유가 질권자에게 이전	목적물의 점유가 저당권설정자에게 그대로 남음
기능		서민의 금융수단	투자의 수단
성립	설정계약	설정계약+목적물 인도	설정계약+등기
	객체	동산·권리(주식, 채권)	부동산·권리(지상권, 전세권)
	선의취득	성립 가능	성립 불능
효력	유치력	있음	없음
	우선변제력	있음	있음
	사용권	보존의 범위 내에서 가능	없음
	유질, 유저당	금지(변제기 이전의 유질계약)	인정
	과실에 대한 효력	효력이 미침	효력이 미치지 않음

3. 동산질권

(1) 의의

채권자가 그 채권을 담보하기 위하여 채무자 또는 제3자 소유의 동산 또는 권리를 채무가 변제될 때까지 유치함으로써 채무자를 간접적으로 강제하는 동시에 변제가 없는 경우에는 그 목적물로부터 우선적으로 변제받는 것을 내용으로 하는 약정담보물권이다.

(2) 법률적 성질

- ① 약정담보물권이다.
- ② 부종성·수반성·불가분성·물상대위성을 가진다.
- ③ 유치적 효력과 우선변제적 효력을 갖는다.

성 립	계약당사자	채권자와 채무자 또는 제3자(물상보증인)이다.
	동산의 인도	① 현실의 인도, 간이인도, 반환청구권의 양도에 의한 질권의 설정도 인정하나 점유개정에 의한 설정은 부정된다. ② 점유개정에 의한 질권설정은 유치적 효력이 확보되지 않기 때문이다.
	객체	양도가 가능해야 한다. ① 양도할 수 없는 물건(금제물, 압류금지물 등)은 객체가 될 수 없다. ② 국가가 정책적 이유에서 권리자로 하여금 스스로 사용·수익하게 하려는 동산(선박·자동차·건설기계·항공기)은 저당권의 객체가 된다.
	피담보채권	담보물권의 부종성으로 인해 반드시 피담보채권의 존재를 요한다.
	법정질권	① 토지임대인의 법정질권(제648조) ② 건물 등의 임대인의 법정질권(제650조)
효 력	효력이 미치는 목적물의 범위	명문의 규정은 없으나 아래와 같이 해석한다. ① 종 물 ② 천연과실 ③ 법정과실 ④ 물상대위성
	피담보채권의 범위	당사자의 약정이 없을 때의 피담보채권의 범위는 다음과 같다. ① 원 본 ② 이 자 ③ 위약금 ④ 질권 실행비용 ⑤ 질물 보존비용 ⑥ 채무불이행으로 인한 손해배상(원본의 이행기일 경과 후 1년분) ⑦ 질물 하자로 인한 손해배상

점유보호청구권	① 점유가 침해된 경우에는 점유보호청구권으로 구제받을 수 있다. ② 질권 자체에 기인한 물권적 청구권을 규정하지 않고 있지만 입법의 미비로 해석하는 것이 다수설이다.
우선변제적 효력	① 질권의 본질적 효력이다. ② 변제기 전의 유질계약은 금지된다.
유치적 효력	피담보채권 전액을 변제받을 때까지 질물의 전부를 유치할 수 있다.

4. 권리질권

권리질권은 채권 기타 재산권을 목적으로 하는 질권을 말한다(제345조 본문). 다만, 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리(지상권·전세권·부동산임차권)는 제외한다(동조 단서).

권리질권의 목적	• 재산권이어야 하며 금전적 가치로서 평가할 수 있는 것이어야 한다. 따라서 인격권·상속권·친족권 등은 인정될 수 없다. • 양도성이 있는 재산권이어야 한다. 부양청구권·재해보상청구권·연금청구권 등은 인정될 수 없다. • 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 지상권·전세권·부동산임차권 등은 권리질권의 목적이 될 수 없다. • 어업권·광업권·공장재단 등은 권리질권의 목적이 될 수 없다. ※ 권리질권의 목적이 되는 것으로 대표적인 것 : 주식, 채권, 지식재산권
채권질권의 공시방법	• 지명채권 : 합의와 채권증서의 교부(채무자에게 통지 또는 승낙은 대항요건) • 지시채권 : 합의와 배서 후 교부 • 무기명채권 : 합의와 교부 • 저당권부채권 : 합의와 부기등기

중요판례

대법원 1981.12.22. 80다2910

동산질권을 선의취득하기 위하여는 질권자가 평온·공연하게 선의이며, 과실 없이 질권의 목적동산을 취득하여야 하고, 그 취득자의 무과실은 동산질권자가 증명하여야 한다.

대법원 2005.12.22. 2003다55059

질권의 목적인 채권의 양도행위는 민법 제352조 소정의 질권자의 이익을 해하는 변경에 해당되지 않으므로 질권자의 동의를 요하지 아니한다.

5. 동산질권자의 전(轉)질권

제336조 【전질권】

질권자는 그 권리의 범위 내에서 자기의 책임으로 질물을 전질할 수 있다. 이 경우에는 전질을 하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여도 책임을 부담한다.

제337조 【전질의 대항요건】

- ① 전조의 경우에 질권자가 채무자에게 전질의 사실을 통지하거나 채무자가 이를 승낙함이 아니면 전질로써 채무자, 보증인, 질권설정자 및 그 승계인에게 대항하지 못한다.
- ② 채무자가 전항의 통지를 받거나 승낙을 한 때에는 전질권자의 동의 없이 질권자에게 채무를 변제하여도 이로써 전질권자에게 대항하지 못한다. 질권자는 채무자의 승낙을 얻어서 또는 그 권리의 범위 내에서 자기책임으로 자기채권을 담보하기 위하여 질물을 다시 입질할 수 있다(제336조). 승낙을 얻어서 하는 것을 승낙전질, 승낙 없이 자기 책임으로 하는 것을 책임전질이라 한다.

(1) 의의 및 종류

① 의의

질권자가 자기의 채무를 담보하기 위하여 다른 제2의 질권을 설정하는 것을 말한다.

② 종류

책임전질과 승낙전질이 있다.

(2) 책임전질과 승낙전질의 비교

사항	질권	저당권
의의	질권자가 질권설정자의 승낙없이 오직 자기의 책임으로 하는 전질이다(제336조).	질권자가 질물소유자의 승낙을 얻어 질물위에 다시 질권을 설정하는 전질이다.
법적 성질	채권·질권공동입질설(다수설)	질물재입질설(통설)
요건	① 원질권자와 전질권자 사이에 합의와 질물의 인도가 있을 것 ② 원질권의 범위 내의 제약일 것 ㉠ 피담보채권액은 원질권의 피담보 채권액을 초과할 수 없고 존속기간도 원질권의 존속기간 내에서만 설정	① 원질권자와 전질권자 사이에 전질권 설정계약과 질물의 인도 이외에 질물 소유자의 승낙이 있을 것 ② 원질권의 범위에 의한 제한을 받지 않는다. ㉠ 원질권의 피담보채권액을 초과하는

사항	질권	저당권
	할 수 있다. ㉠ 초과전질은 원질권의 범위 내에서만 유효하다. ③ 원질권자의 채무자에 대한 통지 또는 채무자의 승낙이 있어야 전질권자가 채무자에게 대항할 수 있다(제337조 제1항)	초과전질도 유효하다. ㉠ 존속기간도 원질권과 관계없이 정할 수 있다. ③ 책임전질과 같은 채무자에의 통지를 요하지도 않는다.
효 과	① 전질하지 않았더라면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여도 책임을 면할 수 없다. ② 원질권자는 질권을 소멸하게 하는 행위를 행하지 못한다. 따라서 질권의 포기나 채무자의 채무를 면제하는 행위를 할 수 없다. ③ 대항요건을 갖춘 책임전질의 경우, 전질권자의 동의 없이 채무자가 원질권자에게 변제하여도 이로써 전질권자에게 대항하지 못한다. 따라서 전질권자에게 질물의 반환을 청구하지 못한다. ④ 대항요건을 갖추지 않은 전질권은 질권설정자는 원질권자에게 변제하고 원질권을 소멸시킬 수 있고 원질권이 소멸되면 전질권도 따라서 소멸한다. ⑤ 전질권이 소멸된 경우, 전질권자에게 소유물반환청구권을 행사하면, 전질권자는 반환청구에 응하여야 한다(제213조). ⑥ 원질권이 소멸하면 전질권도 소멸한다.	① 원질권자는 불가항력으로 인한 손해배상 책임을 부담하지 않는다. ② 원질권이 소멸하여도 전질권에는 영향이 없으므로 전질권은 소멸하지 않는다. ③ 전질권자는 계속 질물을 점유할 수 있다.

6. 권리질권

제345조 【권리질권의 목적】

질권은 재산권을 그 목적으로 할 수 있다. 그러나 부동산의 사용, 수익을 목적으로 하는 권리는 그러하지 아니하다.

제346조 【권리질권의 설정방법】

권리질권의 설정은 법률에 다른 규정이 없으면 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다.

제352조 【질권설정자의 권리처분제한】

질권설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다.

제353조 【질권의 목적이 된 채권의 실행방법】

- ① 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.
- ② 채권의 목적물이 금전인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다.
- ③ 전항의 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제3채무자에 대하여 그 변제금액의 공탁을 청구할 수 있다. 이 경우에 질권은 그 공탁금에 존재한다.
- ④ 채권의 목적물이 금전이외의 물건인 때에는 질권자는 그 변제를 받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다.

권리질권은 채권 기타 재산권을 목적으로 하는 질권을 말한다(제345조 본문). 다만, 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리(지상권·전세권·부동산임차권)는 제외한다(제345조 단서). 보통 권리질권의 목적이 되는 재산권은 채권·주식·지식재산권 등이다. 부동산에 준하여 취급되는 광업권·어업권 등은 물론이고, 소유권·지역권·점유권 등도 그 성질상 권리질권의 목적이 될 수 없다.

〈권리질권의 객체와 공시방법〉

권리질권의 목적	• 재산권이여야 하며 금전적 가치로서 평가할 수 있는 것이어야 한다. 따라서 인격권·상속권·친족권 등은 인정될 수 없다. • 양도성이 있는 재산권이여야 한다. 부양청구권·재해보상청구권·연금청구권 등은 인정될 수 없다. • 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 지상권·전세권·부동산임차권 등은 권리질권의 목적이 될 수 없다. • 어업권·광업권·공장재단 등은 권리질권의 목적이 될 수 없다. • 권리질권의 목적이 되는 것으로 대표적인 것은 주식, 채권, 지식재산권이다.
채권질권의 공시방법	• 지명채권 : 합의와 채권증서의 교부(채무자에게 통지 또는 승낙은 대항요건) • 지시채권 : 합의와 배서 후 교부 • 무기명채권 : 합의와 교부 • 저당권부채권 : 합의와 부기등기

제4절 저당권

1. 저당권의 의의와 성질

(1) 의의

제356조 【저당권의 내용】

저당권자는 채무자 또는 제3자가 점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다.

채무자 또는 제3자(물상보증인)가 점유를 이전하지 않고 채무의 담보로 제공한 물건에서 채권자가 우선변제를 받을 수 있는 약정담보물권이다.

(2) 법률적 성질

- ① 약정담보물권이다.
- ② 우선변제적 효력이 인정된다.
- ③ 목적물의 점유를 수반하지 않는 권리이다.
- ④ 공시방법(등기 또는 등록)을 요하는 권리이다.
- ⑤ 물상대위성·불가분성·타물권·부종성·수반성이 있다.

중요판례

대법원 2010.10.28. 2010다46756

저당권자가 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데에 그 취지가 있다. 따라서 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있다.

2. 저당권의 설정

(1) 저당권 설정계약에 의한 성립

- ① 저당권은 약정담보물권이므로 당사자 간의 저당권설정계약에 의하여 성립되는 것이 원칙이다. 저당권설정계약이란 당사자 간에 저당권을 설정한다는 합의를 하는 것을 말한다.
- ② 저당권설정계약의 당사자는 저당권을 취득할 자(저당권자)와 목적재산에 저당권이라는 부담을 질 자(저당권설정자)이다. 저당권자는 채권자에 한하나, 저당권 설정자는 채무자 이외에 제3자(물상보증인)가 될 수 있다. 저당권설정자는 목적재산의 소유자 외에 지상권자·전세권자도 될 수 있다(제371조).
- ③ 저당권설정계약은 등기를 하여야 그 효력이 생긴다(제186조). 등기하여야 할 사항은 채권채무자, 채권액, 변제기, 이자, 이자의 발생기 또는 지급시기, 원본 또는 이자의 지급장소, 제358조 단서의 약정, 채권이 조건부인 때에 그 조건의 내용 등이다.

(2) 법정저당권의 성립

저당권은 약정담보물권으로서 당사자 사이의 합의와 등기에 의하여 성립하는 것이 원칙이지만, 예외로 법률상 당연히 성립하는 경우가 있는데, 이를 법정저당권이라 한다. 즉, 토지임대인이 변제기를 경과한 후 최후 2년의 차임채권에 의하여 그 지상에 있는 임차인 소유의 건물을 압류한 때에는 저당권과 동일한 효력이 있다(제649조).

(3) 부동산공사수급인의 저당권설정청구권

부동산공사의 수급인은 그 보수채권을 담보하기 위하여 도급인에 대하여 그 부동산을 목적으로 하는 저당권의 설정을 청구할 수 있다(제666조).

〈저당권의 성립〉

성립요건	'설정계약과 등기'로서 설정	
당사자	저당권자(채권자)와 저당권설정자(채무자 또는 물상보증인)	
등기사항	① 채권자	⑤ 이자 및 그 지급시기
	② 채무자	⑥ 원본 또는 이자의 지급장소
	③ 채권액	⑦ 제358조 단서의 약정 등
	④ 변제기	

객체	① 민법상 부동산(제356조)과 지상권·전세권(제371조 제1항) ② 상법상의 등기된 선박(상법 제871조) ③ 입목에 관한 법률에 의한 입목등기가 된 수목의 집단 ④ 광업권·어업권 ⑤ 특별법상의 공장재단·광업재단 ⑥ 특수동산(자동차·항공기·건설기계)
피담보채권	① 금전채권인 것이 보통이나, 반드시 그에 한정되지 아니한다. ② 채권의 일부를 피담보채권으로 할 수 있고, 수개의 채권을 합하여 피담보채권으로 할 수 있다. ③ 장래의 증감변동하는 다수의 채권을 위하여 저당권을 설정할 수 있다(근저당).

중요판례

대법원 2009.11.26. 2008다64478

채권담보의 목적으로 채무자 소유의 부동산을 담보로 제공하여 저당권을 설정하는 경우에는 담보물권의 부종성의 법리에 비추어 원칙적으로 채권과 저당권이 그 주체를 달리할 수 없는 것이지만, 채권자 아닌 제3자의 명의로 저당권등기를 하는 데 대하여 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있었고, 나아가 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있거나, 거래경위에 비추어 제3자의 저당권등기가 한낱 명목에 그치는 것이 아니라 그 제3자도 채무자로부터 유효하게 채권을 변제받을 수 있고 채무자도 채권자나 저당권 명의자인 제3자 중 누구에게든 채무를 유효하게 변제할 수 있는 관계 즉 묵시적으로 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는, 그 제3자 명의의 저당권등기도 유효하다고 볼 것이고, 이러한 법리는 채권 담보를 목적으로 가등기를 하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

대법원 1981.09.08. 80다1468

근저당권 설정계약상의 채무자 아닌 제3자를 채무자로 하여 된 근저당권 설정등기는 채무자를 달리 한 것이므로 근저당권의 부종성에 비추어 원인 없는 무효의 등기이다.

대법원 1980.09.18. 80마75

일정한 금액을 목적으로 하지 아니한 채권을 금전으로 평가하여 그 평가액을 저당권의 피담보채권으로 등기한 경우에 있어서 채권자는 제3자에 대한 관계에 있어서는 그 등기된 평가액의 한도에서만 저당권의 효력을 주장할 수 있다.

3. 저당권의 효력

(1) 저당권의 효력이 미치는 범위

제360조 【피담보채권의 범위】

저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보한다. 그러나 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.

① 원본

담보되는 원본(元本)의 금액과 변제기, 지급장소는 등기하여야 한다. 피담보채권이 금전채권이 아닌 경우에는 미리 그 평가액을 등기하여야 한다(부동산등기법 제77조).

② 이자

이자를 발생하게 하는 특약이 있는 때에는 이자·발생기·지급장소에 관한 약정은 이를 등기하여야 한다(부동산등기법 제75조). 이자채권은 저당권에 의하여 무제한으로 담보된다. 다만, 변제기 이후에는 지연배상(지연이자)으로 되어 일정한 제한이 있게 된다.

③ 채무불이행으로 인한 손해배상

채무불이행으로 인한 손해배상, 즉 지연배상(지연이자)은 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한한다(제360조). 이와 같은 제한은 저당권자의 태만으로 인한 시일경과로 후순위저당권자를 비롯한 다른 채권자에게 손해를 주는 것을 막기 위한 것이다.

④ 위약금

위약금의 특약이 있고 등기가 되어 있으면 저당권에 의하여 담보된다.

⑤ 저당권실행의 비용

저당권의 실행에는 감정평가비용, 경매신청 등록세 등의 비용이 든다. 이는 등기하지 않아도 효력이 미친다.

목적물의 범위	① 저당권의 효력은 저당부동산에 부합(저당권의 설정전후를 불문)된 부합물과 종물에도 미친다. 예외적으로 설정계약에서 반대의 특약을 한 경우와 지상권자·전세권자 등이 부합한 물건에는 미치지 아니한다. ② 토지와 건물은 별개의 부동산이므로 저당목적 토지 위의 건물에는 저당권의
---------	--

	효력이 미치지 아니한다. 단, 설정자가 그 저당 토지 위에 건물을 축조한 경우에는 토지와 함께 건물에 대해서도 경매를 청구할 수 있으나 먼저 건물의 매각대금으로부터는 우선변제를 받지 못한다. ③ 과실에는 저당권의 효력이 미치지 않으나 저당권의 실행으로 목적물에 대한 압류가 있는 후에는 설정자가 수취하는 과실 또는 수취할 수 있는 과실에도 저당권의 효력이 미친다. 그러나 저당권자가 그 부동산에 대한 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자에 대하여는 압류한 사실을 통지한 후가 아니면 대항하지 못한다(제359조 단서). ④ 저당권에도 물상대위성이 있으므로 저당목적물의 멸실·훼손·공용징수로 인하여 저당권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 저당권의 효력이 미친다. 다만 이 경우에는 지급(인도)전에 반드시 압류하여야 한다.
--	--

(2) 우선변제를 받는 모습

① 저당권에 의해 우선변제를 받는 경우

- ㉠ 저당권자 자신이 직접 민사집행법에 의해 경매하여 우선변제를 받는 것을 말한다. 이를 담보권실행 등을 위한 경매(담보권실행경매)라고 한다.
- ㉡ 일반채권자의 강제집행, 전세권자 또는 후순위저당권자의 경매가 있는 경우에, 저당권자는 그가 가지는 우선순위에 따라 당연히 우선변제를 받는다. 다만, 일반채권자 또는 후순위저당권자가 신청하는 경매에 있어서는, 최저매각가격으로부터 그들의 채권에 우선하는 부동산의 모든 부담과 절차비용을 변제하면 남을 것이 없겠다고 인정되는 때에는 법원은 일정한 사유가 없는 한 그 경매 절차를 취소하여야 한다(민사집행법 제102조·268조).

② 단순한 채권자로서 변제를 받는 경우

- ㉠ 경매절차에서 저당부동산의 매각대금으로부터 배당은 받았지만 채권을 완전히 변제받지 못한 경우에는, 저당권자의 나머지 채권은 무담보의 채권으로 남는다.
- ㉡ 나머지 채권에 대해서는 단순한 일반채권자로서 채무자의 재산에 강제집행을 하거나 타인이 집행하는 경우에 배당에 가입하여 변제받을 수 있다.

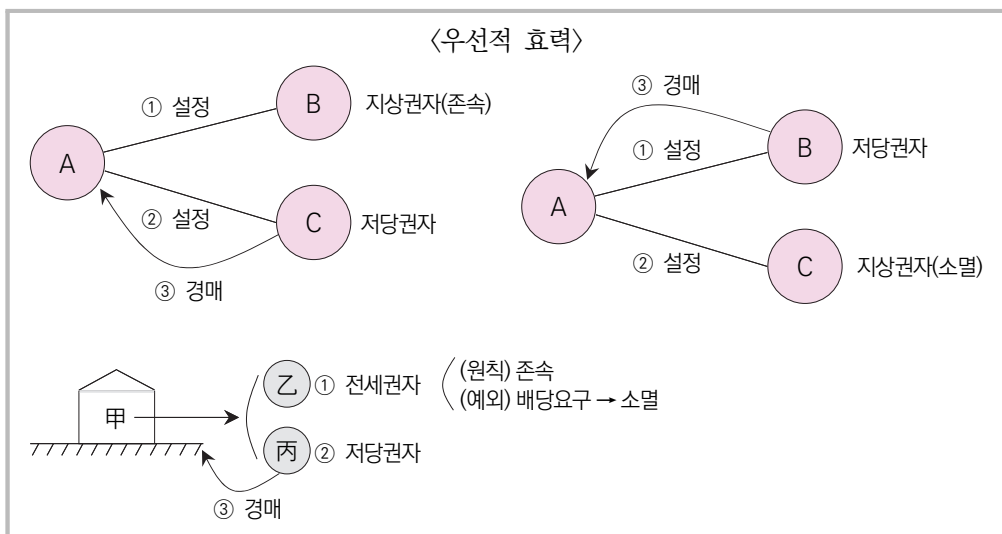
(3) 저당권자의 우선적 지위

- ① 저당권자는 일반채권자에 대해서는 언제나 우선한다.
- ② 다른 저당권자와 전세권자 사이에서는 설정등기의 선후에 의한다.

- ③ 주택(상가)임대차보호법상의 임차인은 대항요건을 갖춘 경우에는 보증금 중의 일정액에 대해서는 최우선변제를 받는다.
- ④ 최종 3개월분의 임금과 최종 3년간의 퇴직금은 저당권에 우선한다.
- ⑤ 저당부동산의 소유자가 체납하고 있는 국세·지방세의 우선순위는 저당권과 동일하나, 그 저당물 자체에 부과된 국세나 지방세 등은 그 법정기일 전에 설정된 저당권에 대해서도 우선한다.
- ⑥ 유치권은 이론상으로는 저당권과의 우열의 문제는 생기지 않으나 유치권자는 사실상으로는 우선변제를 받는 결과가 된다.

(4) 저당권과 용익관계

- ① 저당권을 설정하기 전에 이미 제3자가 목적물에 관하여 저당권에 대항할 수 있는 용익권(지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권)을 가지고 있는 경우에는, 저당권이 실행되더라도 용익권자는 매수인(경락인)에게 대항할 수 있다. 다만, 그 중 전세권의 경우에는 전세권자가 경매절차에서 배당요구를 하면 매각으로 소멸한다(민사집행법 제91조).
- ② 용익권이 저당권의 실행에 의하여 뒤집어지느냐의 여부는 경매를 신청한 저당권자와의 우열이 아니라 그 부동산 위 최고 순위의 저당권과의 사이의 우열로 정하여진다. 왜냐하면, 후순위저당권의 실행으로 인해 선순위저당권도 소멸하고 선순위저당권자는 배당에 참여하여 우선변제를 받기 때문이다(민사집행법 제91조).



(5) 저당권침해에 대한 구제

① 물권적 청구권

저당권자는 그 저당권에 의거하여 침해의 제거 또는 예방을 청구할 수 있다(제214조·제370조). 그러나 저당목적물의 반환청구권은 인정되지 아니한다.

② 손해배상청구권

저당권침해가 불법행위의 요건을 충족하면 저당권자는 손해배상을 청구할 수 있다(제750조). 그러나 침해에 의하여 담보가치가 감소되더라도 잔존부분에 의하여 완제가 가능한 경우에는 손해가 없으므로 손해배상청구권이 생기지 않는다. 그리고 손해배상을 청구함에는 저당권실행 전이라도 무방하다. 그 이전이라도 손해액을 산정할 수 있기 때문이다.

③ 저당물보충청구권

저당권설정자의 책임있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는, 저당권자는 설정자에 대하여 그 원상복구 또는 상당한(적절한) 담보제공을 청구할 수 있다(제362조). 이 청구권을 행사하는 때에는 위의 손해배상청구권과 즉시변제청구권은 행사하지 못한다(통설).

④ 즉시변제청구권

저당권의 침해가 채무자의 귀책사유로 인한 때에는 채무자는 기한의 이익을 상실하고, 저당권자는 즉시 변제를 청구할 수 있고 저당권을 실행할 수 있다(제388조 제1호).

〈채무자에 의한 침해와 제3자에 의한 침해〉

채무자에 의한 침해	① 물권적 청구권은 인정하나 저당물반환청구권은 인정되지 않는다. ② 손해배상청구권은 저당물방해제거청구권·기한이익의 상실로 인한 즉시변제청구권과 결합적으로 행사할 수 있으나 담보물보충청구권과는 선택적으로 행사할 수 있다. ③ 담보물보충청구권은 저당권설정자의 귀책사유로 저당물의 가액이 현저하게 감소한 때에 저당권자가 청구할 수 있다. ④ 채무자가 담보물을 손상·감소·멸실하게 한 때 또는 담보제공의무를 이행하지 아니한 때에는 기한이익을 상실케 하고 즉시변제청구권을 행사할 수 있다.
제3자에 의한 침해	위의 ①과 ②만을 인정한다.

4. 저당권의 실행

(1) 담보권실행경매에 의한 저당권실행

① 담보권실행경매의 의의

담보권의 실행경매는 유치권·질권·저당권 등의 담보권의 실행을 위한 경매를 말하며, 부동산의 경매만을 의미하는 것은 아니다. 그 절차는 민사집행법 제264조 이하의 규정에 의한다. 그리고 이러한 경매는 강제경매와 달리 확정판결과 같은 집행권원을 요하지 않는다.

② 저당권실행의 요건

저당권을 실행하기 위해서는 유효한 피담보채권과 저당권이 존재하고, 또한 채무의 이행기가 도래(채무자의 이행지체)하여야 한다.

③ 경매절차

민사집행법이 규정한 경매절차는 대체로 강제경매에 관한 규정을 준용하여 ① 경매 신청, ② 경매개시결정, ③ 매각, ④ 대금의 납부와 배당의 순서로 진행된다.

(2) 담보권실행경매에 의하지 않는 저당권실행(유저당)

유저당(流抵當)계약이란 저당권설정계약에서 또는 피담보채권의 변제기가 도래하기 전의 특약으로, 저당채무의 불이행이 있는 경우에는 저당목적물의 소유권을 저당권자가 그대로 취득하는 것으로 하거나(대물변제의 예약), 또는 법률로 정하여져 있는 방법(담보권실행경매)이 아닌 임의의 방법으로 저당목적물을 처분 내지 환가하여도 좋다는 내용의 약정(임의환가의 약정)을 말한다.

1) 대물변제의 예약

① 저당권을 설정하면서 피담보채무의 불이행이 있는 경우 저당부동산의 소유권을 저당권자에게 이전한다는 합의인 대물변제예약을 하고 가등기를 한 경우에는 가등기 담보가 되고, 가등기담보 등에 관한 법률이 적용된다. 이 경우에는 당연히 청산절차를 거쳐야 한다(가등기담보법 제3조 이하).

② 대물변제의 예약을 하고 가등기를 하지 않고 소유권이전등기서류만을 교부받고 있거나 아무런 후속조치를 취하지 않고 있는 경우에는 가등기담보법이 적용되지 않는다. 판례는 이러한 경우에는 특별한 사정이 없으면, 약한 의미의 양도담보

계약을 맺은 것으로 보아야 하고, 채권자가 채무의 변제기 후에 반드시 청산절차를 거쳐야 한다고 판시한다.

2) 임의환가의 약정

임의환가의 약정은 저당부동산의 환가를 담보권실행경매가 아닌 임의의 방법, 즉 제3자에게 매각하여 청산하기로 하는 약정을 말한다.

5. 제3취득자의 보호

저당부동산의 제3취득자란 저당부동산의 양수인이나 저당부동산에 대하여 지상권·전세권을 취득한 자를 말한다. 그들은 저당권이 실행되기 전에는 저당권의 존재로 인하여 아무런 영향을 받지 않는다. 그러나 채무자가 변제를 하지 않아 저당권이 실행되면 제3취득자는 그 권리를 잃게 된다. 따라서 제3취득자의 지위는 결국 채무자의 변제의 유무에 달려있고, 그 결과 매우 불안정하므로 그 지위의 보호가 특히 문제된다.

(1) 제3취득자의 변제권

- ① 제3취득자는 저당권을 실행하는 경매에 참가하여 매수인이 될 수 있다(제363조 제2항). 민법은 소유권을 취득한 자만을 규정하고 있으나, 지상권·전세권을 취득한 자도 포함된다고 해석한다.
- ② 저당부동산의 제3취득자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다(제364조). 여기서의 제3취득자는 이해관계 있는 제3자이므로 채무자의 의사에 반하여서도 대신 변제할 수 있다(제469조 제2항).
- ③ 위 ②의 경우에는 제3취득자는 저당권자를 법정대위하며, 채무자에게 구상권을 행사할 수 있다.
- ④ 제3취득자의 변제로 저당권은 말소등기 없이도 당연히 소멸한다(제187조)

(2) 비용상환청구권

저당부동산의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 저당물의 매각대금에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조).

대법원 1996.03.22. 95다55184

저당권자는 물권에 기하여 그 침해가 있는 때에는 그 제거나 예방을 청구할 수 있다고 할 것인바, 공장저당권의 목적 동산이 저당권자의 동의를 얻지 아니하고 설치된 공장으로부터 반출된 경우에는 저당권자는 설정자로부터 일탈한 저당목적물을 저당권자 자신에게 반환할 것을 청구할 수는 없지만, 저당목적물이 제3자에게 선의취득되지 아니하는 한 방해배제청구권의 행사로서 원래의 설치 장소에 원상회복할 것을 청구할 수 있다.

대법원 2008. 2. 15. 2005다47205

토지에 관하여 저당권을 취득함과 아울러 그 저당권의 담보가치를 확보하기 위하여 지상권을 취득하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 지상권은 저당권이 실행될 때까지 제3자가 용익권을 취득하거나 목적 토지의 담보가치를 하락시키는 침해행위를 하는 것을 배제함으로써 저당 부동산의 담보가치를 확보하는 데에 그 목적이 있다고 할 것이므로, 제3자가 저당권의 목적인 토지 위에 건물을 신축하는 경우에는, 그 제3자가 지상권자에게 대항할 수 있는 권원을 가지고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 지상권자는 그 방해배제청구로서 신축중인 건물의 철거와 대지의 인도 등을 구할 수 있다고 할 것이다.

대법원 2006.01.27. 2003다58454

저당권자는 저당권 설정 이후 환가에 이르기까지 저당물의 교환가치에 대한 지배권능을 보유하고 있으므로 저당목적물의 소유자 또는 제3자가 저당목적물을 물리적으로 멸실·훼손하는 경우는 물론 그 밖의 행위로 저당부동산의 교환가치가 하락할 우려가 있는 등 저당권자의 우선변제청구권의 행사가 방해되는 결과가 발생한다면 저당권자는 저당권에 기한 방해배제청구권을 행사하여 방해행위의 제거를 청구할 수 있다.

대법원 2002.09.24. 2002다27910

피담보채권이 소멸하면 저당권은 그 부종성에 의하여 당연히 소멸하므로, 그 말소등기가 경료되기 전에 그 저당권부채권을 가압류하고 압류 및 전부명령을 받아 저당권 이전의 부기등기를 경료한 자라 할지라도, 그 가압류 이전에 그 저당권의 피담보채권이 소멸된 이상, 그 근저당권을 취득할 수 없고, 실체관계에 부합하지 않는 그 근저당권 설정등기를 말소할 의무를 부담한다.

대법원 1976.12.24. 76다957

채무자가 피담보채무를 이행하지 않아 담보권자가 담보권을 실행하였을 때에는 그 실행에 필요한 상당한 비용은 채무불이행으로 인하여 발생한 비용이라고 할 것이므로 당사자 간에 계약이 없는 한 채무자가 부담하여야 한다.

대법원 1997.09.26. 97다10314

- [1] 저당권은 법률에 특별한 규정이 있거나 설정행위에 다른 약정이 있는 경우를 제외하고 그 저당 부동산에 부합된 물건과 종물 이외에까지 그 효력이 미치는 것이 아니므로, 토지에 대한 경매절차에서 그 지상 건물을 토지의 부합물 내지 종물로 보아 경매법원에서 저당 토지와 함께 경매를 진행하고 경락허가를 하였다고 하여 그 건물의 소유권에 변동이 초래될 수 없다.
- [2] 경락에 의하여 건물의 소유자와 그 토지의 소유자가 달라지게 되어 경매 당시의 건물의 소유자가 그 건물의 이용을 위한 법정지상권을 취득한 경우, 토지 소유자는 건물을 점유하는 자에 대하여 그 건물로부터의 퇴거를 구할 수 없다.

대법원 1985. 03.26. 84다카269

저당권의 효력이 미치는 저당부동산의 종물이라 함은 민법 제100조가 규정하는 종물과 같은 의미로서의 종물이기 위하여는 주물의 상용에 이바지 되어야 하는 관계가 있어야 한다.

대법원 1992.12. 08. 92다2672

건물의 증축부분이 기존건물에 부합하여 기존건물과 분리하여서는 별개의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 이상, 기존건물에 대한 근저당권은 민법 제358조에 의하여 부합된 증축 부분에도 효력이 미친다.

대법원 1996.04.26. 95다52864

저당권의 효력이 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다는 민법 제358조 본문을 유추하여 보면 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미치게 되므로, 건물에 대한 저당권이 실행되어 경락인이 그 건물의 소유권을 취득하였다면 특별한 사정이 없는 한, 경락인은 건물 소유를 위한 지상권도登記 없이 당연히 취득하게 되고, 한편 이 경우에 경락인이 건물을 제3자에게 양도한 때에는, 특별한 사정이 없는 한 건물과 함께 종된 권리인 지상권도 양도하기로 한 것으로 본다.

대법원 2008.03.13. 2005다15048

집합건물 구분소유자의 대지사용권은 전유부분과 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 전유부분과 종속적 일체불가분성이 인정되므로, 구분건물의 전유부분에 대한 저당권 또는 경매개시결정과 압류의 효력은 당연히 종물 내지 종된 권리인 대지사용권에까지 미치고, 그에 터잡아 진행된 경매절차에서 전유부분을 경락받은 자는 그 대지사용권도 함께 취득한다.

대법원 2003.04.11. 2003다3850

민법 제365조가 토지를 목적으로 한 저당권을 설정한 후 그 저당권설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자가 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 있도록 규정한 취지는,

저당권은 담보물의 교환가치의 취득을 목적으로 할 뿐 담보물의 이용을 제한하지 아니하여 저당권설정자로서는 저당권설정 후에도 그 지상에 건물을 신축할 수 있는데, 후에 그 저당권의 실행으로 토지가 제3자에게 경락될 경우에 건물을 철거하여야 한다면 사회경제적으로 현저한 불이익이 생기게 되어 이를 방지할 필요가 있으므로 이러한 이해관계를 조절하고, 저당권자에게도 저당토지상의 건물의 존재로 인하여 생기게 되는 경매의 어려움을 해소하여 저당권의 실행을 쉽게 할 수 있도록 한 데에 있다는 점에 비추어 볼 때, 저당지상의 건물에 대한 일괄 경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다.

대법원 1987.02.24. 86다카1963

후순위저당권의 실행으로 목적부동산이 경락되어 그 선순위저당권이 함께 소멸한 경우라면 비록 후순위저당권자에게는 대항할 수 있는 임차권이더라도 소멸된 선순위저당권보다 뒤에登記되었거나 대항력을 갖춘 임차권은 함께 소멸하고, 따라서 이와 같은 경우의 경락인은 주택임대차보호법 제3조에서 말하는 임차주택의 양수인 중에 포함되지 않는다 할 것이므로, 경락인에 대하여 그 임차권의 효력을 주장할 수 없다.

대법원 2022.8.25. 2018다205209 전원합의체

이미 소멸한 근저당권에 기하여 임의경매가 개시되고 매각이 이루어진 경우, 그 경매는 무효이다. 민사집행법 제267조(매수인의 부동산 취득은 담보권 소멸로 영향을 받지 아니한다)는 경매개시결정이 있는 뒤에 담보권이 소멸하였음에도 경매가 계속 진행되어 매각된 경우에만 적용된다.

대법원 2011.12.08. 2011다65396

담보권 실행을 위한 경매절차에서 신청채권자가 경매신청서에 피담보채권의 일부만을 청구 금액으로 하여 경매를 신청하였을 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 신청채권자의 청구 금액은 그 기재된 채권액을 한도로 확정되고 그 후 신청채권자가 채권계산서에 청구금액을 확장하여 제출하는 등 방법에 의하여 청구금액을 확장할 수 없다.

대법원 2006.01.26. 2005다17341

민법 제364조는 “저당부동산에 대하여 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 그러므로 근저당부동산에 대하여 민법 제364조의 규정에 의한 권리를 취득한 제3자는 피담보채무가 확정된 이후에 채권최고액의 범위 내에서 그 확정된 피담보채무를

변제하고 근저당권의 소멸을 청구할 수 있으나, 근저당부동산에 대하여 후순위근저당권을 취득한 자는 제3취득자에 해당하지 아니하므로 이러한 후순위근저당권자가 선순위근저당권의 피담보채무가 확정된 이후에 그 확정된 피담보채무를 변제한 것은 이해관계 있는 제3자의 변제로서 따져볼 수는 있으나, 선순위근저당권의 소멸을 청구할 수 있는 사유로는 볼 수 없다.

대법원 1971.05.15. 71마251

경매부동산을 매수한 제3취득자는 그 부동산으로 담보하는 채권최고액과 경매비용을 변제 공탁하면 그 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

대법원 2014.12.24. 2012다49285

타인의 채무를 담보하기 위하여 저당권을 설정한 부동산의 소유자인 물상보증인으로부터 소유권을 양수한 제3자는 채권자에 의하여 저당권이 실행되게 되면 저당부동산에 대한 소유권을 상실한다는 점에서 물상보증인과 유사한 지위에 있다. 따라서 물상보증의 목적물인 저당부동산의 제3취득자가 채무를 변제하거나 저당권의 실행으로 저당물의 소유권을 잃은 때에는 물상보증인의 구상권에 관한 보증채무에 관한 규정에 의하여 채무자에 대한 구상권이 있다.

6. 특수한 저당권

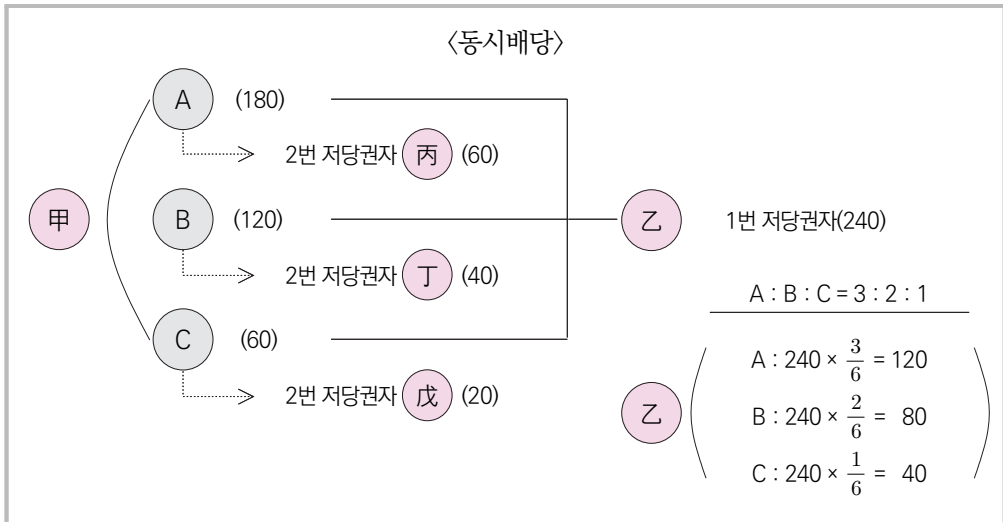
(1) 공동저당

1) 의의

동일한 채권담보를 위하여 여러 개의 부동산 위에 설정되는 저당권으로서 불가분성의 예외가 되며, 일명 총괄저당이라고도 한다.

2) 실행

- ① 동시배당 : 공동저당권의 목적물을 전부 경매하여 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에 비례하여 피담보채권액을 안분한다(제368조 제1항).
- ② 이시배당(순차배당) : 공동저당의 목적물 중 일부만이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 때에는 공동저당권자는 전액변제를 받을 수 있으나, 그 부동산의 후순위 저당권자는 선순위저당권자가 동시배당하였더라면 다른 부동산의 경매대가에서 변제받을 수 있었던 한도에서 선순위를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 제2항).



☑ 채무자와 물상보증인의 부동산에 공동저당이 설정된 경우

1. 채무자 소유의 부동산이 경매된 경우

- ① 甲이 1억 5천만원의 채권을 담보하기 위하여 채무자 乙소유의 X토지와 물상보증인 丙소유의 Y토지에 대해 각각 1번 저당권을 가지고 있고, X토지에는 丁이 2번 저당권을 가지고 있는 경우, 甲이 채무자 乙소유의 X토지에 대해 저당권을 실행하여 채권 전액을 변제받아도 X토지의 후순위자인 丁이 Y토지에 대한 甲의 저당권을 대위하지는 못한다.
- ② 만약 이 경우에도 대위를 허용한다면 공동저당권자 甲을 위해서 담보를 제공한 물상보증인 丙으로서는 예기치 못한 사람의 채권까지 담보해주는 결과가 되기 때문이다.

2. 물상보증인 소유의 부동산이 경매된 경우

- ① 공동저당권자 甲이 물상보증인 丙소유의 Y토지를 먼저 경매하여 채권을 변제받은 경우에는, 丙은 '변제자대위'에 의하여 채무자 乙 소유의 X지에 대한 甲의 1번 저당권을 취득한다. 변제자대위는 물상보증인 丙의 채무자 乙에 대한 구상권의 실현수단으로서 인정되는 것이다.
- ② 물상보증인 丙소유의 Y토지에 戊가 2번 저당권을 가지고 있는 경우, 丙이 변제자대위에 의하여 취득한 X토지상의 甲의 1번 저당권을 다시 戊가 '물상대위'에 의해 대위 취득하여 먼저 우선변제를 받게 된다.
- ③ 물상보증인 丙소유의 Y토지가 먼저 경매되고 甲이 자신의 채권을 모두 변제받은 경우에도 채무자 乙은 X토지에 대한 甲의 저당권에 대해 그 등기의 말소를 청구할 수는 없다. 丙 내지는 戊가 이를 대위하기 때문이다(대판 2009.5.28, 2008마109).

3. 동시배당의 경우

- ① 채무자 소유의 부동산과 물상보증인 소유의 부동산이 함께 경매되어 그 경매대가를 동시에 배당하는 경우에는 채무자 소유 부동산의 경매대가에서 우선적으로 배당을 받고, 부족

분이 있는 경우에 한하여 물상보증인 소유 부동산의 경매대가에서 추가로 배당을 받게 된다. 채무자가 궁극적인 책임을 져야 할 자이기 때문이다. 따라서 이 경우에는 동시 배당에 있어서의 안분부담의 원칙에 관한 「민법」 제368조 제1항이 적용되지 않는다(대판 2010.4.15, 2008다41475).

- ② 위의 예에서 채무자 乙소유의 X토지와 물상보증인 丙소유의 Y토지가 각 1억 원과 2억 원에 경매되고 이를 동시에 배당하는 경우에 공동저당권자 甲은 X토지에서 1억 원 그리고 Y토지에서 5천만 원을 배당받게 된다.

중요판례

대법원 1983.03.22. 81다43

공동저당권자가 공동저당물 중 일부만에 대하여 저당권을 실행하는 것은 저당권자의 권리에 속하는 것으로 권리남용에 해당하지 않는 한 정당하다고 할 것이므로 공동저당물인 토지와 건물 전부에 대하여 경매절차를 진행하던 중 건물에 대한 경매신청을 취하하고 토지에 대해서만 경매를 실행하여 토지소유자가 그에 대한 소유권을 상실하였더라도 불법행위가 된다고 할 수 없다.

대법원 2014.01.23. 2013다207996

공동저당의 목적인 채무자 소유의 부동산과 물상보증인 소유의 부동산 중 채무자 소유의 부동산에 대하여 먼저 경매가 이루어져 그 경매대금의 교부에 의하여 1번 공동저당권자가 변제를 받더라도 채무자 소유의 부동산에 대한 후순위 저당권자는 민법 제368조 제2항 후단에 의하여 1번 공동저당권자를 대위하여 물상보증인 소유의 부동산에 대하여 저당권을 행사할 수 없다. 그리고 이러한 법리는 채무자 소유의 부동산에 후순위 저당권이 설정된 후에 물상보증인 소유의 부동산이 추가로 공동저당의 목적으로 된 경우에도 마찬가지로 적용된다.

대법원 2015.11.27. 2013다41097

공동저당의 목적인 물상보증인 소유의 부동산에 후순위저당권이 설정되어 있는 경우에 물상보증인 소유의 부동산이 먼저 경매되어 경매대금에서 선순위공동저당권자가 변제를 받은 때에는 특별한 사정이 없는 한 물상보증인은 채무자에 대하여 구상권을 취득함과 동시에 변제자대위에 관한 민법 제481조, 제482조에 따라 채무자 소유의 부동산에 대한 선순위 공동저당권자의 저당권을 대위취득하고, 물상보증인 소유의 부동산에 대한 후순위저당권자는 물상보증인이 대위취득한 채무자 소유의 부동산에 대한 선순위공동저당권자의 저당권에 대하여 물상대위를 할 수 있다.

대법원 2002.07.12. 2001다53264

동일한 채권의 담보로 부동산과 선박에 대하여 저당권이 설정된 경우에는 민법 제368조 제2항 후문의 규정이 적용 또는 유추적용되지 아니하므로, 동일한 채권을 담보하기 위하여

부동산과 선박에 선순위저당권이 설정된 후 선박에 대하여서만 후순위저당권이 설정된 경우, 먼저 선박에 대하여 담보권실행절차가 진행되어 선순위저당권자가 선박에 대한 경매대가에서 피담보채권 전액을 배당받음으로써 선박에 대한 후순위저당권자가 부동산과 선박에 대한 담보권실행절차가 함께 진행되어 동시에 배당을 하였더라면 받을 수 있었던 금액보다 적은 금액을 배당받게 되었다고 하더라도, 선박에 대한 후순위저당권자는 부동산에 대한 선순위저당권자의 저당권을 대위할 수 없다.

대법원 2003.04.11. 2003다3850

민법 제365조가 토지를 목적으로 한 저당권을 설정한 후 그 저당권설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자가 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 있도록 규정한 취지는, 저당권은 담보물의 교환가치의 취득을 목적으로 할 뿐 담보물의 이용을 제한하지 아니하여 저당권설정자로서는 저당권설정 후에도 그 지상에 건물을 신축할 수 있는데, 후에 그 저당권의 실행으로 토지가 제3자에게 경락될 경우에 건물을 철거하여야 한다면 사회경제적으로 현저한 불이익이 생기게 되어 이를 방지할 필요가 있으므로 이러한 이해관계를 조절하고, 저당권자에게도 저당토지상의 건물의 존재로 인하여 생기게 되는 경매의 어려움을 해소하여 저당권의 실행을 쉽게 할 수 있도록 한 데에 있다는 점에 비추어 볼 때, 저당지상의 건물에 대한 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다.

(2) 근저당

1) 근저당의 의의 및 설정

- ① 근저당은 거래에 따라 채권액이 증감하더라도 그 증감에 관계없이 결산기에 존재하는 채권을 미리 정한 최고액의 한도에서 담보하는 데 그 특색이 있다.
- ② 근저당을 설정하려면 기본이 되는 계속적인 용자계약을 하고 담보할 최고액을 정하여, 이에 관한 저당권설정계약과 등기를 하게 된다. 이 등기에는 반드시 근저당이라는 취지와 채권의 최고액을 등기하여야 한다. 근저당의 결산기, 즉 존속기간의 등기는 임의적 등기사항이다.

2) 근저당권의 효력

- ① 결산기에 저당권을 실행하여 우선변제를 받을 수 있는 액은 등기된 최고액의 범위 안에서 실제로 결산기에 존재한 채권액이다.

- ② 최고액이란 채권자(근저당권자)의 목적물에 대한 우선변제를 받을 수 있는 한도액을 의미하는 것이지 채무자의 책임의 한도액을 의미하는 것이 아니다.
- ③ 근저당권의 실행비용은 채권최고액에 포함되지 않으며 별도로 우선변제를 받는다.
- ④ 이자는 최고액 속에 산입된 것으로 보게 되므로 원본과 이자를 합한 것이 최고액을 넘으면 그 초과부분은 담보되지 못한다.

3) 피담보채권의 확정

- ① 설정계약 또는 기본계약에서 규정한 결산기의 도래
- ② 근저당권의 존속기간이 있는 경우 존속기간의 만료
- ③ 기본계약 또는 설정계약이 해지 또는 해제된 때
- ④ 근저당권자가 경매를 신청하는 때
- ⑤ 채무자에 대한 회생절차의 개시결정이 있는 때
- ⑥ 제3자(후순위저당권자 등)가 경매 신청한 경우에는 매수인(경락인)이 매각대금을 완납한 때

4) 근저당권의 처분

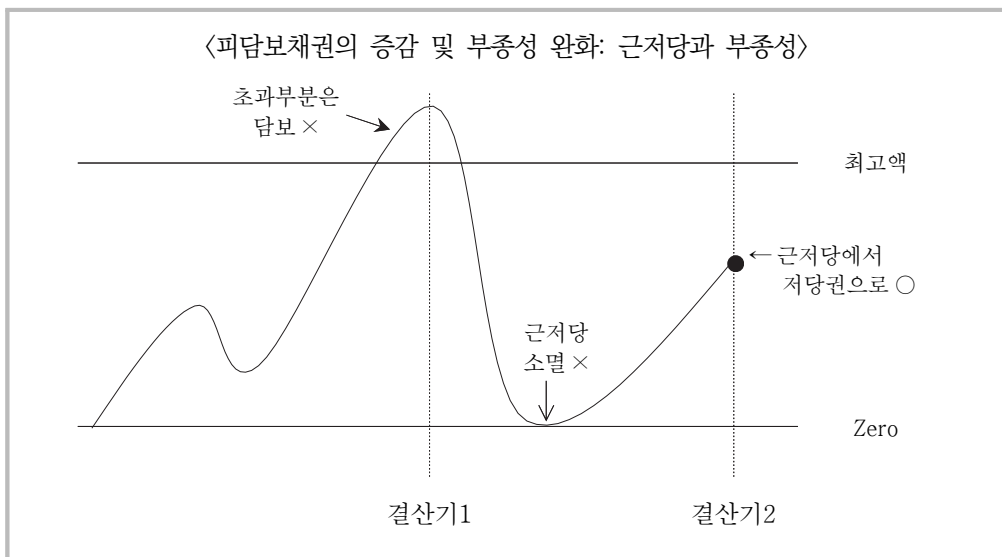
근저당권은 그 기초인 계약관계와 함께 양도할 수 있다. 그러나 그것은 근저당권자라는 지위의 변동은 생기게 하므로 근저당권자와 양수인 이외에 근저당채권의 채무자도 참가시킨 3면 계약으로 하여야 한다. 근저당의 양도는 당연히 저당권의 처분을 의미하므로 등기함으로써 그 효력이 생긴다.

5) 근저당권의 소멸

- ① 피담보채권이 확정되면 근저당권은 보통의 저당권과 동일하게 되고 그 이후에 발생하는 채권은 근저당권에 의해 담보되지 않는다. 예컨대 기본계약인 당좌대월 계약에서 발생한 채무를 담보하기 위한 근저당권은 그 결산기가 도래한 이후에 발행된 약속어음상의 채권을 담보하지 않는다(판례).
- ② 피담보채권이 확정되기 전이라도 채권이 변제 등으로 소멸하거나 또는 거래의 계속을 원하지 않는 경우에는 근저당설정계약을 해지하고 설정등기의 말소를 청구할 수 있다.

〈근저당권의 기본적 사항〉

의의와 성질	• 계속적인 거래관계로부터 생기는 불특정다수의 채무를 장래의 결산기에 있어서 일정한 한도액(최고액)까지 담보하기 위하여 현재에 설정하는 저당권을 말한다(제 357조). • 장래의 증감변동하는 불특정다수의 채권을 담보한다. • 피담보채권이 영(0)이 되거나 일시적으로 소멸하여도 저당권의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. 즉 부종성이 특히 완화된다.
근저당의 설정	• 설정계약과 등기로써 성립한다. • 등기에는 근저당이라는 뜻과 최고액을 반드시 명시하여야 한다.
근저당의 처분	근저당권자와 양수인 및 채무자의 3면 계약으로 양도가 가능하다.
근저당의 효력	• 증감변동하는 채권의 결산기에 있어서의 총화를 일정한 최고액까지 담보한다. • 이자는 최고액 중에 산입된 것으로 다룬다. • '원본 + 이자 = 총액 > 최고액'인 경우 초과부분은 담보되지 아니한다.



중요판례

대법원 2011.04.28. 2010다107408

근저당권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고, 채무의 확정을 장래에 보류하여 설정하는 저당권으로서, 계속적인 거래관계로부터 발생하는 다수의 불특정채권을 장래의 결산기에서 일정한 한도까지 담보하기 위한 목적으로 설정되는 담보권이므로, 근저당권설정행위와는 별도로 근저당권의 피담보채권을 성립시키는 법률행위가 있어야 하고, 근저당권의 성립 당시

근저당권의 피담보채권을 성립시키는 법률행위가 있었는지 여부에 대한 증명책임은 그 존재를 주장하는 측에 있다.

대법원 1988.10.11. 87다카545

근저당권자가 그 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청한 때에는 그 경매신청시에 근저당권은 확정되는 것이며 근저당권이 확정되면 그 이후에 발생하는 원금채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 않는다.

대법원 2010.05.13. 2010다3681

근저당권자의 채권액이 채권최고액을 초과하는 경우, 근저당권자와 그 채무자 겸 근저당권 설정자 사이에서는 채권최고액 등 그 채권 일부의 변제가 있더라도 채권 전액의 변제가 있을 때까지 근저당권의 효력이 잔존채무에 미친다.

대법원 1974.12.10. 74다998

근저당권의 물상보증인은 민법 제357조에서 말하는 채권의 최고액만을 변제하면 근저당권 설정등기의 말소청구를 할 수 있고 채권최고액을 초과하는 부분의 채권액까지 변제할 의무가 있는 것이 아니다.

대법원 2001.11.09. 2001다47528

근저당부동산에 대하여 소유권을 취득한 제3자는 피담보채무가 확정된 이후에 그 확정된 피담보채무를 채권최고액의 범위 내에서 변제하고 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

대법원 1999.09.21. 99다2608

후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우 선순위 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정된다고 보아야 한다.

대법원 2001.12.11. 선고 2001두7329

후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우 선순위 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정되는 것과 마찬가지로, 조세채권자가 채납처분을 하는 경우에도 선순위 근저당권자의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 매수대금을 완납한 때에 확정된다.

대법원 1981. 09. 08. 80다1468

근저당권설정계약상의 채무자 아닌 제3자를 채무자로 한 근저당권설정등기는 채무자를 달리한 것이므로, 근저당권의 부종성에 비추어 원인 없는 무효의 등기이다.

대법원 1999.05.14. 97다15777·15784

근저당권은 당사자 사이의 계속적인 거래관계로부터 발생하는 불특정채권을 어느 시기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정한 한도액 범위 내에서 담보하는 저당권으로서 보통의 저당권과 달리 발생 및 소멸에 있어 피담보채무에 대한 부종성이 완화된 있는 관계로 피담보채무가 확정되기 이전이라면 채무의 범위나 또는 채무자를 변경할 수 있고, 채무의 범위나 채무자가 변경된 경우에는 당연히 변경 후의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권만이 당해 근저당권에 의하여 담보되고, 변경 전의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권은 그 근저당권에 의하여 담보되는 채무의 범위에서 제외된다.

대법원 1996.06.14. 95다53812

근저당권이라고 함은 계속적인 거래관계로부터 발생하고 소멸하는 불특정다수의 장래채권을 결산기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정한 한도액의 범위 내에서 담보하는 저당권이어서, 거래가 종료하기까지 채권은 계속적으로 증감변동되는 것이므로, 근저당 거래관계가 계속 중인 경우 즉 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전에 그 채권의 일부를 양도하거나 대위변제한 경우 근저당권이 양수인이나 대위변제자에게 이전할 여지가 없다.

대법원 1994.01.25. 93다16338

근저당권이 설정된 후에 그 부동산의 소유권이 제3자에게 이전된 경우에는 현재의 소유자가 자신의 소유권에 기하여 피담보채무의 소멸을 원인으로 그 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있음은 물론이지만, 근저당권설정자인 종전의 소유자도 근저당권설정계약의 당사자로서 근저당권소멸에 따른 원상회복으로 근저당권자에게 근저당권설정등기의 말소를 구할 수 있는 권리가 있으므로 이러한 계약상 권리에 터잡아 근저당권자에게 피담보채무의 소멸을 이유로 하여 그 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.

대법원 2002.05.24. 2002다7176

채무자가 채권자로부터 새로이 금원을 차용하는 등 거래를 계속할 의사가 없는 경우에는, 그 존속기간 또는 결산기가 경과하기 전이라 하더라도 근저당권설정자는 계약을 해지하고 근저당권설정등기의 말소를 구할 수 있고, 한편 존속기간이나 결산기의 정함이 없는 때에는 근저당권의 피담보채무의 확정방법에 관한 다른 약정이 없는 경우라면 근저당권설정자가 근저당권자를 상대로 언제든지 해지의 의사표시를 함으로써 피담보채무를 확정시킬 수 있다.

대법원 2002.11.26. 2001다73022

근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우에는 경매신청시에 근저당채무액이 확정되고, 그 이후부터 근저당권은 부종성을 가지게 되어 보통의 저당권과 같은 취급을 받게 되는데, 위와 같이 경매신청을 하여 경매개시결정이 있는 후에 경매신청이 취하되었다고 하더라도 채무확정의 효과가 반복되는 것은 아니다.

대법원 2017.9.21. 2015다50637

공동근저당권자가 목적 부동산 중 일부 부동산에 대하여 제3자가 신청한 경매절차에 소극적으로 참가하여 우선배당을 받은 경우, 해당 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 매수인이 매각대금을 지급한 때에 확정되지만, 나머지 목적 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권은 기본거래가 종료하거나 채무자나 물상보증인에 대하여 파산이 선고되는 등의 다른 확정사유가 발생하지 아니하는 한 확정되지 아니한다.

대법원 2017.12.21. 2013다16992 전원합의체

공동근저당권자가 스스로 근저당권을 실행하거나 타인에 의하여 개시된 경매·공매 절차, 수용 절차 또는 회생 절차 등을 통하여 공동담보의 목적 부동산 중 일부에 대한 환가대금 등으로부터 다른 권리자에 우선하여 피담보채권의 일부에 대하여 배당받은 경우, 공동담보의 나머지 목적 부동산에 대한 경매 등의 환가절차에서 나머지 피담보채권에 대하여 다시 최초의 채권최고액 범위 내에서 공동근저당권자로서 우선변제권을 행사할 수는 없다.

1. 가등기담보의 의의와 성질

(1) 의의

- ① 가등기담보법이 적용되려면 먼저 소비대차계약을 하면서 이행기에 이행하지 못할 경우를 대비해서 대물변제의 예약 또는 매매의 예약을 하고, 이를 담보하기 위해서 가등기(가등기담보) 또는 소유권이전등기(양도담보)를 하여야 한다.
- ② 담보부동산에 대한 예약당시의 시가가 그 피담보채권액에 미치지 못하는 경우에는 가등기담보법이 적용되지 않는다(대판 1993.10.26., 93다26711).
- ③ 매매대금이나 물품대금의 지급을 담보하기 위하여 소유권이전청구권보전을 위한 가등기가 경료된 경우에는 가등기담보법이 적용되지 않는다(대판 1992.10.27, 92다22879).
- ④ 공사대금채권을 담보할 목적으로 가등기가 경료된 경우에는 가등기담보법이 적용되지 않는다(대판 1992.4.10, 91다45356).

(2) 성질

- ① 소유권이전의 법리에 의한 담보제도이다.
- ② 경매청구권(특수한 저당권의 일종)이 인정된다.
- ③ 우선변제권과 별제권(채무자회생법)을 인정한다.
- ④ 담보물권의 통유성(물상대위성·불가분성·타물권·부종성·수반성)을 인정한다.

2. 가등기담보권의 설정 및 이전

(1) 설정

- ① 계약의 당사자는 채권자와 채무자 또는 물상보증인이다.
- ② 계약의 요건은 채권을 담보하는 것이 계약의 내용이며, 채무불이행시에는 일정한 권리를 채권자에게 이전한다는 내용의 계약이 체결되어야 한다.
- ③ 목적물에 대해 가등기 또는 소유권이전등기를 할 수 없는 경우, 목적물이 동산인 경우에도 적용되지 않는다.

- ④ 권리실행방법을 별도로 규정하고 있는 권리질권·저당권 및 전세권의 취득을 목적으로 하는 계약에는 적용되지 않는다.
- ⑤ 따라서 부동산의 소유권·지상권·지역권·임차권과 입목·등기한 선박·자동차·항공기·건설기계 등이 그 객체가 될 수 있다.

(2) 이전

- ① 가등기담보권도 일종의 담보물권으로서 양도성이 있다.
- ② 저당권에 관한 제361조가 적용되므로, 피담보채권과 분리하여 양도할 수 없다.

3. 가등기담보권의 효력과 실행

(1) 일반적 효력

- ① 가등기담보권의 효력이 미치는 범위, 즉 피담보채권(원본이자 등)의 범위, 목적물(부합물·종물)의 범위, 물상대위성 등에 있어서는 저당권의 범위와 같다.
- ② 가등기담보권의 우선변제력도 저당권과 동일하며 채무자회생법상의 별제권을 인정한다.

(2) 실행방법

- ① 권리취득에 의한 실행(귀속청산의 방법에 의한 우선변제)
 피담보채권의 변제기가 도래하였음에도 채무자가 이행하지 않는 경우에, 가등기담보권자는 채무자 등에게 실행통지를 하고, 통지 후 2개월의 청산기간이 지나면 가등기담보권자는 실행하게 된다.
- ② 경매에 의한 실행

제12조 【경매의 청구】

- ① 담보가등기권리자는 그 선택에 따라 제3조에 따른 담보권을 실행하거나 담보목적부동산의 경매를 청구할 수 있다. 이 경우 경매에 관하여는 담보가등기권리를 저당권으로 본다.
- ② 후순위권리자는 청산기간에 한정하여 그 피담보채권의 변제기 도래 전이라도 담보목적 부동산의 경매를 청구할 수 있다.

제13조 【우선변제청구권】

담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등이 개시된 경우에 담보가등기권리자는 다른 채권자보다 자기채권을 우선변제 받을 권리가 있다. 이 경우 그 순위에 관하여는 그 담보가등기

권리를 저당권으로 보고, 그 담보가등기를 마친 때에 그 저당권의 설정등기가 행하여진 것으로 본다.

제14조 【강제경매 등의 경우의 담보가등기】

담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등의 개시 결정이 있는 경우에 그 경매의 신청이 청산금을 지급하기 전에 행하여진 경우(청산금이 없는 경우에는 청산기간이 지나기 전)에는 담보가등기권리자는 그 가등기에 따른 본등기를 청구할 수 없다.

제15조 【담보가등기권리의 소멸】

담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등이 행하여진 경우에는 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸한다.

- ㉠ 담보가등기권리자는 그 선택에 따라 권리취득에 의한 담보권을 실행하거나 목적부동산의 경매를 청구할 수 있다. 이 경우 경매에 관하여는 담보가등기권리를 저당권으로 본다.
- ㉡ 담보가등기가 설정된 부동산에 대하여 경매가 개시된 경우에, 담보가등기권리자는 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있다. 이 경우 그 순위에 관하여는 그 담보가등기권리를 저당권으로 보고, 그 담보가등기가 설정된 때에 그 저당권의 설정등기가 된 것으로 본다.

4. 권리취득에 의한 실행

(1) 실행통지

제3조 【담보권 실행의 통지와 청산기간】

- ① 채권자가 담보계약에 따른 담보권을 실행하여 그 담보목적부동산의 소유권을 취득하기 위하여는 그 채권의 변제기 후에 제4조의 청산금의 평가액을 채무자등에게 통지하고, 그 통지가 채무자등에게 도달한 날부터 2개월(청산기간)이 지나야 한다. 이 경우 청산금이 없다고 인정되는 경우에는 그 뜻을 통지하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 통지에는 통지 당시의 담보목적부동산의 평가액과 민법 제360조에 규정된 채권액을 밝혀야 한다. 이 경우 부동산이 둘 이상인 경우에는 각 부동산의 소유권이전에 의하여 소멸시키려는 채권과 그 비용을 밝혀야 한다.

채권의 변제기 후에 청산금의 평가액을 채무자 등(채무자, 물상보증인, 제3취득자)에게 통지하여야 한다(가등기담보법 제3조).

- ① 청산금은 실행통지 당시의 목적부동산의 가액에서 그 시점의 피담보채권액을 공제한 차액으로, 목적부동산에 선순위 담보권자가 있을 때는 그에게 우선 변제해 주어야 하므로 채권액을 계산함에 있어 이를 포함하여야 한다. 따라서 목적부동산 위에 담보가등기를 하기 전에 이미 성립하고 있는 선순위담보권, 대항력 있는 임차권, 주택 또는 상가임대차보호법에 의해 대항력이 인정되는 소액보증금이 있는 때에는 그 금액도 합산하여 공제하여야 한다.
- ② 그러나 후순위 권리자의 채권액은 포함시킬 필요가 없다. 이는 채무자와 후순위 권리자 등은 자신의 권리를 스스로 행사하라는 취지이다.
- ③ 만약 목적부동산의 가액이 피담보채권액에 미달하여 청산금이 없다고 인정되는 경우에는 청산금이 없다는 뜻을 통지하여야 한다.
- ④ 목적부동산이 2개 이상인 때에는(공동가등기담보) 각 부동산의 소유권이전에 의하여 소멸시키려고 하는 채권과 그 비용을 명시하여야 한다.
- ⑤ 통지는 채무자 등, 모두에게 하여야 하는 것으로서 채무자 등의 전부 또는 일부에 대하여 통지를 하지 않으면 청산기간이 진행할 수 없게 되고, 따라서 가등기담보권자는 그 후 적절한 청산금을 지급하였다 하더라도 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 없으며 양도담보의 경우에는 그 소유권을 취득할 수 없다(대판 1995.4.28, 94다36162).
- ⑥ 채권자는 그가 통지한 청산금의 금액(數額)에 관하여 다룰 수 없다. 즉 실제평가액이 청산금보다 적더라도 채권자는 그가 통지한 청산금에 구속된다. 그러나 채무자 등은 다룰 수 있다.
- ⑦ 채권자가 나름대로 평가한 청산금의 액수가 객관적인 청산금의 평가액에 미치지 못한다고 하더라도 담보권 실행의 통지로서의 효력이나 청산기간의 진행에는 아무런 영향이 없고, 다만 채무자 등은 정당하게 평가된 청산금을 지급받을 때까지 목적부동산의 소유권이전등기 및 인도 채무의 이행을 거절하면서 피담보채무 전액을 채권자에게 지급하고 채권담보의 목적으로 마쳐진 가등기의 말소를 구할 수 있을 뿐이다(대판 1996.7.30, 96다6974).

(2) 청산

제4조 【청산금의 지급과 소유권의 취득】

- ① 채권자는 제3조제1항에 따른 통지 당시의 담보목적부동산의 가액에서 그 채권액을 뺀 금액(청산금)을 채무자 등에게 지급하여야 한다. 이 경우 담보목적부동산에 선순위담보권 등의 권리가 있을 때에는 그 채권액을 계산할 때에 선순위담보 등에 의하여 담보된 채권액을 포함한다.
- ② 채권자는 담보목적부동산에 관하여 이미 소유권이전등기를 마친 경우에는 청산기간이 지난 후 청산금을 채무자등에게 지급한 때에 담보목적부동산의 소유권을 취득하며, 담보가등기를 마친 경우에는 청산기간이 지나야 그 가등기에 따른 본등기를 청구할 수 있다.
- ③ 청산금의 지급채무와 부동산의 소유권이전등기 및 인도채무의 이행에 관하여는 동시이행의 항변권에 관한 민법 제536조를 준용한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 어긋나는 특약으로서 채무자등에게 불리한 것은 그 효력이 없다. 다만, 청산기간이 지난 후에 행하여진 특약으로서 제3자의 권리를 침해하지 아니하는 것은 그러하지 아니하다.

가등기담보권자는 실행통지 당시의 목적물가액과 채권액의 차액(청산금)을 청산기간(실행통지가 채무자 등에게 도달한 날로부터 2개월)이 만료한 때 채무자 등에게 지급하여야 한다.

- ① 청산의무의 발생시기는 청산기간이 만료한 때이다(동법 제3조). 채권자가 그 이전에 변제한 경우에는 후순위권리자에게 대항하지 못한다(동법 제7조).
- ② 청산의무에 관한 가등기담보법 제4조 제1항에 위반하는 특약으로서 채무자 등에게 불리한 것은 무효이다.
- ③ 채무자 등이 채권자에 대하여 청산금의 지급을 면제하는 것과 같은 무청산특약은 일체 부정되나 청산기간이 경과한 후에 하는 무청산특약은 유효하다.
- ④ 청산은 채권자가 청산금을 지급함과 동시에 가등기에 기한 본등기를 함으로써 소유권을 취득하는 귀속청산의 방법에 따라서 하여야 한다는 것이 판례이다(2002.12.10. 2002다42001).
- ⑤ 청산금의 지급의무와 부동산의 소유권이전등기 및 목적물인도의무는 동시이행 관계에 있다.

대법원 2002.12.10. 선고 2002다42001

- [1] 가등기담보 등에 관한 법률이 제3조와 제4조에서 가등기담보권의 사적 실행방법으로 귀속정산의 원칙을 규정함과 동시에 제12조와 제13조에서 그 공적 실행방법으로 경매의 청구 및 우선변제청구권 등 처분정산을 별도로 규정하고 있는 점, 위 제4조가 제1항 내지 제3항에서 채권자의 청산금 지급의무, 청산기간 경과와 본등기청구, 청산금의 지급 의무와 부동산의 소유권이전등기 및 인도 채무의 동시이행관계 등을 순차로 규정한 다음, 제4항에서 제1항 내지 제3항에 반하는 특약으로서 채무자 등에게 불리한 것은 그 효력이 없다(다만, 청산기간 경과 후에 행하여진 특약으로서 제3자의 권리를 해하지 아니하는 경우는 제외된다.)고 규정하고 있는 점, 나아가 제11조는 채무자 등이 청산금 채권을 변제받을 때까지 그 채무액을 채권자에게 지급하고 그 채권담보의 목적으로 경료된 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다고 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 가등기담보권의 사적 실행에 있어서 채권자가 청산금의 지급 이전에 본등기와 담보목적 물의 인도를 받을 수 있다거나 청산기간이나 동시이행관계를 인정하지 아니하는 '처분 정산' 형의 담보권실행은 가등기담보 등에 관한 법률상 허용되지 아니한다.
- [2] 가등기담보 등에 관한 법률 제3조, 제4조의 각 규정에 비추어 볼 때 그 각 규정을 위반 하여 담보가등기에 기한 본등기가 이루어진 경우에는 그 본등기는 무효라고 할 것이고, 설령 그와 같은 본등기가 가등기권리자와 채무자 사이에 이루어진 특약에 의하여 이루어 졌다고 할지라도 만일 그 특약이 채무자에게 불리한 것으로서 무효라고 한다면 그 본등 기는 여전히 무효일 뿐, 이른바 약한 의미의 양도담보로서 담보의 목적 내에서는 유효하다고 할 것이 아니고, 다만 가등기권리자가 가등기담보 등에 관한 법률 제3조, 제4조에 정한 절차에 따라 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지한 후 채무자에게 정당한 청산금을 지급하거나 지급할 청산금이 없는 경우에는 채무자가 그 통지를 받은 날로부터 2월의 청산기간이 경과하면 위 무효인 본등기는 실체적 법률관계에 부합하는 유효한 등기가 될 수 있다.

대법원 2010.11.09. 자2010마1322

- [1] 담보가등기의 경우 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지한 후 채무자에게 정당한 청산금을 지급하거나 지급할 청산금이 없는 경우에는 채무자가 그 청산의 통지를 받은 날로부터 2월의 청산기간이 경과하여야 하는 청산절차를 거친 후에야 그 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 있는데, 위 각 규정을 위반하여 담보가등기에 기한 본등기가 이루어 진 경우에는 그 본등기는 무효이고, 다만 가등기권리자가 이러한 청산절차를 거치면 위 무효인 본등기는 실체적 법률관계에 부합하는 유효한 등기가 될 수 있을 뿐이다.
- [2] 그리고 이러한 청산절차를 거치기 전에 강제경매 등의 신청이 행하여진 경우 담보가등기 권자는 그 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 없고, 그 가등기가 부동산의 매각에 의하여 소멸하되 다른 채권자보다 자기 채권을 우선변제를 받을 권리가 있을 뿐이다.

대법원 2008.04.11. 2005다36618

- [1] 채권자가 가등기담보 등에 관한 법률에 의한 가등기담보권을 실행하여 그 담보목적 부동산의 소유권을 취득하기 위하여 채무자 등에게 하는 담보권 실행의 통지에는 채권자가 주관적으로 평가한 통지 당시의 목적 부동산의 가액과 피담보채권액을 명시함으로써 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지하면 족하며, 채권자가 이와 같이 주관적으로 평가한 청산금의 액수가 정당하게 평가된 청산금의 액수에 미치지 못한다고 하더라도 담보권 실행의 통지로서의 효력이나 청산기간의 진행에는 아무런 영향이 없고 청산기간이 경과한 후에는 그 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 있다.
- [2] 이 경우에, 채무자 등은 채권자가 통지한 청산금액을 다두고 정당하게 평가된 청산금을 지급받을 때까지 목적부동산의 소유권이전등기 및 인도채무의 이행을 거절하거나 피담보채무 전액을 채권자에게 지급하고 채권담보의 목적으로 마쳐진 가등기의 말소를 구할 수 있을 뿐 아니라, 채권자에게 정당하게 평가된 청산금을 청구할 수도 있다. 한편, 채무자는 채권자가 통지한 청산금액에 동의함으로써 청산금을 확정시킬 수 있으며, 그 경우 동의는 명시적 뿐만 아니라 묵시적으로도 가능하다고 할 것이다.

(3) 청산금청구권자

설정자(채무자 또는 물상보증인) 또는 제3취득자 및 후순위권리자가 청산금청구권자이다. 그 밖에 담보가등기 후에 성립한 대항요건을 갖춘 임차인도 청산금의 범위 내에서 보증금의 반환을 청구할 수 있다.

- ① 후순위권리자는 담보가등기 후에 등기된 저당권자·전세권자 등으로 유치권자는 후순위권리자에 포함되지 않는다.
- ② 후순위권리자는 청산기간이 경과한 후 청산금이 채무자에게 지급되기 전에 제3조 제1항의 실행통지시에 채권자가 통지한 청산금의 범위 내에서 우선순위에 따라 자기채권의 명세와 증서를 제시하여 그 변제를 채권자에게 청구할 수 있다. 채권자의 지급에 의하여 그 범위 내에서 채권자의 청산금의무는 당연히 소멸한다(동법 제5조).
- ③ 채무자의 일반채권자는 후순위권리자가 청산금으로부터 자기채권의 우선변제를 받는 것을 저지하려면 미리 청산금을 압류 또는 가압류하여야 한다. 채권자는 청산기간이 지난 후에 청산금을 법원에 공탁하여 채무를 면할 수 있으며, 채무자 등과 압류채권자 또는 가압류채권자에게 지체없이 공탁의 통지를 하여야 한다(동법 제8조).

- ④ 담보가등기 후에 대항요건을 갖춘 임차권을 취득한 자는 청산금의 범위 내에서 임차물의 반환과 상환으로 보증금의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 청산금이 보증금을 지급하기에 부족한 때에는 그 부족을 이유로 임차물의 반환을 거절하지는 못한다.
- ⑤ 청구권자에서 선순위권리자는 제외된다. 선순위담보권자를 청구권자에서 제외한 것은 가등기담보권자가 권리실행으로 목적물의 소유권을 취득하게 되며 선순위담보권은 소멸하지 않고서 그 목적물 위에 그대로 존속하기 때문이다. 다만 채권자가 채무자에게 지급할 청산금을 계산함에 있어서는 선순위권리자의 채권액도 고려하여야 한다.

(4) 소유권 취득

실행통지를 하고 청산기간이 경과한 후 청산을 하게 되면 가등기담보권자는 그의 담보가등기에 기하여 소유권이전등기를 함으로써 목적부동산의 소유권을 취득하게 된다.

- ① 목적부동산의 가액이 채권액에 미달하여 청산금이 없는 때에는 가등기담보권자는 청산기간이 경과한 후에 곧바로 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 있다.
- ② 청산절차를 거치지 아니하고 이루어진 본등기는 무효라고 할 것이고, 설령 그와 같은 본등기가 가등기권리자와 채무자 사이에 이루어진 특약에 의하여 이루어졌다고 할지라도 만일 그 특약이 채무자에게 불리한 것으로서 무효라고 한다면 그 본등기는 여전히 무효일 뿐, 이른바 약한 의미의 양도담보로서 담보의 목적 내에서는 유효하다고 할 것이 아니라고 한다(대판 2002.12.10. 2002다42001).
- ③ 양도담보권자는 이미 소유권 이전등기의 본등기가 행해졌으므로 청산기간 경과 후 청산금이 없을 때는 청산기간의 말일로 소유권을 취득하며 청산금이 있는 때에는 청산금을 채무자에 지급한 때에 소유권을 취득한다.
- ④ 가등기담보권의 실행으로 청산절차가 종료된 후 담보목적물에 대한 과실수취권 등을 포함한 사용수익권은 청산절차의 종료와 함께 채권자에게 귀속된다고 보아야 한다(대판 2001.2.27, 2000다20465).

(5) 채무자 등의 가등기말소청구권

가등기담보계약의 당사자인 채무자나 물상보증인 또는 이들로부터 담보가등기 후에 소유권을 취득한 제3취득자는 채권자로부터 청산금을 지급받을 때까지는 채무액(반환시까지의 이자와 손해금을 포함)을 채권자에게 지급하고, 가등기담보권을 소멸 시킴으로써 가등기의 말소를 청구할 수 있다.

- ① 청산금이 없는 경우에는 채권자는 청산기간이 경과하면 가등기에 기한 본등기를 함으로써 목적부동산의 소유권을 취득할 수 있지만, 이 경우에도 채권자가 본등기를 할 때까지는 채무자 등은 채무를 변제하고 가등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ② 채무의 변제기가 경과한 때로부터 10년이 경과하거나 또는 선의의 제3자가 소유권을 취득한 때에는 채무자가 아직 청산금을 받지 못하고 있더라도 채무액을 제공해서 가등기의 말소를 청구하지 못한다(동법 제11조 단서)

중요판례

대법원 1994.06.28, 94다3087

채권자가 가등기담보권을 실행하여 그 담보목적 부동산의 소유권을 취득하기 위하여 채무자에게 담보권실행을 통지하고 2월의 청산기간이 경과한 후에도, 채무자는 정당하게 평가된 청산금을 지급받을 때까지 목적부동산의 소유권이전등기 및 인도채무의 이행을 거절하면서 피담보채무 전액과 그 이자 및 손해금을 지급하고 그 채권담보의 목적으로 경료된 가등기의 말소를 청구할 수 있다.

☞ 청산기간이 경과된 이후라 하더라도 가등기담보권자로부터 청산금을 지급받기 전에는 채무자는 피담보채무를 변제하고 가등기의 말소를 청구할 수 있다.

4. 가등기담보권의 소멸

(1) 물권에 공통된 소멸원인

- ① 목적물의 멸실 등 물권공통의 소멸사유에 의하여 소멸한다.
- ② 피담보채권의 소멸시효, 채무의 변제 등, 담보물권 공통의 소멸사유로 소멸한다.

(2) 가등기담보에 특유한 소멸원인

- ① 목적부동산에 경매가 행해지면 그 부동산의 매각으로 소멸한다.

- ② 가등기담보권자가 청산금을 지급하고 소유권을 취득한 때 소멸한다(동법 제4조).
- ③ 채무의 변제기가 경과한 때로부터 10년이 경과하거나 또는 선의의 제3자가 소유권을 취득한 때에도 가등기담보권은 소멸한다(동법 11조 단서후단).

중요판례

대법원 1996. 07.30. 95다11900

채권자가 채권담보의 목적으로 부동산에 가등기를 경료하였다가 그 후 변제기까지 변제를 받지 못하게 되어 그 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 경료한 경우에는 당사자들이 달리 특별한 약정을 하지 아니하는 한 그 본등기도 채권담보의 목적으로 경료된 것으로서 당사자 사이에 정산절차를 예정하고 있는 이른바 ‘약한 의미의 양도담보’가 된 것으로 보아야 할 것이고, 약한 의미의 양도담보가 이루어진 경우에는 채무의 변제기가 도과된 후라고 하더라도 채권자가 담보권을 실행하여 정산절차를 마치기 전에는 채무자는 언제든지 채무를 변제하고 채권자에게 가등기 및 가등기에 기한 본등기의 말소를 청구할 수 있는 것이며, 양도담보권자가 변제기 후에 담보권실행을 위하여 담보물을 정당한 가격으로 타에 처분하거나 자기가 그 소유권을 인수하려면 그 대금으로써 피담보채권의 원리금을 충당하고 잔액이 있으면 이를 채무자에게 반환하는 등의 정산을 필하지 않은 상태에서는 아직 그 피담보채권이 소멸되었다고는 볼 수 없다.

대법원 1993.10.26. 93다27611

가등기담보 등에 관한 법률은 재산권 이전의 예약에 의한 가등기담보에 있어서 그 재산의 예약 당시의 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 초과하는 경우에 한하여 그 적용이 있다고 할 것이므로, 담보부동산에 대한 예약 당시의 시가가 그 피담보채무액에 미치지 못하는 경우에 있어서는 같은 법 제3조, 제4조가 정하는 청산금평가액의 통지 및 청산금지급 등의 절차를 이행할 여지가 없다.

대법원 2007.06.15. 2006다5611

가등기담보 등에 관한 법률은 재산권 이전의 예약에 의한 가등기담보에 있어서 그 재산의 예약 당시의 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 초과하는 경우에 적용되는 것인 바, 여기에서 말하는 재산의 가액은 원칙적으로 ‘통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상재산의 내용에 정통한 거래당사자 간에 성립한다고 인정되는 적정가격’이고, 그와 같은 적정가격을 확인하기 어려울 때에는 객관적이고 합리적인 방법으로 평가한 가액이라고 할 것이므로, 대상재산이 토지로서 법정지상권의 성립가능성이 있는 등 토지이용상 제한을 받는지 여부가 불분명한 경우에는 법정지상권의 성립에 관한 사정을 객관적이고 합리적으로 평가하여 그 성립 여부를 판단한 다음 그에 따라 평가한 토지의 가격을 가액으로 봄이 상당하다.

대법원 1996.11.15. 96다31116

가등기담보 등에 관한 법률은 차용물의 반환에 관하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우에 적용되는 것이므로, 공사잔대금의 지급을 담보하기 위하여 체결된 양도담보계약에 기하여 소유권이전등기를 구하는 경우에는 적용되지 않는다.

대법원 1991.09.24. 90다13765

차주가 차용물의 반환에 관하여 차용물에 갈음하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우가 아니라 단순히 매매잔대금 채권을 담보하기 위하여 경료된 가등기에 기하여 본등기를 구하는 경우에는 가등기담보 등에 관한 법률은 적용되지 아니한다.

대법원 2001.03.23. 2000다29356

가등기담보법은 차용물의 반환에 관하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우에 적용되므로 매매대금채권을 담보하기 위하여 경료된 양도담보에는 그 법은 적용되지 아니한다.

대법원 2001.02.27. 2000다20465

일반적으로 담보목적으로 가등기를 경료한 경우 담보물에 대한 사용·수익권은 가등기설정자인 소유자에게 있으나, 가등기담보약정은 채무자가 본래의 채무를 이행하지 못할 경우 채권자에게 담보목적물의 소유권을 이전하기로 하는 예약으로서 유상계약인 쌍무계약적 재산권이전약정에 해당하므로 그 성질에 반하지 않는 한 매매에 관한 민법 규정이 준용된다 할 것이고(민법 제567조), 채권자가 가등기담보권을 실행하여 그 담보목적부동산의 소유권을 취득하기 위하여 가등기담보등에관한법률에 따라 채무자에게 담보권 실행을 통지한 경우 청산금을 지급할 여지가 없는 때에는 2월의 청산기간이 경과함으로써 청산절차는 종료되고, 이에 따라 채권자는 더 이상의 반대급부의 제공 없이 채무자에 대하여 소유권이전등기청구권 및 목적물 인도청구권을 가진다 할 것임에도 채무자가 소유권이전등기의무 및 목적물 인도 의무의 이행을 지연하면서 자신이 담보목적물을 사용·수익할 수 있다고 하는 것은 심히 공평에 반하여 허용될 수 없으므로 이러한 경우 담보목적물에 대한 과실수취권 등을 포함한 사용·수익권은 청산절차의 종료와 함께 채권자에게 귀속된다.

1. 의의

채권담보를 위해 담보목적인 재산을 채권자에게 이전하고 채무불이행시에는 채권자가 그 목적물로부터 우선변제를 받지만, 채무이행시에는 목적물을 그 소유자에게 반환하는 방법에 의한 비전형담보를 말한다. 양도담보권자는 외형상 소유권을 취득하고 있으나 그것은 담보권에 지나지 아니한다.

2. 종류

(1) 협의의 양도담보와 매도담보

- ① 신용의 수수를 소비대차의 형식으로 행하여 당사자 사이에 채권·채무관계를 남겨 두는 방법이 협의의 양도담보이고, 신용의 수수를 소비대차가 아닌 매매의 형식으로 행하고 당사자 사이에 따로 채권·채무관계를 남기지 않는 방법이 매도담보이다.
- ② 현재에는 구별의 실익이 없다고 한다.

(2) 부동산 양도담보와 동산 양도담보

목적물이 부동산인가 동산인가에 따른 구별로서, 부동산 양도담보(또는 등기·등록으로 공시되는 재산을 목적으로 하는 양도담보)는 가등기담보법의 적용을 받는다.

3. 실행

(1) 권리취득에 의한 실행

- ① 실행통지와 청산, 그리고 소유권취득의 단계를 거치는 가등기담보법의 실행방법에 의한다.
- ② 이미 본등기가 되어 있기 때문에 가등기담보에서와 달리 따로 등기를 할 필요는 없다.

(2) 채무자 등의 이전등기말소청구권

- ① 채무자 등은 청산금을 지급받을 때까지는 채무액을 양도담보권자에게 지급하고 이전등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ② 거래안전을 위하여 이전등기말소청구권을 제한할 수 있으며 그 제한사유는 ‘가등기담보 등에 관한 법률’의 규정을 적용한다. 따라서 채무의 변제기가 경과한 때로부터 10년이 경과하거나 또는 선의의 제3자가 소유권을 취득한 때에도 이전등기말소청구권은 소멸한다(가등기담보법 11조 단서후단).

중요판례

대법원 1988.04.25. 87다카2696·2697

부동산의 양도담보권설정자는 그 부동산의 등기명의를 양도담보권자 앞으로 되어있다 할지라도 그 부동산의 불법점유자인 제3자에 대하여는 그 실질적 소유자임을 주장하여 불법점유의 상태의 배제권을 행사할 수 있다.

대법원 2013.01.16. 2012다78726

일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼는 이른바 유동집합물에 대한 양도담보계약의 경우에, 양도담보의 효력이 미치는 범위를 명시하여 제3자에게 불측의 손해를 입지 않도록 하고 권리관계를 미리 명확히 하여 집행절차가 부당히 지연되지 않도록 하기 위하여 그 목적물을 특정할 필요가 있으므로, 담보목적물은 담보설정자의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 소재하는 장소 또는 수량의 지정 등의 방법에 의하여 외부적·객관적으로 특정되어 있어야 하고, 목적물의 특정 여부 및 목적물의 범위는 목적물의 종류, 장소, 수량 등에 관한 계약의 전체적 내용, 계약 당사자의 의사, 목적물 자체가 가지는 유기적 결합의 정도, 목적물의 성질, 담보물 관리와 이용방법 등 여러 가지 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 할 것이다.

대법원 1990.12.26. 88다카20224

- [1] 양도담보계약서 중 양도물건목록에 소재지, 보관창고명과 목적물이 양만장 내 뱀장어, 수량 약 백만마리라고 기재되어 있을 뿐이고 특별히 위 양만장 내의 뱀장어 중 1,000,000마리로 그 수량을 지정하여 담보의 범위를 제한한 사실이 인정되지 않는다면 위 양도담보계약서에 기재된 수량은 단순히 위 계약 당시 위 양만장 내에 보관하고 있던 뱀장어 등의 수를 개략적으로 표시한 것에 불과하고 당사자는 위 양만장 내의 뱀장어 등 어류전부를 그 목적으로 하였다고 봄이 당사자의 의사에 합치된다.
- [2] 성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양만장 내의 뱀장어 등 어류 전부에 대한 양도담보계약은 그 양도담보물이 특정되었으므로 유효하게 성립된다.

[3] 집합물에 대한 양도담보권설정계약이 이루어지면 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동되거나 변형되더라도 한 개의 물건으로서의 동일성을 잃지 아니하므로 양도담보권의 효력은 항상 현재의 집합물 위에 미치는 것이고, 따라서 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하면 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그 때마다 별도의 양도담보권설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다.

대법원 1996.09.10. 96다25463

돼지를 양도담보의 목적물로 하여 소유권을 양도하되 점유개정의 방법으로 양도담보설정자가 계속하여 점유·관리하면서 무상으로 사용·수익하기로 약정한 경우, 양도담보 목적물로서 원물인 돼지가 출산한 새끼 돼지는 천연과실에 해당하고 그 천연과실의 수취권은 원물인 돼지의 사용·수익권을 가지는 양도담보설정자에게 귀속되므로, 다른 특별한 약정이 없는 한 천연과실인 새끼 돼지에 대하여는 양도담보의 효력이 미치지 않는다.

